

## <제1편 총설.제1장 민사소송.제1절 민사소송의 개관>

### I. 서론

#### 1. 민사소송법의 의의와 성격

##### (1) 민사소송법의 개념

- 민사소송법은 사적 분쟁을 국가의 재판권에 의해 강제적으로 해결하기 위한 절차를 규정한 법률이다. 이는 실체법인 민법이나 상법의 권리를 현실적으로 실현하기 위한 도구적 역할을 수행한다.

##### (2) 공법적 성격

- 민사소송법은 사법상의 권리관계를 다루는 소송을 규율하지만, 국가 기관인 법원이 관여하는 절차를 다루므로 공법에 해당한다. 당사자 간의 합의보다 법에 정해진 절차를 중시하는 강행규정적 성격이 강하다.

#### 2. 법원의 역할과 민사 재판

##### (1) 사법권의 행사

- 법원은 독립된 지위에서 헌법과 법률에 의해 양 당사자의 주장을 듣고 법적 결론을 도출한다. 이는 법질서의 최종적 보루로서 기능을 수행하는 것이다.

##### (2) 분쟁의 종국적 해결

- 재판은 확정판결을 통해 분쟁을 영구적으로 종결시키며, 이후 동일한 사건으로 다시 다툴 수 없도록 하는 법적 안정성을 제공한다.

### II. 총설

#### 1. 민사소송의 목적과 이상

##### (1) 민사소송의 목적

###### ① 사권의 보호

- 민사소송은 사적 분쟁을 국가의 재판권에 의해 강제적으로 해결함으로써 개인의 사법상 권리를 실현하는 것을 일차적 목적으로 한다.

###### ② 법질서의 유지

- 개별 분쟁 해결을 통해 궁극적으로는 사회 전체의 사법 질서를 안정시키고 법치주의를 공고히 하는 공익적 성격을 갖는다.

##### (2) 민사소송의 이상

###### ① 적정과 공평

- 재판은 실체적 진실에 부합하는 적정한 판단이어야 하며, 양 당사자에게 동등한 기회를 부여하는 절차적 공평을 기해야 한다.

###### ② 신속과 경제

- 지연된 정의는 정의가 아니라는 원칙하에 가급적 빠른 시간 내에 최소한의 비용으로 분쟁을 종결하는 효율성을 추구한다.

#### 2. 신의성실의 원칙

##### (1) 의의 및 적용범위

###### ① 신의칙의 의의

- 소송 당사자와 소송 관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행해야 한다는 원칙으로, 소송상 권능의 행사를 제한하는 구체적 기준이 된다.

###### ② 적용대상

- 당사자뿐만 아니라 법원의 절차 운영에도 적용되며, 소송 전반에 걸쳐 공정성을 담보하는 역할을 한다.

##### (2) 신의칙의 발현형태

###### ① 부당한 소송상태의 창출 금지

- 부정한 수단으로 유리한 소송 조건을 인위적으로 만들어내는 행위는 허용되지 않는다.

###### ② 모순거동의 금지

- 자신의 이전 행위와 모순되는 소송 행위를 하여 상대방의 신뢰를 저버리는 행위는 금지된다.

#### 3. 민사소송법의 적용범위

##### (1) 인적 적용범위

###### ① 일반적 원칙

- 대한민국의 재판권은 영토 내의 모든 사람에게 미치는 것이 원칙이다.

###### ② 예외적 제한

- 외국 원수나 외교관 등 국제법상 치외법권을 누리는 자에게는 대한민국 재판권이 미치지 않는다.

##### (2) 시간적 적용범위

###### ① 신법 우선의 원칙

- 소송 진행 중 법이 개정되면 원칙적으로 신법을 적용하나, 구법 하에서 이미 완료된 절차의 효력은 유지된다.

###### ② 소송절차의 안정

- 진행 중인 절차의 혼란을 방지하기 위해 개정법 부칙을 통해 경과 조치를 두는 것이 일반적이다.

### III. 소송의 주체

#### 1. 법원

##### (1) 관할

###### ① 법정관할과 재정관할

- 법률에 의해 직접 정해진 관할을 법정관할이라 하며, 상급법원의 결정으로 정해지는 것을 재정관할이라 한다.

###### ② 거동관할

- 당사자의 합의에 의한 합의관할과 피고의 응소로 발생하는 변론관할이 이에 해당한다.

##### (2) 제척·기피·회피

###### ① 제척

- 제척은 법관이 사건과 특수한 관계가 있어 법률상 당연히 직무 집행에서 배제되는 제도이다.

###### ② 기피 및 회피

- 공정한 재판을 기대하기 어려운 경우 당사자의 신청으로 법관을 배제하는 것이 기피이며, 법관 스스로 물러나는 것이 회피이다.

## 2. 당사자

### (1) 당사자의 확정 및 능력

#### ① 당사자 확정

- 소장에 기재된 표시를 기준으로 누가 원고와 피고인지를 결정하며, 표시가 잘못된 경우 정정 절차를 거친다.

#### ② 당사자능력과 소송능력

- 소송의 주체가 될 수 있는 일반적 능력을 당사자능력이라 하고, 유효하게 소송 행위를 할 수 있는 지능적 능력을 소송능력이라 한다.

### (2) 당사자적격 및 소송대리

#### ① 당사자적격

- 특정 소송물에 대하여 원고로서 청구하거나 피고로서 판결을 받을 수 있는 구체적인 권능이다.

#### ② 소송대리인

- 미성년자 등을 위한 법정대리인과 본인의 수권에 의한 임의대리인으로 구분된다.

## IV. 제1심의 소송절차

### 1. 소송의 개시

#### (1) 소 제기의 효과

##### ① 소송계속

- 소장이 피고에게 송달되면 사건이 특정 법원의 심판 대상이 된 상태인 소송계속이 발생한다.

##### ② 중복소제기의 금지

- 이미 진행 중인 사건과 동일한 소를 다시 제기하는 것은 판결의 모순 방지를 위해 금지된다.

#### (2) 실체법상 효과

##### ① 시효중단

- 소 제기는 민법상 소멸시효를 중단시키는 강력한 효과를 발생시킨다.

##### ② 기간준수

- 법률상 정해진 제소 기간을 지키는 효과가 있어 권리 소멸을 방지한다.

### 2. 변론의 원칙

#### (1) 처분권주의

##### ① 의의

- 소송의 개시, 심판 범위의 결정, 소송의 종료를 당사자의 의사에 맡기는 원칙이다.

##### ② 내용

- 법원은 당사자가 신청하지 않은 사항에 대해 판결할 수 없으며, 청구 범위를 초과할 수도 없다.

#### (2) 변론주의

##### ① 사실의 주장책임

- 판결의 기초가 되는 주요 사실은 당사자가 주장해야 하며, 법원이 임의로 탐지할 수 없다.

##### ② 자백의 구속력

- 당사자 사이에 다툼이 없는 사실은 증거조사 없이 그대로 판결의 기초로 삼아야 한다.

### 3. 증거조사

#### (1) 입증책임

##### ① 입증책임의 분배

- 사실의 존부가 불명확할 때 불이익을 받는 당사자의 부담을 의미하며, 통상 권리 발생 요건 사실을 주장하는 자가 부담한다.

##### ② 입증책임의 완화

- 증거 편재 현상을 해결하기 위해 일표적 증명이나 법률상 추정 등을 통해 입증의 곤란을 해소한다.

#### (2) 증거조사 방법

##### ① 서증과 증인신문

- 문서의 내용을 조사하는 서증과 사람의 진술을 듣는 증인신문이 대표적인 증거조사 방법이다.

##### ② 검증과 감정

- 법관이 직접 사물의 상태를 확인하는 검증과 전문가의 지식을 빌리는 감정이 활용된다.

## V. 소송의 종료

### 1. 당사자의 의사에 의한 종료

#### (1) 소의 취하

##### ① 취하의 요건

- 원고가 소를 철회하는 행위로, 피고가 본안 변론을 한 후에는 피고의 동의가 필요하다.

##### ② 효과

- 소송은 소급적으로 소멸하며, 종국판결 선고 후 취하 시 재소금지의 원칙이 적용된다.

#### (2) 청구의 포기·인낙 및 화해

##### ① 포기 및 인낙

- 원고가 청구권을 포기하는 행위를 포기, 피고가 이를 수용하는 행위를 인낙이라고 하며, 조서 기재 시 확정판결과 동일한 효력을 갖는다.

##### ② 재판상 화해

- 소송 중 양 당사자가 합의에 도달하여 분쟁을 종결짓는 절차이다.

### 2. 종국판결에 의한 종료

#### (1) 판결의 효력

### ① 기판력

- 기판력은 확정된 판결의 내용이 후행 소송을 구속하여 동일한 쟁점으로 다시 다투지 못하게 하는 힘이다.

### ② 집행력과 형성력

- 판결 내용을 강제적으로 실현할 수 있는 힘인 집행력과 법률관계를 직접 변동시키는 형성력이 발생한다.

## (2) 기판력의 범위

### ① 주관적 범위

- 판결의 효력은 원칙적으로 소송 당사자에게만 미치며 제3자에게는 미치지 않는 것이 원칙이다.

### ② 객관적 범위

- 판결문의 주문에 나타난 판단에만 발생하며, 판결 이유 중의 판단에는 발생하지 않는다.

## VI. 병합소송 및 소송참가

### 1. 병합소송

#### (1) 객관적 병합

##### ① 단순병합

- 여러 청구를 병렬적으로 세워 모두에 대한 심판을 구하는 형태이다.

##### ② 예비적 병합

- 주된 청구가 인용되지 않을 경우를 대비하여 차순위 청구를 하는 방식이다.

#### (2) 주관적 병합

##### ① 통상 공동소송

- 여러 사람이 함께 소송하되 각자의 소송 행위가 서로에게 영향을 주지 않는 독립 원칙이 적용된다.

##### ② 필수적 공동소송

- 소송물의 성질상 합일적으로 확정되어야 하여 전원이 함께 소송을 수행해야 하는 형태이다.

### 2. 소송참가

#### (1) 보조참가

##### ① 의의

- 소송 결과에 이해관계가 있는 제3자가 어느 한쪽을 돕기 위해 참여하는 제도이다.

##### ② 효력

- 참가인은 당사자를 지원하는 행위를 할 수 있으나 피참가인에게 불리한 행위는 제한된다.

#### (2) 독립당사자참가

##### ① 의의

- 제3자가 소송 당사자 양쪽 또는 한쪽을 상대로 자신의 권리를 주장하며 소송에 개입하는 방식이다.

##### ② 요건

- 기존 소송의 결과에 의해 자신의 권리가 침해될 우려가 있거나 소송물이 자신의 권리임을 주장할 때 가능하다.

## VI. 상소 및 재심절차

### 1. 항소심 절차

#### (1) 항소의 제기

##### ① 기간 및 방법

- 1심 판결 송달 후 2주 이내에 항소장을 제출해야 하며, 불복의 범위를 명시해야 한다.

##### ② 부대항소

- 상대방이 제기한 항소 절차 내에서 자신의 불복을 신청하는 제도로 항소권 소멸 후에도 가능하다.

#### (2) 항소심의 심리

##### ① 속심제

- 1심의 심리 상태를 바탕으로 항소심에서 새로운 자료를 추가하여 심리하는 방식을 취한다.

##### ② 불이익변경금지

- 항소인에게 1심 판결보다 불리한 결과를 초과하여 판결할 수 없다는 원칙이다.

### 2. 상고 및 재심

#### (1) 상고심

##### ① 상고이유

- 2심 판결에 법령 위반이 있는 경우에만 대법원에 상고할 수 있으며 사실관계는 다를 수 없다.

##### ② 심리불속행

- 상고이유가 법정 사유에 해당하지 않으면 더 이상 심리하지 않고 기각하는 제도이다.

#### (2) 재심절차

##### ① 재심사유

- 확정된 판결에 중대한 절차적 하자나 증거 위조 등의 사유가 있는 경우 제기할 수 있다.

##### ② 제척기간

- 재심 사유를 안 날로부터 30일, 판결 확정 후 5년 이내에 제기해야 하는 엄격한 기간 제한이 있다.

## VII. 결 론

- 민사소송법은 사적 분쟁의 공정한 해결을 위한 절차법으로서 적정과 공평, 신속과 경제라는 가치를 균형 있게 추구한다. 법원과 당사자라는 소송 주체의 엄격한 역할 분담과 신의성실의 원칙을 바탕으로, 소의 제기부터 판결의 확정 및 비상 구제 수단인 재심에 이르기까지 정밀한 체계를 갖추고 있다. 본 개론에서 다룬 관할, 당사자 확정, 변론주의 및 처분권주의, 기판력의 범위 등은 실질적인 권리 구제를 보장하는 핵심적 기둥이다. 특히 현대 소송에서

는 복잡해지는 분쟁 양상에 대응하기 위해 병합 소송과 소송 참가 등의 제도가 중요하게 작용하며, 상소 제도를 통해 재판의 오류를 시정할 기회를 보장한다. 결론적으로 민사소송법은 법치주의 하에서 개인의 권리를 실현하고 사회적 정의를 확립하는 필수적인 제도적 장치라 할 수 있다.

## <제1편 총설.제1장 민사소송.제2절 민사소송의 의의와 목적>

### I. 민사소송의 의의

#### 1. 민사소송의 개념

- 민사소송이란 사법상의 권리관계에 관하여 다툼이 생겼을 때, 국가의 재판권에 의하여 법률적·강제적으로 그 분쟁을 해결하기 위한 절차를 의미한다. 이는 사적 자치의 원칙이 지배하는 사법 영역에서 당사자 간의 자율적인 해결이 불가능해진 경우, 국가가 개입하여 법의 잣대로 종국적인 결론을 내리는 공권적 해결 수단이다. 민사소송은 형사소송이나 행정소송과 구별되는 독자적인 영역을 가진다. 형사소송이 국가의 형벌권 행사를 목적으로 하는 국가 대 개인의 관계라면, 민사소송은 대등한 주체 사이의 수평적 권리관계를 다룬다. 또한 행정소송이 행정권의 적법성 통제를 주된 목적으로 하는 것과 달리, 민사소송은 개인의 사익 보호와 사법 질서의 유지를 본질로 한다.

#### 2. 법치주의와 사적 자결의 금지

- 현대 법치국가에서는 개인이 자신의 실력을 사용하여 권리를 실현하는 자력구제를 원칙적으로 금지하고 있다. 만약 개인이 힘을 통해 문제를 해결하도록 방치한다면 사회는 약육강식의 혼란에 빠질 것이기 때문이다. 국가는 자력구제를 금지하는 대신, 국민에게 재판을 청구할 수 있는 권리를 부여하고 이를 수행할 법원과 절차를 마련하였다. 따라서 민사소송은 사적 자결의 금지에 대한 국가적 보상책으로서의 성격을 갖는다. 당사자는 법이 정한 절차 내에서 자신의 주장을 펼치고 증거를 제출하며, 법원은 법률에 근거한 판결을 통해 분쟁을 종식시킨다. 이러한 일련의 과정은 투명하고 공정하게 진행되어야 하며, 이를 규율하는 법이 바로 민사소송법이다.

#### 3. 소송의 주체와 객체

- 민사소송의 주체는 재판권을 행사하는 법원과 판결을 구하는 원고, 그에 대응하는 피고이다. 법원은 중립적인 제3자의 지위에서 양 당사자의 주장을 듣고 판단하는 역할을 수행한다. 당사자인 원고와 피고는 소송의 승패에 직접적인 이해관계를 가지며, 자기 책임 하에 소송을 수행하는 주도적인 지위를 갖는다. 소송의 객체는 당사자가 재판을 통해 해결하고자 하는 구체적인 법률관계, 즉 소송물이다. 이는 특정한 권리의 존부나 의무의 이행 여부 등이 될 수 있다. 법원은 당사자가 신청한 소송물의 범위 내에서만 심판해야 하며, 이를 벗어난 판단을 내릴 수 없다는 처분권주의가 민사소송의 핵심 원칙으로 작용한다.

### II. 민사소송의 목적

#### 1. 사권의 보호

- 민사소송의 가장 일차적인 목적은 개인의 사법상 권리를 보호하는 데 있다. 이를 사권보호설이라 한다. 당사자가 법원에 소를 제기하는 실질적인 이유는 국가 질서의 유지보다는 자신의 침해된 권리를 구제받기 위함이다. 예를 들어, 빌려준 돈을 받지 못한 채권자가 소를 제기하는 것은 국가의 법질서 확립보다는 자신의 재산권 회복이 주된 목적이다. 이 관점에서 민사소송은 사적 이익의 실현을 돕는 보조적 수단이 된다. 소송 절차에서 당사자의 자율성을 중시하는 변론주의와 처분권주의는 이러한 사권 보호의 목적을 달성하기 위한 구체적인 운용 원리이다. 즉, 소송의 개시와 종료, 심판의 대상을 당사자의 의사에 맡김으로써 개인의 권익을 최우선으로 고려한다.

#### 2. 법질서의 유지

- 민사소송은 개별적인 권리 구제를 넘어, 국가 전체의 사법 법질서를 유지하고 확립하는 목적을 가진다. 이를 법질서유지설이라 한다. 법원이 구체적인 사건에 대하여 법을 해석하고 적용하여 판결을 내리는 과정은, 단순히 한 사건의 해결에 그치지 않고 사회 전체에 '법은 살아있다'라는 메시지를 전달한다. 판결을 통해 확립된 법리는 장래의 유사한 분쟁을 예방하는 가이드라인이 된다. 또한, 강제집행 절차를 통해 판결의 실효성을 확보함으로써 법의 권위를 세운다. 민사소송이 원활하게 작동할 때 사회 구성원들은 법적 안정성을 신뢰하게 되며, 이는 평화로운 공동체 생활의 근간이 된다.

#### 3. 분쟁의 종국적 해결

- 최근에는 권리 보호나 법질서 유지라는 관념적 목적보다는, 현실적인 분쟁의 해결 자체에 방점을 두는 견해가 강조되고 있다. 이를 분쟁해결설이라 한다. 민사소송은 복잡다단한 사회적 갈등을 강제력을 동반한 절차를 통해 종지부를 찍음으로써 사회적 비용을 절감하고 평화를 회복하는 데 그 존재의 의미가 있다. 단순히 법적 옳고 그름을 가리는 것을 넘어, 판결의 기판력을 통해 동일한 분쟁이 다시 발생하지 않도록 차단하는 것이 중요하다. 또한 조정, 화해와 같은 제도적 장치를 소송 내에서 적극 활용하는 것 역시 분쟁의 실질적이고 원만한 종결을 목적으로 하는 현대적 민사소송의 흐름을 반영한다.

#### 4. 학설의 종합과 적정·공평·신속·경제의 원칙

- 오늘날 지배적인 견해는 위에서 언급한 목적들을 단일한 것으로 보지 않고 상호 보완적인 관계로 파악한다. 민사소송법 제1조 제1항은 법원은 소송 절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다고 규정하여 소송의 운영 원칙을 명시하고 있다.

##### (1) 적정과 공평

- 재판은 실제적 진실에 부합하도록 적정해야 하며, 양 당사자에게 동등한 기회를 부여하여 공평해야 한다. 이는 절차적 정의를 실현하기 위한 필수 요건이다. 아무리 빠른 재판이라도 공정성을 잃으면 국민의 신뢰를 얻을 수 없다.

##### (2) 신속과 경제

- '지연된 정의는 정의가 아니다'라는 격언처럼, 재판은 불필요한 지체 없이 신속하게 진행되어야 한다. 또한 적은 비용으로 최대의 효과를 거두는 경제성도 무시할 수 없다. 소송 비용이 지나치게 비싸거나 기간이 너무 길어지면 국민의 재판청구권은 형해화될 우려가 있다. 따라서 민사소송의 궁극적 목적은 이러한 4대 이념을 조화롭게 달성함으로써 사권을 보호하고 법질서를 수호하며, 결과적으로 사회적 분쟁을 종결시키는 데 있다고 할 수 있다.

### III. 결론

- 민사소송은 사적 자치의 한계가 드러난 지점에서 국가가 법치주의를 실현하기 위해 마련한 최후의 분쟁 해결 체계이다. 의의 측면에서 민사소송은 자력구제가 금지된 현대 사회에서 공권적 재판권을 통해 개인의 삶을 규율하는 절차법적 근거가 된다. 또한 목적 측면에서는 사권 보호라는 미시적 관점과 법질서 유지라는 거시적 관점, 분쟁 해결이라는 실천적 관점이 유기적으로 결합되어 있다. 결국 민사소송법의 존재 목적은 단순히 승패를 가리는 것이 아니라, 투명한 절차 속에서 당사자가 승복할 수 있는 결과를 도출함으로써 사회적 정의를 실현하는 데 있다. 법원은 적정·공평·신속·경제라는 이념을 내침반 삼아 소송을 주재해야 하며, 당사자는 신의에 따라 성실하게 소송에 임함으로써 민사소송이 지향하는 진정한 평화 회복의 가치를 공유해야 한다. 이러한 이해를 바탕으로 민사소송의 각론적 규정들을 해석하고 적용할 때, 법의 본질에 다가가는 올바른 법적 판단이 가능해질 것이다.

## <제1편 총설.제1장 민사소송.제3절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙>

### I. 의의

- 민사소송의 이상이란 민사소송제도가 지향해야 할 최고지도원리를 의미한다. 민사소송법 제1조 제1항에서 법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.고 규정하고, 제2항에서 당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다.고 규정하여 이를 명문화하고 있다. 민사소송의 3대 이상은 적정·공평, 신속, 경제이다. 적정·공평은 재판의 내용이 실체적 진실에 부합하고 절차적으로 당사자에게 평등한 기회를 부여해야 한다는 원칙이다. 신속은 '지연된 정의는 정의가 아니다'라는 격언처럼 적시에 판결을 내리는 것을 의미하며, 경제는 최소한의 비용과 노력으로 최대의 분쟁해결 효과를 거두는 것을 목표로 한다. 이러한 소송의 이상을 구체적인 소송수행의 지침으로 전환한 것이 신의성실의 원칙(이하 '신의칙')이다. 이는 사법상 신의칙이 소송법 분야로 유입된 것으로, 당사자가 소송상 권능을 행사하거나 의무를 이행할 때 상대방의 신뢰를 배반하지 않도록 성실히 행동해야 한다는 윤리적 법원칙이다. 2002년 민사소송법 개정을 통해 명문으로 도입됨으로써 단순한 선언적 의미를 넘어 실증법상의 구속력을 가진다.

### II. 적용범위

#### 1. 적용여부

- 과거에는 민사소송이 엄격한 법정절차에 의하므로 주관적 요소를 포함하는 신의칙의 적용을 부정하는 견해도 있었으나, 현대 소송법학에서는 이를 당연히 인정한다. 민사소송은 국가와 당사자, 당사자 상호 간의 법적 공동체 형성 과정이므로 그 구성원 간의 신뢰 보호는 필수적이다. 다만, 절차의 안정성을 해치지 않는 범위 내에서 보충적으로 적용되어야 한다는 점에 유의해야 한다.

#### 2. 학설

##### (1) 보충적 적용설

- 개별적인 법규나 법해석으로 해결할 수 없는 경우에만 적용된다는 입장이다.

##### (2) 선택적 적용설[판례]

- 부제소합의에 위반하여 제기된 소에 대해 권리보호의 이익을 부정하면서, 신의칙의 원칙에 반한다고 보는 입장이다.

##### (3) 검토

- 판례와 같이 개별법규가 적용될 사안인지 여부는 불분명한 경우가 대부분이므로 선택적 적용설이 타당하다고 보인다.

### III. 적용모습

#### 1. 소송상태의 부당형성의 금지

- 당사자가 자기에게 유리한 소송상태를 만들기 위해 부당한 수단을 사용하는 것을 금지하는 원칙이다. 소송요건의 작위적 형성으로서 대한민국 법원에 재판관할권을 강제로 발생시키기 위해 허위의 주소를 기재하거나, 전속관할을 회피하기 위해 허위의 공동피고를 추가하는 행위가 이에 해당한다. 또한 증거의 조작 및 방해와 관련하여 상대방의 입증을 곤란하게 할 목적으로 증거물을 인멸하거나, 증인이 출석하지 못하도록 협박하는 행위 등은 신의칙에 반한다. 판례는 당사자 일방이 증거를 인멸한 경우, 그로 인해 입증이 곤란해진 사실을 상대방의 주장대로 인정하거나 입증책임을 전환하는 등의 제재를 가한다.

#### 2. 선행행위와 모순되는 거동의 금지

- 이른바 금반언의 원칙으로, 당사자가 이전에 행한 명시적·묵시적 거동과 모순되는 소송행위를 함으로써 상대방의 정당한 신뢰를 해치는 것을 금지한다. 적용 요건으로 첫째, 당사자의 선행행위가 존재해야 하며, 둘째, 상대방이 그 선행행위를 신뢰하고 소송상 지위를 구축했어야 하고, 셋째, 후행행위가 선행행위와 정면으로 배치되어야 한다. 구체적 사례로는 상대방의 제소에 대하여 본안판결을 구하며 응소한 자가 나중에 소송요건의 흠결을 주장하며 각하를 구하는 경우나, 제1심에서 특정 사실에 대해 다투지 않겠다고 명시적으로 표명한 후 항소심에서 이를 다시 다투는 행위 등이 이에 속한다. 다만, 판례는 강행법규 위반을 알고도 계약을 체결한 자가 나중에 무효를 주장하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙 위반이 아니라고 보아 절차의 엄격성을 유지한다.

#### 3. 소권의 실효

- 관리자가 상당한 기간 소권을 행사하지 않아 상대방이 더 이상 권리행사가 없을 것으로 믿을만한 정당한 사유가 생긴 경우, 그 소권의 행사를 허용하지 않는 원칙이다. 제척기간이나 소멸시효 제도를 보완하여 법적 안정성을 도모하고 상대방의 방어권 침해를 방지하기 위한 취지를 가진다. 판례는 실효의 원칙이 적용되기 위해 상당한 기간의 경과와 권리불행사에 대한 정당한 신뢰라는 두 가지 요건이 충족되어야 한다고 본다. 단순히 기간이 오래되었다는 사실만으로는 부족하며, 관리자가 권리를 행사하지 않을 것 같은 태도를 보여야 한다. 해고된 근로자가 수년간 아무런 이의를 제기하지 않다가 갑자기 해고무효확인소송을 제기하는 경우 등이 대표적인 실효의 사례로 검토된다.

#### 4. 소권의 남용금지

- 외형상으로는 소송상의 권리행사처럼 보이나, 실질적으로는 상대방에게 고통을 주거나 부당한 이익을 얻으려는 목적으로 소를 제기하는 경우 이를 허용하지 않는 것이다. 이미 확정판결을 받은 사안에 대하여 동일한 목적의 소를 반복적으로 제기하는 경우, 승소할 가능성이 전혀 없음에도 상대방을 괴롭히기 위해 제소하는 경우, 기판력의 저축을 피하기 위해 형식적인 당사자만 바꾸어 소를 제기하는 경우 등이 해당한다. 판례는 판결의 편취(허위의 주소나 증거로 승소판결을 받아내는 행위)를 소권 남용의 전형적인 형태로 본다. 이 경우 확정판결의 효력을 부인하거나, 강제집행을 저지하는 소송에서 신의칙 위반을 근거로 당사자의 청구를 기각한다.

### IV. 위반의 조사 및 효과

#### 1. 직권조사사항

- 신의칙 위반 여부는 소송요건에 준하는 사항으로서 당사자의 항변이 없더라도 법원이 직권으로 조사하여야 한다. 이는 공공의 이익과 소송절차의 정당성을 보호하기 위함이다. 당사자가 주장하지 않더라도 기록상 신의칙 위반의 혐의가 있다면 법원은 이를 심리해야 할 의무가 있다.

#### 2. 신의칙을 위반한 경우의 처리

- 당사자의 특정 소송행위가 신의칙에 반하는 경우 그 행위는 무효가 되어 효력이 발생하지 않는다. 예를 들어, 증거방해 행위가 있다면 방해된 증거의 가치를 상대방에게 유리하게 평가한다. 소의 제기 자체가 신의칙 위반(소권 남용, 실효, 부당형성 등)에 해당할 경우, 법원은 본안에 대한 심리를 거절하고 판결으로써 소각하 결정을 내려야 한다. 또한 신의칙 위반으로 인해 상대방에게 불필요한 비용이나 정신적 고통을 가했다면, 이는 실체법상 불법행위를 구성하여 별도의 손해배상 책임을 질 수 있다.

#### 3. 간과판결과 그 구제

- 법원이 신의칙 위반 사실을 알지 못하고 본안판결을 내린 경우, 판결이 확정되기 전이라면 상소(항소, 상고)를 통해 신의칙 위반을 이유로 판결의 취소를 구할 수 있다. 판결이 확정된 후에는 기판력의 원칙상 이를 번복하기 어려우나, 판결의 편취와 같이 신의칙 위반의 정도가 극심하여 정의에 반한다고 인정되는 경우에는 재심사유에 준하여 다루거나, 판결에 기한 강제집행을 신의칙 위반으로 저지하는 청구이의의 소를 허용하는 것이 판례의 경향이다.

## **V. 결론**

- 민사소송의 이상인 적정·공평, 신속, 경제의 가치는 법원의 적극적인 절차 운영과 당사자의 성실한 협력을 통해 달성될 수 있다. 신의성실의 원칙은 이러한 이상적 가치를 소송 현실에서 구현하는 통제 장치로서 작용한다. 다만, 신의칙은 일반조항으로의 도피라는 비판이 있을 수 있으므로, 명문의 절차 규정이 있는 경우에는 우선적으로 그에 따르되 규정의 공백이 있거나 규정의 기계적 적용이 현저히 부당한 경우에 한하여 보충적으로 적용되어야 할 경우도 있다. 법원은 구체적 타당성과 법적 안정성의 조화를 도모하며 신의칙을 엄격히 운용함으로써 사법 신뢰를 확보해야 할 것이다.

## <제1편 총설.제2장 민사소송법.제1절 민사소송법의 의의와 성격>

### I. 민사소송법의 의의

- 민사소송법이란 사적 법률관계에서 발생하는 분쟁을 국가의 재판권에 의하여 강제적·종국적으로 해결하기 위한 절차를 규정하는 법률체계를 의미한다. 사법상의 권리관계는 원칙적으로 당사자 간의 자율적 합의에 의해 해결되어야 하나, 합의가 불가능할 경우 국가가 개입하여 권리관계를 확정하고 강제력을 행사함으로써 사회 질서를 유지하게 된다. 민사소송법은 이러한 과정에서 법원과 당사자가 준수해야 할 행위 규범을 제시하며, 실체법인 민법이나 상법이 규정하는 권리와 의무가 현실적으로 관철될 수 있도록 통로를 마련해주는 역할을 수행한다. 넓은 의미의 민사소송법은 민사소송절차뿐만 아니라 강제집행절차, 가압류·가처분과 같은 보전처분절차, 파산 및 회생절차 등을 모두 포함하는 포괄적인 법률 영역을 의미하며, 좁은 의미로는 판결 절차를 규정하는 성문법전인 민사소송법 자체를 지칭한다.

### II. 민사소송법의 성격

#### 1. 공법

- 민사소송법은 국가기관인 법원이 재판권을 행사하는 과정과 그에 참여하는 당사자와의 관계를 규율하므로 공법적 성격을 가진다. 사적 분쟁을 다룬다는 점에서 사법과 연관이 있으나, 그 해결의 주체가 국가이고 절차 자체가 국가 권력의 행사를 전제로 하므로 민사소송법은 헌법, 행정법, 형사소송법과 궤를 같이하는 공법 영역에 속한다. 따라서 소송상의 권리나 의무는 당사자 간의 계약에 의해 임의로 창설하거나 포기할 수 없는 경우가 많으며, 절차의 정당성을 보장하기 위해 국가가 개입하는 강행규정적 성격이 강하게 나타난다.

#### 2. 절차법

- 민사소송법은 실체법인 민법, 상법 등의 권리를 실현하기 위한 수단과 방법을 규정하는 절차법이다. 실체법이 어떠한 권리가 존재하는가라는 권리의 준부를 다룬다면, 민사소송법은 그 권리를 어떻게 증명하고 확정할 것인가라는 절차적 과정을 다룬다. 절차법으로서 민사소송법은 절차의 안정성과 예견 가능성을 중시하므로, 실체법에 비해 형식주의적 성격이 강하며 법정된 형식을 갖추지 못한 소송행위는 효력이 부인되는 경우가 많다. 그러나 현대 소송법학에서는 단순히 실체법의 수단에 머무는 것이 아니라, 절차 자체의 독자적인 가치와 당사자의 절차적 기본권을 중시하는 방향으로 발전하고 있다.

#### 3. 강행법규성

- 민사소송법의 규정들은 사적 자치가 지배하는 실체 사법과 달리 원칙적으로 강행규정의 성격을 가진다. 소송절차는 국가 재판권의 공정한 행사를 목적으로 하며 다수의 이해관계인에게 영향을 미치므로, 당사자의 합의만으로 절차를 임의로 변경하거나 배제하는 것은 허용되지 않는다. 예를 들어 전속관할에 관한 규정이나 상소 기간에 관한 규정 등은 당사자가 합의하더라도 바꿀 수 없는 강행법규에 해당한다. 다만, 변론주의가 적용되는 범위 내에서 당사자의 처분권이 인정되는 영역(임의관할에 대한 합의 등)에서는 예외적으로 임의규정적 성격이 허용되기도 하지만, 이는 어디까지나 법이 허용하는 범위 내에서의 제한적 자치에 불과하다.

### III. 사법과의 관계

#### 1. 실체법과 절차법의 구별

- 민법과 같은 실체법은 생활 관계의 내용을 규율하고 민사소송법과 같은 절차법은 그 실현 과정을 규율한다. 실체법상 권리가 발생하더라도 이를 국가적으로 승인받기 위해서는 절차법이 정한 요건을 갖추어야 하며, 반대로 절차법상 승소 판결을 받더라도 실체법상 권리가 존재하지 않는다면 이는 실질적인 정의에 부합하지 않는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 양자는 서로 독립된 법 영역이면서도 유기적으로 결합하여 법치주의를 완성하는 보완적 관계에 있다.

#### 2. 소송법적 효과와 실체법적 효과의 분리

- 소송상 행해지는 행위는 원칙적으로 소송법적 효과만을 발생시킨다. 예를 들어 소송상 화해가 이루어지면 판결과 동일한 효력이 발생하여 분쟁이 종결되는데, 이는 실체법상 계약의 무효 사유가 있더라도 소송법적 절차 내에서는 확정적인 효력을 가질 수 있음을 의미한다. 판례 또한 소송행위에 실체법상의 흠결(착오, 사기, 강박 등)이 있더라도 소송법의 안정성을 위해 원칙적으로 그 효력을 부인하지 않는 소송행위의 독립성을 인정하고 있다. 이는 절차의 명확성을 유지하기 위한 조치로 사법상의 법률관계와 소송상의 법률관계를 논리적으로 분리하여 고찰하는 태도이다.

### IV. 형사소송법과의 관계

- 민사소송법과 형사소송법은 모두 국가 재판권을 행사하는 절차법이라는 공통점을 가지나, 그 이념과 구조에서는 뚜렷한 차이를 보인다. 형사소송법은 국가의 형벌권 행사를 목적으로 하며 실체적 진실 발견과 피고인의 인권 보호를 최우선으로 하므로 법원의 직권 탐지주의가 강하게 작용한다. 반면 민사소송법은 사적 분쟁의 해결을 목적으로 하므로 당사자의 의사를 존중하는 변론주의와 처분권주의가 지배적 원리로 작용한다. 증거법에 있어서도 형사소송은 엄격한 증거능력을 요구하는 반면, 민사소송은 증거능력의 제한이 거의 없으며 자유심증주의가 폭넓게 인정되는 등 분쟁의 효율적 해결에 초점을 맞춘다.

### V. 결론

- 민사소송법은 국가 재판권을 통해 사법적 권리를 구제하고 법 질서를 유지하는 필수적인 공법적 절차법이다. 실체법인 사법의 실현을 돕는 도구적 성격과 더불어, 공정한 절차를 통해 당사자의 기본권을 보장하는 독자적인 존재 의의를 지닌다. 따라서 민사소송법의 운용에 있어서는 절차의 안정성을 기하기 위한 강행법규성을 유지하면서도, 실체적 정의가 훼손되지 않도록 사법과의 조화로운 해석이 요구된다. 법원은 민사소송법의 이러한 복합적 성격을 이해하여 국민의 재판받을 권리가 실질적으로 보장될 수 있도록 노력하여야 한다.



<제1편 총설.제2장 민사소송법.제2절 민사소송법규의 종류>

**I. 훈시규정과 효력규정**

- 민사소송법 규정은 그 위반 시 당사자의 소송행위나 법원의 재판상 행위의 효력에 어떠한 영향을 미치느냐에 따라 훈시규정과 효력규정으로 구분된다. 훈시규정이란 법원이나 소송관계인에 대하여 일정한 행위를 하도록 지시하거나 기간을 정해두었으나, 이를 위반하더라도 그 행위의 법적 효력에는 영향을 없는 규정을 의미한다. 대표적으로 판결 선고 기간에 관한 규정이나 판결서 송달 기간 등이 이에 해당한다. 이러한 규정들은 소송의 신속한 진행을 도모하기 위한 정책적 지침에 불과하므로, 법원이 이를 어기고 기간을 도과하여 판결을 선고하더라도 그 판결이 무효가 되거나 상소 사유가 되지 않는다. 반면 효력규정은 그 규정에 정해진 방식이나 절차를 따르지 않을 경우 해당 소송행위의 효력이 부인되는 규정을 말한다. 소장의 필수적 기재사항이나 상소 제기 기간 등이 이에 해당하며, 이를 위반한 소송행위는 원칙적으로 무효가 되거나 부적법한 것으로 간주되어 법적 효과를 발생시키지 못한다. 민사소송법의 규정은 절차의 명확성과 법적 안정성을 위해 대부분 효력규정의 성격을 가지며, 훈시규정으로 해석되는 경우는 극히 제한적이다.

**II. 강행규정과 임의규정**

**1. 강행규정**

**(1) 개념**

- 강행규정이란 당사자의 합의나 의사에 관계없이 반드시 준수되어야 하며, 이를 위반할 경우 절차상의 하자가 발생하는 규정을 의미한다. 민사소송법은 사적 분쟁을 다루지만 그 해결 절차는 국가 권력인 재판권의 행사를 수반하는 공법적 영역이므로, 절차의 정당성과 공정성을 확보하기 위해 원칙적으로 강행규정성을 띤다.

**(2) 성격 및 취지**

- 강행규정은 소송절차의 확실성과 명확성을 보장함으로써 법적 안정성을 유지하고, 당사자 간의 불평등한 지위를 시정하여 공정한 재판을 받을 권리를 보호하는 데 목적이 있다. 소송의 기초가 되는 관할권 중 전속관할에 관한 규정, 소송능력에 관한 규정, 대리권의 존부에 관한 규정 등이 대표적인 예이다. 이러한 규정들은 사적 자치가 허용되지 않는 영역으로서 당사자가 임의로 배제할 수 없다.

**(3) 위반의 효과 및 조사**

- 강행규정 위반 여부는 법원이 당사자의 주장을 기다리지 않고 직권으로 조사하여야 하는 직권조사사항이다. 당사자가 위반 사실에 대하여 이의를 제기하지 않거나 심지어 묵시적으로 동의하였더라도 법원은 이를 간과해서는 안 된다. 만약 강행규정을 위반한 소송행위가 있을 경우 법원은 그 효력을 부인하여야 하며, 이를 간과하고 판결이 내려진 경우 상소나 재심을 통해 구제받을 수 있다. 다만, 절차의 안정을 위해 확정판결의 경우에는 재심사유에 해당하는 중대한 위반이 아닌 한 그 효력이 유지되는 경우도 있다.

**2. 임의규정**

**(1) 개념**

- 임의규정이란 법규의 내용이 당사자의 의사에 의하여 변경되거나 그 적용을 배제할 수 있는 규정을 의미한다. 민사소송법이 공법적 성격을 가지지만, 사적 유치의 영역인 실체법상의 권리관계를 다루는 만큼 당사자의 처분권과 변론주의를 존중하기 위해 일부 규정은 임의규정으로 운용된다.

**(2) 범위와 예시**

- 임의규정은 주로 소송절차의 편의나 당사자의 이익만을 위해 설정된 규정들에서 나타난다. 대표적으로 전속관할이 아닌 임의관할에 관한 규정, 증거조사의 방식에 관한 규정, 변론의 방식 등이 이에 해당한다. 또한 민사소송법 제151조에 규정된 책문권의 대상이 되는 규정들이 전형적인 임의규정의 영역이다. 당사자는 이러한 규정의 위반에 대하여 이의를 제기할 수도 있으나, 명시적 혹은 묵시적으로 이의를 포기함으로써 그 하자를 치유할 수 있다.

**(3) 책문권과 하자의 치유**

- 임의규정에 위반된 소송행위가 있더라도 상대방이 지체 없이 이의를 제기하지 않거나, 그 위반을 알고도 소송절차를 계속 진행한 경우에는 이의권이 상실된다. 이를 책문권의 상실이라고 하며, 이로 인해 절차상의 하자는 치유되어 해당 소송행위는 확정적으로 유효하게 된다. 이는 소송의 경제와 신속을 위해 절차상의 사소한 결함을 뒤늦게 문제 삼아 전체 절차를 무효화하는 것을 방지하기 위한 제도적 장치이다. 다만, 강행규정 위반의 경우에는 이러한 책문권 상실에 의한 하자 치유가 인정되지 않는다는 점이 임의규정과 구별되는 핵심적 실익이다.

**III. 결론**

- 민사소송법규는 그 목적과 기능에 따라 훈시규정과 효력규정, 그리고 강행규정과 임의규정으로 나뉘어 각기 다른 법적 효과를 발생시킨다. 훈시규정은 소송 진행의 효율성을 도모하고, 효력규정은 절차의 엄격성을 유지하며, 강행규정은 공익적 측면에서 재판의 정당성을 담보한다. 반면 임의규정은 당사자의 자율성을 존중하여 유연한 분쟁 해결을 가능하게 한다. 법원은 개별 규정의 성격을 명확히 파악하여 직권조사의 범위와 하자의 치유 여부를 결정함으로써, 소송의 이상인 적정·공평, 신속, 경제가 조화를 이룰 수 있도록 절차를 운영하여야 한다. 특히 강행규정의 무분별한 확장 해석은 당사자의 편익을 해칠 수 있고, 반대로 임의규정의 남용은 절차적 정의를 훼손할 수 있으므로 구체적인 사안에 따른 신중한 법 해석이 요구된다.

## <제2편 소송의 주체.제3장 법원.제1절 민사재판권>

### I. 민사재판권의 대인적 범위

#### 1. 의의

- 민사재판권의 대인적 범위란 대한민국의 재판권이 어떠한 사람에게까지 미치는가의 문제이다. 원칙적으로 대한민국의 통치권이 미치는 영역 내에 있는 모든 사람은 내국인과 외국인을 불문하고 대한민국의 민사재판권에 복종한다. 다만, 국제법상 면제특권을 가진 주권국가나 외교관 등에 대해서는 예외가 인정된다.

#### 2. 외국 주권국가에 대한 재판권의 존부

- 과거에는 주권평등의 원칙에 따라 국가는 다른 국가의 재판권에 복종하지 않는다는 절대적 면제주의가 지배적이었다. 그러나 현대 국가의 활동 영역이 상업적 기능으로 확대됨에 따라 오늘날에는 제한적 면제주의가 통설과 판례의 입장이다. 이에 따르면 외국의 주권적 활동(공법적 행위)에 대해서는 재판권이 면제되지만, 사적 활동(사경제적 행위)에 대해서는 대한민국의 재판권이 행사될 수 있다.

#### 3. 관련 판례 - 외국국가가 국내부동산을 점유하는 경우 국내재판권이 미치는지 여부

- 판례는 외국국가의 사경제적 행위라 하더라도 승인할 수 없는 특별한 사정이 없는 한 재판권을 행사할 수 있다고 본다. 특히, 외국국가가 대한민국 내의 부동산을 점유하고 있는 경우, 해당 부동산에 관한 소송은 부동산 소재지 국가의 전속적 관할과 밀접한 관련이 있으므로 주권 침해의 우려가 적다. 따라서 외국국가가 국내 부동산을 점유·관리하는 행위가 사경제적 활동의 연장선상에 있다면 대한민국의 재판권이 미친다는 것이 법원의 판단이다.

### II. 민사재판권의 대물적 범위(국제재판관할권)

#### 1. 의의

- 민사재판권의 대물적 범위는 특정 사건이 대한민국 법원의 관할에 속하는가의 문제로, 이른바 국제재판관할권의 문제이다. 이는涉外적 요소가 포함된 사건(외국인 간의 분쟁 등)에서 대한민국 법원이 재판을 할 수 있는 실질적인 권한이 있는지를 결정하는 기준이 된다.

#### 2. 결정기준

- 국제재판관할권의 유무를 판단함에 있어서는 국제재판관할의 배분원칙과 당사자의 공평, 재판의 적정·신속을 고려해야 한다. 과거에는 국내법상의 관할 규정을 유추 적용하는 역추지설이 지배적이었으나, 현재는 대한민국과 해당 사건 또는 당사자 사이에 실질적 관련성이 있는지 여부를 기준으로 판단한다. 실질적 관련성이란 대한민국 법원이 재판권을 행사하는 것이 당사자 간의 형평을 해치지 않고 재판의 실효성을 거둘 수 있는 관계를 의미한다.

#### 3. 개정국제사법에 의한 국제재판관할권의 유무

- 개정된 국제사법은 국제재판관할의 판단 원칙을 구체화하였다. 법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다. 이때 실질적 관련성을 판단함에 있어서는 국내법의 관할 규정을 참작하되, 국제재판관할의 특수성을 고려하여야 한다. 특히 소비자계약이나 근로계약과 같이 경제적 약자 보호가 필요한 경우에는 약자의 거주지에 관할권을 인정하는 등 보호적 관할 원칙을 명문화하였다. 또한 전속적 관할 합의가 있는 경우 그 합의의 효력을 인정하되, 대한민국 법원의 전속관할을 배제하는 합의가 현저히 불합리한 경우에는 그 효력을 제한할 수 있다.

#### 4. 국제재판관할권 흠결의 효과

- 대한민국 법원에 국제재판관할권이 없음에도 불구하고 소가 제기된 경우, 이는 소송요건의 흠결에 해당한다. 법원은 이를 직권으로 조사하여야 하며, 관할권이 없다고 판단될 경우 판결로써 소를 각하하여야 한다. 다만, 당사자가 관할권 흠결에 대해 이의를 제기하지 않고 본안에 관하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술한 경우 변론관할이 성립할 수 있는지에 대해서는 긍정설이 다수설이다.

### III. 민사재판권의 장소적 범위

- 민사재판권의 장소적 범위는 대한민국의 영토권이 미치는 범위와 일치한다. 한반도와 그 부속도서 내에서 발생하는 사건은 물론, 영해와 영공 내에서 발생하는 사건에 대해서도 대한민국의 재판권이 미친다. 다만, 대한민국 영토 밖이라 하더라도 국제법상의 근거나 조약에 의해 재판권 행사가 허용되는 특수한 경우(치외법권 지역 제외)가 있을 수 있으나, 원칙적으로는 속지주의 원칙에 따라 결정된다.

### IV. 재판권 흠결의 효과

#### 1. 소의 각하

- 재판권의 존재는 소송요건이므로 법원은 소 제기 당시부터 판결 시까지 이를 직권으로 조사하여야 한다. 재판권이 없음이 밝혀진 경우 법원은 본안 심리를 거절하고 소각하 판결을 내려야 한다. 이는 관할 위반과는 달리 다른 법원으로 이송할 수 없는 성질의 것이다.

#### 2. 판결의 무효와 구제

- 재판권이 없음에도 불구하고 이를 간과하고 선고된 판결은 원칙적으로 무효이다. 이러한 판결은 확정되더라도 기판력이 발생하지 않으며, 강제집행의 근거가 될 수 없다. 만약 판결이 확정되기 전이라면 상소를 통해 취소를 구할 수 있으나, 판결이 이미 확정된 경우에는 재심의 대상조차 되지 않는다는 것이 엄격한 의미의 무효설이다. 다만, 외관상 판결의 형태를 갖추고 있는 경우 실무적으로는 재심청구 등을 통해 그 효력을 다투는 형식을 취하기도 한다.

### V. 결론

- 민사재판권은 국가 주권의 상징이자 사법 정의 실현의 기초가 된다. 대인적 범위에 있어서는 제한적 면제주의를 통해 국가의 상업적 활동에 대한 책임을 강조하고 있으며, 대물적 범위에 있어서는 국제사법상의 실질적 관련성 원칙을 통해 국제적 분쟁 해결의 합리적 기준을 제시하고 있다. 법원은 재판권의 범위를 확정함에 있어 국가 이익뿐만 아니라 사법 자치의 원칙과 당사자의 재판받을 권리를 균형 있게 고려하여야 한다. 특히 글로벌 시대의 도래로 인한 국제적 분쟁의 증가에 발맞추어, 국제재판관할의 유연하면서도 예측 가능한 기준을 확립하는 것이 사법부의 중요한 과제라 할 것이다.

## <제2편 소송의 주체.제3장 법원.제2절 법관의 제척·기피·회피>

### Ⅰ. 법관의 제척

#### 1. 의의

- 법관의 제척이란 법관이 구체적인 사건과 특수한 관계가 있는 경우에 법률에 의하여 당연히 그 사건의 직무집행에서 배제되는 제도를 의미한다. 이는 재판의 공정성에 대한 외관상의 의심을 사전에 차단하고 당사자의 신뢰를 확보하기 위한 강행규정적 성격을 가진다. 제척 사유가 존재하면 별도의 재판이나 신청 없이도 해당 법관은 법률상 당연히 직무수행 권한을 상실한다.

#### 2. 제척이유[민소법 제41조]

- 민사소송법 제41조는 법관이 직무집행에서 제척되는 사유를 한정적으로 열거하고 있다. 첫째, 법관 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 사건의 당사자가 되거나 당사자와 공동권리자·공동의무자의 관계에 있는 경우이다. 둘째, 법관이 당사자와 친족관계에 있거나 있었던 경우이다. 셋째, 법관이 사건에 관하여 증언이나 감정을 한 경우이다. 넷째, 법관이 사건의 당사자의 대리인이었거나 대리인이 된 경우이다. 다섯째, 법관이 불복 사건의 이전 심급의 재판에 관여한 경우이다. 이는 선입견을 배제하고 심급 제도의 실효성을 보장하기 위함이다.

#### 3. 제척효과

- 제척 사유가 있는 법관은 해당 사건에 관한 모든 직무집행을 할 수 없다. 여기에는 변론의 진행, 증거조사, 판결의 선고뿐만 아니라 중국판결 이전의 부수적 결정도 포함된다. 제척된 법관이 재판에 관여하여 내린 판결은 절차상 중대한 하자가 있는 것으로 간주된다. 다만, 제척 결정이 확정되기 전에 한 소송행위라도 후에 제척 결정이 나면 소급하여 효력을 잃는 것이 원칙이나, 긴급을 요하는 행위나 중국판결의 선고 등 예외적인 경우에는 효력이 유지되기도 한다.

#### 4. 관련판례

- 판례는 제척 사유 중 이전 심급의 재판에 관여한 때의 범위를 엄격하게 해석한다. 최종변론과 판결의 합의에 관여하거나 중국판결과 더불어 상급심의 판단을 받는 중간적인 재판에 관여함을 말하는 것이고, 최종변론 전의 변론이나 증거조사 또는 기일지정과 같은 소송지휘상의 재판 등에 관여한 경우는 포함되지 않는다.

### Ⅱ. 법관의 기피

#### 1. 의의

- 법관의 기피란 법관에게 법정 제척 사유는 없으나 재판의 공정성을 기대하기 어려운 객관적 사정이 있는 경우, 당사자의 신청에 의하여 법관을 직무집행에서 배제시키는 제도를 말한다. 제척이 법률에 의한 당연 배제라면, 기피는 당사자의 형성적 권리 행사에 의한 재판상 배제라는 점에서 차이가 있다.

#### 2. 기피이유

- 기피 사유는 법관에게 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 때이다. 이는 통상적인 법관의 입장에서 당사자와의 친분 관계, 원한 관계, 특정 이해관계 등으로 인해 편파적인 재판을 할 염려가 있다고 객관적으로 인정될 만한 사유를 의미한다. 단순히 법관의 재판 진행 방식에 불만을 갖거나 법률 해석에 대한 견해 차이가 있다는 이유만으로는 기피신청이 정당화되지 않는다.

#### 3. 기피절차

- 기피신청은 해당 법관이 소속된 법원에 서면으로 신청하여야 한다. 신청인인 당사자는 신청한 날부터 3일 이내에 기피 사유를 서면으로 소명하여야 한다. 기피신청을 받은 법원은 이에 대한 의견서를 제출하여야 하며, 해당 법관의 소속 법원 합의부에서 기피신청의 수용 여부를 결정한다. 다만, 소송의 지연을 목적으로 함이 명백하거나 신청 방식에 어긋나는 경우에는 해당 법관 또는 재판부가 직접 신청을 각하할 수 있다.

#### 4. 기피신청의 효과

- 기피신청이 제기되면 원칙적으로 소송절차는 정지된다. 이는 불공정한 재판이 진행되는 것을 막기 위한 당연한 조치이다. 절차 정지의 예외로는 중국판결의 선고나 긴급을 요하는 행위가 있다. 만약 절차 정지 규정을 위반하여 소송을 진행하고 판결을 내렸다면, 이는 상소 사유가 된다. 기피신청이 각하되거나 기각된 경우에는 즉시항고를 통해 불복할 수 있으나, 이 경우에도 소송절차는 정지되지 않는 것이 원칙이다.

#### 5. 기피결정의 효과

- 기피신청이 이유 있다고 인정되어 기피결정이 확정되면, 해당 법관은 해당 사건의 직무집행에서 완전히 배제된다. 이후의 재판은 다른 법관에 의해 진행되어야 한다. 기피결정 이전에 해당 법관이 한 소송행위의 효력에 대해서는 견해의 대립이 있으나, 당사자가 이의를 제기하지 않는 한 유효한 것으로 취급되는 것이 일반적이다.

### Ⅲ. 법관의 회피

- 법관의 회피란 법관 스스로 자신에게 제척 또는 기피의 사유가 있다고 판단하는 경우, 자발적으로 해당 사건의 직무집행에서 물러나는 것을 말한다. 이는 법관의 양심과 직업윤리에 기초한 제도로서, 당사자의 신청 없이 법관이 소속 법원의 허가를 받아 결정한다. 회피의 사유는 제척이나 기피 사유와 동일하며, 회피 허가 결정이 내려지면 해당 법관은 사건에서 배제되고 새로운 법관이 지정된다.

### Ⅳ. 결론

- 법관의 제척·기피·회피 제도는 법관은 공정하여야 할 뿐만 아니라 공정하게 보여야 한다는 법언을 실현하는 핵심 기제이다. 제척은 법정 사유를 통한 당연 배제를, 기피는 당사자의 신청을 통한 사후 배제를, 회피는 법관의 자발적 배제를 의미하며 상호 보완적으로 작동한다. 이러한 제도들은 법관 개인의 주관적 성실성을 넘어 시스템적으로 재판의 중립성을 담보한다. 다만, 기피신청이 소송 지연의 수단으로 악용되는 사례를 방지하기 위해 법원은 기피 사유를 엄격히 심사하고 남용적 신청에 대해서는 단호한 각하결정을 내려야 한다. 결국 이 제도들의 올바른 운용은 국민의 재판에 대한 신뢰를 높이고 사법 정의를 확립하는 초석이 된다 할 것이다.

<제2편 소송의 주체.제3장 법원.제3절 관할>

**I. 관할의 개관**

**1. 관할의 의의**

- 관할이란 재판권을 행사하는 여러 법원 사이에서 특정 사건을 어느 법원이 담당하여 심판할 것인가를 정한 재판권의 배분을 의미한다. 재판권이 국가의 통치권적 차원에서 외국에 대하여 대한민국 사법부가 가지는 권한을 뜻한다면, 관할은 국내 법원들 사이의 내부적 업무 분담 체계이다. 이는 재판의 적정·신속 및 당사자의 공평을 도모하기 위해 설정된다.

**2. 관할의 종류**

- 관할은 크게 법률의 규정에 의해 정해지는 법정관할, 법원의 재판에 의해 정해지는 재정관할, 당사자의 합의나 응소에 의해 정해지는 거동관할로 나뉜다. 법정관할은 다시 직분관할, 사물관할, 토지관할로 구분되며, 성격에 따라 반드시 준수해야 하는 전속관할과 당사자의 합의로 배제할 수 있는 임의관할로 구분되기도 한다.

**II. 직분관할**

- 직분관할은 서로 다른 종류의 법원 업무 사이에서의 역할 분담을 의미한다. 제1심, 항소심, 상고심과 같은 심급기관 사이의 부담인 심급관할이 대표적이며, 수소법원과 집행법원, 합의부와 단독판사 사이의 직무 분담 등이 이에 해당한다. 이는 절차의 명확성을 위해 대부분 전속관할의 성격을 가진다.

**III. 사물관할**

**1. 의의**

- 사물관할이란 제1심 사건을 지방법원 합의부와 지방법원 단독판사 중 어느 쪽이 담당할 것인지를 정하는 기준이다. 이는 사건의 경중이나 성질에 따라 결정되며, 재판의 신중함과 효율성을 동시에 확보하려는 취지를 가진다.

**2. 합의부 관할**

**(1) 재정합의 관할**

- 사건의 성질상 단독판사 관할에 속하더라도 그 내용이 복잡하거나 사회적 파장이 커서 합의부에서 심판하는 것이 적절하다고 인정되어 합의부가 스스로 결정하거나 대법원 규칙에 따라 배당된 사건을 의미한다.

**(2) 소송목적의 값이 5억원을 초과하는 민사사건[민사 및 가사소송의 사물관할에 관한 규칙 제2조]**

- 경제적 이해관계가 큰 사건으로서 소가(訴價)가 5억원 초과인 경우 원칙적으로 합의부가 제1심을 담당한다.

**(3) 재산권에 관한 소로서 그 소송목적의 값을 계산할 수 없는 것과 비재산권을 목적으로 하는 소송**

- 소가를 산정하기 곤란한 사건이나, 이혼 등 가사소송 및 행정소송과 같이 비재산적인 권리관계를 다루는 소송은 그 중요성을 고려하여 합의부 관할로 본다.

**(4) 관련 청구**

- 합의부 관할 사건과 관련된 청구를 병합하여 제기하는 경우, 소송의 효율적 해결을 위해 합의부가 함께 심리한다.

**(5) 제척·기피사건**

- 법원에 대한 제척이나 기피 신청 사건은 해당 법관이 소속된 법원의 합의부에서 재판한다.

**3. 단독판사 관할**

**(1) 재정단독사건**

- 합의부 관할에 해당하더라도 사안이 간단하여 단독판사가 심리하는 것이 효율적이라고 판단되어 배당된 사건이다.

**(2) 소송목적의 값이 5억원 이하의 민사사건**

- 비교적 경미한 재산상 분쟁으로서 소가가 5억원 이하인 사건은 단독판사가 담당한다.

**(3) 사안이 단순한 사건**

- 수표·어음금 청구 사건이나 은행 등 금융기관의 대여금 청구 사건 등은 금액에 관계없이 단독판사가 담당하는 경우가 많다.

**(4) 관련 청구**

- 단독판사 관할 사건에 부수되는 관련 청구 역시 단독판사가 함께 심리할 수 있다.

**4. 소가**

**(1) 소가의 의의**

- 소송목적의 값(소가)이란 원고가 소로써 달성하려는 경제적 이익을 객관적으로 평가하여 금액으로 환산한 수치이다. 이는 사물관할의 결정뿐만 아니라 인지액 산정의 기준이 된다.

**(2) 소가의 산정방법**

- 소가는 원칙적으로 소를 제기한 때를 기준으로 산정하며, 원고의 주장을 기초로 한다. 부동산은 공시지가나 시가표준액을 기준으로 하고, 금전채권은 그 금액 자체를 소가로 본다.

**(3) 병합청구의 소가**

- 하나의 소로 여러 개의 청구를 하는 경우 소가는 이를 합산하는 것이 원칙이다(합산의 원칙). 다만, 청구의 목적이 동일하거나 중복되는 경우에는 가장 다액인 청구의 값을 기준으로 산정한다(중복청구의 흡수).

**IV. 토지관할**

**1. 의의**

- 토지관할이란 소재지를 달리하는 같은 종류의 법원들 사이에서 사건의 배분을 정하는 기준이다. 이는 재판적(裁判籍)이라는 개념을 통해 결정된다.

**2. 재판적의 종류와 경합**

**(1) 재판적의 종류**

- 피고의 주소지에 근거하는 일반재판적과 특정 사건의 성질에 따라 인정되는 특별재판적이 있다. 특별재판적에는 의무이행지(재산권 소송), 사고발생지(불법행위 소송), 부동산 소재지 등이 포함된다.

**(2) 재판적의 경합**

- 하나의 사건에 대하여 여러 법원에 재판적이 인정되는 경우를 의미한다. 이 경우 원고는 선택한 법원 중 어느 곳에도 소를 제기할 수 있다.

**(3) 관련재판적**

- 하나의 소로 여러 명의 피고를 상대로 하거나 여러 개의 청구를 하는 경우, 그중 하나에 대해 관할권이 있는 법원에 전체 사건을 제기할 수 있는 제도이다.

## V 재정관할

- 재정관할이란 법률 규정에 의한 관할 법원이 불분명하거나 재판의 공정성을 기대하기 어려운 경우, 상급법원이 재판으로써 관할 법원을 지정하거나 이전하는 것을 의미한다. 이는 관할 제도의 경직성을 보완하기 위한 비상적 조치이다.

## VI 합의관할

### 1. 관할합의의 의의[민소법 제29조]

- 당사자 사이의 계약에 의하여 제1심 관할 법원을 정하는 것을 의미한다. 이는 사적 자치의 원칙에 따라 당사자의 편의를 존중하는 제도이다.

### 2. 관할합의의 법적 성질

- 소송법상의 권리관계에 영향을 미치는 소송계약에 해당한다. 따라서 사법상의 계약과는 달리 소송법적 요건을 갖추어야 효력이 발생한다.

### 3. 관할합의의 요건

#### (1) 제1심법원의 임의관할[민소법 제29조 제1항]

- 전속관할이 아닌 임의관할에 대해서만 합의가 가능하다. 전속관할에 대한 합의는 무효이다.

#### (2) 일정한 법률관계로 특정되었을 것[민소법 제29조 제2항]

- 모든 분쟁에 대해 특정 법원으로 정하는 합의는 허용되지 않으며, 특정 계약이나 사건 등 구체적인 법률관계가 명시되어야 한다.

#### (3) 관할법원이 특정되었을 것

- 어느 법원인지 객관적으로 알 수 있도록 특정되어야 한다.

#### (4) 합의 방식과 시기

- 서면으로 행해져야 하며, 소 제기 전이나 소송계속 중에 모두 가능하다.

#### (5) 특별법상 요건을 갖추는 것

- 약관의 규제에 관한 법률 등 관련 법령에서 정한 제한 사항을 위반하지 않아야 한다.

### 4. 관할합의의 종류

#### (1) 문제점

- 합의 법원만 관할권을 갖게 할 것인지(전속적 합의), 법정관할 법원과 함께 관할권을 갖게 할 것인지(부가적 합의)가 문제된다.

#### (2) 학설

- 당사자의 의사표시가 명확하지 않은 경우, 전속적 합의로 추정할 것인지 부가적 합의로 볼 것인지에 대해 견해가 대립한다.

#### (3) 판례

- 판례는 당사자의 문언을 기초로 해석하되, 통상적으로 법정관할 법원을 배제하는 문구가 있으면 전속적 합의로 보고, 그렇지 않으면 부가적 합의로 보는 경향이 있다. 특히, 전속적 관할 합의가 유효하기 위해서는 합의된 법원에 실질적 관련성이 있어야 한다.

#### (4) 검토

- 당사자의 합의 취지를 존중하되, 재판받을 권리를 과도하게 제한하지 않는 방향으로 해석함이 타당하다.

### 5. 관할합의의 효력

#### (1) 관할의 변동

- 합의에 의해 새로운 관할이 창설되거나 기존 관할이 배제된다. 전속적 합의인 경우 법정관할 법원은 관할권을 상실한다.

#### (2) 효력의 주관적 범위

- 합의 당사자뿐만 아니라 그 포괄승계인에게도 효력이 미친다. 다만, 특정승계인의 경우 합의의 내용을 알고 승계하였는지에 따라 효력 유무가 결정될 수 있다.

## VI 변론관할

### 1. 변론관할의 의의[민소법 제30조]

- 원고가 관할권 없는 법원에 소를 제기했음에도 피고가 관할 위반의 항변을 하지 않고 본안에 대하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술함으로써 생기는 관할을 의미한다. 응소관할이라고도 한다.

### 2. 변론관할의 요건

#### (1) 임의관할 없는 제1심법원에 소가 제기되었을 것

- 전속관할 위반인 경우에는 변론관할이 성립하지 않는다.

#### (2) 피고의 관할위반의 항변이 없을 것

- 피고가 관할권이 없다는 사실을 지적하지 않아야 한다.

#### (3) 피고가 이의 없이 본안변론을 구술하였을 것

- 본안의 청구기각을 구하는 등 실질적인 쟁점에 대해 진술해야 한다. 단순히 기일 연기 신청을 하는 것만으로는 부족하다.

### 3. 변론관할의 효과

- 해당 법원에 적합한 관할권이 발생하며, 이후에는 관할 위반을 이유로 이송을 신청하거나 상소할 수 없다.

## VII 소송의 이송

### 1. 서설

#### (1) 의의

- 소송의 이송이란 법원에 계속된 소송의 전부 또는 일부를 재판에 의해 다른 법원으로 이전하는 것을 의미한다.

#### (2) 구별개념

- 법원 내부의 사무 분담에 따른 사건 배당이나 다른 기관으로의 서류 송부와는 구별된다.

### 2. 이송의 원인

#### (1) 관할위반에 의한 이송[민소법 제34조]

- 소가 관할권 없는 법원에 제기된 경우, 법원은 직권 또는 당사자의 신청에 의해 관할 법원으로 이송하여야 한다. 다만, 단독판사가 합의부 관할 사건을 심리하게 된 경우에는 합의부로 이송한다.

## (2) 심판평의에 의한 이송[민소법 제35조]

- 관할권이 있더라도 소송의 현저한 지연을 피하거나 당사자 간의 형평을 위해 필요한 경우 다른 법원으로 이송할 수 있다.

## (3) 반소제기에 의한 이송

- 본소의 단독판사 관할 사건에 대해 합의부 관할인 반소가 제기된 경우, 원칙적으로 사건 전체를 합의부로 이송하여야 한다.

## 3. 이송의 절차

- 이송은 재판(결정)으로써 행하며, 이송 결정에 대해서는 즉시항고가 가능하다. 반면 이송 신청을 기각한 결정에 대해서는 원칙적으로 불복할 수 없다.

## 4. 이송의 효과[민소법 제38조]

### (1) 이송결정의 구속력

- 이송 결정을 받은 법원은 그 결정에 따라야 하며, 다시 다른 법원으로 재이송할 수 없다.

### (2) 소송계속의 이전

- 이송 결정이 확정되면 소송은 처음부터 이송받은 법원에 계속된 것으로 본다.

### (3) 소송기록의 송부

- 이송 결정이 확정되면 법원 사무관 등은 지체 없이 소송기록을 이송받은 법원으로 보내야 한다.

## Ⅹ. 결론

- 관할 제도는 재판권의 효율적인 배분을 통해 사법 정의를 실현하는 절차적 토대이다. 사물관할과 토지관할을 통해 사건의 적정한 담당 법원을 지정하고, 합의관할과 변론관할을 통해 당사자의 자율성을 존중하며, 이송 제도를 통해 절차적 오류를 시정한다. 이러한 체계는 적정·공평과 신속·경제라는 민사소송의 이념을 구체화하는 장치로서 기능한다. 현대 소송법에서는 특히 국제재판관할과 전자소송 확대에 따른 관할권의 유연한 해석이 중요한 과제로 부각되고 있다. 법원은 관할 규정을 엄격히 준수하면서도 당사자의 재판 접근성을 저해하지 않도록 제도적 운용에 만전을 기해야 할 것이다.

## <보충>

### I. 관할의 일반적 정의 및 분류의 의의

- 민사소송법상 관할이란 특정 사건에 대하여 재판권을 행사할 수 있는 권한을 여러 법원 사이에 배분하는 것을 의미한다. 관할 제도는 법원의 적정한 업무 분담을 통해 재판의 신속을 도모하고 당사자에게 편의를 제공하며 재판의 공정성을 확보하는 데 목적이 있다. 관할은 크게 발생 근거에 따라 법정관할, 재정관할, 거동관할로 구분되며 이는 각기 다른 법적 성격과 발생 요건을 가진다.

### II. 법정관할

- 법정관할은 법률의 규정에 의하여 직접 정해지는 관할을 의미한다. 이는 다시 직분관할, 사물관할, 토지관할로 세분화된다.

#### 1. 직분관할

- 직분관할은 법원이 담당하는 재판 사무의 성격에 따른 분담을 의미한다. 예를 들어 주소법원과 집행법원의 구별, 제1심 법원과 상소심 법원의 구별, 합의부의 재판장과 수명법관의 사무 분담 등이 이에 해당한다. 이는 강행규정적 성격이 매우 강하여 당사자의 합의나 거동으로 변경할 수 없는 것이 원칙이다.

#### 2. 사물관할

- 사물관할은 제1심 사건을 지방법원 합의부와 지방법원 단독판사 중 어디에 배분할 것인가에 관한 관할이다. 주로 소송목적의 값인 소가를 기준으로 하며, 사건의 경중과 난이도에 따라 재판 자원을 효율적으로 배치하기 위한 목적을 가진다.

#### 3. 토지관할

- 토지관할은 소재지를 달리하는 같은 계급의 법원들 사이에서 사건의 토지적 연관성을 기준으로 재판권을 배분하는 것이다. 재판적을 기준으로 결정되며, 피고의 주소지를 기준으로 하는 보통재판적과 특정 사건의 성질과 연관된 지점을 기준으로 하는 특별재판적으로 나뉜다.

### III. 재정관할

- 재정관할은 법률 규정에 의하여 직접 정해지는 것이 아니라, 상급법원의 재판(지정 또는 이전)에 의하여 비로소 정해지는 관할이다. 법정관할 법원이 존재하지 않거나, 관할 구역이 불분명할 때 상급법원이 관할 법원을 지정하는 경우, 또는 법률상 혹은 사실상의 장애로 인하여 공정한 재판을 기대하기 어려울 때 관할을 이전하는 경우가 이에 해당한다.

### IV. 거동관할

- 거동관할은 당사자의 의사나 태도, 즉 거동에 의하여 성립하는 관할을 의미한다. 이는 법정관할 중 전속관할이 아닌 임의관할에 한하여 인정되는 예외적 관할이며, 크게 합의관할과 변론관할로 세분화된다.

#### 1. 합의관할

##### (1) 정의 및 취지

- 합의관할은 당사자 간의 합의에 의하여 발생하는 관할이다. 민사소송법은 제1심 법원에 한하여 당사자가 서면으로 합의한 경우 법정관할이 없는 법원이라도 관할권을 가질 수 있도록 허용한다. 이는 사적 자치의 원칙을 소송 절차에 반영하여 당사자의 편의를 극대화하기 위함이다.

##### (2) 성립 요건

- 합의관할이 성립하기 위해서는 제1심 법원에 관한 합의여야 하며, 전속관할이 아닌 임의관할(토지관할 등)에 대한 합의여야 한다. 또한 합의의 대상이 되는 법원이 특정되어야 하고, 반드시 서면으로 이루어져야 한다. 합의의 형태에 따라 법정관할 법원을 배제하고 합의한 법원에만 소를 제기하기로 하는 전속적 합의와, 법정관할 법원 외에 합의한 법원을 추가하는 부가적 합의로 구분된다.

#### 2. 변론관할(응소관할)

##### (1) 정의 및 발생 배경

- 변론관할은 원고가 관할권 없는 법원에 소를 제기했을 때, 피고가 관할 위반의 항변을 하지 않고 본안에 관하여 변론하거나 변론기일에서 진술함으로써 발생하는 관할이다. 이를 응소관할이라고도 부른다. 이는 무익한 이송 절차를 방지하고 이미 시작된 소송 절차를 유지함으로써 소송 경제를 도모하려는 목적이 있다.

## (2) 성립 요건 및 효과

- 변론관할이 성립하려면 우선 원고가 제기한 법원에 원래 관할권이 없어야 하며, 피고가 관할 위반의 항변을 제출하지 않은 채 본안에 관한 변론(준비절차에서의 진술 포함)을 해야 한다. 또한 피고의 변론이 자발적이어야 하며, 법원이 피고에게 관할 위반에 관한 고지 의무를 다했음에도 응소한 경우에 성립한다. 이 역시 전속관할 사건에서는 인정되지 않는다.

## V. 전속관할과 임의관할의 구별 실익

- 거동관할(합의관할, 변론관할)의 논의에서 가장 중요한 전제는 전속관할과의 구별이다.

### 1. 전속관할의 우선성

- 전속관할은 고도의 공익적 이유로 법률에 의하여 특정 법원에만 배타적으로 부여된 관할이다. 전속관할이 규정된 경우 당사자의 합의나 변론에 의한 거동관할은 성립할 수 없다. 만약 전속관할을 위반하여 합의하거나 응소하더라도 해당 법원은 관할권을 취득하지 못하며, 법원은 직권으로 관할 법원에 사건을 이송해야 한다.

### 2. 임의관할에서의 거동권 인정

- 사물관할의 일부와 토지관할은 주로 당사자의 편의를 위한 임의관할로 취급된다. 이러한 영역에서는 당사자의 의사가 존중되므로 합의관할과 변론관할이 유효하게 성립하여 법정관할의 원칙을 수정할 수 있다.

## VI. 관련 법리의 판례적 해석

### 1. 합의관할의 효력 범위

- 판례는 관할 합의의 효력이 당사자뿐만 아니라 그 일반승계인에게도 미친다고 본다. 그러나 지명채권의 양수인과 같은 특정승계인에 대해서는 채권의 성질상 관할 합의의 효력이 당연히 승계되는지에 대하여 개별적인 권리 의무의 성격을 검토하여 판단한다. 특히, 약관에 의한 관할 합의의 경우 고객에게 부당하게 불리한 전속적 합의는 무효로 판단하는 경향이 있다.

### 2. 변론관할의 성립 시점

- 변론관할이 성립하기 위한 본안 변론의 범위에 대하여 판례는 피고가 원고의 청구기각을 구하는 답변서를 제출하는 것만으로는 부족하고, 실제 기일에서 그 답변서를 진술하거나 청구의 원인 사실을 다투는 등 실질적인 변론 행위가 있어야 한다고 해석한다. 또한 관할 항변은 본안 변론 전에 해야 하므로, 본안에 대해 한 마디라도 언급한 이후에는 더 이상 관할 위반을 주장할 수 없게 된다.

### 3. 전속적 합의와 부가적 합의의 구별 기준

- 당사자의 합의가 전속적인지 부가적인지 불분명한 경우 판례는 당사자의 의사를 해석하되, 가급적 당사자의 선택권을 넓혀주는 부가적 합의로 해석하려는 경향이 있으나, '본 건에 관한 소송은 OO법원을 관할로 한다'는 식의 단정적 표현이 있는 경우에는 전속적 합의로 인정하여 다른 법정관할 법원에의 제소를 차단한다.

## VI. 결론

- 민사소송법상 재판권 배분의 체계에서 관할은 법정관할, 재정관할, 거동관할로 분류되는 것이 강력한 정설이다. 그중 <법정관할>은 법원이 담당하는 재판 사무의 성격에 따른 직분관할, 제1심 사건을 합의부, 단독판사 중 어디에 배분할 것인지를 정하는 사물관할, 사건의 토지적 연관성에 따라 배분하는 토지관할로 세분화 되며, <거동관할>은 다시 사전적 약속인 합의관할과 사후적 추인인 변론관할로 구성된다. 이러한 분류는 관할 제도가 단순한 행정적 배분이 아니라 사적 자치와 소송 경제라는 민사소송의 대원칙을 실현하는 도구임을 보여준다.



## <제2편 소송의 주체.제4장 당사자.제1절 당사자의 개관>

### I. 당사자 일반론

#### 1. 당사자론의 논점

- 통상적으로 소장을 작성하는 자는 실체법상 법률관계의 권리자를 원고로, 의무자를 피고로 적게 된다. 따라서 권리자가 원고이고, 의무자가 피고라고 속단하기 쉬우나, 이렇게 당사자를 정의하면 문제점이 발생한다. 우선 현실의 소송절차에서 원고가 모두 승소하는 것은 아니다. 소송결과 패소한 자는 실체법상 법률관계에서 권리자가 아닌 것으로 판명된 자이다. 그렇다고 해서 패소자를 원고가 아니라고는 하기 어렵다. 이 문제점은 자기가 실체법상 법률관계의 권리자라고 주장하는 자를 원고, 이러한 원고에 의하여 의무자라고 주장되는 자를 피고라고 보게 되면 해결되나, 이러한 방법만으로는 설명하기 어려운 부분이 존재한다. 예를 들어 파산절차의 개시로 파산관재인이 선임된 경우와 같이 어떤 재산의 권리자와 관리처분권자가 분리되어 각기 다른 사람에게 귀속되는 경우, 법률이 정하는 바에 따라 조금씩 차이가 있기는 하나, 파산관재인이 선임된 경우에는 파산관재인이 원고가 된다.

#### 2. 당사자의 개념

- 전술한 경우까지 모두 포섭할 수 있도록 당사자의 개념을 정의하면, 당사자는 자기의 이름으로 판결을 요구하는 사람과 그 사람에 의하여 상대방으로 지목된 사람이라고 할 수 있다. 이러한 당사자의 개념을 형식적 당사자 개념이라고 부른다.

### II. 당사자확정

#### 1. 당사자확정의 의의

- 당사자확정이란 현실적으로 전개되고 있는 소송절차에서 누가 원고이고 누가 피고인가를 결정하는 작업을 말한다. 소장에 기재된 표시와 실제 소송을 수행하는 자가 일치하지 않거나, 사망자를 상대로 소를 제기하는 등 당사자의 정체성에 의문이 있는 경우에 누구를 당사자로 보아 절차를 진행할 것인지가 문제된다. 이는 당사자능력이나 당사자적격을 판단하기 위한 선행 작업이다.

#### 2. 당사자확정의 기준

##### (1) 학설

- 당사자를 어떠한 기준으로 확정할 것인가에 대하여 세 가지 견해가 대립한다. 첫째, 의사설은 소를 제기하는 원고나 법원의 주관적 의사를 기준으로 당사자를 결정해야 한다는 견해이다. 둘째, 표시설은 소장의 당사자란의 기재 및 청구취지 등 외관상 나타난 표시를 기준으로 결정해야 한다는 견해이다. 셋째, 규범설(실질적 표시설)은 소장의 전체적인 기재와 소송의 전 과정을 통하여 합리적인 제3자가 객관적으로 판단하였을 때 누구를 당사자로 보고 있는가를 기준으로 결정해야 한다는 견해로, 현대 소송법의 통설적 입장이다.

##### (2) 판례

- 판례는 원칙적으로 규범설의 입장을 취하고 있다. 소장에 기재된 표시뿐만 아니라 청구원인 등 전체적인 내용을 종합하여 객관적으로 당사자를 확정하여야 한다고 본다. 특히, 당사자 표시가 잘못되었다고도 실질적으로 누구를 가리키는지 명확하다면 표시정정을 통해 바로잡을 수 있다고 판시하여, 절차의 형식적 기재보다는 실질적 관련성을 중시한다.

##### (3) 검토

- 의사설은 주관적 요소로 인해 법적 안정성을 해칠 수 있고, 표시설은 명확하나 지나치게 형식에 치우칠 우려가 있다. 따라서 소장의 전체적인 기재를 바탕으로 객관적으로 당사자를 확정하는 규범설이 타당하다.

#### 3. 당사자확정 후 당사자적격 판단과 흠결 시 보정방법

##### (1) 당사자적격 판단 및 보정

- 당사자가 확정된 후에는 그 자가 당사자능력이 있는지, 해당 사건의 본안판결을 받기에 적합한 자격인 당사자적격이 있는지를 판단한다. 만약, 확정된 당사자에게 이러한 자격이 흠결되었다면 소송요건 불비로 소가 각하될 수 있다.

##### (2) 보정조치

- 법원은 소송요건의 흠결을 발견한 경우 즉시 각하하기보다 당사자에게 보정할 기회를 부여하여야 한다. 이는 국민의 재판받을 권리를 보호하고 소송 경제를 도모하기 위함이다.

##### (3) 보정방법

- 당사자 능력이 없는 자를 있는 자로 바꾸거나, 적격이 없는 자를 있는 자로 교체하는 방식이 사용된다. 다만, 이는 당사자의 동일성을 해치지 않는 범위 내에서의 당사자표시정정이나 법률이 정한 당사자변경(피고경정 등)의 절차를 통해 이루어져야 한다.

### III. 당사자표시정정

#### 1. 의의

- 당사자표시정정이란 당사자의 동일성을 유지하면서 소장에 기재된 잘못된 명칭이나 주소 등을 바르게 고치는 것을 말한다. 이는 새로운 당사자를 추가하거나 교체하는 당사자변경과는 구별된다.

#### 2. 요건

##### (1) 동일성 인정

- 당사자의 동일성이 인정되어야 한다. 단순히 명칭을 오기하였거나 법인의 종류를 잘못 기재한 경우 등 실질적으로 같은 사람을 지칭하고 있음이 객관적으로 인정되어야 한다.

##### (2) 방어권 준수

- 정정으로 인해 상대방의 방어권이 침해되지 않아야 한다.

#### 3. 절차

- 당사자는 신청서를 제출하여 표시정정을 구할 수 있으며, 법원은 동일성이 인정된다면 이를 허가하는 결정을 내린다. 실무상으로는 변론기일에서 구술로 신청하고 조서에 기재하는 방식도 널리 사용된다.

#### 4. 효력

- 표시정정이 이루어지면 소급하여 처음부터 정정된 당사자 사이에 소송이 계속된 것으로 본다. 따라서 시효중단이나 기간 준수의 효력은 소 제기 시를 기준으로 유지된다.

### IV. 성명모용소송

#### 1. 의의



- 성명모용소송이란 원고 또는 피고가 타인의 성명을 무단으로 사용하여 소송을 수행하는 것을 의미한다. 모용자가 피모용자인 것처럼 행세하여 법원을 기망하는 행위이다.

## 2. 당사자의 확정

- 규범설에 의할 때, 소송을 실제 수행하고 있는 모용자가 당사자로 확정된다. 이름은 피모용자의 것이나 실질적으로 소송의 주체가 되는 자는 모용자이기 때문이다.

## 3. 발견 시 법원의 조치

- 법원이 소송 중에 모용 사실을 발견하면, 당사자 표시가 실제 소송 수행자와 일치하지 않으므로 당사자표시정정을 명하여야 한다. 만약, 원고가 모용자임이 밝혀지고 이를 정정하지 않는다면 소를 각하하며, 피고가 모용된 경우에는 모용자를 절차에서 배제하고 실제 피고를 참여시켜야 한다.

## 4. 간과판결의 효력 및 피모용자의 구제책

- 성명모용을 간과하고 판결이 내려진 경우, 판결의 효력은 실제 당사자인 모용자에게 미친다. 그러나 판결서에 이름이 기재된 피모용자에게 외관상 효력이 미칠 위험이 있으므로, 피모용자는 대리권 흠결을 이유로 상소를 제기하거나 판결 확정 후 재심을 통해 자신의 권리를 구제받을 수 있다. 판례는 피모용자가 판결의 효력을 받지 않음을 명확히 하고 있다.

## 5. 송달과정에서 피고모용

- 피고의 성명이 모용되어 판결 정본이 피모용자에게 송달된 경우, 피모용자는 자신에게 판결의 효력이 없음을 주장하는 집행에 관한이의 등을 제기할 수 있다.

# V. 사자상대소송

## 1. 제소 전에 사망한 경우

- 원고가 이미 사망한 자를 피고로 기재하여 소를 제기한 경우이다. 이때 당사자확정 기준에 따라 사자(死者)가 당사자로 확정되나, 사자는 당사자능력이 없으므로 원칙적으로 소는 부적법하다. 다만, 원고가 피고의 사망 사실을 모르고 제소한 경우 실질적 피고인 상속인으로 당사자표시정정을 하는 것이 허용된다는 것이 판례의 태도이다.

## 2. 소제기 후 소장부분 송달 전에 피고가 사망한 경우

- 이 시기에는 아직 소송계속이 발생하기 전이므로, 원고는 상속인으로 당사자표시정정을 하여 절차를 유지할 수 있다. 만약, 이를 간과하고 사자에게 송달되어 판결이 났다면 그 판결은 당연무효이다.

## 3. 소송대리인에게 소송위임 후 제소 전 사망한 경우의 법률관계

- 판례에 의하면 소송대리인에게 소송을 위임한 후 소 제기 전에 당사자가 사망하더라도 소송대리권은 소멸하지 않는다.(민소법 제95조) 따라서 이 경우의 소 제기는 유효하며, 사망한 자의 상속인이 소송을 승계하게 된다.

## 4. 소송계속 후 변론종결 전에 사망한 경우[민소법 제233조]

- 소송 도중 당사자가 사망하면 소송절차는 당연히 중단된다. 이때 상속인 등이 소송절차를 승계하여야 한다. 법원이 사망 사실을 모르고 중단 절차 없이 내린 판결은 대리권 흠결과 유사한 하자가 있는 판결로서 상소나 재심의 대상이 된다.

## 5. 변론종결 뒤에 사망한 경우

- 변론이 종결된 후에는 당사자의 참여가 필요 없으므로 소송절차는 중단되지 않으며, 법원은 사망한 자를 그대로 당사자로 하여 판결을 선고할 수 있다. 이 판결의 효력은 상속인에게 미친다.

# VI. 법인격부인

## 1. 법인격부인의 법리

- 법인격부인이란 특정한 사안에서 법인의 독립된 인격성을 부정하고 그 배후에 있는 개인이나 다른 회사에 책임을 묻는 이론이다. 법인이 형해화되었거나 채무 면탈 등 불법적인 목적으로 남용되는 경우에 적용된다.

## 2. 법인격이 부인되는 법인에 대한 소제기가 적법한지 여부

- 법인격부인의 법리가 적용되더라도 법인의 존재 자체가 소멸하는 것은 아니다. 따라서 해당 법인을 상대로 소를 제기하는 것 자체는 당사자능력 면에서 적법하다. 다만, 실질적인 책임을 배후자에게 묻기 위한 절차가 추가로 필요할 뿐이다.

## 3. 발견 시 채권자의 조치

- 채권자는 법인뿐만 아니라 그 배후자를 공동피고로 하여 소를 제기하거나, 이미 법인에 대한 판결을 얻은 경우 배후자에게 별도의 소를 제기하여 집행권원을 확보해야 한다. 판례는 원칙적으로 법인에 대한 판결의 기판력이나 집행력이 당연히 배후자에게 미치지 않는다고 보므로, 별도의 제소가 필요함을 유의해야 한다.

# VI. 결론

- 당사자의 확정 은 민사소송의 인적 범위를 결정하는 첫 단추로서 공정한 재판을 위한 필수적 전제이다. 규범설과 판례의 태도에 따라 실질적인 당사자를 확정하고, 표시상의 오류는 당사자표시정정을 통해 유연하게 해결함으로써 소송 경제를 도모할 수 있다. 또한 성명모용이나 사자상대소송과 같은 특수한 경우에도 당사자 보호와 절차의 안정을 동시에 고려하는 법리적 해석이 요구된다. 법원은 당사자의 정체성에 관한 의문을 소홀히 다루지 않으므로써, 판결의 효력이 엉뚱한 자에게 미치는 부당한 결과를 사전에 방지하여야 할 것이다.

<제2편 소송의 주체.제4장 당사자.제2절 당사자의 자격>

**I. 당사자능력**

**1. 서설**

**(1) 의의**

- 당사자능력이란 소송의 주체가 될 수 있는 일반적인 능력을 의미한다. 이는 민법상의 권리능력에 대응하는 개념으로, 원고나 피고가 되어 재판을 받을 수 있는 법률상의 자격이다.

**(2) 구별개념**

- 당사자능력이 소송의 주체가 될 수 있는 추상적 자격이라면, 당사자적격은 구체적인 소송물에 대하여 본안판결을 받기에 적합한 자격을 의미한다. 또한 소송능력은 스스로 유효한 소송행위를 할 수 있는 능력을 의미하므로 당사자능력과는 구별된다.

**2. 실질적 당사자능력**

- 실질적 당사자능력은 민법상 권리능력자에게 인정된다. 따라서 자연인은 생존하는 동안 누구나 당사자능력을 가지며, 태아는 민법상 불법행위로 인한 손해배상청구 등에서 권리능력이 인정되는 범위 내에서 예외적으로 당사자능력이 인정된다. 법인 역시 설립등기를 마침으로써 권리능력을 취득함과 동시에 당사자능력을 가진다. 외국인이나 외국법인도 상호주의 원칙이나 관련 법령에 따라 당사자능력이 인정된다.

**3. 형식적 당사자능력**

**(1) 비법인사단의 소송수행방안**

- 민사소송법 제52조는 법인이 아닌 사단이나 재단이라도 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단이나 재단의 이름으로 당사자가 될 수 있다고 규정한다. 이는 실체법상 권리능력이 없더라도 사회적 실체로서 활동하는 단체의 분쟁을 효율적으로 해결하기 위한 소송법적 정책에 해당한다. 비법인사단이 당사자가 되기 위해서는 단체로서의 조직을 갖추고 의사결정기관과 집행기관이 존재하며, 고유한 목적을 가지고 구성원의 변동과 관계없이 단체 자체가 존속해야 한다.

**(2) 조합의 소송수행방안**

- 민법상 조합은 원칙적으로 당사자능력이 없다. 조합의 사무에 관한 소송은 조합원 전원이 공동으로 제기하거나(고유필수적 공동소송), 조합원 중 1인 또는 제3자를 선정당사자로 내세워 수행해야 한다. 다만, 판례는 조합의 실질을 갖추었더라도 그 명칭과 상관없이 실무적으로 비법인사단의 요건을 갖춘 경우에는 민사소송법 제52조를 유추 적용하여 당사자능력을 인정하기도 한다. 업무집행조합원이 있는 경우에도 그가 조합 전체를 대리하여 소송을 수행할 수는 있으나, 조합 자체의 이름으로 소를 제기하는 것은 원칙적으로 불가능하다.

**4. 당사자능력 조사와 그 흠결의 효과**

**(1) 소 제기 시 흠결**

- 소 제기 당시부터 당사자능력이 없는 자를 상대로 하거나 그 이름으로 소를 제기한 경우, 법원은 직권으로 이를 조사하여야 한다. 보정이 가능한 경우(사자상대소송에서의 표시정정 등)를 제외하고는 소를 각하하여야 한다.

**(2) 소송계속 중 흠결**

- 소송 도중에 당사자가 사망하거나 법인이 해산된 경우 소송절차는 중단된다. 이때 상속인이나 합병 후의 법인이 소송을 승계하여야 하며, 승계가 이루어지지 않으면 절차를 진행할 수 없다.

**(3) 당사자능력에 대하여 다툼이 있는 경우**

- 당사자능력의 존부는 소송요건이므로 법원은 증거조사를 통해 이를 확정하여야 한다. 능력의 존재가 불분명한 경우 그 불이익은 소송을 제기한 원고가 부담한다.

**(4) 간과판결의 효력**

- 당사자능력이 없는 자에 대한 판결은 원칙적으로 무효이다. 사자를 상대로 한 판결은 기판력이 발생하지 않으며, 강제집행의 근거가 될 수 없다. 다만, 비법인사단인데 대표자 자격에 하자가 있는 경우 등은 상소나 재심을 통해 다룰 수 있다.

**II. 당사자적격**

**1. 의의**

- 당사자적격이란 특정한 소송물에 대하여 원고로서 소송을 수행하고 본안판결을 받을 수 있는 자격(정당한 원고) 또는 피고로서 소송을 수행당하고 판결을 받을 수 있는 자격(정당한 피고)을 의미한다. 이는 소송수행권이라고도 불리며, 재판의 실효성을 담보하기 위한 소송요건이다.

**2. 일반적 당사자적격자**

**(1) 이행의 소**

- 이행의 소에서는 원고가 자기에게 이행청구권이 있다고 주장하는 자가 원고적격을 가지며, 원고로부터 이행의무자로 지명된 자가 피고적격을 가진다. 실제로 청구권이나 의무가 존재하는지는 본안심리 단계에서 판단할 문제이므로, 주장 자체로 적격이 결정된다.

**(2) 확인의 소**

- 확인의 소에서는 당해 법률관계에 대하여 확인의 이익이 있는 자가 원고적격을 가진다. 즉, 판결을 통해 자신의 법적 지위의 불안을 제거할 필요가 있는 자가 적격자가 된다.

**(3) 형성의 소**

- 형성의 소는 법률에 규정된 자만이 제기할 수 있다. 예를 들어 주주총회결의취소의 소는 주주·이사·감사만이 제기할 수 있으며, 이들이 정당한 당사자적격자가 된다.

**(4) 고유필수적 공동소송**

- 여러 사람이 공동으로만 소송을 수행해야 하는 고유필수적 공동소송(공유물 분할의 소)에서는 전원이 함께 참여해야만 당사자적격이 인정된다. 1인이라도 누락되면 당사자적격 흠결로 소가 각하된다.

**3. 제3자 소송담당**

**(1) 의의**

- 권리관계의 주체인 당사자가 아닌 제3자가 자신의 이름으로 소송을 수행하고 그 판결의 효력이 권리 주체에게 미치는 경우를 의미한다.

**(2) 법정 소송담당**

- 법률의 규정에 의해 제3자에게 소송수행권이 부여되는 경우이다. 채권자대위소송을 제기하는 채권자, 파산재단에 관한 소송을 수행하는 파산관재인, 유언집행자 등이 이에 해당한다. 이는 대리인의 지위와 달리 자신의 이름으로 소송을 수행한다는 특징이 있다.

### (3) 임의적 소송담당★

- 권리 주체의 의사에 의해 제3자에게 소송수행권을 수여하는 경우이다. 원칙적으로 민사소송법은 변호사대리의 원칙을 잠탈할 우려가 있어 이를 엄격히 제한한다. 다만, 공동의 이해관계를 가진 자들이 선출하는 선정당사자는 법이 명문으로 인정하는 임의적 소송담당이다. 판례는 변호사법 위반의 우려가 없고 소송수행을 맡길 합리적 필요가 있는 특수한 경우(업무집행조합원 등)에 한하여 예외적으로 허용한다.

### (4) 제3자 소송담당과 기판력

- 제3자 소송담당에 의해 내려진 판결의 효력(기판력)은 권리관계의 본래 주체인 이익 귀속자에게도 미친다. 다만, 채권자대위소송의 경우 채무자가 대위소송의 제기 사실을 알았을 때에 한하여 기판력이 미친다는 것이 판례의 태도이다.

## 4. 당사자적격 흠결의 효과

### (1) 소제기 흠결

- 원고나 피고에게 당사자적격이 없는 경우 법원은 직권으로 이를 조사하여 소를 각하하여야 한다.

### (2) 소송계속 중 흠결

- 소송 도중 권리관계의 양도 등으로 적격이 상실된 경우, 승계인이 소송을 인수하거나 당사자가 소송을 탈퇴하는 절차를 거쳐야 한다.

### (3) 당사자적격에 관하여 다툼이 있는 경우

- 본안판결의 전제조건이므로 법원은 증거조사를 통해 적격 유무를 판단한다.

### (4) 간과판결의 효력

- 당사자적격이 없는 자에 대한 판결은 원칙적으로 부적법한 판결로서 상소 사유가 된다. 다만, 판결이 확정된 후에는 기판력의 주관적 범위가 문제 될 뿐 판결 자체가 당면무효가 되지는 않는 경우가 많다.

## III. 소송능력

### 1. 서설

#### (1) 의의

- 소송능력이란 당사자로서 유효하게 소송행위를 하거나 상대방의 소송행위를 수령할 수 있는 능력을 말한다. 이는 민법상의 행위능력에 대응하는 개념이다.

#### (2) 소송능력자

- 원칙적으로 민법상 성년자인 자는 소송능력을 가진다. 법인이나 비법인사단은 대표자를 통해 소송을 수행하므로 단체 자체가 능력을 가지는 것이 아니라 대표자의 행위로 귀속된다.

### 2. 소송무능력자[민소법 제55조]

#### (1) 민법상 제한능력자

- 미성년자, 피성년후견인 등은 원칙적으로 소송능력이 없다. 이들은 법정대리인에 의하여 소송을 수행하여야 한다. 다만, 미성년자가 독립하여 경제 활동을 할 수 있는 경우 등 민법상 예외적으로 행위능력이 인정되는 범위 내에서는 소송능력도 인정된다. 피한정후견인의 경우에는 원칙적으로 소송능력이 있으나, 법원이 정한 범위 내에서는 제한될 수 있다.

#### (2) 법인 또는 비법인사단·재단

- 이들은 자연인이 아니므로 스스로 소송을 수행할 수 없다. 따라서 법정대리인에 관한 규정이 준용되는 대표자를 통하여서만 소송능력을 행사할 수 있다.

### 3. 소송법적 효과

#### (1) 소송행위의 유효요건

- 소송무능력자가 직접 한 소송행위나 그를 상대로 한 소송행위는 원칙적으로 무효이다. 다만, 후에 소송능력을 취득한 당사자나 법정대리인이 이를 추인하면 소급하여 유효하게 된다.

#### (2) 소송능력흠결의 효과

- 법원은 소송능력의 유무를 직권으로 조사하여야 하며, 흠결이 발견된 경우 기간을 정하여 보정을 명한다. 보정이 불가능하거나 불응할 시 소를 각하한다.

## IV. 변론능력

### 1. 의의

- 변론능력이란 법원에 출석하여 유효하게 구술로 변론을 할 수 있는 능력을 말한다. 소송능력이 소송 전반에 걸친 자격이라면, 변론능력은 기일에서의 실제 수행 능력을 의미한다.

### 2. 변론무능력자

- 당사자가 소송능력자라 하더라도 말을 할 수 없거나 정신적 장애 등으로 인해 재판장의 질문에 적절히 응답할 수 없는 경우 법원은 변론을 금지할 수 있다. 또한 변호사 대리 원칙이 적용되는 소송에서 변호사를 선임하지 않은 경우에도 실질적 변론능력이 없는 것으로 취급될 수 있다.

### 3. 변론능력흠결의 효과

#### (1) 소송행위의 유효요건

- 변론능력이 없는 자가 행한 구술 진술은 법률상 효과를 발생시키지 못한다.

#### (2) 변호사선임명령 불응 시 소·상소의 각하

- 법원이 변론능력 부족을 이유로 변호사 선임을 명하였음에도 이에 응하지 않을 경우, 법원은 판결로서 소나 상소를 각하할 수 있다.

#### (3) 변론능력 흠결을 간과한 판결의 효력

- 변론능력은 소송의 원활한 진행을 위한 기술적 능력이므로, 이를 간과하고 판결이 내려졌더라도 판결 자체가 당면무효가 되지는 않는다.

## V. 결론

- 당사자의 자격은 소송의 주체가 갖추어야 할 기본적 요건으로서, 당사자능력부터 변론능력에 이르기까지 단계별로 엄격한 판단이 요구된다. 당사자 능력이 소송의 문턱을 넘기 위한 최소한의 자격이라면, 당사자적격은 구체적인 권리 실현의 정당성을 부여하며, 소송능력과 변론능력은 절차의 적법한 수행을 보장한다. 법원은 이러한 자격 요건을 직권으로 조사함으로써 부적격한 당사자에 의한 소송 남발을 방지하고, 동시에 보정 제도를 통해 진정한

권리자가 절차에서 배제되지 않도록 균형 있는 사법 행정을 펼쳐야 한다. 특히, 복잡해지는 현대 사회의 분쟁 구조 속에서 제3자 소송담당이나 비법인 단체의 소송수행권에 대한 명확한 해석은 사법 정의 실현의 핵심적 과제라 할 것이다.

<제2편 소송의 주체.제4장 당사자.제3절 소송상의 대리인>

**I. 서설**

**1. 소송상의 대리인의 의의**

- 소송상의 대리인이란 당사자의 이름으로 소송행위를 하거나 소송행위를 수령함으로써 그 효과를 직접 당사자에게 귀속시키는 제3자를 의미한다. 이는 당사자가 소송무능력자이거나 법률 지식이 부족한 경우, 또는 신속한 절차 진행을 위해 대리인의 조력을 받을 필요가 있을 때 활용되는 제도이다.

**2. 소송상의 대리인의 종류**

- 소송상의 대리인은 대리권의 발생 원인에 따라 법정대리인과 임의대리인으로 구분된다. 법정대리인은 본인의 의사와 관계없이 법률의 규정 등에 의해 대리권이 발생하는 자이며, 임의대리인은 본인의 수권행위에 의해 대리권이 발생하는 자이다. 또한 소송물인 권리관계와 관련하여 포괄적인 권한을 갖는가에 따라 포괄적 대리인과 개별적 대리인으로 나뉘기도 한다.

**II. 법정대리인**

**1. 의의**

- 법정대리인이란 본인의 의사에 의하지 않고 법률의 규정이나 법원의 선임 등에 의하여 대리권이 발생하는 소송대리인을 말한다. 미성년자나 성년후견대상자와 같은 소송무능력자를 보호하고 소송절차의 원활한 진행을 도모하기 위해 존재한다.

**2. 법정대리권의 발생**

**(1) 실체법상 법정대리인**

- 민법 등 실체법상의 규정에 의하여 당연히 대리권이 발생하는 경우이다. 친권자나 성년후견인 등이 이에 해당하며, 이들은 별도의 선임 절차 없이 법률상 지위에 따라 소송대리권을 갖는다.

**(2) 소송법상 특별대리인**

- 소송무능력자에게 법정대리인이 없거나 대리권을 행사할 수 없는 경우, 소송 지연으로 인한 손해를 방지하기 위해 법원이 선임하는 대리인이다(민소법 제62조). 이는 당해 소송에 한하여 한시적으로 대리권을 가진다.

**(3) 법인 등 대표자**

- 법인이나 비법인사단의 대표자는 성질상 법정대리인에 관한 규정이 준용된다(민소법 제64조). 이들은 법인 등기부상의 기재나 정관에 정해진 선임 절차를 통해 대표권을 취득한다.

**3. 법정대리권의 범위[민소법 제56조]**

**(1) 실체법상 법정대리인**

- 실체법상 법정대리인은 본인을 위하여 소송행위에 관한 포괄적인 대리권을 가진다. 다만, 상대방이 제기한 소송이나 상소에 대응하는 응소행위는 제한 없이 가능하나, 본인을 위해 소를 제기하거나 화해, 포기, 인낙 등 실체적 권리에 영향을 미치는 행위는 민법상 제한(가족법상의 동의 등)이 있는 경우 그에 따라야 한다.

**(2) 소송법상 특별대리인**

- 특별대리인은 본인을 위하여 해당 소송의 모든 소송행위를 할 권한을 가진다. 다만, 후견인에 관한 규정이 준용되므로 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙 등 중요한 처분행위를 할 때에는 법원이나 감독인의 허가를 얻어야 한다.

**(3) 법인 등 대표자**

- 법인의 대표자는 법인의 업무 전반에 관하여 포괄적인 대표권을 가지며, 소송에서도 제한 없는 대리권을 가진다. 정관이나 이사회 결의로 대표권을 제한하더라도 소송법상으로는 선의의 제3자(상대방 당사자)에게 대항할 수 없다.

**(4) 공동대리**

- 법정대리인이 여러 명인 경우(예 : 부모의 공동친권) 원칙적으로 공동으로 대리권을 행사하여야 한다. 다만, 상대방의 소송행위를 수령하는 수동대리에 있어서는 각자가 본인을 대리할 수 있다.

**4. 법정대리인의 지위**

**(1) 제3자의 지위**

- 법정대리인은 소송의 당사자가 아닌 제3자이다. 따라서 증인능력을 가지며, 본인에 대한 판결의 기판력은 법정대리인 개인에게 미치지 않는다.

**(2) 본인에 유사한 지위**

- 법정대리인의 소송상 행위는 본인의 행위와 동일한 효력을 가지므로, 그가 알고 있는 사정은 본인이 알고 있는 것과 같이 취급된다. 또한 법정대리인은 본인을 대신하여 자백하거나 증거조사에 참여할 수 있는 등 실질적으로 당사자와 유사한 지위에서 소송을 주도한다.

**5. 법정대리권의 소멸**

**(1) 대리권 소멸원인**

- 본인의 사망, 대리인의 사망·결격사유 발생, 본인의 소송능력 회복(예 : 미성년자의 성년 도달) 등이 소멸 원인이 된다.

**(2) 대리·대표권소멸통지**

- 법정대리권이 소멸하더라도 그 사실을 상대방 당사자에게 통지하지 않으면 대리권 소멸의 효력을 주장할 수 없다(민소법 제63조). 이는 소송절차의 안정을 보호하기 위함이다.

**III. 임의대리인**

**1. 의의**

- 임의대리인이란 당사자 본인의 수권행위(소송위임 등)에 의하여 대리권을 취득하는 자를 말한다. 변호사가 가장 전형적인 예이다.

**2. 법률상의 소송대리인**

- 본인의 의사에 기하여 선임되었으나 그 대리권의 범위가 법률에 규정되어 있는 자를 의미한다. 상법상의 지배인이나 선박관리인 등이 이에 해당하며, 이들은 본인의 영업에 관한 소송에서 포괄적인 대리권을 가진다.

**3. 소송위임에 의한 소송대리인**

**(1) 의의**

- 당사자가 특정 소송을 수행하기 위하여 특정인을 대리인으로 선임하는 경우이다. 이를 통상 소송대리인이라 부른다.

**(2) 소송대리인의 자격**

- 민사소송법은 변호사 대리의 원칙을 채택하고 있어 원칙적으로 변호사만이 소송대리인이 될 수 있다(민소법 제87조). 다만, 단독판사가 심리하는 소액사건 등 예외적인 경우에는 당사자와 밀접한 관계가 있는 친족이나 고용관계에 있는 자가 법원의 허가를 얻어 대리인이 될 수 있다.

**(3) 소송대리권의 발생**

- 본인과 대리인 사이의 소송위임 계약과 법원에 대한 위임장 제출로 발생한다.

**(4) 소송대리권의 범위[민소법 제90조]**

- 소송대리인은 위임받은 사건에 대하여 일체의 소송행위를 할 수 있는 포괄적 권한을 가진다. 반소의 제기, 응소, 강제집행에 관한 행위 등이 포함된다. 다만, 반소 제기, 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙, 상소의 제기·취하 등 당사자의 실체적 이익에 중대한 영향을 미치는 행위는 특별수권이 있어야만 가능하다.

**(5) 소송대리인의 지위**

- 소송대리인은 본인의 이름으로 행위하되 독립하여 소송을 수행한다. 여러 명의 대리인이 있는 경우에도 각자가 본인을 대리하는 각자대리의 원칙이 적용된다. 소송대리인의 자백은 본인이 기일에 출석하여 지체 없이 취소하거나 경정하지 않으면 본인의 자백으로서 효력을 갖는다.

**(6) 소송대리권의 소멸**

- 본인이나 대리인의 사망, 파산 등이 소멸 원인이다. 그러나 소송위임에 의한 대리권은 본인이 사망하거나 소송능력을 상실하더라도 소멸하지 않는다는 특칙이 있다(민소법 제95조). 이는 소송절차의 중단을 방지하고 연속성을 보장하기 위함이다.

**IV. 무권대리인**

**1. 의의**

- 무권대리인이란 대리권이 없음에도 불구하고 당사자의 이름으로 소송행위를 하는 자를 말한다. 소송법상 대리권의 존재는 소송요건이므로 무권대리인의 행위는 원칙적으로 무효이다.

**2. 소송상 취급**

**(1) 소송요건**

- 대리권의 존부는 법원의 직권조사사항이다. 법원은 대리권에 의심이 있는 경우 자명한 증거를 요구하거나 보정을 명하여야 한다.

**(2) 소송행위의 유효요건**

- 무권대리인이 행한 소송행위는 무효이나, 당사자 본인이 이를 추인하면 소급하여 유효하게 된다. 추인은 명시적이어야 할 필요는 없으나, 소송 전 반에 걸친 묵시적 승인으로 해석될 수 있는 행위가 있어야 한다.

**3. 쌍방대리의 금지**

**(1) 쌍방대리행위**

- 한 사람이 원고와 피고 쌍방을 대리하여 소송을 수행하는 것은 금지된다. 이는 이해상충을 방지하고 공정한 재판을 보장하기 위함이다.

**(2) 변호사법 제31조 제1항 위반의 대리행위**

- 변호사가 상대방으로부터 수임을 받거나 이해관계가 대립하는 사건에 관여하는 것은 금지된다. 이를 위반한 대리행위는 원칙적으로 무효이며, 상대방이 이익을 제기할 경우 법원은 해당 대리인을 절차에서 배제하여야 한다.

**4. 표현대리의 법리적용 여부**

**(1) 학설**

- 민법상의 표현대리 규정이 소송법에도 적용되는지에 대해 견해가 대립한다. 긍정설은 거래의 안전과 신뢰 보호를 중시하며, 부정설은 소송절차의 명확성과 안정성을 중시한다.

**(2) 판례**

- 판례는 원칙적으로 민사소송법상 소송행위에는 민법상의 표현대리 규정이 적용되지 않는다는 입장이다. 소송행위는 법원이 직권으로 그 유효성을 판단하여야 하는 공법적 행위이므로, 외관만으로 대리권의 효력을 인정할 수 없다고 본다. 따라서 무권대리인의 소송행위는 본인의 추인이 없는 한 절대적 무효이다.

**(3) 검토**

- 소송절차는 획일적이고 명확해야 하므로, 개별적인 신뢰 보호를 이유로 불확실한 대리권의 효력을 인정하는 것은 타당하지 않다. 따라서 판례와 같이 표현대리 적용을 부정하고 추인을 통해서만 구제하는 것이 법적 안정성에 부합한다.

**V. 결론**

- 소송상의 대리인 제도는 당사자의 능력을 보완하고 재판의 전문성을 높여 사법 정의를 실현하는 중추적 역할을 수행한다. 법정대리인은 무능력자의 권리를 보호하며, 임의대리인은 당사자의 자율적 선택에 기해 최선의 방어권을 행사하게 한다. 특히 소송대리권의 범위와 소멸에 관한 법리는 절차의 중단 없는 진행과 당사자의 실체적 권리 보호 사이의 균형을 맞추는 데 초점이 맞춰져 있다. 법원은 대리권의 존부를 엄격히 심사하여 무권대리에 의한 피해를 방지하는 동시에, 표현대리 배제 원칙 등을 통해 소송절차의 명확성을 유지함으로써 공정한 재판이 이루어질 수 있도록 감독하여야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제1절 소송의 개시>

**I. 소의 의의**

- 소란 원고가 피고를 상대로 법원에 대하여 특정한 심판을 구하는 신청을 의미한다. 이는 민사소송 절차를 개시시키는 유일한 수단이며, 법원의 판결을 이끌어내기 위한 기초가 된다. 소는 권리보호의 필요성이 인정되어야 하며, 소장이 법원에 접수됨으로써 그 절차가 시작된다. 현대 민사소송 체계에서 소는 사적 자치의 원칙에 따라 당사자의 자발적인 의사에 의해서만 개시된다는 처분권주의의 적용을 받는다.

**II. 소의 종류**

**1. 청구의 성질·내용에 따른 분류**

- 청구의 성질과 내용에 따라 소는 크게 이행의 소, 확인의 소, 형성의 소로 나뉜다. 이는 원고가 법원으로부터 어떠한 형태의 판결을 얻고자 하는가에 따른 구분이다.

**(1) 이행의 소**

- 이행의 소란 원고가 피고에 대하여 특정한 이행의무를 이행할 것을 구하는 소이다. 금전의 지급, 물건의 인도, 등기 절차의 이행 등이 대표적인 예이다. 이행의 소는 원칙적으로 현재 그 의무의 이행기가 도래한 경우에만 제기할 수 있는 현재의 이행의 소를 의미하나, 예외적으로 미리 청구할 필요가 있는 경우에는 이행기가 도래하지 않았더라도 장래의 이행의 소를 제기할 수 있다. 이행판결이 확정되면 그 판결 자체로 강제집행의 근거인 집행권원이 형성된다는 특징이 있다.

**(2) 확인의 소**

- 확인의 소란 특정한 법률관계의 존재 또는 부존재를 확정해 줄 것을 법원에 구하는 소이다. 확인의 소는 원칙적으로 현재의 법률관계를 대상으로 하여야 하며, 단순한 사실관계나 과거의 법률관계는 대상이 되지 않는다. 또한 원고의 법적 지위가 불안정하여 판결을 통해 이를 제거할 필요가 있는 확인의 이익이 인정되어야 한다. 확인판결은 법률관계를 공적으로 확정함으로써 분쟁을 종식시키는 기능을 하며, 별도의 강제집행 절차를 수반하지 않는다.

**(3) 형성의 소**

- 형성의 소란 새로운 법률관계를 발생시키거나, 기존의 법률관계를 변경, 소멸시킬 것을 구하는 소이다. 이는 당사자의 합의만으로는 목적을 달성할 수 없고 반드시 판결에 의해서만 법률적 변화가 일어나는 경우에 제기한다. 주주총회결의취소의 소, 공유물분할의 소, 재판상 이혼의 소 등이 이에 해당한다. 형성판결은 확정된 때로부터 즉시 대세적인 효력이 발생하여 법률관계를 형성시킨다. 법령에 특별한 규정이 있는 경우에만 허용된다는 법정주의 원칙이 적용된다.

**2. 소제기의 모습에 따른 분류**

- 소 제기가 어떤 방식으로 이루어지는가에 따른 분류이다.

**(1) 독립의 소**

- 하나의 소장에 하나의 청구를 담아 제기하는 일반적인 소의 형태를 말한다.

**(2) 청구의 병합**

- 소송 경제를 도모하고, 심리 중복을 피하기 위해 여러 개의 청구를 하나의 소송 절차에서 처리하는 것을 말한다.

**(3) 공동소송**

- 여러 당사자가 관련된 소송을 말한다.

**(4) 반소**

- 피고가 원고에 대응하여 같은 절차 내에서 제기하는 소를 말한다.

**(5) 소송참가**

- 소송 도중 제3자가 개입하는 것을 말한다.

**3. 소제기의 시기에 따른 분류**

- 소 제기가 소송 절차의 어느 단계에서 이루어지는가에 따른 분류이다.

**(1) 최초의 소**

- 소송 절차가 처음 시작될 때 제기되는 소를 의미한다.

**(2) 청구의 변경**

- 이미 소송이 계속 중인 상태에서 청구의 내용을 변경하거나 추가하는 소를 말한다.

**(3) 부대항소**

- 상소 절차에서 제기되는 소이다.

**(4) 재심의 소**

- 판결 확정 후 예외적으로 허용되는 소의 형태이다.

**III. 결론**

- 소의 개시는 당사자의 신청에 의해 국가의 재판권을 발동시키는 절차로서, 법치주의 하에서 권리 구제를 위한 핵심적인 통로이다. 이행, 확인, 형성의 소로 대표되는 내용적 분류는 각 분쟁의 특성에 맞는 적절한 보호 수단을 제공하며, 소제기의 모습과 시기에 따른 분류는 절차적 유연성을 부여한다. 법원은 원고가 제기한 소의 종류와 성질을 정확히 파악하여 그에 부합하는 소송요건과 본안 심리를 진행하여야 한다. 특히, 소제기 방식의 다양화는 복잡해지는 현대 사회의 분쟁을 일거에 해결할 수 있는 수단을 제공하는바, 이를 남용하지 않으면서도 실질적인 권리 구제가 이루어질 수 있도록 제도를 운영하는 지혜가 필요하다.

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제2절 소송요건>

**I. 승소판결을 받기 위한 요건**

**1. 소장의 적식심사**

- 소장의 적식심사란 원고가 제출한 소장이 법률이 정한 형식적 요건을 갖추었는지를 심사하는 단계이다. 재판장은 소장에 당사자, 법정대리인, 청구 취지, 청구원인이 제대로 기재되어 있는지, 정해진 인지가 첨부되었는지를 확인한다. 기재사항에 흠결이 있거나 인지가 부족한 경우 재판장은 상당한 기간을 정하여 보정을 명하며, 원고가 이에 응하지 않을 시 소장각하명령을 내린다. 이는 본안 심리에 들어가기 위한 가장 기초적인 형식적 관문이다.

**2. 소의 적법심사**

- 소의 적법심사란 소송요건을 구비하였는지를 판단하는 절차이다. 소송요건은 법원이 본안 판결(승소 또는 패소 판결)을 내리기 위해 필요한 전제 조건이다. 관할권의 존재, 당사자능력 및 당사자적격, 소의 이익 등이 여기에 해당한다. 만약, 소송요건이 결여되어 있고 그것이 보정될 수 없는 것이라면 법원은 본안에 대한 판단 없이 소장각하판결을 내린다.

**3. 주장 자체의 정당성**

- 주장 자체의 정당성이란 원고가 주장하는 사실이 모두 진실이라고 가정했을 때, 법률적으로 원고가 원하는 승소 판결을 얻을 수 있는 상태인지를 의미한다. 이를 청구의 이유 있음이라고도 한다. 원고가 주장하는 사실관계가 법령상의 요건을 충족하지 못하거나, 원고가 주장하는 법률효과가 인정되지 않는 경우에는 증거조사를 할 필요도 없이 청구기각판결을 받게 된다.

**4. 주장사실의 증명**

- 원고가 주장한 사실이 법률적으로 정당하더라도, 피고가 그 사실을 다투는 경우에는 원고가 그 사실의 존재를 증명하여야 한다. 법원이 원고의 주장 사실이 진실하다는 확신을 갖게 하는 증거력을 확보하는 단계이다. 만약, 원고가 증거를 통해 요건사실을 증명하지 못하면 진위불명의 상태가 되어 증명 책임의 원칙에 따라 원고는 패소의 불이익을 입게 된다.

**II. 소송요건**

**1. 소송요건의 의의**

- 소송요건이란 법원이 사건의 본안에 대하여 심리하고 판결하기 위하여 필요한 전제 조건을 말한다. 소송요건은 당사자가 임의로 배제할 수 없는 강행규정적 성격을 지니며, 이는 국가 재판권의 적정한 행사를 보장하고 부적법한 소송으로부터 피고와 법원을 보호하기 위한 장치이다.

**2. 소송요건의 종류**

**(1) 법원에 관한 것**

- 대한민국의 재판권이 존재하여야 하며, 당해 사건에 대한 관할권이 있어야 한다. 또한 법관에게 제척·기피 사유가 없어야 한다.

**(2) 당사자에 관한 것**

- 당사자가 실재하여야 하며, 당사자능력, 소송능력, 정당한 당사자적격이 있어야 한다. 법정대리인이 필요한 경우에는 대리권의 흠결이 없어야 한다.

**(3) 소송물에 관한 것**

- 소의 이익(권리보호의 이익)이 존재하여야 하며, 확정판결이 있는 사건과 동일한 사건이 아니어야 한다(기판력의 저촉 금지). 또한 중복제소에 해당하지 않아야 한다.

**(4) 특수소송에 관한 것**

- 행정소송에서의 전심절차 이행이나, 가사소송에서의 조정전치주의 등 특별법상 요구되는 전제 조건들이 이에 해당한다.

**3. 소송요건의 모습**

**(1) 적극적 요건과 소극적 요건**

- 적극적 요건은 재판을 받기 위해 존재하여야 하는 요건(관할권, 당사자능력 등)이며, 소극적 요건은 재판을 받기 위해 존재하지 않아야 하는 요건(법관의 제척·기피 사유, 중복제소, 기판력의 저촉 등)을 의미한다.

**(2) 직권조사사항과 항변사항**

- 직권조사사항은 당사자의 주장 여부와 관계없이 법원이 스스로 조사하여야 하는 사항이며 소송요건의 대부분이 이에 해당한다. 반면, 항변사항은 피고가 관할 위반의 항변이나 중재 합의의 존재 등을 주장하여야만 비로소 법원이 고려하는 사항이다.

**4. 소송요건의 조사**

**(1) 직권조사사항에 대한 조사**

- 법원은 소송의 어느 단계에서나 직권으로 소송요건의 존부를 조사할 수 있다. 상고심에서도 새로운 증거를 통해 소송요건의 흠결을 판단할 수 있으며, 당사자가 다투지 않더라도 법원이 인지한 경우 반드시 판단하여야 한다.

**(2) 항변사항에 대한 조사**

- 임의관할 위반이나 소송비용 담보제공 신청 등은 피고가 본안에 관하여 변론하기 전까지 이의를 제기하여야 조사 대상이 된다. 피고가 이의 없이 변론하면 관할권 등이 확정되는 변론관할의 효과가 발생한다.

**5. 소송요건의 증명**

**(1) 증명방법**

- 소송요건의 존부에 관한 사실은 본안에 관한 사실과 달리 엄격한 증명을 요하지 않으며 자유로운 증명으로 족하다. 법원은 공문서나 당사자의 진술 등을 통해 소송요건의 유무를 판단할 수 있다.

**(2) 증명책임**

- 적극적 요건의 존재에 대해서는 원칙적으로 소를 제기한 원고가 증명책임을 진다. 반면, 기판력이나 중복제소와 같은 소극적 요건의 존재에 대해서는 이를 주장하며 소의 부적법을 다투는 피고가 증명책임을 진다.

**(3) 존재의 판단시기**

- 소송요건의 존부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 판단한다. 소 제기 당시에는 흠결이 있었더라도 변론종결 시까지 구비되었다면 적법한 소가 된다. 반대로 소 제기 시에는 구비되었으나 그 후 상실되었다면 부적법한 소가 된다.

**6. 조사의 순서**

**(1) 문제점**

- 여러 개의 소송요건이 문제될 때 어떤 순서로 심리하여야 하는지가 문제된다.



## (2) 학설

- 특정한 순서가 있다는 견해와 법원의 자유로운 선택에 맡겨야 한다는 견해가 대립한다. 다만, 재판권의 존재나 당사자 실재 여부 등 근본적 요건은 우선 심리되어야 함에 이견이 없다.

## (3) 판례(소송요건심리의 선순위성 인정)

- 판례는 소송요건은 본안 심리에 앞서 판단되어야 한다는 선순위성을 강조한다. 소송요건이 구비되지 않은 경우에는 본안에 관한 심리를 진행해서는 안 된다는 것이 확고한 태도이다.

## (4) 검토

- 불필요한 본안 심리를 방지하고 소송 경제를 도모하기 위해 명백한 소송요건 흠결이 있는 경우 이를 우선적으로 판단하여 소를 종결시키는 것이 타당하다.

## 7. 조사 후 법원의 조치

### (1) 소송요건이 구비된 경우

- 법원은 본안 심리로 나아가 청구의 당부를 판단한다.

### (2) 소송요건에 흠이 있는 경우

- 보정이 가능한 경우(예 : 대리권 흠결) 법원은 보정을 명하여야 한다. 보정이 불가능하거나 기간 내에 보정되지 않으면 판결로써 소를 각하한다.

### (3) 흠결을 간과한 판결

- 소송요건 흠결을 간과하고 내린 본안 판결은 상소 사유가 된다. 다만, 당사자능력 흠결(사자상대)과 같은 중대한 하자가 아닌 한 판결이 확정되면 기판력이 발생하며 당연무효라고 보기는 어렵다.

### (4) 소송요건이 구비되었음에도 소각하판결을 한 경우

- 원고는 상소를 통해 구제를 받을 수 있다. 상소심 법원은 소각하판결이 부당하다고 인정하면 원심판결을 취소하고 사건을 원심법원으로 환송하여 본안 심리를 하게 하여야 한다.

## Ⅲ. 결론

- 승소 판결을 얻기 위한 과정은 형식적 소장 심사에서 시작하여 소송요건의 적법 심사를 거쳐 본안의 실질적 정당성과 증명에 이르는 단계적 구조를 가진다. 소송요건은 법원이 본안에 대한 판단을 내리기 위한 문턱으로서, 공정한 재판의 전제 조건이자 절차적 정의의 핵심이다. 법원은 소송요건을 엄격히 심사하여 부적법한 소송을 걸러내야 하지만, 동시에 보정 기회를 충분히 부여함으로써 국민의 재판받을 권리가 형식적인 이유로 박탈되지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다. 본안 심리와 소송요건 심리의 조화로운 운용은 민사소송의 이상인 적정·평등·신속·경제의 실현을 위한 기초가 된다 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제3절 소의 이익>

**I. 소의 이익의 의의**

- 소의 이익이란 원고가 제기한 소가 법원의 판결을 받을 만한 가치와 필요성이 있는지를 의미한다. 이는 국가의 재판권이라는 한정된 자원을 낭비하지 않고, 부당한 소송으로부터 상대방을 보호하며, 구체적인 분쟁 해결에 실효성이 있는 경우에만 재판을 허용하겠다는 취지의 소송요건이다. 소의 이익은 크게 소송물이 재판에 적합한 대상인지를 판단하는 권리보호의 자격(대상적격)과 구체적으로 판결을 얻을 필요가 있는지를 판단하는 권리보호의 이익(협약의 소의 이익)으로 나뉜다.

**II. 권리보호의 자격**

**1. 청구가 소구할 수 있는 구체적인 권리 또는 법률관계일 것**

**(1) 소구할 수 있는 것**

- 소구할 수 있는 권리란 법원에 의해 강제적으로 실현될 수 있는 성질을 가진 것이어야 한다. 민사소송의 대상은 원칙적으로 사법상의 권리나 법률 관계에 한정된다. 종교 단체의 내부 규율이나 단순한 도덕적 의무, 자연채무 등은 강제 이행을 구할 수 없으므로 소구할 수 없다.

**(2) 구체적인 권리 또는 법률관계의 주장일 것**

- 추상적인 법령의 해석이나 단순한 사실의 존부 확인은 소송의 대상이 되지 않는다. 반드시 당사자 사이의 구체적인 권리 의무에 관한 다툼이어야 한다. 학설이나 이론의 타당성 여부를 묻는 소송은 부적법하다.

**(3) 법원의 권한에 속하는 법률상 쟁송일 것**

- 헌법상 통치행위나 국회의 자율권에 속하는 사항 등 사법 심사가 제한되는 영역은 소구할 수 없다. 또한 행정처분의 무효나 취소를 민사소송으로 구하는 것과 같이 행정소송의 배타적 관할에 속하는 사항도 민사소송의 대상으로서의 자격이 결여된다.

**2. 법률상·계약상 소제기 금지사유가 없을 것**

**(1) 법률상 소제기 금지사유가 없을 것**

- 법률에 의해 일정 기간 소제기가 금지되거나 특정 절차를 거쳐야 하는 경우가 있다. 제소기간의 도과, 조정전치주의 위반 등이 이에 해당한다. 또한 변호사법 위반의 대리행위 등 공익적 사유로 소제기가 차단되는 경우도 포함된다.

**(2) 계약상 소제기 금지사유가 없을 것**

- 당사자 사이에 특정한 분쟁에 대하여 소를 제기하지 않기로 하는 부제소 합의가 있는 경우이다. 이러한 합의는 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리에 관한 것이어야 하며, 방식이 명확하고 불공정하지 않아야 유효하다. 유효한 부제소 합의를 위반하여 제기된 소는 소의 이익이 없어 각하된다.

**3. 재소장애사유가 없을 것**

- 판결이 선고된 후 소를 취하한 자는 동일한 소를 다시 제기하지 못한다(민소법 제266조). 이는 법원의 판단을 농락하는 행위를 방지하기 위한 제도이다.

**(1) 국·공유재산 관련 판례**

- 국유재산의 무단 점유자에 대한 변상금 부과 처분 등 행정처분이 개입된 사안에서, 민사상 손해배상 청구와 행정상 변상금 청구가 병행될 때 재소 금지 원칙의 적용 범위에 유의하여야 한다.

**(2) 부기등기 관련 판례**

- 주등기가 취하되거나 말소된 경우 그에 의존하는 부기등기에 대하여 별도로 소를 제기하는 것이 재소금지에 해당하는지에 대하여, 판례는 등기의 독립성과 동일성을 기준으로 판단하여 절차적 안정을 도모한다.

**4. 원고가 동일한 청구에 대하여 승소확정판결을 받은 경우가 아닐 것**

**(1) 원칙**

- 원고가 이미 승소확정판결을 받았다면 다시 소를 제기할 이익이 없다. 중복된 판결을 방지하고 법원의 업무 과중을 막기 위함이다.

**(2) 예외**

- 다만, 판례는 소멸시효 중단을 위해 재소가 필요한 경우나 판결 내용이 불분명하여 집행이 불가능한 경우 등 특별한 사정이 있는 때에는 예외적으로 재소를 허용한다. 최근 판례는 시효중단을 위한 재소 시 새로운 방식의 확인소송 등을 인정하여 당사자의 편의를 도모하기도 한다.

**5. 신의칙 위반의 재소가 아닐 것**

- 신의성실의 원칙에 반하는 소제기는 권리남용에 해당하여 소의 이익이 부정된다. 모순행위 금지 원칙이나 실효의 원칙에 따라, 장기간 권리를 행사하지 않다가 갑자기 소를 제기하여 상대방의 정당한 신뢰를 저해하는 경우 등이 이에 해당한다.

**III. 권리보호의 이익★**

**1. 이행의 소**

**(1) 현재이행의 소**

- 이행기가 도래하였음에도 채무자가 이행하지 않는 경우이다. 원칙적으로 이행을 청구하는 것만으로 소의 이익이 인정되나, 채무자가 이행의 의사를 명확히 하고 이행할 준비가 되어 있는 등 다툼이 전혀 없는 경우에는 예외적으로 이익이 부정될 수 있다.

**(2) 장래이행의 소**

- 이행기가 장래에 도래하는 경우로서, 미리 청구할 필요가 있어야 한다(민소법 제251조). 채무자가 채무의 존재를 다투거나, 채무자의 태도에 비추어 이행기에 자발적 이행을 기대하기 어려운 경우에 인정된다. 판례는 부당이득 반환이나 불법행위로 인한 계속적 손해배상 청구 등에서 장래 발생할 금액이 확정적인 경우 이를 널리 인정한다.

**2. 확인의 소**

**(1) 서설**

- 확인의 소는 원고의 법적 지위에 현존하는 불안·위험이 있고, 확인판결이 이를 제거하는 데 가장 유효적절한 수단인 경우에 허용된다.

**(2) 대상적격(권리보호자격)**

- 확인의 대상은 현재의 법률관계여야 한다. 과거의 법률관계나 단순한 사실관계는 원칙적으로 대상이 될 수 없으나, 그것이 현재의 권리관계를 결정하는 전제가 되는 경우에는 예외적으로 허용되기도 한다.

**(3) 확인의 이익(권리보호이익)**

- 이행의 소를 제기할 수 있음에도 확인의 소를 제기하는 것은 방법의 선택에 있어 적절하지 않은 것으로 본다(확인소송의 보충성). 다만, 이행 청구만으로는 분쟁이 완전히 해결되지 않거나 피고가 다수여서 일률적인 확정이 필요한 경우에는 확인의 소가 허용될 수 있다.

#### (4) 증서의 진부 여부를 확인하는 소[민소법 제250조]

- 사실관계 확인임에도 법률이 예외적으로 인정한 경우이다. 서면의 작성자가 본인인지 여부 등에 대한 다툼을 미리 해결함으로써 법적 혼란을 방지하려는 목적이다.

#### 3. 형성의 소

- 형성의 소는 법률에 명문의 규정이 있는 경우에만 허용되는 것이 원칙이므로, 그 요건 자체가 권리보호의 이익을 포함하고 있다. 법령이 정한 사유가 발생하였고, 판결을 통해서만 법률관계를 변화시킬 수 있는 경우에 소의 이익이 인정된다. 형성판결이 확정되면 그 효과는 제3자에게도 미치는 경우가 많으므로 법원은 형성권 행사의 요건을 엄격히 심사하여야 한다.

#### IV. 결론

- 소의 이익은 민사소송이 단순한 감정의 배출구나 이론적 유희의 장으로 전락하는 것을 방지하는 법적 장치이다. 권리보호의 자격이 소송의 문턱을 결정한다면, 권리보호의 이익은 그 문턱을 넘어야 할 실질적 필요성을 검증한다. 현대 소송법은 당사자의 권리 구제 범위를 확대하기 위해 장래이행의 소나 시효중단을 위한 재소 등을 전향적으로 검토하고 있으나, 동시에 신의칙 위반이나 부제소 합의 위반 등 부당한 소송에 대해서는 엄격한 잣대를 적용하고 있다. 법원은 개별 사건에서 소의 이익 유무를 면밀히 살핍으로써 사법 자원의 효율적 배분과 실질적 권리 보호라는 두 가지 가치를 조화롭게 실현하여야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제4절 소송물>

**I. 소송물 일반**

**1. 서설**

**(1) 소송물의 의의**

- 소송물이란 민사소송에서 심리의 대상이 되는 구체적인 권리 또는 법률관계를 의미한다. 이는 원고가 소를 통해 재판을 구하는 핵심적인 대상이며, 중복제소 금지, 청구의 변경, 기판력의 범위를 결정하는 기준이 된다.

**(2) 소송물이론**

- 소송물을 어떻게 파악하느냐에 따라 구이론, 신이론(일원이론·이원이론) 등으로 나뉜다. 구소송물설은 실체법상의 권리마다 별개의 소송물이 성립한다고 보며, 신소송물설은 원고가 구하는 법적 지위나 신청의 목적에 따라 소송물을 단일하게 파악한다. 판례는 원칙적으로 구소송물설의 입장을 취하고 있다.

**2. 소송물의 특징**

**(1) 이행의 소**

- 이행의 소에서 소송물은 실체법상의 급부청구권이다. 따라서 동일한 급부를 구하더라도 그 근거가 되는 실체법상 권리(불법행위로 인한 손해배상 청구권과 계약불이행으로 인한 손해배상청구권)가 다르면 소송물도 별개로 구성된다.

**(2) 확인의 소**

- 확인의 소에서 소송물은 확인의 대상이 되는 법률관계 자체이다. 원고가 주장하는 권리의 존재 또는 부존재 여부가 심리의 대상이 된다.

**(3) 형성의 소**

- 형성의 소에서 소송물은 법률관계의 변동을 일으키는 형성권 또는 형성원인이다. 구체적인 형성 사유마다 별개의 소송물이 성립하는 것이 원칙이다.

**II. 일부청구에 대한 주요논점**

**1. 일부청구의 의의**

- 일부청구란 가분적인 채권(금전채권)의 일부분만을 소송상 청구하는 것을 말한다. 원고가 소송비용을 절감하거나 장래의 승소 가능성을 탐색하기 위해 활용하는 전략적 소재기 방식이다.

**2. 일부청구한 경우의 소송물**

**(1) 학설**

- 채권의 일부분만을 청구하더라도 채권 전액이 소송물이 된다는 전부설과, 원고가 명시적으로 청구한 범위 내에서만 소송물이 성립한다는 일부설(명시설)이 대립한다.

**(2) 판례**

- 판례는 원고가 소송상 청구하는 채권이 전체 채권의 일부임을 명시한 경우에는 그 청구한 부분만이 소송물이 되지만, 명시하지 않은 경우에는 채권 전액이 소송물이 된다는 명시설의 입장을 취하고 있다.

**(3) 검토**

- 당사자의 처분권주의를 존중하고 소송비용의 합리적 지출을 보장하기 위해, 명시적으로 일부임을 밝힌 경우에는 그 범위 내로 소송물을 제한하는 명시설이 타당하다.

**3. 일부청구의 소의 이익**

- 가분채권의 일부청구는 원칙적으로 허용된다. 다만, 채권자가 아무런 합리적 이유 없이 채권을 세분하여 반복적으로 소를 제기하는 것은 상대방에게 응소의 고통을 주고 사법 자원을 낭비하는 것이므로, 신의칙 위반이나 권리남용에 해당할 경우 소의 이익이 부정될 수 있다.

**4. 잔부청구 시 중복제소 여부**

**(1) 문제점**

- 일부청구 소송이 계속 중인 상태에서 나머지 잔부를 별도로 청구하는 것이 중복제소에 해당하는지가 문제된다.

**(2) 학설**

- 전부설에 의하면 소송물이 동일하므로 중복제소에 해당하나, 명시설에 의하면 소송물이 다르므로 중복제소가 아니라고 본다.

**(3) 판례**

- 판례는 일부청구임을 명시하여 소를 제기한 경우, 잔부청구는 별개의 소송물이므로 중복제소에 해당하지 않는다고 판단한다.

**(4) 검토**

- 소송물의 범위가 명시된 부분에 한정된다면 잔부청구는 심리 대상이 겹치지 않으므로 중복제소 금지 원칙에 위배되지 않는다고 보는 것이 논리적이다.

**5. 잔부청구 시 기판력 작용 여부**

**(1) 문제점**

- 일부청구에 대한 판결이 확정된 후 잔부를 청구할 때, 전소 판결의 기판력이 잔부청구 소송에 미치는지 여부이다.

**(2) 학설**

- 전부설은 채권 전액에 기판력이 미친다고 보며, 명시설은 명시된 부분에만 기판력이 미친다고 본다.

**(3) 판례**

- 판례는 명시적 일부청구의 경우 전소의 판결은 청구된 부분에 대해서만 기판력이 발생하므로, 잔부청구 소송에 기판력이 미치지 않는다고 본다. 반대로 일부임을 명시하지 않은 경우에는 전소 판결의 효력이 채권 전부에 미쳐 잔부청구가 차단된다.

**(4) 검토**

- 명시 여부에 따라 기판력 범위를 결정하는 것은 당사자의 의사와 절차적 안정성을 조화시키는 합리적인 기준이다.

**6. 일부청구 시 시효중단범위**

**(1) 문제점**

- 일부청구의 소를 제기했을 때 시효중단의 효력이 채권 전부에 미치는지, 아니면 청구된 일부에만 미치는지에 관한 논의이다.

**(2) 학설**

- 채권의 불가분성을 강조하여 전부에 미친다는 견해와, 소송상 권리 행사의 범위를 기준으로 일부에만 미친다는 견해가 있다.

### (3) 판례

- 판례는 소송상 청구한 일부에 대해서만 시효중단의 효력이 발생함을 원칙으로 한다. 다만, 청구원인에서 채권 전액을 주장하면서 우선 일부만을 청구한 경우에는 잔부 부문에 대해서도 권리 행사의 의사가 표명된 것으로 보아 전부에 시효중단의 효력을 인정하기도 한다.

### (4) 검토

- 시효중단은 권리 위에 잠자지 않는 자를 보호하는 취지이므로, 청구취지에 명시된 금액뿐만 아니라 소송 과정에서 나타난 권리 행사의 실질적 범위를 고려하여 판단해야 한다.

## 7. 일부청구 시 과실상계

### (1) 문제점

- 일부청구 사건에서 법원이 과실상계를 할 때 전체 손해액에서 먼저 공제해야 하는지, 아니면 청구된 금액 내에서 공제해야 하는지이다.

### (2) 학설

- 전체 손해액에서 과실비율을 공제한 금액이 청구액보다 크면 청구액 전부를 인용해야 한다는 외측설과, 청구액을 기준으로 과실상계를 적용해야 한다는 내측설이 대립한다.

### (3) 판례

- 판례는 외측설을 취하고 있다. 즉, 전체 손해액에 과실상계를 적용한 금액이 원고가 청구한 일부청구액을 초과한다면 원고의 청구 금액 전부를 인용하여야 한다.

### (4) 검토

- 원고가 손해의 일부만을 청구한 의도는 손해 전체 중 책임이 인정되는 범위를 우선 확보하겠다는 것이므로, 외측설이 원고의 의사와 실질적 공평에 부합한다.

## 8. 청구취지의 확장의 소의 변경 여부

- 일부청구 소송 도중 청구취지를 확장하는 것은 청구의 추가적 변경에 해당한다. 이는 새로운 소송물을 추가하는 행위로서 민사소송법상 소의 변경 절차에 따라야 하며, 구소송물의 시효중단 효력은 확장된 시점에 발생함이 원칙이다.

## 9. 전부승소자의 상소 가부

### (1) 문제점

- 일부청구에서 청구한 금액 전부를 인용받은 원고가 잔부 청구를 위해 상소를 제기할 수 있는지가 문제된다.

### (2) 학설

- 형식적 불복설에 의하면 청구취지대로 판결이 나왔으므로 상소권이 없으나, 실질적 불복설에 의하면 잔부 권리가 남아있는 한 상소 이익을 인정할 수 있다.

### (3) 판례

- 판례는 형식적 불복설의 입장이다. 일부청구에서 청구한 금액이 전부 인용되었다면 원고는 전부 승소한 것이므로 판결에 불복하여 상소할 이익이 없다. 잔부 채권에 대해서는 별소를 제기하는 등의 방식으로 해결해야 한다.

### (4) 검토

- 상소는 재판의 결과가 신청한 내용과 다를 때 허용되는 것이므로, 스스로 제한하여 청구한 범위 내에서 승소했다면 상소의 이익을 부정하는 것이 절차 원칙에 부합한다.

## III. 결론

- 소송물은 민사소송의 심판 대상을 확정하는 기초 단위로서, 절차 전반에 걸쳐 강력한 기준이 된다. 특히, 일부청구 제도는 청구의 전략적 운용이라는 측면에서 긍정적이나, 중복제소나 기판력, 시효중단 등 복잡한 법적 쟁점을 야기한다. 판례가 취하고 있는 명시설과 외측설 등은 당사자의 처분권주의와 실질적 권리 보호를 조화시키려는 고심의 결과이다. 법원은 소송물의 정확한 파악을 통해 불필요한 분쟁의 반복을 막고, 일부청구가 부당한 소송 지연이나 상대방의 방어권 침해로 이어지지 않도록 운영의 묘를 살려야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제5절 소의 제기>

**I. 소제기의 방식**

**1. 소장제출주의**

- 민사소송법은 제소의 방식으로 소장제출주의를 채택하고 있다(민소법 제248조). 소는 원고가 법원에 소장을 제출함으로써 제기되며, 이는 서면주의의 발현이다. 말에 의한 소제기는 원칙적으로 허용되지 않으며, 전자소송의 경우에도 전자문서 형태의 소장을 제출하여야 한다. 소장 제출은 소송 계속의 효과를 발생시키는 기초가 되며, 법원은 제출된 소장의 부분을 피고에게 송달함으로써 절차를 진행한다.

**2. 소제기의 간주**

- 직접적인 소장 제출이 없더라도 특정한 절차적 사유에 의해 소가 제기된 것으로 보는 경우이다. ① 시분할 또는 배당요구 등의 절차에서 소송으로 이행되는 경우나, 제소전화해가 불성립하여 소송으로 이행되는 경우가 이에 해당한다. ② 지급명령에 대한 이의신청이 있거나 조정신청 후 조정이 불성립하여 소송으로 이행될 때, 당초의 신청 시에 소가 제기된 것으로 간주한다. 이는 소제기 시점을 소급시켜 소멸시효 중단 등의 법익을 보호하기 위함이다.

**II. 소장의 기재사항**

**1. 필요적 기재사항[민소법 제249조]**

- 소장에는 반드시 기재하여야 할 사항이 정해져 있으며, 이 중 하나라도 누락되면 재판장의 보정명령 대상이 된다.

**(1) 당사자와 법정대리인**

- 원고와 피고를 특정할 수 있는 성명, 주소 등을 기재하여야 한다. 당사자가 법인인 경우 명칭과 주된 사무소의 소재지를 기재하며, 소송무능력자인 경우에는 법정대리인을 반드시 기재하여야 한다.

**(2) 청구취지**

- 청구취지란 원고가 법원에 대하여 구하는 판결의 내용과 범위를 결론적으로 기재한 것이다. 이는 판결의 주문에 대응하는 부분으로서, 그 내용이 명확하고 특정되어야 한다. 청구취지가 불분명하면 강제집행이 불가능해지므로 법원은 이를 엄격히 심사한다.

**(3) 청구원인**

- 청구원인이란 원고가 청구취지와 같은 판결을 구하게 된 근거가 되는 구체적인 사실관계를 말한다. 원고의 청구를 정당화하는 권리 발생의 요건사실을 기재하여야 하며, 소송물을 특정하는 기능을 수행한다.

**2. 임의적 기재사항**

- 소송절차의 원활한 진행을 위해 기재가 권장되나, 누락되어도 소장 자체가 부적법해지지는 않는 사항이다.

**(1) 증거방법**

- 원고의 주장을 뒷받침하는 서증, 증인 신청 등을 미리 기재할 수 있다. 소장에 서증의 사본을 첨부하는 것이 실무적인 관행이다.

**(2) 부속서류의 표시**

- 위임장, 법인 등기부 등본 등 소장에 첨부된 서류의 목록을 기재한다.

**(3) 연락처 및 전자우편주소**

- 신속한 송달과 연락을 위해 당사자의 전화번호나 이메일 주소를 기재하는 것이 권장된다.

**III. 결론**

- 소의 제기는 국가의 재판권을 발동시키는 시발점으로서 형식적 엄격성이 요구된다. 소장제출주의는 절차의 명확성을 보장하며, 소제기 간주 제도는 당사자의 권리 구제를 유연하게 한다. 소장의 기재사항 중 당사자, 청구취지, 청구원인은 필요적 기재사항으로서 소송의 성격과 범위를 확정하는 핵심 요소인바, 원고는 이를 명확히 기재하여 불필요한 보정 절차나 소장 각하의 위험을 방지하여야 한다. 임의적 기재사항 역시 실무상 심리의 효율성을 높이는 중요한 역할을 하므로 성실히 기재하는 것이 바람직하다. 법원은 소 제기 단계에서부터 기재사항의 적정성을 면밀히 살펴 신속하고 공정한 재판이 이루어질 수 있도록 기초를 닦아야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제6절 재판장의 소장심사와 그 후의 조치>

**I. 재판장의 소장심사[민소법 제254조]**

**1. 의의**

- 재판장의 소장심사란 원고가 제출한 소장이 법률상 정해진 형식적 요건을 구비하였는지를 재판장이 단독으로 조사하는 절차를 의미한다. 이는 소송 요건을 심사하는 소의 적법심사와는 구별되는 단계로서, 소송의 효율적 진행을 위해 본안 심리에 앞서 외관상의 하자를 치유하기 위한 목적을 가진다.

**2. 심사의 대상**

- 소장심사의 주된 대상은 민사소송법 제249조 제1항에서 정한 필요적 기재사항(당사자, 법정대리인, 청구취지, 청구원인)의 누락 여부와 소장에 규정된 액수의 인지가 첨부되었는지 여부이다. 또한 소송무능력자에게 법정대리인이 기재되어 있는지, 대표권의 증명서면이 첨부되었는지 등도 심사 대상에 포함된다. 다만, 청구원인이 실체법상 타당한지 여부와 같은 본안에 관한 사항은 심사 대상이 아니다.

**3. 보정명령[민소법 제265조]**

- 심사 결과 소장에 기재사항의 흠결이 있거나 인지가 부족한 경우, 재판장은 상당한 기간을 정하여 원고에게 그 하자를 보정할 것을 명한다. 보정명령은 재판장의 권한이며, 원고가 보정 기간 내에 하자를 치유하면 소장은 처음 제출된 때에 소급하여 효력을 발생한다.

**4. 소장각하명령과 즉시항고**

- 원고가 재판장의 보정명령을 받고도 정해진 기간 내에 보정하지 않는 경우, 재판장은 명령으로 소장을 각하한다. 소장각하명령은 판결이 아닌 명령의 형태를 취하며, 소송계속의 효과가 발생하기 전의 조치이므로 종국판결과는 성질이 다르다. 원고는 이 명령에 대하여 즉시항고를 함으로써 불복할 수 있다. 항고심에서 보정이 이루어지면 원심의 각하명령은 취소된다.

**II. 피고의 답변제출의무와 무변론판결[민소법 제257조]**

**1. 피고의 답변서제출의무**

- 법원은 소장부분을 피고에게 송달하면서, 피고가 원고의 청구를 다투는 경우에는 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 함을 고지한다. 피고가 이 기한 내에 답변서를 제출하지 않거나, 제출하더라도 청구원인 사실을 모두 인정하는 취지인 경우에는 다툼이 없는 것으로 간주한다. 이는 피고의 응소 의사를 조기에 확인하여 소송 절차를 신속히 진행하기 위한 장치이다.

**2. 무변론판결**

- 피고가 기한 내에 답변서를 제출하지 않거나 원고의 주장 사실을 자백하는 취지의 답변서를 제출한 경우, 법원은 변론기일을 열지 않고 바로 판결을 선고할 수 있다. 이를 무변론판결이라 한다. 다만, 공시송달 사건이거나 직권조사사항이 있는 경우, 또는 판결 선고 전까지 피고가 원고의 청구를 다투는 답변서를 제출한 경우에는 무변론판결을 할 수 없으며 변론기일을 지정하여야 한다.

**III. 변론준비절차회부와 변론기일의 지정**

**1. 변론준비절차의 의의 및 회부**

- 사건이 복잡하여 변론기일 전에 당사자의 주장과 증거를 정리할 필요가 있는 경우, 재판장은 사건을 변론준비절차에 회부할 수 있다(민소법 제258조). 변론준비절차는 서면에 의한 준비절차와 변론준비기일에 의한 절차로 나뉜다. 이를 통해 쟁점을 미리 명확히 함으로써 실제 변론기일에서의 집중 심리를 도모한다.

**2. 변론기일의 지정 및 통지**

- 재판장은 소장이 접수되고 적식심사를 마친 후, 피고가 답변서를 제출하여 다툼이 생긴 경우 지체 없이 변론기일을 지정하여야 한다. 기일이 지정되면 법원은 당사자에게 기일통지서를 송달하여 출석을 명한다. 변론준비절차를 거친 경우에는 준비절차가 종결된 후 즉시 변론기일을 지정하여 심리를 이어간다.

**IV. 결론**

- 재판장의 소장심사와 이후의 조치들은 소송 절차의 입구에서 불필요한 분쟁의 지연을 막고 효율적인 심리 토대를 마련하는 과정이다. 형식적 요건을 심사하는 소장심사는 국가 재판권 행사의 정확성을 기하며, 무변론판결 제도는 다툼 없는 사건을 조기에 종결시킴으로써 사법 자원의 낭비를 방지한다. 변론준비절차는 복잡한 현대 소송에서 쟁점을 날카롭게 다듬어 집중 심리를 가능케 하는 핵심적인 단계이다. 법원은 이러한 일련의 절차를 통해 원고의 재판받을 권리와 피고의 방어권을 조화롭게 보장하면서도, 소송의 경제와 신속이라는 목적을 달성할 수 있도록 각 단계를 엄격하고 세심하게 운영하여야 할 것이다.

### <제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제7절 소제기의 효과>

#### I. 소송계속

##### 1. 의의

- 소송계속이란 특정한 사건이 법원에 제출되어 심판의 대상이 된 상태를 의미한다. 이는 판결의 선고나 소의 취하 등 종국적인 사유로 소송이 종료될 때까지 지속되는 공법상의 상태이다. 소송계속이 발생하면 법원은 당해 사건에 대해 심리하고 판결할 의무를 지게 되며, 당사자는 그 절차 내에서 소송 행위를 수행할 권리와 의무를 갖는다.

##### 2. 소송계속의 발생시기

- 소송계속의 발생 시점에 관하여는 소장 제출 시라는 견해와 소장 부분이 피고에게 송달된 때라는 견해가 대립한다. 우리 민사소송법은 소장 부분이 피고에게 송달된 때에 비로소 소송계속이 발생한다고 보는 것이 통설적 입장이다. 소장 제출만으로는 법원과 원고 사이의 관계만 형성될 뿐, 피고가 절차에 편입되어 방어권을 행사할 수 있는 상태가 아니기 때문이다. 다만, 시효중단과 같은 실체법상 효과는 소장 제출 시에 소급하여 발생한다(민소법 제265조).

##### 3. 효과

- 소송계속이 발생하면 법원은 당해 사건을 심판할 권한과 의무를 가지며, 중복소제기 금지의 원칙이 적용된다. 또한, 당사자는 당해 소송 절차를 통하지 않고는 동일한 청구를 별소로 제기할 수 없게 된다. 소송계속 중에 소송물이 양도되는 경우 승계인의 참여 문제가 발생하며, 소송계속은 판결의 기판력이 미치는 시적 범위를 확정하는 기준이 되기도 한다.

#### II. 중복된 소제기의 금지★

##### 1. 의의[민소법 제259조]

- 이미 소송이 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다. 이는 동일한 사건에 대하여 서로 모순되는 판결이 선고되는 것을 방지하고, 피고에게 이중 응소의 고통을 주지 않으며, 법원의 심리 중복으로 인한 사법 자원의 낭비를 막기 위한 제도이다.

##### 2. 중복소제기의 요건

###### (1) 당사자의 동일

- 전소와 후소의 당사자가 동일하여야 한다. 원고와 피고의 지위가 바뀌어 있는 경우(채무부존재확인 소 계속 중 이행 소 제기)에도 당사자가 동일하다면 중복소제기에 해당할 수 있다. 또한, 판결의 효력이 제3자에게 미치는 경우(채권자대위소송)에는 그 제3자가 제기한 후소도 중복소제기로 본다.

###### (2) 청구의 동일

- 전소와 후소의 소송물이 동일하여야 한다. 소송물의 동일성은 청구취지와 청구원인을 기준으로 판단한다. 청구취지가 정반대인 경우에도 그 실질이 동일한 권리관계를 다루는 것이라면 중복소제기가 성립한다. 판례는 선행 소송의 공격방어방법에 불과한 사항을 후소의 소송물로 삼는 경우에도 절차적 안정을 위해 중복소제기를 인정하는 경향이 있다.

###### (3) 전소의 소송계속 중 후소를 제기하였을 것

- 후소의 제기 당시에 전소가 법원에 계속 중이어야 한다. 전소가 취하되거나 각하되어 소송계속이 소멸한 경우에는 후소는 더 이상 중복소제기가 아니게 된다. 전소의 판결이 확정된 경우에는 중복소제기가 아니라 기판력의 문제로 전이된다.

##### 3. 소송법상 효과

###### (1) 직권조사사항

- 중복소제기 금지는 공공의 이익을 위한 강행규정이므로 법원의 직권조사사항이다. 당사자의 주장이 없더라도 법원은 소송 기록을 통해 중복소제기 여부를 확인하여야 하며, 요건을 충족하면 후소를 부적법 각하하여야 한다.

###### (2) 중복소제기임을 간과한 판결

- 법원이 중복소제기임을 알지 못하고 본안 판결을 내린 경우, 그 판결은 상소 사유가 된다. 그러나 판결이 확정되면 그 하자는 치유되며 기판력이 발생한다. 만약, 전소와 후소의 판결이 모두 확정되어 서로 모순되는 경우에는 재심 사유가 될 수 있는지에 대해 논의가 있으나, 원칙적으로 후소 판결이 기판력을 갖게 된다.

##### 4. 국제적 중복소제기

###### (1) 문제점

- 외국 법원에 이미 소가 제기되어 계속 중인 사건을 우리나라 법원에 다시 제기한 경우, 민소법 제259조를 적용하여 각하할 수 있는지가 문제된다.

###### (2) 견해의 대립

- 국제적 예외와 소송 경제를 위해 금지해야 한다는 견해와, 외국 판결의 승인 여부가 불확실한 상황에서 우리 국민의 재판받을 권리를 박탈해서는 안 된다는 견해가 대립한다.

###### (3) 개정 국제사법의 태도

- 개정된 국제사법은 외국 법원에 소가 제기된 경우 우리 법원이 소송 절차를 중지할 수 있는 근거를 마련하였다. 외국 판결이 장차 우리나라에서 승인될 가능성이 있는 경우, 법원은 후소의 절차를 중지하여 중복 심리를 피할 수 있다.

#### III. 실체법상 효과

##### 1. 의의

- 소의 제기는 소송법적 효과뿐만 아니라 실체법상 권리에도 영향을 미친다. 가장 대표적인 효과는 소멸시효의 중단과 법률상 기간의 준수이다. 이는 권리자가 권리를 행사하겠다는 의사를 객관적으로 표명한 것에 대한 법적 보호이다.

##### 2. 시효중단의 대상[민소법 제170조, 제265조]

###### (1) 중단의 대상이 되는 소

- 민사소송법상의 소제기뿐만 아니라 중재신청, 조정신청 등 재판상 권리 행사에 준하는 행위도 포함된다. 다만, 소가 각하되거나 취하된 경우에는 시효중단의 효력이 소급하여 소멸한다. 이 경우 6개월 내에 다시 소를 제기하거나 압류 등을 하면 시효는 첫 소제기 시점에 중단된 것으로 본다.

###### (2) 중단의 범위

- 시효중단의 효력은 소송물인 권리에 한하여 발생한다. 일부청구의 경우 명시적 일부청구라면 그 일부에 대해서만 시효가 중단되는 것이 원칙이다. 다만, 전액의 확정을 구하는 취지가 포함되어 있다면 전부에 효력이 미칠 수 있다. 시효중단의 효력은 소장이 법원에 접수된 때에 발생한다(민소법 제265조).



### (3) 응소와 시효중단

- 피고로서 소송에 응하여 자신의 권리를 주장하는 응소 행위도 시효중단의 사유가 된다. 판례는 피고가 적극적으로 자신의 권리를 주장하며 승소 판결을 얻어낸 경우, 소제기에 준하는 권리 행사로 보아 응소 시에 시효가 중단된 것으로 인정한다.

## 3. 법률상 기간의 준수

### (1) 의의

- 법령에서 정한 제척기간이나 출소기간 내에 소를 제기하여야 하는 경우, 소제기는 그 기간을 준수한 것으로 본다. 형성의 소(취소의 소)에서 기간 준수는 권리 발생 및 소멸의 핵심 요건이다.

### (2) 효과

- 소 제기 시에 기간을 준수한 것으로 간주됨으로써, 소송 계속 중에 기간이 경과하더라도 권리가 소멸하지 않는다. 이는 시효중단과 유사하게 소장 제출 시를 기준으로 판단하여 당사자의 불이익을 방지한다.

## IV 결론

- 소제기의 효과는 소송계속이라는 공법적 상태를 형성함으로써 법원과 당사자에게 새로운 권리 의무 관계를 부여한다. 중복소제기 금지는 판결의 모순을 방지하여 사법의 신뢰를 지키는 핵심 기제이며, 시효중단과 기간 준수의 효과는 권리자의 실체적 권리를 보호하는 강력한 수단이 된다. 특히, 국제적 중복소제기와 관련한 논의는 현대 국제 거래의 증가에 발맞추어 절차 중지 등 유연한 해결책을 모색하는 방향으로 발전하고 있다. 법원은 소제기로 발생하는 이들 효과를 정확히 파악하여, 절차적 남용을 막는 동시에 정당한 권리 행사가 법적 보호의 울타리 안에서 온전히 실현될 수 있도록 관리하여야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제8절 채권자대위소송에 대한 주요 논점>

**I. 의의**

- 채권자대위소송이란 채권자가 자신의 채권을 보전하기 위하여 채무자의 제3채무자에 대한 권리를 채무자를 대신하여 행사하는 소송이다. 이는 실체법상 채권자대위권(민법 제404조)에 근거를 두고 있으나, 소송법적으로는 당사자적격의 소재와 기판력의 확장 범위 등 독특한 쟁점을 다수 포함하고 있다.

**II. 채권자대위소송의 법적 성질 ★**

**1. 법적 성질**

- 채권자대위소송의 법적 성질에 관하여는 채권자가 자신의 권리를 행사하는 것이라는 견해와 채무자의 대리인으로서 소송을 수행하는 것이라는 견해가 대립한다. 통설과 판례는 채권자가 법률의 규정에 의하여 타인의 권리에 대하여 소송수행권을 부여받는 법정소송담당으로 파악한다. 그중에서도 채무자의 의사와 관계없이 제기할 수 있다는 점에서 갈음형 법정소송담당에 해당한다.

**2. 대위소송의 요건흡결 시 처리**

- 채권자대위소송의 요건(채권보전의 필요성, 채무자의 권리불행사 등) 중 일부는 실체법상 권리 발생 요건인 동시에 소송법상 당사자적격을 결정하는 요소가 된다. 따라서 피보전채권이 존재하지 않거나 채무자가 이미 스스로 권리를 행사하고 있는 경우, 법원은 본안 심리를 하지 않고 원고의 당사자적격 흡결을 이유로 소각하판결을 내려야 한다.

**III. 채권자대위소송과 중복소제기**

**1. 채권자대위소송 계속 중 채무자가 소를 제기한 경우**

- 채권자가 먼저 대위소송을 제기하여 소송계속이 발생한 후, 채무자가 동일한 피대위권리를 대상으로 제3채무자에게 소를 제기하는 경우이다. 판례는 채권자대위소송의 소송물과 채무자의 직접 소송의 소송물은 동일하다고 보므로, 채무자가 나중에 제기한 소는 중복소제기에 해당하여 부적법하다.

**2. 채무자의 제3자에 대한 소송 중 채권자대위소송이 제기된 경우**

- 채무자가 이미 제3채무자를 상대로 소를 제기하여 재판이 진행 중이라면, 채권자대위소송의 요건인 채무자의 권리불행사를 충족하지 못하게 된다. 이 경우 나중에 제기된 채권자대위소송은 당사자적격이 없는 자에 의한 소로서 소송요건 흡결로 각하된다.

**3. 채권자대위소송 계속 중 다른 채권자가 다시 대위소송을 제기한 경우**

- 수인의 채권자가 동일한 피대위권리에 대하여 각자 대위소송을 제기하는 경우이다. 먼저 제기된 소송이 계속 중이라면 나중에 제기된 다른 채권자의 대위소송은 소송물이 동일하므로 중복소제기에 해당한다.

**4. 압류채권자의 추심소송 중 채무자가 별소를 제기한 경우**

- 추심명령을 받은 채권자가 제기하는 추심소송도 법정소송담당의 일종이다. 추심소송이 계속 중일 때 채무자가 동일한 채권에 대해 소를 제기하는 것은 중복소제기 금지 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

**5. 채무자가 제소한 후 압류채권자가 추심소송을 제기한 경우**

- 채무자가 먼저 소를 제기한 경우 압류채권자는 별소를 제기할 수 없다. 대신 압류채권자는 채무자의 소송에 승계참가하거나 공동소송인으로 참가하여 자신의 권리를 보호받아야 한다.

**IV. 피대위자의 재소금지 여부**

**1. 문제점**

- 채권자가 대위소송을 제기했다가 판결 선고 후 소를 취하한 경우, 채무자가 나중에 직접 소를 제기하는 것이 재소금지 원칙(민소법 제266조 제2항)에 저촉되는지가 문제된다.

**2. 학설**

- 채권자와 채무자는 별개의 인격체이므로 재소금지가 적용되지 않는다는 견해와, 소송물이 동일하므로 채무자도 재소금지의 효력을 받는다는 견해가 대립한다.

**3. 판례**

- 판례는 채무자가 채권자대위소송이 제기된 사실을 알았을 때에 한하여, 채권자의 소취하에 따른 재소금지의 효력이 채무자에게도 미친다고 판단한다. 이는 기판력의 확장 원리를 재소금지에도 유추 적용한 결과이다.

**4. 검토**

- 채무자가 소송 제기 사실을 알았다면 스스로 권리를 행사할 기회가 있었음에도 방치한 것이므로, 절차적 안정을 위해 재소금지의 효력을 인정하는 판례의 태도가 타당하다.

**V. 채권자대위소송과 기판력의 확장**

**1. 채권자대위소송 확정판결의 효력이 채무자에게 미치는지 여부**

- 과거에는 채무자가 소송에 참가하거나 고지받은 경우에만 미친다는 견해가 있었으나, 현재 판례는 채무자가 대위소송이 제기된 사실을 어떤 경로로든 알았을 경우에는 그 확정판결의 효력이 채무자에게도 미친다고 본다.

**2. 채무자의 제3채무자에 대한 확정판결의 효력이 대위채권자에게 미치는지 여부**

- 채무자가 제3채무자를 상대로 제기한 소송에서 패소 판결이 확정되었다면, 그 기판력은 법정소송담당의 원리에 따라 채권자에게도 미친다. 따라서 채권자는 동일한 권리에 대해 다시 대위소송을 제기할 수 없다.

**3. 채권자대위소송 확정판결의 효력이 다른 채권자에게 미치는지 여부**

- 수인의 채권자들 사이에서도 소송물이 동일하므로, 어느 한 채권자가 얻은 확정판결의 효력은 다른 채권자에게도 미친다. 다만, 이는 채무자가 소송 계속 사실을 알았을 것을 전제로 한다.

**4. 채권자의 채무자를 상대로 한 소송의 확정판결의 효력이 제3채무자를 상대로 한 채권자대위소송에 미치는지 여부**

- 채권자가 채무자를 상대로 피보전채권의 존재를 확인받거나 이행 판결을 받은 경우, 그 기판력은 대위소송에서의 피보전채권 존부 판단에 영향을 미친다. 제3채무자는 대위소송에서 채무자가 주장할 수 없는 사유로 채권자의 피보전채권을 다툴 수 없다.

**5. 채권자의 제3채무자를 상대로 한 채권자대위소송 확정판결의 효력이 채권자의 채무자를 상대로 한 소송에 미치는지 여부**

- 대위소송에서 제3채무자가 승소(청구기각)하더라도 이는 피대위권리의 부존재를 확정할 뿐이다. 따라서 채권자가 채무자를 상대로 제기하는 피보전채권 자체에 관한 소송에는 기판력이 미치지 않는다.

## **V. 원시적 공동소송의 가부**

### **1. 대위채권자와 채무자의 공동소송**

- 채권자가 대위소송을 제기하면서 채무자를 공동피고로 삼아 피보전채권의 이행을 구하는 소송(이른바 대위소송과 본안소송의 병합)은 실무상 널리 허용된다.

### **2. 수인의 대위채권자의 공동소송**

- 여러 채권자가 처음부터 공동하여 대위소송을 제기하는 경우, 이는 민사소송법 제65조 전단에 의한 공동소송으로서 통상공동소송이 된다.

## **VI. 공동소송참가와 보조참가의 가부**

### **1. 채권자대위소송 계속 중 채무자가 참가하는 경우**

- 채무자는 소송 결과에 따라 자신의 권리가 확정되므로 이익관계가 명백하다. 채무자는 채권자의 소송에 공동소송참가(민소법 제72조)를 하여 직접 당사자로서 권리를 주장할 수 있다.

### **2. 채무자의 제3자에 대한 소송 중 채권자가 참가하는 경우**

- 채권자는 채무자가 승소해야 자신의 채권을 보전할 수 있으므로 법률상 이해관계가 있다. 따라서 채권자는 채무자의 승소를 돕기 위해 보조참가를 할 수 있다.

### **3. 채권자대위소송 계속 중 다른 채권자가 참가하는 경우**

- 다른 채권자는 먼저 소를 제기한 채권자와 소송목적이 결정적으로 동일하므로 공동소송참가를 할 수 있다. 만약, 별소를 제기하면 중복소제기가 되므로 참가가 강제되는 측면이 있다.

## **VII. 결론**

- 채권자대위소송은 다수의 이해관계인이 얹힌 복합적인 소송 형태로서, 소송물 및 기판력의 법리가 당사자 확정의 핵심을 이룬다. 판례가 채무자가 알았는지 여부를 기준으로 기판력과 재소금지의 범위를 확정하는 것은 채무자의 절차적 기본권을 보호하면서도 판결의 모순을 방지하려는 합리적 선택이다. 중복소제기 논의 역시 채무자의 권리 행사가 우선한다는 원칙 하에 대위채권자의 지위를 보충적으로 파악함으로써 절차적 혼란을 최소화하고 있다. 법원은 대위소송의 특수성을 고려하여 당사자적격의 존부를 엄격히 심사하되, 공동소송참가 등의 제도를 적극 활용하여 관련 분쟁이 하나의 절차 내에서 모순 없이 해결될 수 있도록 유도하여야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제1절 변론의 의의와 종류>

**I. 의의**

**1. 변론의 개념**

- 변론이란 소송의 주체인 당사자가 법원의 공개된 법정에서 판결의 기초가 될 소송자료, 즉 사실과 증거를 제출하는 구술활동을 의미한다. 넓은 의미로는 당사자의 구술활동뿐만 아니라 법원이 사건의 실체를 파악하기 위해 행하는 심리 절차 전반을 포함하며, 좁은 의미로는 기일에 당사자가 하는 말하기 활동에 한정된다.

**2. 변론의 기능**

- 변론은 당사자에게 재판에 참여하여 자신의 주장을 펼칠 기회를 보장함으로써 절차적 정당성을 확보하는 기능을 한다. 법원은 변론을 통해 형성된 소송자료를 바탕으로 사실을 인정하고 법률을 적용하여 종국판결을 내린다. 따라서 변론은 심리의 핵심이며, 판결의 직접적인 기초가 되는 절차이다.

**3. 변론의 주체와 장소**

- 변론의 주체는 당사자이며, 법원의 지휘 아래 행해진다. 변론은 원칙적으로 수소법원의 구성원인 법관의 면전에서 행해져야 하며, 공개가 원칙인 법정에서 이루어져야 한다. 이는 재판의 공정성과 투명성을 확보하기 위한 헌법적 요구이기도 하다.

**II. 필요적 변론**

**1. 의의**

- 필요적 변론이란 판결을 내리기에 앞서 반드시 당사자에게 구술로 변론할 기회를 주어야 하는 원칙을 말한다. 민사소송법 제134조 제1항은 당사자는 소송에 대하여 법원에서 변론하여야 한 다라고 규정하여 이를 명시하고 있다. 이는 당사자의 청구에 대한 당부를 판단하는 종국판결을 내릴 때 반드시 적용된다.

**2. 적용 범위**

**(1) 종국판결을 내리는 경우**

- 본안에 대한 판결뿐만 아니라, 소송요건 흠결을 이유로 하는 소각하판결을 내릴 때도 원칙적으로 필요적 변론을 거쳐야 한다. 당사자의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 판단은 구술에 의한 충분한 심리가 전제되어야 하기 때문이다.

**(2) 예외적 허용(무변론판결 등)**

- 필요적 변론의 예외로서 피고가 자백하거나 답변서를 제출하지 않는 경우의 무변론판결(민소법 제257조), 항소심에서 항소장의 각하, 소액사건에서의 변론 없는 기각 등이 법률에 의해 인정된다.

**3. 필요적 변론의 절차적 효과**

- 필요적 변론을 거치지 않고 내린 판결은 절차상의 중대한 하자가 있는 것으로 보아 상소 사유가 된다. 또한 직접주의와 구술주의가 강하게 요구되므로, 법관이 교체된 경우에는 변론을 갱신하여야 하는 등 절차적 엄격성이 강조된다.

**III. 임의적 변론**

**1. 의의**

- 임의적 변론이란 법원이 판단을 내릴 때 변론을 거칠 것인지 여부를 자유로운 재량으로 결정할 수 있는 경우를 의미한다. 주로 판결이 아닌 결정이나 명령의 형태로 재판을 하는 경우에 적용된다. 법원은 서면 심리만으로 충분하다고 판단되면 변론 없이 결정을 내릴 수 있으며, 필요하다고 판단되면 변론을 열 수도 있다.

**2. 대상**

**(1) 결정 및 명령으로 하는 재판**

- 소송비용의 확정, 담보제공명령, 가압류·가처분 등 부수적 절차에서의 재판은 신속성과 효율성을 기하기 위해 임의적 변론을 원칙으로 한다.

**(2) 소송지휘에 관한 사항**

- 기일의 지정, 변론의 분리·병합 등 소송의 운영과 관련한 사항은 법원이 구술 심리 없이 재량으로 결정할 수 있다.

**3. 심문의 활용**

- 임의적 변론의 경우 법원은 변론을 여는 대신 당사자를 불러 의견을 듣는 심문 절차를 활용할 수 있다. 심문은 변론에 비해 절차적 형식이 완화되어 있으며, 비공개로 진행될 수도 있다는 점에서 차이가 있다. 임의적 변론 절차에서도 법원은 당사자에게 충분한 소명 기회를 제공하여야 한다.

**IV. 결론**

- 변론은 민사소송 절차의 심장부로서 당사자의 주장과 증거가 법원의 판단과 만나는 지점이다. 필요적 변론은 당사자의 재판받을 권리를 실질적으로 보장하는 장치이며, 임의적 변론은 절차의 신속과 경제를 도모하는 유연한 운용 수단이다. 현대 민사소송법은 구술주의의 원칙 아래 필요적 변론을 견지하면서도, 서면에 의한 사전 준비절차를 강화하여 변론의 효율성을 극대화하는 방향으로 발전하고 있다. 법원은 사건의 성격에 따라 필요적 변론과 임의적 변론을 적절히 운영함으로써, 신속하면서도 공정한 재판이라는 사법의 이상을 실현하여야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제2절 심리에 관한 제 원칙>

**I. 개관**

- 심리에 관한 제 원칙이란 법원이 소송사건을 심리하고 판결의 기초가 될 소송자료를 수집하는 과정에서 준수해야 할 기본 지침을 의미한다. 민사소송은 당사자의 사적 자치를 존중하는 처분권주의와 변론주의를 근간으로 하며, 소송의 신속과 효율을 위해 적시제출주의를 채택하고 있다. 이러한 원칙들은 공정하고 신속한 재판이라는 민사소송의 이상을 실현하기 위한 구체적인 실천 방안이다.

**II. 처분권주의**

**1. 의의[민소법 제203조]**

- 처분권주의란 소송의 개시, 심판의 대상 및 범위, 소송의 종결에 대하여 당사자에게 주도권을 주고 그 처분에 맡기는 원칙을 말한다. 사적 자치의 원칙이 소송법적으로 발현된 것으로서, 법원은 당사자가 신청하지 아니한 사항에 대하여는 판결하지 못한다.

**2. 절차의 개시**

- 소송 절차는 원고의 소 제기 에 의해서만 개시된다. 법원이 직권으로 소송을 시작할 수 없으며, 이는 '소 없으면 판결 없다'라는 원칙으로 표현된다.

**3. 심판의 대상과 범위**

**(1) 내용**

- 법원은 당사자가 신청한 청구의 범위 내에서만 심리하고 판결해야 한다. 이는 단순한 금액적 한도뿐만 아니라 청구의 성질과 내용에도 적용된다.

**(2) 질적 동일**

- 당사자가 주장하는 권리나 법률관계의 종류와 다른 판결을 내릴 수 없다. 예를 들어, 원고가 소유권에 기한 인도청구를 하는데 법원이 임대차 종료에 기한 인도판결을 내리는 것은 질적 동일성을 해치는 것으로서 처분권주의 위반이다.

**(3) 양적 동일**

- 당사자가 청구한 수량적 범위를 초과하여 판결할 수 없다. 1억 원을 청구했는데 법원이 심리 결과 손해액이 1억 2천만 원이라고 판단되더라도 1억 원을 초과하여 인용할 수 없다. 다만, 판례는 원고의 청구가 전부청구인지 명시적 일부청구인지에 따라 과실상계 등의 계산 방식에서 차이를 둔다.

**4. 절차의 종결**

**(1) 내용**

- 당사자는 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 소송상 화해 등을 통해 소송을 법원의 판결에 의하지 않고 임의로 종료시킬 수 있다.

**(2) 제한**

- 공익적 성격이 강한 가사소송이나 현대형 소송 중 일부에서는 절차 종결의 자유가 제한되기도 한다. 또한, 소 취하의 경우 피고가 본안에 관하여 응소한 후에는 피고의 동의를 얻어야 하는 등의 절차적 제한이 존재한다.

**5. 처분권주의 위반의 효과**

- 법원이 처분권주의를 위반하여 판결한 경우, 이는 상소 사유가 된다. 확정된 후에는 재심 사유가 되는지에 대해 논의가 있으나, 원칙적으로 기판력의 결합 문제로 다루어진다.

**III. 변론주의**

**1. 의의**

- 변론주의란 판결의 기초가 될 소송자료(사실과 증거)의 수집 및 제출 책임을 당사자에게 지우고, 당사자가 제출한 소송자료만을 바탕으로 법원이 재판해야 한다는 원칙이다. 이는 사법상의 권리관계는 당사자의 자유로운 처분에 맡겨져 있다는 관념에 기초한다.

**2. 변론주의의 내용**

**(1) 사실의 주장책임**

- 법원은 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판결의 기초로 삼을 수 없다. 여기서 사실이란 권리의 발생·변경·소멸이라는 법률효과를 일으키는 주요사실에 한정된다. 간접사실이나 보조사실은 당사자의 주장이 없더라도 변론 전체의 취지를 통해 법원이 인정할 수 있다.

**(2) 자백의 구속력**

- 당사자 사이에 다툼이 없는 사실(재판상 자백)은 그대로 판결의 기초로 삼아야 하며, 법원이 이와 반대되는 사실을 인정할 수 없다. 자백은 법원뿐만 아니라 자백한 당사자 본인도 구속하므로 함부로 취소할 수 없다.

**(3) 증거제출책임**

- 다툼이 있는 사실을 인정하기 위한 증거는 당사자가 제출해야 한다. 법원이 직권으로 증거조사를 하는 것은 원칙적으로 금지되며, 당사자가 신청한 증거에 의해서만 사실을 확정해야 한다.

**3. 변론주의의 적용범위**

**(1) 변론주의의 적용범위**

- 변론주의는 원칙적으로 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 사법상의 권리관계에 관한 소송에 적용된다.

**(2) 변론주의의 위반**

- 법원이 당사자가 주장하지 않은 주요사실을 근거로 판결하거나, 자백된 사실과 다른 사실을 인정하는 경우 변론주의 위반으로서 상소의 대상이 된다.

**4. 변론주의의 한계와 보완**

**(1) 변론주의의 한계**

- 당사자의 능력이 불충분하거나 소송수행 기술의 차이로 인해 진실 발견이 저해될 수 있다는 한계가 있다.

**(2) 변론주의의 보완**

- 법원은 석명권을 행사하여 불분명한 주장을 명확히 하고 누락된 사실을 지적함으로써 변론주의의 부작용을 보완한다. 또한, 지적의무를 통해 당사자가 예상치 못한 법률적 판단으로 불이익을 입지 않도록 한다.

**5. 변론주의의 예외**

**(1) 직권탐지주의**

- 가사소송이나 행정소송 중 일부 사안에서는 공익적 요청에 의해 법원이 직접 사실을 조사하고 증거를 수집하는 직권탐지주의가 적용된다.

**(2) 직권조사사항**

- 소송요건이나 법원의 관할 등 소송의 적법 여부에 관한 사항은 당사자의 주장 여부와 관계없이 법원이 직권으로 조사하여야 한다.

## 6. 석명권

### (1) 의의[민소법 제136조]

- 석명권이란 소송관계를 분명하게 하기 위하여 당사자에게 질문하거나 증명을 촉구하는 법원의 권한이자 의무이다.

### (2) 석명의무

- 단순한 권한을 넘어, 당사자의 주장이 모순되거나 불투명할 때 법원이 이를 바로잡지 않고 판결하는 것은 석명의무 위반으로 위법하다.

### (3) 석명의 범위

- 적극적 석명(새로운 주장 권유)은 원칙적으로 금지되나, 소송의 경과에 비추어 당사자가 실수로 빠뜨린 것이 명백한 경우에는 예외적으로 허용된다. 소극적 석명(주장의 명확화)은 널리 인정된다.

### (4) 석명의 대상

- 사실관계뿐만 아니라 법률적 관점에 대해서도 석명해야 한다. 특히, 당사자가 간과하고 있는 법률적 쟁점에 대해 의견 제출의 기회를 주는 법률적 사항에 관한 석명(지적의무)이 중요하다.

### (5) 석명권의 행사

- 재판장은 기일이나 기일 외에서 구술 또는 서면으로 석명권을 행사할 수 있다. 합의부의 경우에는 법관도 재판장에게 알리고 행사할 수 있다.

### (6) 석명처분

- 법원은 소송관계를 명확히 하기 위해 당사자 본인의 출석 명이나 문서 제출 명령 등 구체적인 처분을 할 수 있다(민소법 제140조).

## IV. 적시제출주의

### 1. 의의[민소법 제146조]

- 적시제출주의란 공격 또는 방어의 방법(사실주장 및 증거신청)을 소송의 진행 정도에 따라 적절한 시기에 제출해야 한다는 원칙이다. 이는 과거의 수시제출주의가 소송 지연의 수단으로 악용되는 것을 막기 위해 도입되었다.

### 2. 적시제출주의의 내용

#### (1) 재정기간제도

- 재판장이 특정 사실이나 증거를 제출할 기간을 정해주는 제도이다. 이 기간을 넘겨 제출한 자료는 원칙적으로 각하될 수 있다.

#### (2) 실기한 공격방어방법의 각하[민소법 제149조]

- 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 뒤늦게 제출한 공격방어방법이 소송의 완결을 지연시킨다고 판단될 경우, 법원은 이를 결정으로 각하할 수 있다. 이는 적시제출주의를 강제하는 가장 강력한 수단이다.

#### (3) 적시제출주의의 확보를 위한 기타의 수단

- 답변서 제출의무 부여, 변론준비절차를 통한 쟁점 정리, 증거조사의 집중 등이 적시제출주의를 실현하기 위한 구체적 방법들이다.

### 3. 적시제출주의의 예외

- 직권조사사항이나 법원이 직권으로 탐지해야 할 사항에 대해서는 적시제출주의가 적용되지 않는다. 또한, 기일의 실효 등으로 인하여 지연의 결과가 발생하지 않는 경우에도 각하할 수 없다.

## V. 결론

- 심리에 관한 제 원칙은 당사자의 자율성과 법원의 후견적 역할 사이의 균형을 맞추는 틀이다. 처분권주의와 변론주의가 당사자의 주도권을 보장한다면, 석명권과 적시제출주의는 소송의 적정성과 신속성을 확보하기 위한 법원의 개입과 통제 장치이다. 현대 민사소송법은 당사자의 실질적 평등을 위해 법원의 적극적인 석명과 지적의무를 강조하는 한편, 소송 경제를 위해 적시제출주의를 엄격히 적용하는 추세이다. 법원은 이러한 원칙들을 유기적으로 운용함으로써 당사자가 납득할 수 있는 공정한 절차 내에서 실체적 진실이 발견될 수 있도록 심리 전 과정을 세심하게 지휘해야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제3절 변론의 준비>

**I. 준비서면**

**1. 의의**

- 준비서면이란 당사자가 변론기일에서 진술하고자 하는 사항을 기일 전에 미리 작성하여 법원에 제출하는 서면을 의미한다. 이는 구술주의의 원칙을 보완하고, 상대방에게 방어 기회 제공하며, 법원이 심리 계획을 수립할 수 있도록 하여 변론의 집중과 신속을 도모하는 데 그 목적이 있다.

**2. 준비서면의 판단기준**

- 준비서면이 적법하게 제출되었는지, 그리고 그 내용이 소송자료로서 가치가 있는지는 해당 서면이 상대방에게 송달되었는지와 변론기일에서 실제로 진술되었는지를 기준으로 판단한다. 단순히 서면을 제출한 것만으로는 소송자료가 되지 않으며, 기일에서의 진술(또는 진술간주) 절차를 거쳐야 비로소 판결의 기초가 될 수 있다.

**3. 준비서면의 기재사항**

- 준비서면에는 당사자의 성명·주소, 사건번호, 공격 또는 방어의 방법(사실상의 주장 및 증거신청), 상대방의 주장에 대한 답변 등을 기재하여야 한다. 특히, 복잡한 사건의 경우 사실관계를 항목별로 구분하여 정리하고, 관련 증거물과의 연관성을 명시함으로써 법원의 이해를 돕도록 작성하는 것이 권장된다.

**4. 준비서면의 제출·교환**

**(1) 제출 시기**

- 준비서면은 상대방이 준비하는 데 필요한 기간을 두고 미리 제출하여야 한다. 민사소송법은 적시제출주의를 실현하기 위해 재판장이 제출 기한을 정할 수 있도록 규정하고 있다.

**(2) 교환 방식**

- 준비서면은 법원에 제출함과 동시에 상대방에게도 그 부분이 송달되어야 한다. 전자소송의 경우 전자망을 통해 즉시 교환되나, 종이 소송의 경우 법원을 경유하여 송달되는 것이 원칙이다.

**5. 준비서면의 제출·부제출의 효과**

**(1) 준비서면의 제출의 효과**

**① 진술간주**

- 당사자가 기일에 출석하지 아니하더라도 미리 제출한 준비서면이 있으면 이를 진술한 것으로 간주할 수 있어 절차의 단절을 막을 수 있다.

**② 상대방의 방어권 보장**

- 준비서면에 기재되지 아니한 사실은 상대방이 출석하지 아니한 기일에서 주장하지 못하는 것이 원칙이므로, 상대방의 불측의 손해를 방지한다.

**(2) 준비서면의 부제출의 효과**

**① 실기한 공격방어방법의 각하**

- 준비서면을 기한 내에 제출하지 않아 소송이 지연될 경우, 법원은 이를 각하할 수 있다.

**② 불이익한 사실인정**

- 상대방의 주장에 대하여 적절한 시기에 준비서면으로 반박하지 않으면, 해당 사실을 자백한 것으로 간주(자백간주)될 위험이 있다.

**II. 변론준비절차**

**1. 의의**

- 변론준비절차란 변론기일에 앞서 당사자의 주장과 증거를 정리하여 변론이 집중적이고 효율적으로 이루어질 수 있도록 하는 예비적 절차이다. 서면에 의한 준비절차와 변론준비기일에 의한 절차로 구분된다.

**2. 변론준비절차의 진행**

**(1) 회부**

- 재판장은 사건의 내용이 복잡하여 쟁점 정리가 필요하다고 판단되는 경우 사건을 변론준비절차에 회부한다.

**(2) 서면 준비절차**

- 당사자 간에 준비서면을 수차례 교환하게 하여 쟁점을 좁히는 단계이다. 법원은 필요한 경우 당사자에게 특정 사항에 대한 소명을 요구할 수 있다.

**(3) 변론준비기일**

- 서면 교환만으로 쟁점이 정리되지 않는 경우, 법원은 변론준비기일을 열어 당사자를 직접 대면하고 쟁점과 증거를 확정한다. 이 기일은 원칙적으로 비공개로 진행될 수 있어 자유로운 의견 교환이 가능하다.

**3. 변론준비절차의 종결**

**(1) 종결의 원인**

**① 쟁점 및 증거의 정리 완료**

- 당사자의 주장과 증거가 충분히 정리되어 변론기일로 이행할 준비가 된 경우이다.

**② 절차의 지연**

- 당사자가 준비에 협조하지 않아 절차가 불필요하게 지연될 경우 재판장은 이를 종결하고 변론기일을 지정할 수 있다.

**(2) 종결의 효과**

**① 실권효의 발생**

- 변론준비절차에서 제출하지 아니한 공격방어방법은 변론기일에서 원칙적으로 제출할 수 없다. 다만, 절차 중에 제출하지 못한 데에 상당한 이유가 있거나 법원이 직권으로 조사할 사항인 경우에는 예외적으로 허용된다.

**② 집중심리의 토대 마련**

- 준비절차에서 정리된 결과는 변론준비기일 결과조서에 기재되며, 이후의 변론기일은 이 조서를 바탕으로 핵심 쟁점에 대해서만 집중적으로 심리하게 된다.

**III. 결론**

- 변론의 준비는 현대 민사소송이 지향하는 집중심리주의를 구현하기 위한 필수적인 단계이다. 준비서면을 통한 사전 정보 교환은 당사자 간의 공방을 날카롭게 닦아 법정에서의 혼란을 최소화하며, 변론준비절차는 복잡한 사건의 실태를 미리 풀어 변론의 효율성을 극대화한다. 특히 변론준비절차

종결 후의 실권효는 당사자에게 성실한 준비 의무를 부과하여 소송 경제를 도모하는 강력한 기제가 된다. 법원은 이러한 준비 절차들을 유연하면서도 엄격하게 운영함으로써, 변론기일이 단순한 주장 반복의 장이 아닌 실질적인 증거조사와 진실 발견의 장이 될 수 있도록 지휘하여야 할 것이다.



**I. 변론의 내용**

**1. 본안의 신청**

**(1) 의의**

- 본안의 신청이란 당사자가 법원에 대하여 어떠한 내용의 판결을 구하는가를 명시하는 의사표시이다. 원고의 경우 소장에 기재된 청구취지를 진술함으로써 본안의 신청을 하며, 이는 심판의 대상과 범위를 확정하는 기초가 된다.

**(2) 상대방의 태도 - 반대신청**

- 피고는 원고의 본안 신청에 대응하여 '원고의 청구를 기각한다'라는 내용의 반대신청을 한다. 이는 원고의 청구가 이유 없음을 주장하며 자신에게 유리한 판결을 구하는 적극적인 소송행위이다.

**2. 공격방어방법**

**(1) 의의**

- 공격방어방법이란 당사자가 자신의 본안 신청을 뒷받침하기 위해 제출하는 일체의 소송자료를 의미한다. 원고가 청구를 근거 짓기 위해 제출하는 자료는 공격방법이라 하고, 피고가 청구를 배척하기 위해 제출하는 자료는 방어방법이라 한다. 사실의 주장, 법률적 견해의 개진, 증거의 신청 등이 이에 포함된다.

**(2) 주장**

- 당사자는 자신에게 유리한 법률효과를 발생시키는 기초 사실을 주장하여야 한다. 변론주의 원칙상 법원은 당사자가 주장하지 않은 주요사실을 판결의 기초로 삼을 수 없으므로, 적절한 시기에 명확한 사실주장을 하는 것이 중요하다.

**3. 증거신청**

**(1) 의의**

- 증거신청이란 다툼이 있는 사실의 존부를 확정하기 위하여 법원에 증거조사를 요구하는 행위이다. 증인신문, 감정, 서증의 제출, 검증 신청 등이 대표적이다.

**(2) 상대방의 태도**

- 상대방은 증거신청에 대하여 증거능력이나 증거력을 다투거나, 반대증거를 신청함으로써 대응한다. 또한 서증의 경우 인부(인정·부인) 절차를 통해 해당 문서의 진정성립 여부를 밝히게 된다.

**4. 항변**

**(1) 항변의 의의**

- 항변이란 상대방의 주장 사실을 인정하면서도, 그 사실에 의한 법률효과를 배제하기 위해 별개의 사실을 주장하는 방어방법이다.

**(2) 소송상의 항변**

- 본안 판결을 막기 위해 소송요건의 흠결을 주장하는 것이다. 관할 위반의 항변, 중복소제기의 항변 등이 이에 해당하며, 이는 소송판결을 구하는 방어수단이다.

**(3) 본안의 항변**

- 원고의 청구가 실체법상 이유 없게 만드는 사실을 주장하는 것이다. 소멸시효의 완성, 변제, 상계, 정지조건의 미성취 등이 전형적인 본안의 항변이다.

**5. 부인과 항변의 구별**

**(1) 부인과 항변의 의의**

- 부인이란 상대방이 주장하는 사실 자체를 부정하는 것이고, 항변은 상대방의 사실은 인정하되 새로운 사실을 추가하여 효과를 뒤집는 것이다.

**(2) 부인과 항변의 구별**

- 부인은 상대방이 주장하는 사실의 부존재를 주장하는 것이므로 증명책임이 상대방(원고)에게 그대로 남는다. 반면, 항변은 새로운 사실을 도입하는 것이므로 그 항변 사실에 대한 증명책임은 항변자(피고)가 부담한다.

**(3) 간접부인과 항변의 구별**

- 간접부인이란 상대방의 주장 사실과 양립할 수 없는 별개의 사실을 주장함으로써 결과적으로 상대방의 주장을 부정하는 것이다. 이는 사실의 부정이라는 점에서 부인의 일종이며, 증명책임이 전환되지 않는다는 점에서 항변과 구별된다.

**(4) 구별의 실익**

- 가장 큰 실익은 증명책임의 소재에 있다. 당사자의 주장이 부인인지 항변인지에 따라 어느 쪽이 입증에 실패했을 때 불이익을 받을지가 결정되기 때문이다.

**6. 소송상 형성권의 행사**

**(1) 의의**

- 소송 계속 중에 상계, 해제, 취소와 같은 실체법상 형성권을 행사하는 것을 의미한다.

**(2) 학설**

- 사법행위설(실체법상 효과 중시), 소송행위설(소송절차 내의 효과 중시), 병존설(양 성질을 모두 가짐) 등이 대립한다.

**(3) 판례**

- 판례는 원칙적으로 소송상 형성권 행사를 사법상 행위와 소송행위가 결합된 형태로 보며, 소송이 취하되거나 각하되면 형성권 행사의 실체법적 효과도 소멸한다고 보는 병존설 중 소송적 효과를 중시하는 입장에 가깝다.

**(4) 검토**

- 절차의 안정성과 실체적 정의를 조화시키기 위해서는 소송상 형성권 행사의 운명을 소송 절차의 운명과 결합시키는 것이 타당하다.

**7. 상계항변에 대한 재항변의 가부**

**(1) 문제점**

- 피고가 상계의 항변을 했을 때, 원고가 다시 그 자동채권에 대해 소멸시효 완성 등의 사유로 재항변을 할 수 있는지가 문제된다.

**(2) 소송상 상계의 재항변 허용 여부**

- 판례는 원고가 피고의 자동채권에 대하여 별도의 채권을 가지고 다시 상계하는 상계의 재항변은 원칙적으로 금지한다. 이는 심리를 지나치게 복잡하게 하고 중복제소의 위험이 있기 때문이다. 다만, 피고의 자동채권이 이미 소멸했다는 등의 일반적인 재항변은 당연히 허용된다.

## II. 소송행위

### 1. 소송행위의 의미

- 소송행위란 소송절차를 구성하고 판결의 기초가 되는 효과를 발생시키는 법원과 당사자의 행위를 말한다. 주로 당사자의 행위를 지칭하며, 실체법상의 법률행위와 달리 절차적 확실성을 강조한다.

### 2. 소송상 합의★

#### (1) 소송상 합의의 의미

- 당사자 간의 합의로 소송법상의 효과를 발생시키는 것을 말한다.

#### (2) 소송상 합의의 허용 여부

- 강행법규에 반하지 않는 범위 내에서 허용된다. 관할 합의, 상소권 포기 합의 등은 법률이 명시적으로 허용하고 있다.

#### (3) 소송상 합의의 방식

- 원칙적으로 명시적이어야 하며, 법원에 제출된 서면이나 변론조서에 기재됨으로써 효력이 발생한다.

#### (4) 소송상 합의가 미치는 범위

- 합의의 당사자뿐만 아니라 그 승계인에게도 효력이 미치는 경우가 많다. 다만, 제3자의 절차적 권리를 침해하는 합의는 무효이다.

#### (5) 개별적 검토

- 부제소 특약(소를 제기하지 않기로 하는 합의)은 특정 법률관계에 한정되고 당사자가 처분할 수 있는 권리라면 유효하다.

### 3. 소송행위의 의사표시의 하자과 철회

#### (1) 의사표시의 하자과 소송행위의 취소

- 실체법상의 착오, 사기, 강박에 의한 취소 규정은 소송행위에 원칙적으로 적용되지 않는다. 소송절차의 외관과 안정성을 중시하기 때문이다. 다만, 형사상 처벌받을 타인의 행위로 인한 경우 등 극히 예외적인 경우에만 취소가 인정된다.

#### (2) 소송행위의 철회의 자유

- 소송행위는 상대방에게 기득권이 생기기 전이나 법원의 판단이 내려지기 전까지는 원칙적으로 철회할 수 있다. 예를 들어 자백의 경우 상대방의 동의가 있거나 착오에 의한 것임을 증명하면 철회가 가능하다.

#### (3) 소송행위의 효력을 다투는 방법

- 소송행위의 무효나 취소는 당해 소송절차 내에서 주장하여야 하며, 별개의 소로써 다투는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

### 4. 소송행위의 하자과 치유

#### (1) 소송행위의 하자

- 방식의 위배, 대리권의 흠결, 기간의 도과 등이 소송행위의 하자가 된다.

#### (2) 하자의 치유

- 무효인 소송행위라 하더라도 사후에 추인하거나, 상대방이 책문권을 상실(이의를 제기하지 않음)함으로써 유효하게 될 수 있다. 특히 임의규정 위반의 경우 책문권 상실에 의한 하자 치유가 빈번하게 일어난다.

## III. 결론

- 변론은 당사자의 주장과 방어수단이 격돌하는 동적인 과정이며, 그 안에서 행해지는 소송행위들은 실체법과는 다른 독자적인 논리에 의해 지배된다. 부인과 항변의 정확한 구별은 증명책임의 분배를 결정짓는 핵심이며, 소송상 형성권 행사는 사법적 권리와 소송적 절차의 접점을 보여준다. 법원은 소송행위의 하자를 엄격히 관리하면서도 당사자의 진정한 의사가 재판에 반영될 수 있도록 석명권을 행사하고 절차를 유연하게 운영하여야 한다. 특히, 소송절차의 안정성을 위해 소송행위의 철회나 취소를 제한하는 법리는 당사자의 절차적 기본권과 충돌할 수 있으므로, 구체적 사안에서 형평에 맞는 세밀한 해석이 요구된다.

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제5절 변론의 실시>

**I. 변론의 경과**

**1. 변론의 개시와 상정**

- 변론기일이 도래하면 재판장은 사건을 호명하여 당사자의 출석 여부를 확인하고 변론을 개시한다. 당사자가 출석한 경우 양쪽 당사자는 본안의 신청을 진술하며, 이는 소장이나 답변서의 기재 내용을 구술로 확인하는 방식으로 이루어진다.

**2. 당사자의 진술 및 공방**

- 당사자는 준비서면에 기재된 내용을 바탕으로 공격방어방법을 진술한다. 사실상의 주장, 법률적 견해의 제시, 상대방 주장에 대한 답변 등이 구술로 교환되며, 재판장은 이를 토대로 쟁점을 명확히 한다. 변론은 원칙적으로 공개되어야 하며, 구술주의와 직접주의가 지배한다.

**3. 증거조사의 실시**

- 주장에 대한 다툼이 있는 경우 법원은 증거조사를 실시한다. 증인신문, 서증의 조사, 검증 등이 기일 중에 진행되며, 법원은 직접 보고 들은 증거자료를 바탕으로 심증을 형성한다.

**4. 변론의 종결**

- 더 이상 제출할 공격방어방법이 없고 증거조사가 완료된 경우 재판장은 변론을 종결한다. 변론이 종결되면 법원은 판결 선고 기일을 지정하며, 종결 후에는 원칙적으로 새로운 자료를 제출할 수 없다.

**II. 변론의 정리**

**1. 변론의 제한**

- 법원은 소송상태에 따라 변론을 특정 쟁점이나 특정 당사자 간의 관계로 한정할 수 있다. 이는 복잡한 사건에서 심리의 혼란을 방지하고 쟁점별로 집중적인 심리를 가능하게 한다.

**2. 변론의 분리**

- 하나의 소송절차 내에 여러 개의 청구(병합소송)나 여러 명의 당사자(공동소송)가 있는 경우, 법원은 심리의 편의를 위해 이를 분리하여 별도의 절차로 진행할 수 있다. 분리된 변론은 각각 독립적으로 종결될 수 있으며 일부판결의 대상이 된다.

**3. 변론의 병합**

- 서로 관련 있는 여러 개의 사건이 별개로 진행되고 있을 때, 심리의 중복을 피하고 판결의 모순을 방지하기 위해 법원은 이를 하나의 절차로 합쳐서 진행할 수 있다. 병합된 사건은 동일한 증거조사 결과를 공유하게 된다.

**4. 변론의 재개**

- 변론이 종결된 후라도 법원이 판결을 내리기에 불충분하다고 판단하거나 당사자가 증대한 새로운 자료를 발견한 경우, 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 의해 종결된 변론을 다시 열 수 있다. 이는 실체적 진실 발견을 위해 허용되는 예외적 조치이다.

**III. 변론조서**

**1. 의의 및 성격**

- 변론조서란 변론기일의 경과를 법원사무관 등이 기록한 공문서이다. 변론의 절차적 적법성을 증명하고 판결의 기초가 된 소송행위를 확인하는 공식적인 수단이 된다.

**2. 기재사항**

- 변론조서에는 기일과 장소, 법관·사무관·당사자의 성명, 변론의 공개 여부, 본안의 신청, 사실상의 주장, 증거의 신청과 조사 결과, 재판장의 선고 및 고지 사항 등을 기재하여야 한다. 쟁점 정리를 위해 필요한 경우 당사자의 구체적인 진술 내용을 상세히 기록하기도 한다.

**3. 조서의 증명력**

- 변론의 방식에 관한 규정이 준수되었는지 여부는 오직 변론조서에 의해서만 증명할 수 있다. 이를 변론조서의 배타적 증명력이라 하며, 조서에 기재되지 않은 절차는 행해지지 않은 것으로, 조서에 기재된 절차는 그대로 행해진 것으로 확정된다.

**4. 조서에 대한 이의와 경정**

- 당사자는 조서의 기재 내용에 대해 이의를 제기할 수 있다. 법원은 이의가 이유 있다고 판단될 경우 조서를 경정하며, 이의를 기재하도록 규정되어 있다. 이는 조서의 객관성을 담보하기 위한 장치이다.

**IV. 결론**

- 변론의 실시는 민사소송 절차 중 당사자의 공방이 실질적으로 이루어지는 핵심 단계이다. 변론의 경과를 통해 심판의 대상이 구체화되고, 변론의 정리를 통해 복잡한 쟁점이 체계적으로 관리된다. 특히, 변론조서는 이러한 역동적인 과정에 법적 안정성과 증명력을 부여하는 필수적인 기록이다. 현대 소송에서는 구술주의를 실질화하기 위해 조서 작성을 간소화하는 대신 녹음이나 속기 방식을 병행하기도 하지만, 조서가 지니는 배타적 증명력의 원칙은 변함없이 절차적 정의의 근간을 이룬다. 법원은 변론의 전 과정을 충실히 실시하고 이를 조서에 정확히 담아냄으로써, 판결의 정당성을 확보하고 상급심에서의 사후 검토가 가능하도록 보장하여야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제6절 변론기일에서의 당사자의 결석>

**I. 당사자 결석의 요건**

**1. 필요적 변론기일일 것**

- 당사자 결석의 효과가 발생하기 위해서는 원칙적으로 판결을 내리기 위해 반드시 열어야 하는 필요적 변론기일이여야 한다. 임의적 변론기일이나 변론준비기일 외의 단순한 사무 처리 기일 등에서는 민사소송법이 정한 결석의 일반적 효과가 발생하지 않는다.

**2. 적법한 기일통지를 받고도 불출석할 것**

- 당사자가 기일에 출석하지 않은 것이 법적 의미를 가지려면 해당 당사자에게 기일통지서가 적법하게 송달되었어야 한다. 송달이 부적법하거나 기일 지정에 오류가 있는 경우에는 불출석하더라도 결석의 효과를 귀속시킬 수 없다.

**3. 불출석하거나 출석하여도 변론하지 않을 것**

- 물리적으로 법정에 나타나지 않는 불출석뿐만 아니라, 법정에 출석하였더라도 사건 호명 시에 아무런 변론을 하지 않고 침묵하거나 변론을 거부하는 출석 무변론의 경우도 결석과 동일하게 취급한다. 이는 당사자가 소송 절차에 협조하지 않음으로써 발생하는 지연을 방지하기 위함이다.

**II. 당사자 쌍방의 결석**

**1. 의의[민소법 제268조]**

- 양쪽 당사자가 모두 적법한 통지를 받고도 기일에 출석하지 않거나 출석하여도 변론하지 않는 경우를 의미한다. 이를 쌍방 불출석 또는 쌍방 결석이라 하며, 소송의 진행 의사가 없는 것으로 간주하여 일정한 요건 하에 소 취하의 효과를 발생시킨다.

**2. 취하간주의 요건**

**(1) 1회 쌍방 불출석**

- 최초로 양 당사자가 불출석하면 법원은 다시 기일을 정하여 통지한다.

**(2) 2회 쌍방 불출석**

- 다시 정한 기일(또는 다음 기일)에도 양 당사자가 불출석하면 소송은 정지 상태에 놓인다.

**(3) 1월 이내 기일지정신청의 부존재**

- 2회 쌍방 불출석 후 1개월 이내에 어느 당사자도 기일지정신청을 하지 않거나, 기일지정신청에 의해 정해진 기일에 다시 양쪽이 불출석한 경우 소가 취하된 것으로 본다. 이를 취하간주라 한다.

**3. 취하간주의 효과**

- 취하간주의 요건이 충족되면 별도의 재판이나 선고 없이 법률상 당연히 소송이 종료된다. 이는 소 취하와 동일한 효력을 가지므로 해당 소송절차는 소급적으로 소멸한다. 다만, 본안에 대한 중국판결이 있을 후에 취하간주가 된 경우에는 재소금지의 원칙이 적용되어 동일한 소를 다시 제기할 수 없다.

**4. 변론준비기일에서의 쌍방 불출석의 효과가 변론기일에 승계되는지 여부**

- 변론준비기일에서의 쌍방 불출석 횟수와 변론기일에서의 불출석 횟수는 원칙적으로 합산되지 않는다. 즉, 변론준비절차에서의 태만은 해당 절차 내에서만 평가되어야 하며, 이를 변론기일의 불출석 횟수에 산입하여 취하간주의 효과를 발생시킬 수는 없다는 것이 통설적 견해이다.

**III. 당사자 일방의 결석**

**1. 의의**

- 한쪽 당사자는 출석하여 변론 준비를 마쳤으나, 상대방이 적법한 기일통지를 받고도 출석하지 않거나 변론하지 않는 경우를 말한다. 소송 절차의 공전(空轉)을 막기 위해 불출석한 당사자에게 일정한 불이익을 주어 절차를 진행한다.

**2. 진술간주[민소법 제148조]**

**(1) 내용**

- 출석하지 아니한 당사자가 미리 제출한 소장, 답변서 또는 준비서면이 있는 경우, 출석한 상대방이 변론을 하면 불출석한 당사자가 그 서면의 내용을 진술한 것으로 본다.

**(2) 취지**

- 구술주의 원칙에 의하면 기일에 진술하지 않은 서면은 소송자료가 될 수 없으나, 일방 결석 시 무조건 기일을 연기하면 소송이 무한정 지연될 수 있으므로 서면에 의한 진술을 의제하여 절차의 신속을 기하는 것이다.

**(3) 요건 및 한계**

- 서면이 제출되어 있어야 하며, 서면에 기재되지 않은 새로운 사실은 출석하지 않은 당사자에게 불리하게 주장될 수 없다. 또한, 공시송달에 의한 기일통지의 경우에도 적용되나, 이 경우 아래의 자백간주 규정과는 차이가 있다.

**3. 자백간주[민소법 제150조, 제276조]**

**(1) 내용**

- 당사자가 상대방의 주장 사실을 명백히 다투지 아니하거나 기일에 출석하지 아니한 경우, 그 사실을 자백한 것으로 보는 제도이다. 불출석한 당사자가 답변서나 준비서면조차 제출하지 않은 경우에 주로 발생한다.

**(2) 공시송달과의 관계**

- 기일통지가 공시송달에 의하여 이루어진 경우에는 자백간주의 규정이 적용되지 않는다. 공시송달은 당사자가 실제로 기일을 알지 못할 가능성이 크기 때문에, 단순히 불출석했다는 이유만으로 상대방의 주장을 인정한 것으로 간주하는 것은 가혹하기 때문이다.

**(3) 효과**

- 자백간주가 성립하면 법원은 증거조사 없이 해당 사실을 판결의 기초로 삼아야 한다. 이는 불출석한 당사자에게 매우 치명적인 불이익이 되므로, 소송대리인이 없는 당사자는 기일 준수에 주의를 기울여야 한다.

**IV. 결론**

- 변론기일에서의 당사자 결석에 관한 규정은 소송의 경제와 신속을 도모하고 당사자의 성실한 소송수행을 강제하기 위한 장치이다. 쌍방 결석 시의 취하간주는 소송 의사의 포기를 법률적으로 확정하여 불필요한 절차의 존속을 막으며, 일방 결석 시의 진술간주와 자백간주는 소송의 공전을 방지하여 출석한 당사자의 권리를 보호한다. 특히, 자백간주와 취하간주는 당사자의 실체법적 권리에 중대한 영향을 미치므로 법원은 기일통지의 적법성을 엄격히 심사하여야 한다. 한편으로 공시송달의 경우 자백간주를 배제하는 등의 보완책은 절차적 정의와 효율성 사이의 균형을 맞추려는 입법적 배려로 이해된다.

다. 당사자는 자신의 권리를 방어하기 위해 제출한 서면의 내용을 명확히 하고, 정해진 기일에 출석하여 변론함으로써 이러한 불이익을 예방하여야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제7절 기일·기간 및 송달>

**I. 기일**

- 기일이란 법원, 당사자 기타 소송관계인이 회합하여 소송절차를 진행하기 위해 정해진 시간적 시점을 의미한다. 기일은 재판장이나 수명법관, 수탁법관이 지정하며, 합의부 사건의 경우에도 재판장이 지정하는 것이 원칙이다. 기일은 원칙적으로 법원 안에서 진행되나, 필요한 경우 법원 밖에서도 열 수 있다. 기일의 지정은 직권에 의하는 것이 원칙이나 당사자의 신청에 의해서도 가능하다. 기일은 통지서의 송달이나 기일 고지 등을 통해 당사자에게 알려야 하며, 적법한 통지 없이는 기일 불출석의 불이익을 과할 수 없다.

**II. 기간**

**1. 의의**

- 기간이란 소송절차에서 어떠한 소송행위를 하거나 법적 효과를 유지하기 위해 정해진 시간적 계속을 의미한다. 기간은 절차의 신속한 진행과 법적 안정성을 확보하기 위해 설정된다.

**2. 법정기간**

**(1) 의의**

- 법률에 의해 그 길이가 직접 정해져 있는 기간을 말한다.

**(2) 유형**

- 상소 제기 기간, 재심 제기 기간 등이 이에 해당하며, 법원은 이를 임의로 늘리거나 줄일 수 없는 것이 원칙이다.

**3. 재정기간**

**(1) 의의**

- 법원이나 재판장이 재량에 따라 정하는 기간을 의미한다.

**(2) 유형**

- 준비서면 제출 기한이나 보정 기간 등이 이에 속하며, 법원은 상황에 따라 이를 연장하거나 단축할 수 있다.

**3. 불변기간**

**(1) 의의**

- 법정기간 중에서도 특히 법률에 의해 불변임이 명시된 기간을 말한다. 이는 당사자의 합의나 법원의 결정으로도 연장할 수 없는 엄격한 기간이다.

**(2) 유형**

- 항소 기간(2주), 상고 기간(2주), 항고 기간, 재심 제기 기간 등이 대표적인 불변기간이다. 다만, 당사자가 책임질 수 없는 사유로 이를 준수하지 못한 경우에는 아래에서 다루는 추후보완이 허용된다.

**III. 기간의 부준수와 소송행위의 추후보완**

**1. 의의[민소법 제173조]**

- 당사자가 그 책임질 수 없는 사유로 인하여 불변기간을 지킬 수 없었던 경우, 그 사유가 없어진 후 일정한 기간 내에 게을리한 소송행위를 보완하여 수행할 수 있도록 하는 구제제도이다.

**2. 소송행위의 추후보완의 요건**

**(1) 추후보완사유**

- 당사자가 책임질 수 없는 사유가 있어야 한다. 이는 당사자가 통상의 주의를 다하였음에도 불구하고 기간을 준수할 수 없었던 객관적 사정을 의미한다. 판례는 천재지변뿐만 아니라, 공시송달에 의하여 판결이 송달되어 당사자가 판결 사실을 알지 못한 경우 등도 이에 포함시킨다.

**(2) 추후보완대상 - 불변기간**

- 추후보완은 오직 불변기간에 대해서만 인정된다. 법정기간 중 불변기간이 아닌 것이나 재정기간의 부준수에 대해서는 이 규정이 적용되지 않는다.

**(3) 추후보완기간**

- 사유가 없어진 날부터 2주 이내에 보완하여야 한다. 다만, 그 사유가 없어진 때에 외국에 있는 당사자의 경우에는 그 기간을 30일로 한다.

**3. 추후보완의 절차**

**(1) 서면신청**

- 추후보완은 게을리한 소송행위(예 : 항소장 제출)와 함께 추후보완 신청서를 작성하여 제출하는 방식으로 이루어진다.

**(2) 항소를 추완항소로 보는 경우**

- 당사자가 판결 송달 사실을 뒤늦게 알고 항소장을 제출하면서 별도의 추완 신청을 하지 않았더라도, 그 취지가 불변기간 도과에 대한 구제를 구하는 것이라면 법원은 이를 추완항소로 선해하여 판단한다.

**(3) 추완항소를 항소로 보는 경우**

- 반대로 기간 내에 적법하게 항소가 제기되었음에도 당사자가 추완 신청 형식을 빌린 경우에는 이를 통상의 항소로 취급한다.

**4. 추후보완의 효과**

**(1) 형식적 확정력과 판결의 집행정지**

- 추후보완 신청이 제기되더라도 이미 발생한 판결의 형식적 확정력이나 집행력이 당연히 정지되는 것은 아니다. 따라서 집행을 정지시키기 위해서는 별도의 강제집행정지 신청을 하여야 한다.

**(2) 심급의 이익과 반소제기**

- 추후보완에 의해 상급심 절차가 개시되면 당사자는 해당 심급에서의 소송상 권리를 온전히 행사할 수 있다. 다만, 반소 제기 등은 심급의 이익을 해치지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용될 수 있다.

**5. 추후보완상소와 재심의 소와의 관계**

**(1) 구제방법의 선택**

- 공시송달에 의해 판결이 확정된 경우 당사자는 추완항소와 재심의 소를 선택할 수 있다. 일반적으로 상소 절차를 통한 구제가 우선시된다.

**(2) 구제방법의 차이**

- 추완상소는 판결의 당부 자체를 다투는 것이고, 재심은 확정된 판결에 중대한 흠이 있음을 이유로 그 취소를 구하는 것이다. 양자는 요건과 제척기간 등에서 차이가 있으므로 당사자에게 유리한 절차를 선택하여야 한다.

## **IV. 송달**

### **1. 의의**

- 송달이란 소송절차의 공정성과 방어권 보장을 위하여 법원이 소송 당사자나 이해관계인에게 소송상의 서류 내용을 알 수 있는 기회를 부여하고 이를 공증하는 행위를 의미한다.

### **2. 송달기간 및 송달서류[민소법 제175조, 제176조]**

#### **(1) 송달사무담당기관**

- 송달에 관한 사무는 법원사무관 등이 담당한다.

#### **(2) 송달실시기관**

- 실제로 송달을 수행하는 기관은 우편집배원, 법원소속 집행관 등이 있다.

#### **(3) 송달서류**

- 소장 부분, 답변서 부분, 준비서면, 판결서 정본, 기일통지서 등이 주요 송달 대상이다.

### **3. 송달받을 사람**

- 송달은 원칙적으로 당사자 본인이나 법정대리인, 소송대리인에게 하여야 한다. 법인인 경우에는 그 대표자에게 송달한다.

### **4. 송달실시의 방법**

#### **(1) 교부송달[민소법 제178조, 제183조]**

- 송달받을 사람에게 직접 서류를 교부하는 방식이다. 이는 송달의 원칙적 방법이다.

#### **(2) 보충송달[민소법 제186조]**

- 송달받을 사람을 만나지 못한 경우 그 사무원, 피용자 또는 동거인으로서 사리를 분별할 지능이 있는 사람에게 서류를 교부하는 방식이다.

#### **(3) 유치송달[민소법 제186조]**

- 송달받을 사람이 정당한 사유 없이 송달받기를 거부하는 경우, 그 장소에 서류를 놓아둠으로써 송달의 효력을 발생시키는 방식이다.

#### **(4) 우편송달**

- 교부송달 등이 불가능한 경우 서류를 등기우편으로 발송하고, 발송한 때에 송달된 것으로 간주하는 방식이다.

### **5. 공시송달[민소법 제194조]**

#### **(1) 공시송달의 의의**

- 당사자의 주소나 소재를 알 수 없는 경우, 법원 게시판에 게시하거나 관보 등에 게재하여 일정한 기간이 지나면 송달된 것으로 간주하는 제도이다.

#### **(2) 공시송달의 요건**

- 당사자의 주소, 거소 기타 송달할 장소를 알 수 없는 경우여야 하며, 송달받을 사람이 외국에 있어 다른 송달 방법이 불가능한 경우에도 인정된다.

#### **(3) 공시송달의 절차**

- 당사자의 신청 또는 법원의 직권으로 실시한다. 법원사무관이 서류를 보관하고 그 사유를 게시판에 게시한다.

#### **(4) 공시송달의 효력**

- 첫 공시송달은 게시한 날부터 2주(외국은 2월)가 지나면 효력이 발생한다. 같은 당사자에 대한 이후의 공시송달은 게시한 다음 날부터 바로 효력이 발생한다.

### **6. 송달의 하자과 치유**

#### **(1) 송달의 하자**

- 송달권한이 없는 자에 의한 송달, 송달장소의 오기, 보충송달 요건 불비 등이 하자가 된다.

#### **(2) 하자의 치유**

- 송달에 하자가 있더라도 당사자가 그 서류를 실제로 수령하여 소송행위를 한 경우나, 책문권을 상실한 경우에는 하자가 치유되어 유효한 송달로 간주된다.

## **V. 결론**

- 기일·기간 및 송달에 관한 규정은 민사소송 절차의 질서와 안정성을 유지하는 근간이다. 특히, 불변기간의 엄격한 준수는 소송의 신속을 기하는 장치이나, 이로 인해 발생할 수 있는 당사자의 억울한 피해를 방지하기 위해 추후보완제도가 마련되어 있다. 송달은 당사자에게 절차 참여의 기회를 보장하는 핵심적인 절차로, 공시송달과 같은 간주 제도는 재판권 행사의 공백을 막는 동시에 당사자의 방어권을 침해할 위험이 공존한다. 따라서 법원은 송달의 적법성을 면밀히 심사하고, 하자가 발견된 경우 이를 적극적으로 시정하거나 추후보완을 통해 실질적인 재판을 받을 권리를 보장하여야 한다. 이러한 절차적 세부 규정들이 엄격히 운용될 때 비로소 민사소송의 신뢰성이 확보될 수 있다.

### <제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제8절 소송절차의 정지>

#### **I. 소송절차의 정지의 의의 및 종류**

- 소송절차의 정지란 소송이 계속되는 동안 일정한 법정 사유의 발생으로 인하여 절차의 진행이 법률상 당연히 멈추거나, 법원의 결정에 의하여 멈추게 되는 상태를 말한다. 소송절차의 정지는 크게 중단과 중지로 구분된다. 중단은 당사자 측에 소송을 수행할 수 없는 사유가 발생한 경우 새로운 수행자가 나타나 절차를 이어받을 때까지 당연히 정지되는 상태를 의미한다. 반면, 중지는 법원이나 당사자의 외부적 장애로 인하여 사실상 소송을 진행하기 어려운 경우에 법률의 규정 또는 법원의 결정에 의하여 절차가 멈추는 것을 의미한다.

#### **II. 소송절차의 중단**

##### **1. 의의**

- 중단이란 당사자나 그 법정대리인에게 소송수행을 불가능하게 하는 사유가 발생하였을 때, 그를 대신하여 소송을 수행할 사람이 정해질 때까지 법률상 당연히 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다. 이는 당사자의 소송수행권과 방어권을 보호하고, 부적격한 상태에서의 소송행위로 인하여 당사자가 불이익을 입는 것을 방지하기 위한 제도이다.

##### **2. 중단사유**

###### **(1) 당사자의 사망[민소법 제233조]**

- 소송계속 중 당사자가 사망하면 소송절차는 중단된다. 이때 소송을 이어받을 상속인, 상속재산관리인 또는 법률에 의하여 소송을 계속할 사람이 수계할 때까지 중단 상태가 유지된다. 다만, 해당 소송관계가 당사자 본인에게만 한정되는 전속적 권리인 경우에는 소송이 종료되며 중단의 문제가 발생하지 않는다.

###### **(2) 법인의 합병[민소법 제234조]**

- 당사자인 법인이 합병에 의하여 소멸한 경우 소송절차는 중단된다. 합병 후 설립된 법인이나 합병 후 존속하는 법인이 소송을 수계하여야 한다.

###### **(3) 소송능력의 상실, 법정대리권의 소멸로 인한 중단[민소법 제235조]**

- 당사자가 소송능력을 상실하거나, 법정대리인이 사망하거나 대리권을 상실한 경우 소송절차는 중단된다. 새로운 법정대리인이 선임되거나 당사자가 소송능력을 회복하여 소송을 수계할 때까지 절차는 멈춘다.

###### **(4) 자격상실로 인한 중단[민소법 제237조]**

- 일정한 자격에 기하여 남을 위하여 소송당사자가 된 사람이 그 자격을 상실하거나 사망한 경우 절차가 중단된다. 파산관재인이 자격을 상실한 경우나 유언집행자가 사망한 경우 등이 이에 해당하며, 새로 자격을 갖춘 승계인이 소송을 수계하여야 한다.

##### **3. 중단의 예외**

###### **(1) 소송대리인이 있는 경우[민소법 제238조]**

- 당사자에게 선임된 소송대리인이 있는 경우에는 위와 같은 중단사유가 발생하더라도 소송절차는 중단되지 않는다. 소송대리인의 대리권은 당사자의 사망이나 소송능력 상실 등에 의하여 소멸하지 않기 때문이다. 이는 소송절차의 원활한 진행과 상대방 당사자의 이익을 보호하기 위한 예외 규정이 다.

###### **(2) 상소의 특별수권이 없는 경우(판결정본 송달시 중단)**

- 소송대리인이 있으나 상소 제기에 관한 특별수권이 없는 경우, 당해 심급의 판결 정본이 소송대리인에게 송달된 때에 비로소 소송절차가 중단된다. 판결 송달로 인하여 해당 심급의 대리권이 종료되기 때문이다.

###### **(3) 상소의 특별수권이 있는 경우(상소제기시 중단)**

- 상소 제기의 특별수권이 있는 대리인이 상소를 제기한 경우에는 상소심에 사건이 계속된 이후에 대리인이 선임되지 않은 상태라면 비로소 절차가 중단될 수 있다. 즉, 특별수권에 의하여 상소 제기 행위까지는 유효하게 진행되나 그 이후의 절차는 수행자가 확정되어야 한다.

##### **4. 중단의 해소**

###### **(1) 수계신청**

- 소송절차가 중단된 경우 새로운 소송수행 권한을 가진 자(상속인, 합병 후 법인 등) 또는 상대방 당사자가 법원에 소송절차를 계속하겠다는 의사를 표시하는 것을 수계신청라 한다. 법원은 수계신청이 있으면 상대방에게 이를 통지하고, 수계할 자격이 있는지 조사하여 결정한다.

###### **(2) 속행명령**

- 당사자가 수계신청을 게을리하는 경우 법원은 직권으로 소송절차를 진행하도록 명령할 수 있다. 이를 속행명령이라 하며, 법원은 수계할 자에게 일정한 기간 내에 소송을 계속할 것을 명함으로써 절차의 지연을 막는다.

##### **5. 중단의 효과**

###### **(1) 중단 중 소송행위 가부와 효력**

- 소송절차가 중단된 동안에는 원칙적으로 법원과 당사자 모두 소송행위를 할 수 없다. 중단 중에 행해진 소송행위는 무효이나, 나중에 수계인이 이를 추진하면 유효하게 될 수 있다. 다만, 판결의 선고는 중단 사유가 발생한 이후라도 변론이 종결된 상태라면 가능하다.

###### **(2) 중단을 간과한 판결의 효력**

- 법원이 중단 사유를 알지 못하고 판결을 내린 경우, 그 판결은 당연히 무효는 아니며 대리권 없는 자에 의하여 소송이 진행된 것과 유사한 하자가 있는 판결이 된다. 따라서 상소 또는 재심의 소에 의하여 취소를 구할 수 있다. 판례에 따르면 당사자가 사망하였음에도 이를 간과하고 판결이 내려진 경우 상속인들이 그 판결의 효력을 다투는 방법으로 구제받을 수 있다.

#### **III. 소송절차의 중지**

- 중지란 법률상 또는 사실상의 장애로 인하여 법원이나 당사자가 소송을 진행할 수 없는 상태를 의미한다. 중지는 중단과 달리 당사자의 소송수행능력과 무관하게 발생한다. 당연중지는 천재지변 등으로 법원이 직무를 수행할 수 없게 된 경우 법률 규정에 의하여 당연히 발생하는 것이며, 재판중지는 법원의 결정에 의하여 절차를 멈추는 것이다. 예를 들어 제권판결 절차가 진행 중이거나 다른 재판의 결과가 본 소송의 전제가 되는 경우 법원은 재량으로 소송절차를 중지할 수 있다.

#### **IV. 결론**

- 소송절차의 정지는 당사자의 절차적 권리를 보호하고 실체적 진실 발견을 위한 기초를 마련하는 중요한 장치이다. 특히, 중단 제도는 당사자의 급작스러운 지위 변화에 대응하여 새로운 적격자가 소송을 수행하게 함으로써 판결의 정당성을 확보한다. 소송대리인이 있는 경우 중단을 배제하는 예외 규정은 절차의 경제성과 효율성을 도모하는 측면이 강하다. 법원은 중단 사유의 발생 여부를 엄격히 관리하여 중단을 간과한 판결이 나오지 않도록 주의하



여야 하며, 당사자 역시 수계 절차를 신속히 밟아 소송 지연을 방지하여야 한다. 결국 소송절차의 정지와 해소 과정은 공정한 재판을 받을 권리와 신속한 재판을 받을 권리 사이의 조화를 추구하는 과정이라 할 수 있다.

### <제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제1절 증거의 총설>

#### I. 증거의 의의

##### 1. 개념

- 증거란 재판에서 사실인정의 근거가 되는 자료를 의미한다. 민사소송에서 법원은 당사자 사이에 다툼이 있는 사실에 대하여 판단을 내려야 하며, 이때 판단의 기초가 되는 지식이나 자료를 증거라고 한다. 증거는 넓은 의미에서 증거방법과 증거자료, 증거원인을 모두 포괄하는 개념이다. 증거방법은 법원이 그 내용을 조사하기 위하여 대하는 유체물을 의미하며, 증인·감정인·문서·검증물 등이 이에 해당한다. 증거자료는 증거방법을 조사하여 얻은 내용, 즉 증인의 증언이나 감정 결과 등을 뜻한다. 증거원인은 법원이 증거조사를 통해 얻은 확신이나 심증을 말한다.

##### 2. 필요성

- 재판은 법적 효과를 발생시키는 요건사실의 존부를 확정하는 과정이다. 당사자가 주장하는 사실에 대하여 상대방이 다투지 않는 경우에는 증거가 필요 없으나, 사실관계에 관하여 다툼이 있는 경우에는 법관이 객관적인 근거 없이 판결을 내릴 수 없다. 따라서 법관이 합리적인 확신을 가지고 사실을 인정하기 위해서는 증거가 반드시 필요하다. 이는 자의적인 재판을 방지하고 판결의 객관성과 신뢰성을 확보하기 위한 법치주의적 요청이기도 하다. 만약 증거에 의하여 사실이 확정되지 않는다면 법원은 입증책임의 원칙에 따라 판결할 수밖에 없으므로, 당사자 입장에서 자신의 주장을 관철하기 위해 증거 제시는 필수적이다.

#### II. 증거능력과 증거력

##### 1. 증거능력

- 증거능력이란 특정 증거방법이 법정의 증거조사 절차에 사용될 수 있는 법률상 자격을 의미한다. 민사소송법은 형사소송법과 달리 자유심증주의를 채택하고 있으므로 증거능력에 대한 제한이 매우 완화되어 있다. 즉, 원칙적으로 모든 증거방법은 증거능력이 인정된다. 다만, 신의칙에 반하여 위법하게 수집된 증거의 경우 그 증거능력이 부정될 수 있다는 논의가 존재한다. 예를 들어 도청이나 비밀 녹취와 같은 위법 수집 증거에 대해 판례는 그 증거능력을 원칙적으로 인정하면서도, 인격권 침해의 정도와 진실 발견이라는 공익을 비교衡量하여 개별적으로 판단하고 있다.

##### 2. 증거력

- 증거력이란 법관이 증거조사를 마친 후 그 증거자료를 통해 사실의 존부에 대하여 얻게 된 확신의 정도, 즉 증거의 실질적 가치를 의미한다. 이를 증거의 가치 또는 신빙성이라고도 한다. 증거력의 판단은 전적으로 법관의 자유로운 판단에 맡겨져 있으며, 이를 자유심증주의라고 한다. 법관은 증인이나 문서의 내용을 종합적으로 검토하여 어느 정도의 무게를 둘 것인지를 결정한다. 증거능력이 증거가 법정에 들어올 수 있는 문턱이라면, 증거력은 그 문턱을 넘은 증거가 판결에 얼마나 영향을 미치는가의 문제이다.

#### III. 증거의 종류

##### 1. 본증과 반증

- 본증은 입증책임을 지는 당사자가 자기의 주장사실을 확정하기 위해 제출하는 증거를 의미한다. 반면, 반증은 본증에 의해 인정되는 사실을 부정하기 위하여 상대방이 제출하는 증거를 말한다. 본증은 법관으로 하여금 확신을 갖게 해야 하지만, 반증은 본증에 의한 법관의 확신을 흔들어 불명의 상태로 만드는 것만으로도 그 목적을 달성한다. 즉, 반증은 본증이 주장하는 사실이 진실이 아닐지도 모른다는 의심을 불러일으키는 것만으로 충분하다.

##### 2. 직접증거와 간접증거

- 직접증거는 요건사실인 주된 사실의 존부를 직접 증명하는 증거를 의미한다. 예를 들어 계약의 성립 여부가 쟁점일 때 해당 계약서나 계약 체결을 직접 목격한 증인의 증언이 이에 해당한다. 간접증거는 요건사실을 직접 증명하지는 않지만, 요건사실의 존부를 추인하게 하는 사실(간접사실)을 증명하는 증거를 말한다. 대여금 소송에서 차용증은 없으나 돈을 송금한 영수증이나 돈을 빌려달라고 요청했던 문자 메시지 등은 간접증거가 된다. 현대 소송에서는 직접증거가 없는 경우가 많으므로 여러 간접증거를 종합하여 사실을 추론하는 방식이 빈번하게 사용된다.

#### IV. 증명과 소명

##### 1. 증명

- 증명이란 법관이 사실의 존부에 관하여 확신을 얻은 상태, 또는 그러한 상태에 이르도록 증거를 제시하는 활동을 의미한다. 민사재판에서 증명은 고도의 개연성을 필요로 한다. 즉, 통상적인 사람이 의심을 품지 않을 정도의 확신이 있어야 사실로 인정된다. 만약 법관이 확신에 이르지 못하고 진위 불명의 상태에 머문다면 입증책임의 분배 원칙에 따라 해당 사실이 없는 것으로 간주되어 판결이 내려진다.

##### 2. 소명

- 소명이란 증명보다 낮은 단계의 확신을 의미한다. 즉, 법관이 일단 그럴 것이라고 추측할 수 있는 정도의 상태를 말한다. 소명은 주로 신속성을 요하는 가압류, 가처분과 같은 결정 절차나 소송절차상의 부수적 사항을 신청할 때 요구된다. 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거방법에 한정되는 것이 원칙이며, 증명에 비해 입증의 정도가 완화되어 있다. 법률에서 '소명하여야 한다'고 규정한 경우에는 증명에 준하는 엄격한 확신까지는 필요하지 않다.

#### V. 결론

- 증거는 재판의 승패를 결정짓는 가장 핵심적인 요소로서, 법치주의에 입각한 공정한 사실확정의 토대가 된다. 증거능력의 개방성과 증거력의 자유로운 심증 형성을 특징으로 하는 현대 민사소송법은 법관의 합리적인 재량을 존중하면서도, 본증과 반증의 대립 및 직접·간접증거의 조화를 통해 실체적 진실에 다가가고자 한다. 당사자는 자신이 주장하는 바에 따라 증명과 소명의 단계를 명확히 구분하여 적절한 증거방법을 제시해야 하며, 법원은 제출된 증거자료를 신중히 검토하여 정의로운 판결을 내려야 한다. 결국 증거법의 원리는 절차적 정당성을 유지하면서도 구체적 타당성을 확보하기 위한 법적 장치로서 그 의의를 지닌다.

### <제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제2절 증명의 대상>

#### **I. 사실**

##### **1. 의의**

- 증명의 대상이란 재판의 기초가 되는 요건사실의 존부를 확정하기 위하여 증거조사를 필요로 하는 대상을 의미한다. 민사소송에서 증명의 가장 주된 대상은 사실이다. 여기서 말하는 사실은 구체적인 권리나 법률관계의 발생·변경·소멸이라는 법률효과를 가져오는 법률요건에 해당하는 사실을 뜻한다.

##### **2. 주요사실**

- 주요사실은 법률효과를 일으키는 법규의 구성요건에 직접 해당하는 사실을 의미하며, 이를 요건사실이라고도 한다. 변론주의 원칙상 당사자가 주장하지 않은 주요사실을 법원이 판결의 기초로 삼을 수 없으므로, 당사자 사이에 다툼이 있는 주요사실은 반드시 증명의 대상이 된다. 예를 들어 대여금 반환청구 소송에서 돈을 빌려준 사실(금전소비대차계약의 체결), 돈을 전달한 사실, 변제기가 도래한 사실 등이 주요사실에 해당한다.

##### **3. 간접사실**

- 간접사실은 주요사실의 존부를 추인하게 하는 사실을 의미한다. 주요사실을 직접 증명할 수 있는 증거가 없는 경우, 여러 가지 간접사실을 증명함으로써 경험법칙을 통해 주요사실을 추정하게 된다. 간접사실은 변론주의의 적용을 받지 않으므로 당사자의 주장이 없더라도 법원이 증거자료를 통해 인정할 수 있으나, 주요사실의 존부를 판단하기 위한 기초 자료로서 여전히 증명의 대상에 포함된다.

##### **4. 보조사실**

- 보조사실은 증거방법의 신용력에 영향을 미치는 사실을 말한다. 증인의 증언이 믿을만한 것인지(성실성, 지각능력 등) 혹은 문서의 진위 여부와 관련된 사실 등이 보조사실이다. 보조사실 역시 법관의 심증 형성에 중요한 역할을 하므로 다툼이 있는 경우 증명의 대상이 된다.

##### **5. 증명이 불필요한 사실**

- 모든 사실이 증명의 대상이 되는 것은 아니다. 민사소송법은 재판의 신속과 효율을 위하여 특정 사실들에 대해서는 증명책임을 면제한다. 첫째, 재판상 자백이 성립한 사실이다. 당사자가 자기에게 불리한 사실을 시인하고 상대방이 이를 원용하면 그 사실은 다툼이 없는 것으로 간주되어 증명이 필요 없다. 둘째, 자백간주 사실이다. 상대방의 주장 사실에 대하여 다투지 않거나 기일에 출석하지 않은 경우 자백한 것으로 보아 증명을 생략한다. 셋째, 현저한 사실이다. 법관이 직무상 알고 있거나 일반 사회 통념상 명백한 사실은 증거조사 없이 판결의 기초로 삼을 수 있다.

#### **II. 경험법칙**

##### **1. 의의**

- 경험법칙이란 인간의 경험에서 얻어진 사물의 이치, 법칙, 공통된 판단의 기준을 의미한다. 구체적인 사실을 인정하거나 법률적 판단을 내릴 때 전제가 되는 일반적인 지식 체계이다. 경험법칙은 일반적인 상식 수준의 것부터 고도의 전문적 지식을 필요로 하는 것까지 그 범위가 매우 넓다.

##### **2. 증명의 여부**

- 경험법칙은 원칙적으로 증명의 대상이 아니다. 일반적인 경험법칙은 법관이 직권으로 알 수 있는 것으로 간주되기 때문이다. 법관은 별도의 증거조사 없이도 일상적인 사물의 이치를 재판에 적용할 수 있다. 그러나 예외적으로 전문적인 학술, 기술, 특수한 직업적 분야의 경험법칙으로서 일반인이 알기 어려운 경우에는 증명의 대상이 된다. 이때 법원은 감정이나 조회 등의 증거조사 절차를 거쳐 해당 경험법칙을 확인하게 된다.

##### **3. 경험법칙 위반과 상고이유**

- 경험법칙은 사실인정의 단계에서 가교 역할을 수행한다. 법관이 사실인정을 함에 있어 논리와 경험의 법칙에 반하여 채증법칙을 위반하였다면 이는 단순한 사실오인을 넘어 법령 위반의 문제가 된다. 따라서 대법원은 사실오인을 사유로 하는 상고는 제한하되, 경험법칙에 위반한 사실인정은 법률적 판단의 오류로 보아 상고이유로 허용하고 있다. 이는 법관의 자유심증주의가 자의적으로 행사되는 것을 방지하기 위한 통제 장치로서의 의미를 갖는다.

#### **III. 법규**

##### **1. 의의**

- 법규란 재판의 기준이 되는 법률 조항이나 성문법령을 의미한다. 재판의 기본 원칙인 법관은 법을 안다는 원칙에 따라, 국내의 성문법이나 일반적으로 알려진 관습법은 증명의 대상이 되지 않는다. 법관은 직권으로 법령을 찾아 적용할 의무가 있기 때문이다.

##### **2. 증명이 필요한 법규**

- 국내법임에도 불구하고 증명이 필요한 예외적인 경우가 존재한다. 지방자치단체의 조례나 규칙 등은 법관이 모든 내용을 알기 어려우므로 당사자가 그 존재를 제출하거나 입증해야 하는 경우가 있다. 또한, 특수한 분야의 관습법 역시 그 존재가 명백하지 않을 때는 당사자의 입증이 필요하다.

##### **3. 외국법의 취급**

- 외국법은 원칙적으로 법규이지만 실무상 사실과 유사하게 취급된다. 법관이 모든 외국의 법령을 알 수는 없기 때문이다. 따라서 외국법의 존재와 내용은 당사자가 증거에 의하여 입증해야 하는 것이 원칙이다. 다만, 법원은 직권으로 외국법의 내용을 조사할 수 있으며, 당사자의 입증이 불가능하거나 불충분할 경우에도 법관이 가능한 수단을 동원하여 그 내용을 확정해야 한다.

##### **4. 자치법규와 정관**

- 법인이 정한 정관이나 사적 단체의 규약 등은 엄밀한 의미의 법규라기보다는 사실의 영역에 가깝다. 따라서 이러한 자치적 규정들은 당사자가 증거(문서 등)를 제출하여 그 내용을 증명해야만 재판의 기초로 삼을 수 있다.

#### **IV. 결론**

- 증명의 대상에 관한 논의는 소송 절차에서 무엇을 증거로 확정해야 하는가의 경계를 설정하는 중요한 작업이다. 사실관계는 변론주의의 원칙에 따라 당사자의 증명 활동이 중심이 되며, 경험법칙과 법규는 원칙적으로 법관의 직권 영역에 속하나 전문성이나 특수성에 따라 예외적으로 증명의 대상이 된다. 특히, 현대 소송에서는 의료, 환경, 지식재산권 등 고도의 전문적 경험법칙이 요구되는 분야가 확대됨에 따라 감정 등을 통한 경험법칙의 증명 중요성이 더욱 커지고 있다. 법원은 증명의 대상이 되는 사실과 법률 영역을 엄격히 구분하면서도, 진실 발견을 위해 필요한 경우 적절한 증거조사 절차를 안내하고 협력할 의무가 있다. 결론적으로 증명의 대상을 명확히 확정하는 것은 재판의 효율성을 높이고 불필요한 쟁점 확산을 방지하여 사법 정의를 실현하는 필수적인 전제 조건이라 할 수 있다.

### <제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제3절 불요증사실>

#### I. 의의[민소법 제288조]

- 불요증사실이란 법원이 판결의 기초가 되는 사실을 인정함에 있어서 증거조사를 거칠 필요가 없는 사실을 의미한다. 민소소송법 제288조 본문은 법원에서 당사자가 자백한 사실과 현저한 사실은 증명을 필요로 하지 아니한다.라고 규정하여 불요증사실의 범위를 명시하고 있다. 이는 변론주의 원칙에 따라 당사자 사이에 다툼이 없는 사실에 대하여 불필요한 증거조사를 생략함으로써 심리의 신속과 경제를 도모하기 위함이다. 또한, 법관이 이미 확신을 가지고 있는 현저한 사실에 대하여 다시 증명을 요구하는 것은 무의미하다는 실무적 판단이 반영된 것이다.

#### II. 재판상 자백

##### 1. 재판상 자백의 의의

- 재판상 자백이란 소송의 계속 중에 당사자가 자기에게 불리한 사실을 시인하는 진술을 말한다. 이는 상대방의 주장과 일치하는 진술이어야 하며, 변론기일 또는 변론준비기일에 행해져야 한다. 자백이 성립하면 그 사실은 법원을 구속하며, 법원은 증거조사 없이 이를 판결의 기초로 삼아야 한다.

##### 2. 재판상 자백의 요건

###### (1) 소송의 계속 중 변론 또는 변론준비기일에서의 진술

- 자백은 반드시 해당 소송 절차 내(변론 또는 변론준비기일)에서 행해져야 한다. 소송 외에서 행한 자백은 재판상 자백으로서의 구속력이 없으며, 단지 하나의 증거자료가 될 뿐이다.

###### (2) 상대방의 주장과 일치하는 사실에 관한 진술

- 상대방이 주장하는 사실과 부합해야 한다. 만약 상대방이 주장하지 않은 사실을 스스로 진술한다면 이는 선행자백이 되며, 나중에 상대방이 이를 원용함으로써 자백의 효력이 발생한다.

###### (3) 자기에게 불리한 사실의 진술

- 자기에게 불리한 사실이란 상대방이 증명책임을 지는 사실을 의미하는 것이 통설의 입장이다. 즉, 상대방이 주장하는 권리관계의 발생·변경·소멸의 요건사실 중 자신에게 불리한 결과를 초래하는 사실을 인정하는 것이다.

###### (4) 구체적인 사실에 관한 진술

- 자백의 대상은 사실에 한정된다. 법률 적용이나 법적 가치 판단은 법원의 전권 사항이므로 자백의 대상이 될 수 없다. 다만, 권리자백(소유권의 인정 등)은 원칙적으로 자백으로서의 효력이 없으나, 예외적으로 요건사실을 포함하는 경우에는 그 범위 내에서 효력을 가질 수 있다.

##### 3. 재판상 자백의 효력

###### (1) 심판대상에서의 제외(증명책임의 면제)

- 자백이 성립한 사실은 불요증사실이 되므로 더 이상 증거조사를 할 수 없다. 법원은 자백된 사실과 반대되는 사실을 인정할 수 없다.

###### (2) 법원에 대한 구속력

- 법원은 당사자가 자백한 사실에 구속되어 이를 그대로 판결의 기초로 삼아야 한다. 설령 법관이 심증적으로 그 사실이 허위라고 믿더라도 자백과 다른 판단을 내릴 수 없다.

###### (3) 당사자에 대한 구속력(철회의 제한)

- 자백을 한 당사자는 임의로 이를 철회할 수 없는 것이 원칙이다. 다만, 자백이 제3자의 형사상 처벌을 받을 만한 행위로 인하여 이루어졌거나, 자백이 객관적 진실에 반하고 착오에 의한 것임을 증명한 경우에는 예외적으로 철회가 허용된다.

#### III. 자백간주

##### 1. 자백간주의 의의

- 자백간주란 당사자가 명시적으로 자백하지는 않았으나, 소송상의 태도에 비추어 사실을 다투지 않는 것으로 보아 자백과 동일한 법적 효과를 부여하는 제도를 의미한다. 이는 불성실한 당사자에게 불이익을 주고 소송 절차의 지연을 방지하는 데 목적이 있다.

##### 2. 자백간주의 요건

###### (1) 명백히 다투지 않는 경우[제150조 제1항]

- 당사자가 변론에서 상대방이 주장하는 사실을 명백히 다투지 아니한 때에는 그 사실을 자백한 것으로 본다. 다만, 답변서 등으로 다투었거나 전체적인 변론의 취지로 보아 다투는 것으로 인정될 때는 제외된다.

###### (2) 한쪽 당사자의 기일 불출석[제150조 제3항]

- 당사자가 변론기일에 출석하지 아니하고 답변서나 그 밖의 준비서면도 제출하지 아니한 경우, 상대방이 주장한 사실을 자백한 것으로 간주한다. 다만, 공시송달에 의한 기일 통지의 경우에는 적용되지 않는다.

###### (3) 무변론 판결의 경우[제257조]

- 피고가 소장 부분을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하지 아니하거나, 제출하더라도 청구의 원인이 된 사실을 모두 자백하는 취지인 경우 법원은 변론 없이 판결할 수 있으며, 이때 피고는 청구 원인 사실을 자백한 것으로 간주된다.

##### 3. 자백간주의 효력

###### (1) 증명의 불필요

- 자백간주가 성립하면 재판상 자백과 마찬가지로 해당 사실은 증명을 필요로 하지 않는다.

###### (2) 구속력의 차이

- 재판상 자백과 달리 자백간주는 법원을 완전히 구속하지 않는다. 법원은 자백간주가 성립하더라도 다른 증거자료를 통하여 그와 반대되는 사실을 인정할 수 있는 재량을 가진다. 또한, 당사자는 사실심 변론종결 전까지 언제든지 상대방의 주장 사실을 다투으로써 자백간주의 효력을 소멸시킬 수 있다.

#### IV. 현저한 사실

##### 1. 현저한 사실의 의의

- 현저한 사실이란 법관이 이미 확실한 지식을 가지고 있어 증거조사를 통하여 그 존부를 확인할 필요가 없을 정도로 명백한 사실을 말한다. 현저한 사실은 증명을 필요로 하지 않으며, 법원은 이를 판결의 기초로 삼을 수 있다.

##### 2. 현저한 사실의 유형

###### (1) 공지의 사실

- 일반 사회 구성원이 보통의 지식과 경험에 의하여 의심 없이 알고 있는 사실을 의미한다. 역사적 사건, 대규모 자연재해, 널리 알려진 통계적 수치 등이 이에 해당한다. 단순히 특정 지역이나 소수의 전문가 집단만이 아는 사실은 공지의 사실이라 할 수 없다.

## **(2) 직무상 현저한 사실**

- 법관이 법원에서 직무를 수행하면서 알게 된 사실로서, 기록이나 과거의 경험을 통해 확신을 가지고 있는 사실이다. 해당 법원에서 이전에 선고된 확정판결의 내용이나 현재 계속 중인 다른 사건의 기록 등이 전형적인 예이다. 다만, 다른 법원의 기록은 직접적으로 직무상 현저한 사실이라 보기 어렵다.

## **3. 소송법적 효과**

### **(1) 증거조사의 불필요**

- 현저한 사실에 대해서는 당사자의 증거가 필요 없으며, 법원은 직권으로 이를 인정할 수 있다.

### **(2) 당사자의 원용 여부**

- 현저한 사실은 당사자가 주장하지 않더라도 법원이 직권으로 판결의 기초로 삼을 수 있다는 것이 다수설의 입장이다. 다만, 당사자의 예측하지 못한 타격을 방지하기 위해 법원은 해당 사실에 대해 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주는 것이 바람직하다.

### **(3) 증명력과 관계**

- 현저한 사실은 강한 증명력을 가지므로, 이에 반대되는 사실을 주장하는 당사자는 매우 엄격하고 확실한 증거를 제시하여야만 그 인정을 뒤집을 수 있다.

## **V. 결론**

- 민사소송법상 불요증사실 제도는 심리의 효율성과 법적 안정성을 조화시키는 핵심 기제이다. 재판상 자백은 당사자의 의사를 존중하여 심판 범위를 확정하고, 자백간주는 소송 참여의 성실성을 담보하며, 현저한 사실은 불필요한 증명 절차를 제거하여 실체적 진실에 신속히 접근하게 한다. 이러한 제도들은 변론주의의 근간을 이루는 동시에 법관의 자유심증주의를 합리적으로 제한하거나 보완하는 역할을 수행한다. 특히, 재판상 자백의 구속력은 당사자에게 자신의 진술에 책임감을 갖게 하며, 법원이 불필요한 사실 확정에 에너지를 소모하지 않도록 돕는다. 최근 정보통신기술의 발달로 현저한 사실의 범위가 정보 검색 등을 통해 확장될 가능성이 있으나, 법관은 여전히 객관성과 보편성을 기준으로 이를 엄격히 판단하여야 한다. 결국 불요증사실에 대한 명확한 이해와 적용은 신속하고 공정한 재판을 구현하기 위한 소송법적 대원칙의 실천이라 할 수 있다.

<제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제4절 증거조사의 개시와 실시>

**I. 증거조사의 개시**

**1. 증거신청**

**(1) 증거신청의 의의**

- 증거신청이란 당사자가 자기의 주장을 뒷받침하기 위하여 법원에 대하여 특정한 증거방법을 조사하여 줄 것을 요구하는 소송행위를 말한다. 변론주의가 적용되는 민사소송에서 증거조사는 원칙적으로 당사자의 신청에 의하여 개시된다.

**(2) 증거신청의 절차**

- 증거신청은 증명할 사실을 구체적으로 표시하여야 하며, 증거방법을 특정하여야 한다. 서증은 문서를 제출하거나 제시하는 방식, 증인은 성명과 주소를 기재하여 신청하는 방식 등을 취한다. 신청 시기는 변론준비기일이나 변론기일 등 적절한 시기에 행해져야 하며, 법원이 정한 기간 내에 제출하지 않으면 실기한 공격방어방법으로 각하될 수 있다.

**(3) 증거신청의 철회**

- 당사자는 신청한 증거를 법원이 채택하기 전이나 채택한 후라도 증거조사가 개시되기 전까지는 자유롭게 철회할 수 있다. 그러나 일단 증거조사가 시작되어 그 결과가 법관의 심증 형성에 영향을 미친 후에는 상대방의 동의 없이 함부로 철회할 수 없다는 것이 통설의 입장이다.

**2. 증거신청에 대한 채부결정**

**(1) 증거신청의 채부결정[민소법 제290조]**

- 법원은 당사자가 신청한 증거에 대하여 채택 여부를 결정할 권한을 가진다. 민사소송법 제290조 본문에 따라 법원은 당사자가 신청한 증거가 불필요하다고 인정되는 경우에는 이를 조사하지 아니할 수 있다. 다만, 사실인정에 결정적인 영향을 미치는 증거를 정당한 이유 없이 배척하는 것은 채증법칙 위반이 될 수 있다.

**(2) 유일한 증거**

- 당사자의 주장 사실을 증명할 수 있는 유일한 증거방법인 경우, 법원은 특별한 사정이 없는 한 이를 반드시 채택하여 조사하여야 한다. 이는 당사자의 증명권 보장과 실체적 진실 발견을 위한 예외적 강제 사항이다.

**(3) 증거결정**

- 법원이 증거신청을 받아들이는 것을 증거채택결정, 거부하는 것을 증거각하결정이라 한다. 증거결정은 판결 전의 소송절차에 관한 결정이므로 독립하여 상소할 수 없으며, 종국판결에 대한 상소로 다투어야 한다.

**3. 직권증거조사[민소법 제292조]**

- 민사소송법 제292조는 법원은 당사자가 신청한 증거에 의하여 심증을 얻을 수 없거나, 그 밖에 필요하다고 인정한 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 현대 소송에서 실질적 공평을 기하기 위한 변론주의의 보완책으로 활용된다.

**II. 증거조사의 실시**

**1. 의의**

- 증거조사의 실시란 채택된 증거방법을 통해 증거자료를 획득하는 구체적인 절차를 의미한다. 법원은 증거조사를 통해 사실인정의 기초가 되는 확신을 얻게 된다.

**2. 증인신문**

**(1) 의의**

- 증인신문이란 법원이 소송당사자 이외의 제3자로부터 그가 과거에 경험한 사실을 진술하게 하여 증거자료를 얻는 증거조사 방법이다.

**(2) 증인능력**

- 누구든지 증인이 될 수 있는 법률적 자격을 가진다. 유아나 정신지체인이라도 자기의 체험을 진술할 수 있는 지적 능력이 있다면 증인능력이 인정된다.

**(3) 증인의무**

- 모든 국민은 증인으로서 출석의무, 선서의무, 진술의무를 진다. 정당한 사유 없이 출석하지 않거나 진술을 거부할 경우 과태료나 감치 등의 제재를 받을 수 있다.

**(4) 증인조사방식**

- 원칙적으로 구술 신문 방식에 의하며, 증인이 법정에서 출석하여 신문에 응해야 한다. 다만, 예외적으로 서면에 의한 답변으로 갈음하는 것도 가능하다.

**(5) 증인신문방법[민소법 제327조]**

- 신문은 주신문, 반대신문, 재주신문 순서로 진행된다. 증인을 신청한 당사자가 먼저 주신문을 하고, 상대방이 반대신문을 통해 진술의 탄핵 및 유리한 사실을 이끌어낸다.

**(6) 유도신문**

- 주신문에서는 원칙적으로 유도신문이 금지되나, 반대신문에서는 증인의 기억을 환기시키거나 진술의 모순을 지적하기 위해 널리 허용된다.

**3. 감정**

**(1) 의의**

- 감정이란 법관의 판단 능력을 보충하기 위하여 특별한 학식이나 경험을 가진 자로부터 그 전문적 지식을 활용한 판단을 보고받는 증거조사 방법이다.

**(2) 감정결과의 증거력**

- 감정결과는 법원을 구속하지 않는 자유심증주의의 대상이다. 그러나 감정인의 판단이 논리적이고 객관적이라면 법원이 이를 합리적 이유 없이 배척하기는 어렵다.

**(3) 감정결과의 채택 여부**

- 법원은 감정결과가 미진하다고 판단될 경우 재감정을 명하거나 추가 설명을 요구할 수 있다.

**4. 당사자 신문[민소법 제367조, 제372조]**

**(1) 의의**

- 당사자 신문이란 법원이 당사자 본인을 신문하여 사실인정의 자료를 얻는 증거조사 방법이다. 법정대리인도 이에 준하여 취급된다.

## (2) 보충성의 폐지

- 과거에는 다른 증거방법이 없는 경우에만 예외적으로 허용되었으나, 현행법상 보충성이 폐지되어 다른 증거가 있더라도 언제든지 신청할 수 있다.

## (3) 당사자신문의 절차

- 증인신문 절차를 준용하며, 선서 후 신문이 이루어진다. 다만, 당사자는 증인과 달리 과태료 외에 진술 거부 시 주장 사실의 자백 간주라는 불이익을 받을 수 있다.

## (4) 당사자신문의 효과

- 신문 결과 얻어진 자료는 독립적인 증거원인이 되며 법관의 심증 형성 자료가 된다.

## (5) 관련 문제

- 공동소송인 중 1인에 대한 신문 결과가 다른 공동소송인에게 미치는 영향 등은 소송 형태에 따라 개별적으로 판단된다.

## 5. 서증

### (1) 서설

- 서증이란 문서를 읽어 그 기재 내용을 증거자료로 삼는 증거조사 방법이다. 민사재판에서 가장 비중이 큰 증거방법이다.

### (2) 문서의 증거능력

- 민사소송에서는 원칙적으로 문서의 증거능력에 제한이 없다. 사적인 서신이나 일기 등도 증거로 사용될 수 있다.

### (3) 문서의 증거력

- 문서가 작성자의 의사에 따라 진정하게 성립되었는가가 핵심이다. 특히, 처분문서(계약서 등)는 진정성립이 인정되면 그 기재 내용대로 법률행위의 존재를 인정해야 하는 강력한 증거력을 가진다.

### (4) 서증의 신청절차[민소법 제343조]

- 문서를 직접 제출하거나, 상대방 또는 제3자가 소지한 경우 문서제출명령을 신청하는 방식으로 행해진다.

## 6. 검증

### (1) 의의

- 검증이란 법관이 자신의 오관(눈, 코, 귀 등)의 작용에 의해 사물의 성상이나 현상을 직접 관찰하여 증거자료를 얻는 조사 방법이다.

### (2) 검증의 대상

- 동영상 파일, 부동산의 현황, 물건의 파손 부위, 인체의 상흔, 소리나 냄새 등 오관으로 지각할 수 있는 모든 유체물이 대상이 된다.

## 7. 증거보전

### (1) 증거보전의 의의

- 미리 증거조사를 해 두지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란한 사정이 있는 경우, 본안 소송의 개시 전이나 소송 중에 미리 증거조사를 하는 제도이다.

### (2) 증거보전의 요건

- 증거를 미리 조사하지 않으면 증거방법의 멸실, 훼손 또는 변경 등의 우려가 있어야 한다. 증인의 해외 출국이나 중병, 물건의 부패 가능성 등이 예시가 된다.

### (3) 증거보전의 절차

- 당사자의 신청에 의하며, 원칙적으로 해당 증거를 소지한 사람의 거소지나 물건 소재지 관할 법원에 신청한다.

### (4) 증거보전의 효력

- 보전된 증거조사 결과는 본안 소송에서 별도의 신청 없이도 증거자료로 사용될 수 있다. 다만, 당사자가 이를 변론에서 원용하여야 한다.

## Ⅲ. 결론

- 증거조사의 개시와 실시는 민사재판에서 실체적 진실을 규명하기 위한 핵심적인 과정이다. 증거신청과 채부결정이라는 입구 단계에서부터 증인, 서증, 감정 등 다양한 증거방법이 개별적 절차에 따라 실시되는 과정 전반은 법관의 합리적 심증 형성을 목적으로 한다. 특히, 서증 중심의 재판 실무 속에서도 증인신문이나 당사자신문의 적절한 운영은 사건의 이면에 숨겨진 진실을 파악하는 데 필수적이다. 또한, 증거보전 제도는 시간적 경과에 따른 증거인멸의 위험을 방지함으로써 당사자의 증명권을 실질적으로 보장한다. 법원은 각 증거방법의 특성을 고려하여 절차의 공정성을 유지하고, 당사자는 적절한 시기에 효과적인 증거방법을 제시함으로써 자신의 권리를 방어해야 한다. 이러한 유기적 협력을 통해 민사소송법이 지향하는 적정·신속·경제의 이념이 구현될 수 있다.

<제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제5절 자유심증주의>

**I. 의의[민소법 제202조]**

- 자유심증주의란 법원이 사실을 인정함에 있어서 증거방법의 선택과 증거력의 평가를 법관의 자유로운 판단에 맡기는 원칙을 말한다. 민사소송법 제202조는 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 사실주장이 진실한지 아닌지를 판단한다고 규정하고 있다. 이는 과거의 법정증거주의(증거의 가치를 법률로 미리 정해두는 방식)를 배격하고, 구체적 사안에 적합한 실체적 진실을 발견하기 위한 현대 소송법의 대원칙이다. 법관은 논리와 경험법칙에 반하지 않는 한 어떠한 증거에 의하여 사실을 인정할 것인가를 자유롭게 결정할 수 있다.

**II. 증거원인**

- 법관이 심증을 형성하는 기초가 되는 자료를 증거원인이라 하며, 민사소송법은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 그 요소로 명시하고 있다.

**1. 변론 전체의 취지**

**(1) 의의**

- 변론 전체의 취지란 증거조사의 결과를 제외하고 기일에서의 변론 과정에서 나타난 모든 자료와 상태를 의미한다. 여기에는 당사자의 주장 내용, 태도, 답변의 모순, 소송상의 거동, 상대방의 주장에 대한 침묵 등이 포함된다.

**(2) 독립된 증거원인 여부**

- 통설과 판례는 변론 전체의 취지가 증거조사의 결과와 결합하여 심증을 형성하는 자료가 될 뿐만 아니라, 증거조사 없이 변론 전체의 취지만으로도 사실인정을 할 수 있는 독립된 증거원인이 된다고 본다.

**(3) 활용 범위**

- 당사자가 서류의 존재를 시인하면서도 제출을 거부하는 경우나 신문 시 답변을 회피하는 경우 등을 참작하여 사실인정의 근거로 삼을 수 있다. 다만, 변론 전체의 취지만으로 주요사실을 인정하는 것에는 신증을 기해야 하며, 보충적인 자료로 활용하는 것이 일반적이다.

**2. 증거조사의 결과**

**(1) 의의**

- 증거조사의 결과란 증인신문, 서증, 감정, 검증, 당사자신문 등 법정 증거조사 절차를 통해 얻어진 증거자료를 말한다.

**(2) 증거력의 자유평가**

- 법관은 증인의 일부만을 믿고 일부를 배척할 수 있으며, 여러 명의 증인 중 한 명의 진술만을 채택할 수도 있다. 서증의 경우에도 해당 문서가 진정하게 성립되었다고 하더라도 그 기재 내용이 진실한지 여부는 법관의 자유로운 판단에 속한다.

**(3) 증거조사 결과의 종합**

- 법관은 개별적인 증거조사 결과를 파편적으로 보지 않고, 전체를 종합하여 모순 없는 하나의 사실관계를 재구성하게 된다. 이 과정에서 각 증거의 비중을 어떻게 둘 것인가는 전적으로 법관의 재량에 속한다.

**III. 자유심증의 정도**

- 자유로운 심증이라 하여 법관의 자의적인 판단이나 주관적인 추측을 허용하는 것은 아니다.

**1. 자의의 금지**

- 법관은 심증을 형성함에 있어서 논리법칙과 경험법칙에 따라야 한다. 논리법칙이란 사유의 타당한 형식을 의미하며, 경험법칙이란 인간이 경험을 통해 얻게 되는 일반적인 인과관계나 상관관계에 관한 지식을 말한다.

**(1) 경험법칙의 적용**

- 예를 들어 물건을 매수했다면 대금을 지급하는 것이 일반적인 경험법칙이다. 특별한 사정 없이 이와 반대되는 사실을 인정하려면 그에 합당한 구체적인 근거가 제시되어야 한다.

**(2) 위반의 효과**

- 논리법칙이나 경험법칙에 반하는 사실인정은 채증법칙 위반으로서 상고이유가 된다. 즉, 자유심증주의는 객관적 정당성을 담보할 수 있는 범위 내에서만 자유롭다.

**2. 사실인정에 필요한 확신의 정도**

- 사실인정에 있어 법관이 도달해야 하는 확신의 정도에 대하여 논란이 있으나, 민사소송에서는 고도의 개연성을 필요로 한다는 것이 통설적 견해이다.

**(1) 고도의 개연성**

- 반대 사실이 존재할 가능성을 완전히 배제할 수 있는 절대적 진실까지는 아니더라도, 보통 사람이라면 누구나 의심을 품지 않을 정도의 확신을 의미한다.

**(2) 증명책임과의 관계**

- 만약 증거조사를 거친 후에도 법관이 이러한 고도의 개연성에 도달하지 못하여 사실의 존부가 불분명한 상태(진위불명)에 빠진다면, 법관은 증명책임의 원칙에 따라 해당 사실이 존재하지 않는 것으로 취급하여 판결해야 한다.

**IV. 자유심증주의의 예외**

- 법률의 규정이나 당사자의 합의에 의해 법관의 자유로운 평가권이 제한되는 경우가 존재한다.

**1. 명문규정에 의한 예외**

**(1) 자백의 구속력**

- 당사자가 변론에서 상대방의 주장 사실을 시인하는 재판상 자백이 성립하면, 법원은 그 사실에 구속되어 증거조사 없이 이를 판결의 기초로 삼아야 한다. 이는 법관의 자유로운 사실인정권을 법률로 제한한 대표적인 사례이다.

**(2) 법률상의 추정**

- 어떤 사실(전제사실)이 증명되면 다른 사실(추정사실)이 존재하는 것으로 법률이 규정하고 있는 경우(점유자의 권리 적법 추정), 법관은 반증이 없는 한 추정사실을 인정해야 한다.

**(3) 문서의 진정성립 추정**



- 공문서는 그 형식과 취지에 비추어 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정될 때 진정한 것으로 추정하며, 사문서라도 본인이나 대리인의 날인이 있으면 진정한 것으로 추정된다.

**2. 증명방해**

**(1) 의의**

- 당사자 일방이 상대방의 증명을 곤란하게 할 목적으로 증거를 인멸하거나 사용을 방해하는 경우를 말한다.

**(2) 효과**

- 상대방이 문서제출명령에 따르지 않거나 증거를 훼손한 경우, 법원은 그 문서의 기재나 증거에 관한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(민소법 제350조). 이는 법관이 증거의 가치를 자유롭게 평가하는 것이 아니라, 방해 행위에 대한 제재로서 일정한 사실을 인정하게 되는 예외적 상황이다.

**3. 증거계약**

**(1) 의의**

- 당사자 사이에서 특정한 증거방법만을 사용하기로 하거나, 특정한 사실에 대해 증거력을 제한하기로 하는 합의를 의미한다.

**(2) 허용 여부**

- 변론주의 원칙상 원칙적으로 허용되나, 현저하게 불공정한 계약이나 법관의 사실인정권을 완전히 박탈하는 계약은 무효가 될 수 있다. 예를 들어 ‘서면 증거만으로 사실을 인정한다’는 식의 합의는 유효할 수 있으나, 법관에게 ‘거짓을 사실로 인정하라’고 강요하는 계약은 불가능하다.

**V. 자유심증주의의 한계**

- 자유심증주의는 법관에게 독점적인 사실인정 권한을 부여하는 것이 아니라, 객관적 자료를 바탕으로 가장 합리적인 결론에 도달하도록 촉구하는 원칙이다.

**1. 이유 기재의 의무**

- 법관은 판결서에 심증 형성의 과정을 합리적으로 설명해야 한다. 어떤 증거를 왜 믿었는지, 왜 배척했는지를 기재함으로써 당사자가 납득할 수 있도록 해야 하며, 이는 사후적 통제의 근거가 된다.

**2. 증거 공통의 원칙**

- 일단 증거조사가 이루어지면, 그 증거가 자신에게 유리하든 불리하든 법관은 이를 전체적으로 고려해야 한다. 당사자가 자신에게 유리한 부분만 취사선택하여 심증을 유도할 수 없으며, 법관 역시 제출된 증거 중 불리한 결과를 초래하는 자료를 임의로 무시할 수 없다.

**3. 심리미진의 금지**

- 법관이 충분한 증거조사를 하지 않은 채 단순히 자유심증을 내세워 사실관계를 단정 짓는 것은 허용되지 않는다. 가능한 범위 내에서 필요한 증거조사를 다하였음에도 불구하고 진위불명일 때에 비로소 증명책임에 따라 판단해야 한다.

**VI. 결론**

- 자유심증주의는 민사소송에서 실체적 진실을 발견하기 위한 법관의 고유한 권한이자 의무이다. 법정증거주의의 경직성을 탈피하여 사안의 구체적 타당성을 확보할 수 있게 하지만, 그 이면에는 논리법칙과 경험법칙이라는 엄격한 외부적 한계가 존재한다. 법관은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 종합하여 고도의 개연성 있는 확신에 도달해야 하며, 이 과정에서 자의를 배제하고 객관적인 근거를 판결문에 명시함으로써 재판의 신뢰성을 높여야 한다. 또한, 자백이나 법률상의 추정과 같은 예외적 상황을 정확히 인지하여 법적 안정성을 해치지 않는 범위 내에서 심증을 형성해야 한다. 결국 자유심증주의의 성공적인 운용은 법관의 합리적 이성과 법률적 양심에 달려 있으며, 이는 민사재판이 단순한 규칙의 적용을 넘어 정의로운 사실인정에 이르게 하는 핵심적인 동력이 된다.

<제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제6절 증명책임>

**I. 서설 - 증명책임의 의의**

**1. 개념**

- 증명책임이란 요건사실의 존부가 확정되지 않은 상태, 즉 진위불명의 상태로 인하여 판결에서 불이익을 입게 되는 당사자의 법률적 지위를 의미한다. 법관은 심리 결과 사실관계가 명확히 밝혀지지 않았더라도 재판을 거부할 수 없으므로, 증명책임의 원칙에 따라 그 사실이 존재하지 않는 것으로 취급하여 패소의 위험을 특정 당사자에게 부담시킨다. 이를 객관적 증명책임이라 하며, 소송 중 당사자가 패소의 위험을 피하기 위해 증거를 제출해야 하는 활동상의 의무인 주관적 증명책임과 구별된다.

**2. 구별**

**(1) 거증책임**

- 주관적 증명책임 혹은 거증책임은 소송의 진행 과정에서 당사자가 자기에게 유리한 심증을 형성하기 위해 증거를 제출하는 행위적 부담을 말한다. 이는 소송 도중 심증의 변화에 따라 당사자 간에 이동할 수 있다는 점에서 객관적 증명책임과 차이가 있다.

**(2) 본증과 반증**

- 본증은 증명책임을 지는 당사자가 그 사실의 확신을 주기 위해 제출하는 증거이며, 반증은 상대방이 그 확신을 흔들어 다시 진위불명의 상태로 되돌리기 위해 제출하는 증거를 의미한다. 반증은 진위불명 상태만 만들어도 목적을 달성하므로 본증과 같은 정도의 확신을 요구하지 않는다.

**II. 증명책임의 분배**

**1. 증명책임의 분배의 의의**

- 증명책임의 분배란 어떤 사실이 진위불명일 때 누가 패소의 불이익을 입을 것인가를 미리 정하는 기준을 말한다. 이는 재판의 예견가능성을 확보하고 법적 형평성을 유지하기 위해 매우 중요하다.

**2. 법률요건분류설의 내용과 비판**

**(1) 내용**

- 각 당사자는 자기에게 유리한 법률효과를 발생시키는 법률규정의 요건사실에 대하여 증명책임을 진다는 학설이다. 통설과 판례의 입장이다. 권리 발생사실은 권리 주장자가, 권리장해 · 권리소멸 · 권리저지사실은 그 상대방이 증명책임을 부담한다.

**(2) 비판**

- 법문의 규정 방식에 따라 증명책임이 결정되므로 입법자의 입법 기술에 지나치게 의존한다는 비판이 있다. 또한, 구체적 사안에서 증거의 거리나 증명의 곤란성 등을 고려하지 못하여 실질적 형평에 어긋날 수 있다는 지적이 존재한다.

**3. 증명책임의 분배에 대한 신설의 내용과 비판**

**(1) 내용**

- 법률요건분류설의 형식성을 극복하기 위해 등장한 견해들로, 증거거리설, 위험영역설, 증명곤란설 등이 있다. 증거에 접근하기 쉬운 자나 위험을 통제할 수 있는 영역 내에 있는 자가 증명책임을 져야 한다는 실질적 공평을 강조한다.

**(2) 비판**

- 기준이 다의적이고 모호하여 법관의 자의가 개입될 우려가 크며, 소송 전 단계에서 당사자가 누가 패소할지 예측하기 어렵게 만든다는 법적 안정성 측면의 비판을 받는다.

**III. 증명책임의 전환**

**1. 증명책임의 전환의 의의**

- 증명책임의 전환이란 원칙적인 분배 기준에 따르면 일방이 증명해야 할 사실을, 특정한 사정으로 인해 타방이 그 반대 사실을 증명하도록 책임을 바꾸는 것을 말한다. 이는 대등한 당사자 간의 실질적 무기대등을 보완하기 위한 장치이다.

**2. 증명책임의 전환의 유형**

**(1) 법률에 의한 전환**

- 법률이 명문으로 증명책임을 전환하는 경우이다. 민법 제759조(동물의 점유자의 책임) 등에서 점유자가 상당한 주의를 하였음을 증명하지 못하면 책임을 면할 수 없도록 규정한 것이 예이다.

**(2) 판례에 의한 전환**

- 제소물책임이나 의료소송, 환경오염 소송 등 증거의 편재가 심한 현대형 소송에서 판례는 해석을 통해 증명책임을 완화하거나 전환한다. 가해자 측에서 자기의 과실 없음을 증명하도록 유도하는 방식으로 운용된다.

**IV. 증명책임의 완화**

**1. 증명책임의 완화의 의의**

- 증명책임의 분배 자체를 바꾸지는 않되, 증명의 정도를 낮추어 주거나 간접사실을 통해 주요사실을 추단하게 함으로써 증명책임자의 부담을 덜어주는 기법이다.

**2. 법률상 추정**

- 법률에 규정된 전제사실이 증명되면 요건사실이 존재하는 것으로 법률이 인정하는 것이다. 이를 깨뜨리기 위해서는 상대방이 반대 사실을 증명해야 하므로 증명책임의 전환과 유사한 효과를 낸다.

**3. 일응의 추정**

- 표표적 증명이라고도 하며, 경험칙을 이용하여 특정 간접사실이 증명되면 그에 따른 주요사실을 추정하는 기법이다. 예를 들어 자동차가 보도를 침범하여 행인을 쳤다면 운전자의 과실이 일단 추정된다. 상대방은 경험칙의 적용을 배제할 만한 특수한 사정을 제시하여 이를 번복할 수 있다.

**4. 간접반증**

- 증명책임이 없는 상대방이 주요사실과 양립할 수 없는 별개의 간접사실을 증명함으로써, 본증에 의한 추인을 방해하는 방법이다. 이는 현대형 소송에서 원고의 증명 부담을 덜어주기 위해 피고 측에 반대 사실의 증명을 요구하는 형태로 자주 활용된다.

**V. 주장책임**

**1. 주장책임의 의의**

- 당사자가 자기에게 유리한 법률효과를 발생시키는 요건사실을 변론에서 주장하지 않으면, 그 사실이 없는 것으로 취급되어 법원이 판결의 기초로 삼을 수 없는 불이익을 말한다. 이는 변론주의 원칙의 당연한 결과이다.

## 2. 주장책임의 적용범위

- 주장책임은 원칙적으로 주요사실에 대해서만 적용된다. 간접사실이나 보조사실은 당사자의 명시적 주장이 없더라도 법원이 증거조사를 통해 인정할 수 있다. 다만, 취소권이나 해제권과 같은 형성권의 행사는 그 권리 행사의 의사표시가 있었다는 사실이 반드시 주장되어야 한다.

## 3. 주장책임의 분배

- 주장책임의 분배는 증명책임의 분배와 일치한다. 즉, 특정 사실에 대해 증명책임을 지는 당사자가 그 사실에 대한 주장책임도 함께 부담하는 것이 원칙이다. 이를 주장책임과 증명책임의 일치 원칙이라 한다.

## VI. 결론

- 증명책임은 현대 민사소송법에서 사법의 척도라 불릴 만큼 중추적인 역할을 수행한다. 진위불명의 상태에서 법관의 자의적 판단을 방지하고 당사자에게 공평한 패소 위험을 분배함으로써 재판의 객관성을 담보한다. 과거 법률요건분류설에 치중했던 엄격한 분배 원칙은 오늘날 현대형 소송의 등장과 함께 증명책임의 전환 및 완화라는 유연한 해석론을 통해 보완되고 있다. 특히 의료, 환경, 정보통신 등 전문적 영역에서 일반 당사자의 증명 곤란을 해소하기 위한 판례의 노력은 실질적 형평성을 구현하는 핵심적 수단이 된다. 다만, 이러한 완화가 법적 안정성을 해치지 않도록 논리적 근거와 한계를 명확히 설정해야 한다. 결국 증명책임론은 절차적 정의와 실체적 진실 발견이라는 두 가지 가치를 조화롭게 유지하며, 법치주의 하에서의 공정한 재판을 실현하는 최후의 보루로서 기능한다.

#### <제4편 소송의 종료.제8장 총설.제1절 소송종료사유>

### I. 소송종료의 의의 및 종료사유 총설

- 소송의 종료란 제기된 소송사건이 계속 중에 어떤 사유로 인하여 법원의 심리·재판을 기다리지 않고 완결되는 상태를 의미한다. 소송종료사유는 크게 당사자의 의사에 의한 종료, 법원의 중국판결에 의한 종료, 법률상 당연히 종료되는 경우로 나뉜다. 민사소송법상 소송종료사유는 소송의 주체인 법원과 당사자 중 어느 쪽의 행위에 의하여 발생하는가에 따라 분류할 수 있다. 당사자에 의한 종료는 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 소송상의 화해 등이 대표적이며, 법원에 의한 종료는 원칙적으로 중국판결의 확정을 의미한다. 그 외에 당사자의 사망이나 합병 등으로 소송물인 권리관계가 상속되지 않는 경우 소송은 당연히 종료된다.

### II. 당사자의 의사에 기한 종료

#### 1. 소의 취하

##### (1) 개념

- 소의 취하란 원고가 제기한 소의 전체 또는 일부를 철회하여 소송계속을 소멸시키는 편면적 소송행위이다. 판결이 확정될 때까지 소의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다. 소의 취하가 있으면 소송은 처음부터 제기되지 않았던 것과 같은 효과를 발생시킨다.

##### (2) 요건 및 방식

- 소의 취하는 피고가 본안에 관하여 응소한 후에는 피고의 동의를 얻어야 효력이 발생한다. 이는 피고가 유리한 판결을 받을 기회를 보호하기 위함이다. 취하의 방식은 원칙적으로 서면으로 하여야 하나, 변론기일 또는 변론준비기일에는 말로써 할 수도 있다.

##### (3) 효과

- 소송계속이 소급적으로 소멸한다. 다만, 본안에 대한 중국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 사람은 같은 소를 제기하지 못한다는 재소금지의 원칙이 적용된다.

#### 2. 청구의 포기·인낙

##### (1) 개념

- 청구의 포기란 원고가 자기의 소송상의 청구가 이유 없음을 자인하는 단독적 소송행위이며, 청구의 인낙이란 피고가 원고의 소송상의 청구가 이유 있음을 인정하는 단독적 소송행위이다.

##### (2) 성질 및 효과

- 청구의 포기나 인낙은 변론기일 또는 변론준비기일에 말로써 하여야 한다. 이를 조서에 기재하면 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 이에 따라 소송은 종료되며 재판상 화해와 마찬가지로 기판력과 집행력이 발생한다.

#### 3. 소송상의 화해

##### (1) 개념

- 소송상의 화해란 소송계속 중에 당사자 양쪽이 서로 양보하여 소송물인 권리관계에 관한 다툼을 그만두기로 합의하는 소송행위이다. 이는 법원 앞에서 행해지는 재판상 화해의 일종이다.

##### (2) 요건 및 효과

- 당사자가 처분할 수 있는 권리관계여야 하며, 소송능력이 있어야 한다. 화해가 성립하여 조서에 기재되면 소송은 완결되며, 그 조서는 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 화해조서에 기재된 내용에 대해서는 준재심의 소에 의해서만 그 효력을 다툴 수 있다.

### III. 법원의 중국판결에 의한 종료

#### 1. 중국판결의 확정

##### (1) 개념

- 중국판결이란 하급심 법원이 해당 심급에서 소송의 전부 또는 일부를 완결하기 위하여 내리는 판결이다. 이러한 중국판결이 선고되고 상소기간의 도과 등으로 확정되면 소송은 종료된다.

##### (2) 효과

- 판결이 확정되면 형식적 확정력과 내용적 확정력인 기판력이 발생한다. 기판력이 발생하면 동일한 사건에 대하여 다시 소를 제기할 수 없으며, 후행 소송의 법원은 확정판결의 내용에 구속된다.

#### 2. 상소권의 포기 및 상소취하

##### (1) 상소권의 포기

- 판결 선고 후 아직 상소기간이 만료되지 않은 상태에서 상소하지 않겠다는 의사를 표시하는 것이다. 상소권 포기가 있으면 판결은 그 시점에서 확정되어 소송이 종료된다.

##### (2) 상소의 취하

- 상소를 제기한 자가 그 상소를 철회하는 소송행위이다. 상소취하가 있으면 원심판결이 확정되며 소송계속이 종료된다. 소의 취하와 달리 상대방의 동의를 필요로 하지 않는다.

### IV. 법률상 당연 종료

#### 1. 당사자의 사망

##### (1) 소송물이 승계되지 않는 경우

- 이혼소송이나 부양료 청구권과 같이 당해 소송의 권리관계가 당사자 일신에 전속하여 상속이나 승계의 대상이 되지 않는 경우, 당사자 일방이 사망하면 소송은 당연히 종료된다. 법원은 소송종료선언을 할 필요 없이 그대로 절차를 종결한다.

##### (2) 소송물이 승계되는 경우

- 반면 소송물이 상속되는 일반 재산권인 경우 소송은 중단되며, 상속인 등이 소송을 수계하여야 한다. 이 경우에는 당연 종료 사유에 해당하지 않는다.

#### 2. 법인의 합병 및 해산

- 법인이 소송계속 중 합병에 의하여 소멸한 경우, 그 권리의무가 합병 후의 법인에 승계된다면 소송은 중단되고 수계 절차를 밟게 된다. 그러나 승계되지 않는 특수한 관계가 소멸한 경우라면 소송은 당연히 종료될 수 있다.

#### 3. 소송계속의 상실

- 기타 법령의 개정이나 특정 사건의 해결로 인하여 소송을 유지할 법률상 이익이나 대상이 완전히 사라진 경우, 소송은 당연히 종료된 것으로 취급된다.

## **V. 소송종료선언**

### **1. 의의**

- 소송이 이미 종료되었음에도 불구하고 당사자가 이를 다투며 소송의 진행을 요구하는 경우, 법원이 소송이 종료되었음을 확인하기 위하여 내리는 판결이다.

### **2. 사유**

- 소의 취하가 부적법하게 취소되었거나, 화해가 성립하였음에도 기일 지정을 신청하는 경우 등에 법원은 심리 후 소송종료선언 판결을 한다. 이는 성질상 종국판결에 해당한다.

## **VI. 결론**

- 소송의 종료는 법적 분쟁의 최종적인 해결을 의미하며, 이는 국가 형벌권이나 행정권의 행사와 달리 당사자의 사적 자치가 광범위하게 허용되는 영역이다. 원고와 피고는 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 소송상 화해 등을 통하여 법원의 강제적인 판단에 앞서 스스로 분쟁을 종결시킬 수 있다. 이러한 당사자에 의한 종료는 법원의 업무 부담을 경감시키고 당사자 간의 실질적 합의를 도모한다는 측면에서 긍정적인 기능을 수행한다. 동시에 법원은 종국판결을 통하여 소송을 확정적으로 종결시킴으로써 법적 안정성을 확보한다. 확정판결의 기판력은 분쟁의 재발을 방지하고 법률관계에 대한 공적 신뢰를 부여하는 핵심적 기초가 된다. 다만, 당사자의 사망과 같이 법률상 당연히 종료되는 사유에 있어서는 권리관계의 성질에 따라 승계 여부를 엄격히 판단하여 당사자의 절차적 권리가 침해되지 않도록 주의하여야 한다. 결과적으로 소송종료사유에 관한 제도적 장치들은 소송의 경제성과 효율성, 당사자의 자주적 결정권 사이의 균형을 맞추는 역할을 한다. 특히, 소송종료선언과 같은 절차는 이미 완결된 분쟁이 불필요하게 반복되는 것을 차단함으로써 사법자원의 낭비를 막고 소송계속의 불확정 상태를 신속히 제거하는 중요한 보완책으로 기능한다.

<제4편 소송의 종료.제8장 총설.제2절 소송종료선언>

**I. 의의**

**1. 소송종료선언의 정의**

- 소송종료선언이란 이미 소송이 유효하게 종료되었음에도 불구하고, 당사자가 그 종료 사실을 다투어 소송의 계속을 주장하며 기일지정신청 등을 하는 경우에 법원이 심리 결과 소송이 이미 종료되었음을 확인하여 선고하는 중국판결이다.

**2. 소송 종료 방법**

- 민사소송법상 소송은 중국판결의 확정뿐만 아니라 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 재판상 화해 등에 의하여 종료될 수 있다.

**3. 법원의 심리와 판결**

- 당사자 일방이 종료 사유의 유효성을 부정하며 소송의 진행을 구하는 경우, 법원은 다시 절차를 열어 해당 사유의 존부 및 유효 여부를 심리하게 된다. 심리 결과 소송이 이미 적법하게 종료된 것으로 판명되면 법원은 더 이상 본안에 대한 심리를 진행할 수 없으므로, 소송이 이미 어느 시점에 어떠한 사유로 종료되었음을 판결로써 선언하게 된다.

**4. 판결의 성격**

- 해당 판결은 해당 심급의 소송절차를 완결시킨다는 점에서 중국판결의 성질을 가지며, 소송계속의 존재를 전제로 하는 판결이 아니라 소송계속이 이미 소멸하였음을 공적으로 확인하는 확인적 판결의 성격을 띤다.

**II. 소송종료선언의 사유**

**1. 기일지정신청이 이유 없는 경우**

**(1) 개념 및 발생 원인**

- 당사자가 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 재판상 화해를 한 후 그 행위에 결함이 있다고 주장하거나 착오 등을 이유로 소송의 부활을 꾀하며 기일지정을 신청하는 경우이다. 법원은 이에 대해 기일을 열어 종료 사유의 존부를 심리하게 된다.

**(2) 심리 결과의 처리**

- 법원이 기일지정신청에 따라 심리한 결과, 소의 취하나 화해 등이 유효하여 소송이 이미 종료된 것이 맞다면 기일지정신청은 이유 없는 것이 된다. 이때 법원은 신청을 기각하는 결정을 하는 것이 아니라, 소송종료선언의 판결을 내린다.

**(3) 무효 주장과의 관계**

- 만약 당사자가 소 취하 등의 소송행위에 의사표시의 하자가 있다고 주장하더라도, 소송행위에는 민법상의 비진의표시, 착오, 사기·강박에 관한 규정이 원칙적으로 적용되지 않으므로 그 하자가 치유되지 않는 한 소송종료의 효과는 유지된다. 따라서 법원은 소송종료선언을 통해 절차를 마무리한다.

**2. 소송종료를 간과한 것이 발견된 경우**

**(1) 간과의 의의**

- 간과란 법원이 소송의 종료 사유가 발생하였음에도 불구하고 이를 알지 못한 채 본안 심리를 계속 진행하는 경우를 의미한다. 예를 들어, 소 취하서가 제출되었으나 기록에 편철되지 않아 법원이 변론을 계속하거나 판결을 선고하는 경우가 이에 해당한다.

**(2) 발견 시의 조치**

- 변론 종결 전이나 판결 선고 전에 소송종료 사유를 발견한 경우, 법원은 즉시 변론을 멈추고 소송종료선언 판결을 하여야 한다. 이미 판결이 선고되었으나 아직 확정되지 않은 상태에서 상소심이 이를 발견한 경우에도 상소심 법원은 원심판결을 파기하고 소송종료선언을 한다.

**(3) 판결 선고 후의 처리**

- 이미 중국판결이 선고된 후에 소송종료 사실이 밝혀진 경우, 그 판결은 실질적으로 존재하지 않는 소송계속에 기반한 것이므로 효력이 없다. 상소심은 원심이 간과한 종료 시점을 기준으로 소송이 종료되었음을 선언함으로써 잘못된 판결의 외관을 제거한다.

**3. 당사자대립구조가 소멸한 경우**

**(1) 혼동에 의한 소멸**

- 소송계속 중 원고와 피고의 지위가 동일인에게 귀속되는 경우이다. 예를 들어 소송 중에 원고가 피고를 상속하거나 법인이 합병되어 당사자가 한 사람이 된 경우, 소송의 기본 전제인 당사자 대립 구조가 붕괴된다.

**(2) 권리관계의 소멸**

- 소송물인 권리가 당사자의 사망으로 상속되지 않고 당연히 소멸하는 일신전속적 권리인 경우(이혼소송 중 일방의 사망)에도 당사자 대립 구조가 사라진다.

**(3) 절차적 특징**

- 이러한 당연 종료 사유가 발생했음에도 불구하고 상속인이나 이해관계인이 이를 다투며 소송 진행을 요구할 경우, 법원은 소송종료선언을 통해 해당 소송이 당사자 대립 구조의 상실로 인해 종료되었음을 확인한다.

**III. 소송종료선언의 효력**

**1. 소송절차 완결 확정력**

- 소송종료선언은 당해 심급에서 소송절차가 완전히 끝났음을 대외적으로 확정하는 효력을 가진다. 이 판결이 확정되면 해당 사건에 대한 소송계속은 소멸한 상태로 고착되며, 법원은 동일한 청구에 대해 다시 심리할 수 없다.

**2. 불복과 상소**

- 소송종료선언 판결은 중국판결이므로 이에 대해 불복하는 당사자는 항소나 상고를 제기할 수 있다. 상소심에서 심리한 결과 소송종료 사유가 없음이 밝혀지면, 상소심 법원은 소송종료선언 판결을 취소하고 사건을 원심법원으로 환송하여 본안 심리를 계속하도록 한다.

**3. 기판력 범위**

- 소송종료선언은 기판력을 가진다. 다만, 이 기판력은 본안 청구의 존부에 관한 것이 아니라, '해당 소송이 특정 시점에 종료되었다'는 절차적 사실에 국한된다. 따라서 소송종료선언이 확정된 후 다시 동일한 소를 제기하는 경우, 그것이 재소금지 원칙에 위배되지 않는 한 새로운 소송계속이 형성될 수 있으나, 이전 소송의 부활을 주장하는 것은 허용되지 않는다.

**4. 소송비용 부담 결정**

- 마지막으로 소송비용의 부담에 관한 결정도 소송종료선언과 함께 이루어져야 한다. 법원은 소송이 종료된 원인을 파악하여 소송비용 지출의 책임이 있는 당사자에게 비용 부담을 명하게 된다.

## **IV. 결론**

### **1. 제도적 중요성**

- 소송종료선언은 소송의 동태적 성격과 절차적 안정성을 동시에 보장하는 중요한 제도적 장치이다. 민사소송법은 당사자의 의사나 법률상 당연한 사유에 의해 소송이 종료될 수 있음을 인정하고 있으나, 현실에서는 종료 여부를 둘러싼 당사자 간의 다툼이 빈번하게 발생한다. 이때 법원이 판결이라는 엄격한 형식을 통해 소송계속의 소멸을 공식화하는 것은 불필요한 절차의 공전을 막는 핵심적인 역할을 수행한다.

### **2. 기일지정 신청 심리와 법적 평화**

- 기일지정신청에 대한 심리 과정에서 나타나는 소송종료선언은 당사자의 소송행위에 대한 신뢰를 보호하고, 한번 유효하게 이루어진 소 취하나 화해의 효과를 함부로 뒤집을 수 없게 함으로써 법적 평화를 유지한다.

### **3. 소송종료 간과 및 대립구조 소멸 선언의 공익성**

- 소송종료를 간과한 경우나 당사자 대립 구조가 소멸한 경우에 내려지는 선언은 사법 자원의 효율적 배분이라는 공익적 목적에도 부합한다.

### **4. 소송종료의 명확성 확보**

- 결국 소송종료선언은 소송의 시작만큼이나 종료 역시 명확한 법적 근거와 절차에 따라 이루어져야 함을 시사한다. 이는 당사자에게는 절차적 예측가능성을 제공하고, 법원에는 무용한 심리를 차단할 수 있는 근거를 마련해 줌으로써 민사소송 절차의 완결성을 높이는 데 기여한다.

<제4편 소송의 종료.제9장 당사자 행위에 의한 종료.제1절 소의 취하와 재소금지>

**I. 소의 취하**

**1. 서설**

**(1) 의의**

- 소의 취하란 원고가 제기한 소의 전체 또는 일부를 철회하여 소송계속을 소멸시키는 소송법상 의사표시를 의미한다. 이는 소송의 주도권이 원고에게 있다는 처분권주의의 발현으로, 원고는 판결이 확정될 때까지 소를 취하함으로써 소송절차를 종료시킬 수 있다.

**(2) 구별개념**

- 소의 취하는 소송물인 권리 자체를 부정하는 청구의 포기과 구별된다. 청구의 포기는 본안에 대한 패소 판결과 같은 효력을 가져 기판력이 발생하지만, 소의 취하는 소송절차만을 무효로 돌리는 것이므로 원칙적으로 재소가 가능하다. 또한 소송요건의 흠결을 이유로 소를 부적법하게 처리하는 소각하 판결과도 구분되는데, 취하는 당사자의 의사에 의한 종료인 반면, 각하는 법원의 판단에 의한 종료이다.

**2. 소취하의 요건[민소법 제266조, 제277조]**

**(1) 당사자에 대한 요건**

- 소의 취하는 소송행위이므로 원고에게 소송능력이 있어야 하며, 소송대리인이 취하할 경우에는 소의 취하에 관한 특별수권이 있어야 한다. 피고가 여러 명인 임의적 공동소송의 경우 원고는 그중 1인에 대해서만 소를 취하할 수 있는 것이 원칙이나, 필수적 공동소송의 경우에는 공동소송인 전원이 함께하거나, 전원에게 대하여 하지 않으면 효력이 없다.

**(2) 소송물에 대한 요건**

- 소의 전체뿐만 아니라 소의 일부에 대해서도 취하가 가능하다. 단, 일부 취하는 소송물의 가분성이 전제되어야 하며, 특정되지 않은 일부 취하는 허용되지 않는다.

**(3) 시기**

- 소의 취하는 소가 제기된 후부터 판결이 확정될 때까지 언제든지 할 수 있다. 상소심에서도 가능하다. 다만, 항소심에서 소를 취하하면 제1심 판결은 소급하여 효력을 잃게 된다.

**(4) 방식**

- 소의 취하는 서면으로 하는 것이 원칙이나, 변론기일 또는 변론준비기일에서는 구술로도 할 수 있다. 구술로 취하하는 경우에는 그 내용을 조서에 기재하여야 한다. 소 취하서가 제출된 경우 법원은 이를 상대방에게 송달하여야 한다.

**(5) 피고의 동의**

- 피고가 본안에 대하여 준비서면을 제출하거나 변론을 한 후에는 피고의 동의를 얻어야 취하의 효력이 발생한다. 이는 피고가 응소하여 승소 판결을 받을 기대를 가지게 된 것을 보호하기 위함이다. 소 취하 통지를 받은 날로부터 2주 이내에 피고가 이의를 제기하지 않으면 동의한 것으로 간주한다.

**3. 소취하의 효과**

**(1) 소송법상 효과**

- 소 취하가 유효하면 소송계속은 소급적으로 소멸한다. 처음부터 소가 제기되지 않았던 것과 같은 상태가 되며, 이미 선고된 판결이 있더라도 그 효력은 상실된다. 다만, 소송비용은 원칙적으로 취하한 원고가 부담하게 된다.

**(2) 사법상 효과**

- 소의 제기로 발생하였던 시효중단의 효과나 법률상 기간 준수의 효과가 소급적으로 소멸한다. 민법 제170조에 의하면 소 취하 후 6개월 이내에 다시 재판상 청구 등을 하지 않으면 시효중단의 효력이 없다.

**4. 소취하 간주**

- 당사자 쌍방이 변론기일에 불출석하거나 출석하더라도 변론하지 아니한 경우, 1개월 이내에 기일지정신청을 하지 않거나 다시 열린 기일에서도 양쪽이 불출석하면 소를 취하한 것으로 본다. 이를 상불출에 의한 소취하 간주라 하며, 소송 지연을 방지하기 위한 제도이다.

**5. 소취하의 효력을 다투는 절차**

- 소 취하가 무효이거나 취소 사유가 있다고 주장하는 당사자는 소송종료선언을 구하는 기일지정신청을 할 수 있다. 법원은 기일을 열어 취하의 유효여부를 심리하며, 취하가 유효하다고 판단되면 소송종료선언 판결을 하고, 유효하지 않다고 판단하면 변론을 계속하여 진행한다.

**II. 재소금지**

**1. 서설**

**(1) 의의**

- 민소법 제267조 제2항에 따라 본안에 대한 중국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 사람은 같은 소를 제기하지 못한다는 원칙을 의미한다.

**(2) 취지**

- 법원의 중국판결이 내려졌음에도 불구하고 당사자가 임의로 소를 취하하고 다시 같은 소를 제기하여 법원을 농락하거나 상대방을 괴롭히는 부당한 소송행위를 방지하기 위함이다. 즉, 국가의 재판권 낭비를 막고 판결의 권위를 보호하기 위한 공익적 목적을 가진다.

**2. 재소금지의 요건★**

**(1) 당사자의 동일**

- 전소의 원고와 후소의 원고가 동일인이어야 한다. 원고의 포괄승계인도 동일인에 포함된다. 다만, 피고가 달라지는 경우에는 원칙적으로 재소금지가 적용되지 않으나, 소송물의 성질상 피고가 달라도 실질적으로 동일한 분쟁이라면 적용될 수 있다.

**(2) 소송물의 동일**

- 전소와 후소의 청구취지 및 청구원인이 동일해야 한다. 소송물의 범위가 전소보다 축소된 경우에도 재소금지에 해당할 수 있으나, 소송물이 전혀 별개인 경우에는 적용되지 않는다.

**(3) 권리보호이익의 동일**

- 후소를 제기할 만한 새로운 정당한 사유가 없어야 한다. 판결 후 사정변경이 생겨 다시 소를 제기할 수밖에 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 재소금지에 저촉되지 않는다는 것이 판례의 태도이다.

**(4) 본안에 대한 중국판결 후 소취하**

- 제1심 판결이 선고된 후 상소심에서 소를 취하하는 경우가 대표적이다. 판결이 형식적으로 확정되기 전이라도 중국판결이 선고된 상태에서 취하했다면 이 요건을 충족한다.



### 3. 재소금지의 효과

#### (1) 소송법상 효과

- 재소금지의 요건에 해당하면 후소는 부적법한 소가 되어 법원은 판결로써 이를 각하하여야 한다. 이는 직권조사사항이며, 피고의 동의 여부와 관계없이 적용된다.

#### (2) 실체법상 효과

- 재소금지는 소송법상의 제재이므로 원고의 실체법상 권리 자체를 소멸시키는 것은 아니다. 따라서 소송 외에서 그 권리를 행사하거나 상계의 자료로 삼는 것은 가능하다. 다만, 재판을 통해서 그 권리를 실현할 길은 봉쇄된다.

### Ⅳ. 결론

- 소의 취하와 재소금지는 민사소송법에서 처분권주의와 소송경제의 조화를 꾀하는 핵심 기제이다. 원고는 소 취하를 통해 언제든지 소송의 구속에서 벗어날 수 있는 자유를 누리지만, 법원의 종국판결이 내려진 후에는 그 자유에 엄격한 책임이 따른다. 재소금지 원칙은 당사자가 국가의 재판 기능을 무의미하게 만드는 행위를 차단함으로써 소송 제도의 존엄성을 유지한다. 당사자는 소 취하 시 발생할 수 있는 시효중단의 실효 및 재소금지의 위험을 충분히 인지하여야 하며, 법원은 취하의 유효성 여부와 재소금지 해당 여부를 엄격히 심사하여 절차적 정의를 실현하여야 한다. 결국 이러한 제도적 장치들은 소송절차의 효율성을 도모하고 당사자 간의 불필요한 분쟁 반복을 방지하여 법적 평화를 조속히 정착시키는 데 기여한다.

#### <제4편 소송의 종료.제9장 당사자 행위에 의한 종료.제2절 청구의 포기·인낙>

### I. 의의[민소법 제220조]

#### 1. 청구의 포기

- 청구의 포기란 원고가 변론이나 변론준비기일에서 소송물인 권리관계가 존재하지 않음을 자인하는 법원에 대한 일방적 의사표시를 말한다.

#### 2. 청구의 인낙

- 청구의 인낙이란 피고가 원고의 청구내용이 정당함을 자인하는 법원에 대한 일방적 의사표시이다.

#### 3. 공통점

- 이들은 모두 당사자의 처분권주의에 기초한 소송종료행위로서, 조서에 기재됨으로써 확정판결과 동일한 효력을 가진다.

### II. 법적 성질

#### 1. 학설의 대립

- 청구의 포기·인낙의 법적 성질에 대해서는 사법상의 의사표시로 보는 사법행위설, 소송상의 행위로 보는 소송행위설, 소송행위와 사법행위가 병존한다는 병존설이 대립한다.

#### 2. 통설과 판례

- 통설과 판례는 이를 순수한 소송행위로 파악한다. 따라서 민법상의 비진의표시, 착오, 사기·강박에 관한 규정은 원칙적으로 적용되지 않으며, 오로지 소송법적 요건과 절차에 따라 그 효력이 결정된다. 다만, 형사상 처벌받을 타인의 행위로 인하여 행해진 경우와 같은 중대한 결함이 있는 때에 한하여 예외적으로 재심의 소에 준하여 그 효력을 다룰 수 있을 뿐이다.

### III. 요건

#### 1. 당사자에 대한 요건

- 당사자는 유효한 소송행위를 할 수 있는 소송능력을 갖추어야 한다. 법정대리인이 포기나 인낙을 하는 경우에는 특별한 권한이 있어야 하며, 소송대리인이 이를 행할 때에도 민사소송법 제90조 제2항에 따른 특별수권이 반드시 필요하다. 공동소송의 경우 통상 공동소송에서는 각자 독립하여 할 수 있으나, 필수적 공동소송에서는 전원이 함께하거나, 전원에 대하여 하지 않으면 효력이 발생하지 않는다.

#### 2. 소송물에 대한 요건

- 당사자가 임의로 처분할 수 있는 사적 권리관계여야 한다. 따라서 처분권주의가 제한되는 직권탐지주의 영역인 가사소송(혼인무효, 친생자관계 등)이나 행정소송 중 일부 절차에서는 청구의 포기·인낙이 허용되지 않는다. 또한, 소송물이 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하거나 강행법규에 위반되는 경우에도 법원은 이를 수리해서는 안 된다.

#### 3. 시기와 방식

- 소송계속 중이라면 변론종결 전뿐만 아니라 상소심에서도 가능하다. 방식은 반드시 변론기일 또는 변론준비기일에서 구술로 행하여야 한다. 서면(준비서면 등)에 의한 포기·인낙의 의사표시가 제출된 경우, 상대방이 기일에 출석하지 아니하더라도 그 서면의 내용을 진술한 것으로 간주하여 처리할 수 있다. 포기·인낙의 의사가 표시되면 법원사무관 등은 이를 조서에 기재하여야 한다.

### IV. 효과

#### 1. 소송종료효

- 청구의 포기·인낙이 조서에 기재되면 해당 소송은 즉시 종료된다. 별도의 판결 선고가 필요하지 않으며, 소송계속은 그 시점에서 소멸한다. 만약, 소송의 일부에 대해서만 포기·인낙이 이루어졌다면 그 부분에 한하여 소송이 종료된다.

#### 2. 확정판결과 동일한 효력

- 민사소송법 제220조에 의거하여 포기·인낙을 기재한 조서는 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 따라서 기판력이 발생하여 동일한 사안으로 다시 소를 제기할 수 없으며, 인낙조서의 경우 강제집행을 위한 집행권원이 된다. 형성소송의 경우에는 형성적 효력도 발생한다.

#### 3. 인낙불이행으로 인한 손해배상청구 또는 해제 거부

- 청구의 인낙은 소송행위이므로 사법상의 계약인 화해와는 성질이 다르다. 따라서 피고가 인낙의 내용을 이행하지 않는다고 하여 원고가 인낙의 의사표시를 해제하거나 이를 이유로 별도의 손해배상을 청구할 수는 없다. 원고는 오로지 인낙조서라는 집행권원을 바탕으로 강제집행 절차를 밟아야 한다. 이는 인낙조서에 의해 실체법상 권리관계가 확정되었기 때문이다.

### V. 청구의 포기·인낙의 효력을 다투는 절차

#### 1. 조서 작성 전

- 당사자가 기일에서 포기나 인낙의 의사를 표시하였으나 아직 조서에 기재되기 전이라면 그 의사표시를 철회하거나 취소할 수 있는지가 문제 된다. 소송행위의 명확성과 안정성을 중시하는 관점에서는 원칙적으로 철회가 불가능하다고 보나, 조서 기재라는 형식적 요건이 갖추어지기 전까지는 당사자가 의사를 번복할 수 있다는 견해도 존재한다. 실무상으로는 기일이 종료되어 조서가 완성되기 전까지는 신중한 검토가 가능하다.

#### 2. 조서 작성 후

- 일단 조서에 기재되어 확정판결과 동일한 효력이 발생한 후에는 이를 단순한 소송행위의 철회나 취소로 다룰 수 없다. 판결의 확정력을 제거하기 위해서는 재심의 소에 준하는 준재심의 소를 제기하여야 한다. 민사소송법 제461조에 따라 소송행위의 원인이 된 외형적 절차에 중대한 결함(소송능력의 흠결, 대리권의 부존재 등)이 있거나 형사상 처벌받을 타인의 행위가 개입된 경우 등에 한하여 제한적으로 효력을 다툴 수 있다. 단순한 착오나 사법상 사유로는 그 효력을 부인하기 어렵다.

### VI. 결론

#### 1. 제도의 역할 및 의의

- 청구의 포기·인낙은 당사자의 자율적인 의사에 따라 분쟁을 신속하게 종결짓는 강력한 소송법상 수단이다. 원고는 청구의 포기를 통해 불필요한 소송 지속을 방지하고, 피고는 인낙을 통해 패소가 확실한 소송에서 비용과 시간을 절약할 수 있다. 특히, 인낙조서가 확정판결과 동일한 효력을 가짐으로써 집행권원을 즉시 확보하게 하는 점은 소송 효율성 측면에서 매우 유용하다.

#### 2. 주의사항

- 이러한 행위는 기판력을 발생시켜 추후 다시 다툴 수 없게 만드는 엄중한 법적 구속력을 가지므로, 당사자는 특별수권의 유무와 소송물의 처분 가능성을 면밀히 검토하여야 한다. 법원 역시 공익적 한계를 벗어나는 포기·인낙이 이루어지지 않도록 절차적 요건을 엄격히 준수해야 한다.

### 3. 핵심 가치

- 결국 이 제도는 처분권주의의 극치를 보여주는 동시에, 사법 자원의 낭비를 줄이고 당사자 간의 법적 평화를 조기에 달성하는 데 그 핵심적 가치가 있다.

<제4편 소송의 종료.제9장 당사자 행위에 의한 종료.제3절 재판상 화해>

**I. 소송상 화해**

**1. 의의**

- 소송상 화해란 소송계속 중 양 당사자가 소송물의 권리관계에 관하여 상호 양보하여 소송을 종료시키기로 하는 합의를 법원에 진술하고, 이를 조서에 기재함으로써 소송을 종료시키는 행위를 말한다. 이는 당사자의 자율적 분쟁 해결을 존중하는 처분권주의의 결과물이다.

**2. 법적 성질**

**(1) 학설**

- 사법행위설은 화해를 민법상 화해계약으로 보며 조서 기재는 그 증명방법에 불과하다고 본다. 소송행위설은 화해를 순수한 소송상 행위로 보아 사법상 실제적 하자가 있더라도 소송법적 요건만 갖추면 유효하다고 본다. 양성을 인정하는 병존설과 두 성질이 융합되었다는 취지의 무명계약설 등이 대립한다.

**(2) 판례**

- 대법원은 소송상 화해를 원칙적으로 소송행위로 파악한다. 따라서 사법상의 착오, 사기, 강박 등을 이유로 화해의 효력을 다툴 수 없으며, 오로지 재심 사유에 해당하는 중대한 결함이 있는 경우에만 준재심의 소를 통해 그 효력을 다툴 수 있다는 입장을 견지하고 있다.

**(3) 검토**

- 소송절차의 안정성과 명확성을 고려할 때 소송행위설이 타당하다. 일단 조서가 작성되면 확정판결과 동일한 효력이 발생하므로 실제법상의 사유로 그 효력을 쉽게 부정하는 것은 법적 안정성을 해칠 우려가 크기 때문이다.

**(4) 논의의 실익**

- 사법행위설에 의하면 민법상의 취소·해제 규정이 적용될 수 있으나, 소송행위설에 의하면 이러한 사법상 규정의 적용이 배제되고 소송법적 구제 수단인 준재심으로만 다툴 수 있게 된다.

**3. 성립요건**

**(1) 당사자에 대한 요건**

- 당사자는 유효한 소송행위 능력을 갖추어야 한다. 소송대리인의 경우 민사소송법 제90조 제2항에 따른 화해에 관한 특별수권이 반드시 있어야 한다. 또한 당사자 본인이나 대리인이 기일에 직접 출석하여 화해의 의사를 표시해야 한다.

**(2) 소송물에 대한 요건**

- 당사자가 임의로 처분할 수 있는 사적 권리관계여야 한다. 직권탐지주의가 적용되는 가사소송이나 공익적 성격이 강한 행정소송 중 일부 절차에서는 원칙적으로 화해가 허용되지 않는다. 또한, 반사회적 내용이거나 강행법규 위반인 경우 법원은 화해를 수리할 수 없다.

**(3) 시기**

- 소송이 계속 중인 상태라면 제1심부터 상고심까지 어느 단계에서든 가능하다. 변론기일뿐만 아니라 변론준비기일에서도 행해질 수 있다.

**(4) 방식**

- 변론기일 또는 변론준비기일에서 당사자 쌍방이 출석하여 구술로 합의 내용을 진술해야 한다. 법원사무관 등은 이 진술 내용을 화해조서에 기재하여야 하며, 조서의 기재가 완료됨으로써 화해가 성립한다.

**4. 효과**

**(1) 소송종료효**

- 화해조서가 작성되면 소송은 그 즉시 종료된다. 소송물 전부에 관한 화해라면 소송 전체가 소멸하며, 일부 화해라면 해당 부분에 대해서만 소송이 종료된다.

**(2) 확정판결과 동일한 효력 - 기판력**

- 민사소송법 제220조에 따라 화해조서는 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 기판력이 발생하므로 동일한 청구에 대하여 다시 소를 제기할 수 없으며, 후행 소송의 법원은 화해의 내용과 모순되는 판단을 할 수 없다.

**(3) 확정판결과 동일한 효력 - 집행력과 형성력**

- 화해조서에 급부의무가 포함된 경우 이는 독립된 집행권원이 되어 강제집행을 할 수 있다. 또한, 형성소송에서의 화해는 법률관계를 직접 변동시키는 형성적 효력을 가진다.

**(4) 실제법상 화해의 창설적 효력인정 여부**

- 판례는 소송상 화해에도 민법 제733조의 창설적 효력을 인정한다. 화해가 성립하면 종전의 법률관계를 바탕으로 한 권리 주장은 소멸하고, 화해에 의해 형성된 새로운 법률관계가 효력을 갖게 된다.

**5. 소송상 화해의 효력을 다투는 절차**

**(1) 기속력을 다투는 방법**

- 조서에 오키나 계산상의 착오 등 명백한 오류가 있는 경우에는 경정결정을 통해 수정할 수 있다.

**(2) 기판력을 다투는 방법**

- 화해조서에 기판력이 발생한 후에는 오로지 준재심의 소를 통해서만 다툴 수 있다. 민사소송법 제461조가 규정하는 재심 사유(대리권 흠결, 형사상 처벌받을 타인의 행위 등)가 증명되어야 화해의 효력을 부인할 수 있다.

**(3) 화해조서상 의무불이행을 이유로 하는 화해해제 가부**

- 소송상 화해는 소송행위이므로 사법상의 해제 규정이 적용되지 않는다. 따라서 상대방이 화해 조서상의 의무를 이행하지 않는다고 하더라도 화해 자체를 해제하고 종전의 소송 상태로 복귀할 수는 없으며, 오로지 조서에 기한 강제집행만이 가능하다.

**6. 화해권고결정[민소법 제225조]**

**(1) 의의**

- 법원·수명법관 또는 수탁판사가 소송계속 중인 사건에 대하여 직권으로 당사자의 이익, 그 밖의 모든 사정을 참작하여 사건의 공평한 해결을 위해 내리는 결정을 말한다.

**(2) 요건**

- 소송계속 중이어야 하며, 당사자의 합의가 없더라도 법원이 직권으로 적절한 해결책을 제시할 필요가 있다고 판단될 때 행해진다.

**(3) 절차**

- 법원이 결정서 정본을 당사자에게 송달하며, 당사자는 송달받은 날로부터 2주 이내에 이의신청을 할 수 있다. 만약, 이의신청이 없거나 이의신청이 취하·각하된 경우에는 그 결정이 확정된다.

#### (4) 효과

- 확정된 화해권고결정은 재판상 화해와 동일하게 확정판결과 같은 효력을 가진다. 만약, 적법한 이의신청이 있으면 결정은 효력을 잃고 소송은 이전 상태로 복귀한다.

### II. 제소 전 화해

#### 1. 의의

- 제소 전 화해란 일반 민사분쟁이 소송으로 이행되는 것을 방지하기 위하여 소 제기 전에 지방법원 판사 앞에서 화해를 성립시키는 절차를 말한다. 이는 소송계속을 전제로 하지 않는다는 점에서 소송상 화해와 구별된다.

#### 2. 법적 성질

##### (1) 학설

- 독립된 특별절차로 보는 견해와 사법상 합의를 공증하는 절차로 보는 견해가 대립하나, 기본적으로는 재판상 화해의 일종으로 파악한다.

##### (2) 판례

- 판례는 제소 전 화해조서 역시 확정판결과 동일한 효력을 가지며, 그 기판력의 범위 내에서는 실체법상 하자를 이유로 무효를 주장할 수 없다는 태도를 취한다.

##### (3) 검토

- 분쟁 예방이라는 목적과 집행권원 부여라는 기능을 고려할 때, 재판상 화해에 준하는 소송법적 성격을 강조하는 것이 타당하다.

#### 3. 성립요건

- 당사자 간의 사전 화해 합의가 있어야 하며, 신청인은 상대방의 보통재판적 소재지 지방법원에 신청하여야 한다. 소송상 화해와 마찬가지로 처분 가능한 권리관계여야 하며, 강행법규 위반 등의 내용이 포함되지 않아야 한다.

#### 4. 절차

- 화해 신청이 접수되면 법원은 기일을 정하여 당사자를 소환한다. 기일에서 양 당사자의 의사가 합치되면 화해조서를 작성한다. 만약, 일방이 출석하지 않거나 화해가 성립되지 않으면 법원은 화해 불성립으로 처리하고 사건을 종결하거나, 신청인의 신청에 의해 소송절차로 이행할 수 있다.

#### 5. 화해조서의 효력

##### (1) 학설

- 무효인 화해조서의 효력에 관하여 당연무효설과 취소가능설이 대립한다.

##### (2) 판례

- 판례는 제소 전 화해 내용이 강행법규에 위반된다 하더라도 그것만으로 조서가 당연무효가 되는 것은 아니며, 준재심 절차에 의해 취소되지 않는 한 확정판결과 동일한 효력이 유지된다고 본다.

##### (3) 검토

- 법적 안정성을 위해 당연무효설보다는 준재심을 통해서만 다룰 수 있다는 판례의 입장이 타당하다.

#### 6. 제소 전 화해를 다투는 방법 - 소송상 화해와 동일

- 제소 전 화해조서의 기판력을 부인하기 위해서는 민사소송법이 규정하는 재심 사유를 원인으로 한 준재심의 소를 제기하여야 한다. 단순한 사법상 하자만으로는 그 효력을 다툴 수 없다.

#### 7. 제소 전 화해의 채무불이행을 원인으로 한 해제와 취소 가부 - 소송상 화해와 동일

- 제소 전 화해 역시 재판상 화해로서 소송법적 효력을 가지므로, 실체법상의 해제권 행사나 취소는 허용되지 않는다. 당사자는 조서의 내용에 따라 이행을 강제할 수 있을 뿐이다.

### III. 결론

- 재판상 화해는 당사자의 양보를 통해 분쟁을 중국적으로 해결하는 제도로써, 소송경제와 당사자의 만족도를 동시에 충족시킨다. 특히, 화해조서가 확정판결과 동일한 효력을 가짐으로써 발생하는 강한 기판력과 집행력은 법적 분쟁의 조기 종결에 크게 기여한다. 그러나 그 효력이 강력한 만큼 준재심 이외의 방법으로는 다룰 수 없다는 위험성도 존재하므로, 당사자는 화해 조항을 작성함에 있어 신중을 기해야 한다. 또한, 법원은 제소 전 화해 등이 강행법규를 잠탈하는 수단으로 악용되지 않도록 실질적인 심사를 강화할 필요가 있다. 결과적으로 이 제도는 사법 자원의 효율적 배분과 실질적 정의 실현이라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 필수적인 절차적 장치라 할 수 있다.

## <제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제1절 재판>

### I. 재판의 의의

#### 1. 재판의 정의

- 재판이란 법원 또는 법관이 소송사건에 대하여 일정한 절차를 거쳐 내리는 공권적인 판단이나 의사표시를 의미한다. 이는 국가의 사법권을 행사하는 구체적인 태양으로서, 당사자 간의 분쟁을 법적으로 확정하여 법적 안정성과 정의를 실현하는 것을 목적으로 한다. 민사소송절차에서의 재판은 소송의 주체인 법원이 소송의 객체인 소송물 또는 절차적 사항에 대하여 내리는 판단을 포괄한다.

#### 2. 재판의 구성요소

- 재판은 크게 관념적 판단인 판단적 요소와 외부에 표명되는 선언적 요소로 구성된다. 법관이 내심으로 형성한 결론만으로는 재판으로서의 효력이 발생하지 않으며, 반드시 법률이 정한 방식에 따라 외부에 표시되어야 한다.

#### 3. 재판의 구분

- 이러한 재판은 소송의 진행을 목적으로 하는 절차적 재판과 사건의 실체에 대하여 판단하는 실체적 재판으로 구분될 수 있다.

#### 4. 재판의 형태

- 민사소송법상 재판은 원칙적으로 판결·결정·명령의 세 가지 형태로 나타난다. 판결은 변론을 거쳐 법원이 행하는 가장 전형적인 재판의 형태이며, 결정과 명령은 보다 간이하거나 부수적인 사항을 처리하기 위한 형식이다. 이러한 재판의 형식에 따라 불복 방법과 효력 발생 요건이 달라지므로 이를 엄격히 구분하는 것이 소송법적으로 중요하다.

### II. 재판의 종류

#### 1. 재판의 형식에 따른 분류

##### (1) 판결

- 판결은 법원이 소송의 전부 또는 일부를 해결하기 위하여 변론을 거쳐 행하는 재판이다. 원칙적으로 필요적 변론을 거쳐야 하며, 판결서라는 서면을 작성하고 선고 절차를 밟아야 효력이 발생한다. 판결에 대한 불복은 항소 또는 상고의 방법으로 한다. 중국판결은 소송을 해당 심급에서 종료시키는 판결을 의미하며, 중간판결은 중국판결을 준비하기 위해 소송의 전제 조건 등에 대해 미리 판단하는 판결이다.

##### (2) 결정

- 결정은 법원이 변론을 거치지 않고 행하는 재판이다. 주로 소송 절차상의 부수적 사항이나 신속을 요하는 사항에 대하여 행해진다. 결정은 선고를 필요로 하지 않으며, 당사자에게 고지함으로써 효력이 발생한다. 결정에 대한 불복은 항고 또는 재항고의 방법으로 한다. 예를 들어 소송비용액 확정결정이나 가압류·가처분 결정 등이 이에 해당한다.

##### (3) 명령

- 명령은 법원이 아닌 재판장, 수명법관, 수임법관 등이 법관의 자격으로 행하는 재판이다. 법원이라는 기관의 판단이 아니라 개별 법관의 판단이라는 점에서 판결이나 결정과 구별된다. 대표적으로 소장부분 송달 불능 시 내리는 주소보정명령이나 소장각하명령 등이 있다. 불복 방법은 원칙적으로 결정과 같이 항고의 절차를 따른다.

#### 2. 재판의 내용에 따른 분류

##### (1) 실체재판

- 실체재판은 소송물인 권리관계의 존부에 대하여 판단하는 재판이다. 청구가 이유 있는지 여부를 따져 청구인용판결 또는 청구기각판결을 내리는 것이 이에 해당한다. 실체재판이 확정되면 기판력이 발생하여 당사자는 동일한 사항으로 다시 다툴 수 없게 된다.

##### (2) 소송재판

- 소송재판은 소송 요건의 구비 여부 등 소송 절차상의 적법성에 대하여 판단하는 재판이다. 소송 요건이 흠결된 경우 실체 판단에 들어가기 전 소를 부적법 각하하는 판결이 대표적이다. 소송재판은 소송물인 권리관계에 대한 판단을 포함하지 않으므로, 실체적 기판력은 발생하지 않으나 해당 소송 요건의 흠결에 관한 판단에는 일정한 구속력이 인정된다.

#### 3. 소송의 종료 여부에 따른 분류

##### (1) 중국판결

- 중국판결은 해당 심급에서 소송의 전부 또는 일부를 종료시키는 판결이다. 소송의 전부를 종료시키는 전부판결과, 여러 개의 청구 중 일부나 당사자 일부에 대해서만 종료시키는 일부판결이 있다. 또한 이미 내린 중국판결의 흠결을 보충하는 추가판결도 중국판결의 일종이다.

##### (2) 중간판결

- 중간판결은 중국판결을 내리기에 앞서 소송의 전제가 되는 개별적인 쟁점을 미리 확정하여 심리를 정리하기 위한 판결이다. 소송 요건의 존부나 청구 원인에 대한 판단 등이 대상이 된다. 중간판결은 소송을 종료시키지 않으며, 독자적으로 상소할 수 없고 나중에 나올 중국판결과 함께 상소심의 심판을 받게 된다. 중간판결은 법원이 자기의 판단에 구속되는 기속력을 발생시켜 이후의 심리를 간명하게 하는 효과가 있다.

#### 4. 기타의 분류

##### (1) 독립재판과 부수재판

- 독립재판은 소송물 자체에 대한 판단을 주된 목적으로 하는 재판이며, 부수재판은 소송비용의 부담이나 가집행 선고와 같이 주된 재판에 부수하여 행해지는 재판이다.

##### (2) 유권재판과 무권재판

- 재판권이 있는 법원이 행한 정상적인 재판을 유권재판이라 하며, 재판권이 없는 자가 행하거나 중대한 절차적 하자가 있어 재판으로서의 외관조차 갖추지 못한 경우를 무권재판 또는 부존재 재판이라 한다. 판례는 법관이 아닌 자가 행한 재판이나 선고되지 않은 판결 등은 효력이 발생할 수 없다고 본다.

### III. 결론

#### 1. 재판의 중요성

- 재판은 민사소송 절차의 핵심적인 종착지이자 사법 정의를 구체화하는 수단이다. 재판의 의의를 정확히 이해하는 것은 국가 형벌권이나 강제집행권의 근거가 되는 공권적 판단의 성격을 파악하는 것에서 시작된다.

#### 2. 재판 종류 구분 이유

- 재판의 종류를 판결·결정·명령으로 구분하고 이를 다시 실체재판과 소송재판, 중국판결과 중간판결로 세분화하여 고찰하는 이유는 각 형식마다 부여되는 법적 효력과 불복 절차가 상이하기 때문이다. 특히, 판결은 엄격한 변론절차를 거쳐 기판력을 발생시킴으로써 분쟁을 영구적으로 해결하는 기

능을 수행하며, 결정과 명령은 절차의 원활한 진행과 부수적 이익을 보호하는 역할을 한다.

### **3. 체계적 분류의 효과**

- 이러한 체계적 분류는 당사자의 절차적 권리를 보장하고 법원의 재판 행위에 명확한 지침을 제공한다.

<제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제2절 판결>

**I. 판결의 종류**

**1. 중간판결[민소법 제201조]**

**(1) 의의**

- 중간판결이란 중국판결을 내리기에 앞서 소송의 전제가 되는 개별적 쟁점에 대하여 미리 판단을 내려 심리 절차를 정리하고 확정하기 위한 판결이다. 이는 독립하여 소송을 종료시키지는 못하나, 법원 스스로가 내린 판단에 구속되게 함으로써 이후의 심리를 간명하게 하는 기능을 한다.

**(2) 중간판결사항**

- 민사소송법 제201조에 따르면 법원은 독립된 공격방어방법이나 그 밖의 중간적인 쟁점에 대하여 판결할 수 있다. 구체적으로는 소송요건의 존부, 청구원인의 성립 여부, 소송 절차상의 다툼 등이 대상이 된다. 예를 들어 피고가 제기한 소멸시효 항변이나 본안전 항변에 대하여 미리 중간판결을 함으로써 본안 심리의 범위를 확정할 수 있다.

**2. 중국판결[민소법 제198조]**

- 중국판결은 해당 심급에서 소송의 전부 또는 일부를 종료시키는 판결이다. 법원은 심리를 마친 때에는 중국판결을 하여야 하며, 이는 당해 법원의 수소관계를 탈퇴시키는 효력을 가진다. 전부판결, 일부판결, 잔부판결 등이 이에 속하며, 상소에 의하여 취소되지 않는 한 해당 사건에 대한 법원의 판단은 최종적인 것으로 확정된다.

**II. 기판력 개관**

**1. 서설**

**(1) 기판력의 의의**

- 기판력이란 확정된 중국판결에서 내린 공권적 판단에 부여되는 소송법상의 효력이다. 일단 판결이 확정되면 당사자는 동일한 사항에 대하여 다시 다툴 수 없고, 후소 법원도 전소 판결의 판단과 모순되는 판단을 할 수 없는 구속력을 의미한다.

**(2) 정당성의 근거**

- 기판력의 근거는 법적 안정성의 유지와 분쟁의 일회적 해결에 있다. 동일한 분쟁이 무한히 반복되는 것을 방지하여 국가 사법 자원의 낭비를 막고, 모순된 판결로 인한 법 질서의 혼란을 방지하는 것이 주된 목적이다.

**(3) 직권조사사항 및 소송요건**

- 기판력의 존부는 소송요건의 하나로서 법원의 직권조사사항이다. 당사자의 주장이 없더라도 법원은 전소 판결의 존재 여부를 확인하여 기판력에 저촉될 경우 후소를 부적법 각하하거나 전소 판단에 따라 본안 판단을 하여야 한다.

**2. 기판력 있는 재판**

**(1) 유효하게 확정된 판결**

- 원칙적으로 기판력은 유효하게 확정된 중국판결에만 발생한다. 중간판결이나 소송지휘적 결정 등에는 기판력이 인정되지 않는다.

**(2) 결정·명령**

- 절차적 사항에 대한 결정이나 명령은 대내적 구속력은 가지나 원칙적으로 기판력은 인정되지 않는다. 다만, 항고로 불복할 수 있는 결정 등 실체적 권리관계와 유사한 효력을 갖는 일부 재판에 대해서는 제한적으로 인정될 여지가 있다.

**(3) 확정판결과 동일한 효력이 있는 조서**

- 청구의 포기·인낙조서 및 화해조서는 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 기판력이 발생한다.

**(4) 외국법원의 확정판결[민소법 제217조]**

- 민사소송법 제217조의 요건(재판관, 송달, 공서양속, 상호보증 등)을 갖춘 외국법원의 확정판결은 국내에서도 기판력이 인정된다.

**(5) 소송물에 대한 실질적 판단**

- 기판력은 판결주문에 포함된 소송물에 대한 실질적 판단이 있을 때 발생한다. 따라서 소송요건 흠결로 인한 각하판결은 해당 소송요건의 부존재에 대해서만 기판력이 있고 실체적 권리관계에는 영향을 미치지 않는다.

**3. 기판력의 본질**

**(1) 학설**

- 기판력의 본질에 관하여는 후소 법원이 전소 판단과 다른 판단을 할 수 없다는 반복금지설과 전소의 판단 내용이 후소의 실체적 내용을 구속한다는 실체협력설 등이 대립한다.

**(2) 판례**

- 대법원은 확정판결의 기판력은 그 판결의 주문에 포함된 것, 즉 소송물로 주장된 법률관계의 존부에 관한 판단에만 미친다는 입장을 견지하며, 후소 법원이 전소 판단과 모순되는 판단을 할 수 없음을 강조한다.

**(3) 검토**

- 현대 소송법에서는 법적 안정성과 당사자의 신뢰 보호를 위해 전소의 판단 내용이 후소를 구속한다는 구속력설의 관점에서 기판력을 파악하는 것이 타당하다.

**III. 기판력의 범위**

**1. 기판력의 주관적 범위**

**(1) 당사자**

- 기판력은 원칙적으로 판결에 관여한 당사자에게만 미친다. 이는 절차적 기본권인 들을 권리를 보장하기 위함이다.

**(2) 당사자와 같이 불 제3자[민소법 제218조]**

- 민사소송법 제218조에 따라 변론종결 후의 승계인, 목적물 소지자, 당사자를 위하여 소송대리인으로서 소송을 수행한 자 등에게 기판력이 확장된다.

**(3) 일반 제3자에의 확장**

- 가사소송이나 형성소송과 같이 대세효가 인정되는 경우에는 당사자 이외의 제3자에게도 기판력이 미칠 수 있다.

**2. 기판력의 객관적 범위**

**(1) 판결주문에서의 판단[민소법 제216조]**

- 기판력은 판결주문에 포함된 소송물에 관한 판단에만 미치는 것이 원칙이다. 청구의 인용 또는 기각 여부가 그 대상이다.



## (2) 판결이유 중의 판단

- 판결이유에서 실시된 사실인정이나 법률적 판단에는 원칙적으로 기판력이 발생하지 않는다. 다만, 민사소송법 제216조 제2항에 의해 상계의 항변이 판단된 경우에는 그 상계로 주장한 채권의 존부에 대하여 예외적으로 기판력이 인정된다.

## 3. 기판력의 시적 범위

### (1) 기판력의 표준시

- 기판력은 사실심 변론종결 시를 표준으로 하여 발생한다. 변론 없이 한 판결의 경우에는 판결 선고 시가 표준이 된다.

### (2) 변론종결 전에 존재한 사유

- 표준시 이전에 존재하였던 사유는 설령 소송에서 주장하지 않았더라도 실권된다. 따라서 이를 근거로 확정판결의 효력을 다룰 수 없다.

### (3) 변론종결 뒤에 발생한 새로운 사유

- 표준시 이후에 새롭게 발생한 사실관계(채무의 변제, 소멸시효의 완성 등)는 기판력의 차단을 받지 않으므로 이를 근거로 청구이익의 소 등을 제기할 수 있다.

### (4) 변론종결 뒤의 형성권 행사

- 상계권, 해제권 등 형성권이 변론종결 뒤에 행사된 경우, 그 기초가 되는 사실이 종결 전의 것이라면 기판력에 의해 차단된다는 것이 판례의 일반적 입장이다.

### (5) 정기금판결에 대한 변경의 소[민소법 제252조]

- 장래의 부양료 등 정기금 지급을 명한 판결이 확정된 후, 표준시 이후에 사정변경이 생긴 경우 당사자는 그 판결의 변경을 구하는 소를 제기할 수 있다.

## IV. 채권자취소소송의 주요논점

### 1. 채권자취소권의 요건사실

- 채권자취소권이 성립하기 위해서는 피보전채권의 존재, 채무자의 사해행위, 채무자 및 수익자의 사해의사가 필요하다. 피보전채권은 원칙적으로 사해행위 이전에 발생하여야 하나, 예외적으로 사해행위 당시 채권 성립의 기초가 형성되어 있고 가까운 시일 내에 성립할 고도의 개연성이 있는 경우 인정된다.

### 2. 채권자취소소송의 법적 성질

- 학설은 채권적 효력만을 인정하는 상대적 무효설과 실질적인 법률관계의 복구를 인정하는 형성소송설 등이 대립하나, 판례는 사해행위 취소의 효력이 취소채권자와 수익자 사이에서만 발생하는 상대적 효력설(형성소송과 이행소송의 병합)의 입장을 취한다.

### 3. 채권자취소소송의 피고적격

- 채권자취소소송의 피고는 수익자 또는 전득자이며, 채무자는 피고적격이 없다. 이는 사해행위의 취소로 인한 권리 복구가 채무자와 수익자 사이의 관계를 직접 해소하는 것이 아니라 채권자에 대한 관계에서만 상대적으로 무효화되는 것이기 때문이다.

### 4. 채권자취소소송 중 채권자취소소송의 제기의 중복소제기 여부

#### (1) 수인의 채권자가 채권자취소소송을 행사하는 경우

- 여러 채권자가 동일한 사해행위에 대하여 각각 취소소송을 제기하는 경우, 이는 중복소제기에 해당하지 않는다. 각 채권자는 자신의 채권을 보전하기 위해 독립된 소권이 있기 때문이다.

#### (2) 채권자가 수익자를 피고로 채권자취소의 소를 이중으로 행사하는 경우

- 동일한 채권자가 동일한 피보전채권을 바탕으로 동일한 사해행위를 취소하는 소를 다시 제기하는 것은 중복소제기 또는 기판력에 저촉되어 불허된다.

### 5. 채권자취소소송에서의 기판력의 범위

#### (1) 채무자 또는 채무자와 수익자와의 관계에서 기판력의 저촉 여부

- 채권자취소소송의 판결은 채권자와 피고(수익자 등) 사이에서만 효력이 있으므로, 채무자에게는 기판력이 미치지 않는다.

#### (2) 각 채권자가 채권자취소 및 원상회복소송을 제기한 경우

- 어느 한 채권자가 승소하여 원상회복이 이루어지면 다른 채권자의 소송물은 목적을 달성하여 소의 이익이 소멸될 수 있으나, 원칙적으로 각 소송의 기판력은 개별적으로 발생한다.

#### (3) 한 명의 취소채권자가 피보전채권을 달리하여 채권자취소권을 이중으로 행사하는 경우

- 피보전채권이 다르다면 소송물도 다르다고 보아 기판력이 미치지 않는다는 것이 일반적 견해이다.

#### (4) 원물반환 청구 승소 후 다시 가액배상을 청구하는 경우

- 원물반환 판결이 확정된 후에는 특별한 사정변경이 없는 한 동일한 사해행위에 대해 가액배상을 청구하는 것은 기판력에 저촉되어 허용되지 않는다.

#### (5) 선행소송 종료 후 증가된 시가상당의 가액반환을 구하는 후행소송

- 가액배상액의 산정은 사해행위 취소 판결 선고 시를 기준으로 하므로, 확정판결 후 시가 상승분만을 따로 청구하는 것은 기판력의 시적 범위에 비추어 허용되기 어렵다.

### 6. 채권자취소소송에서 피보전채권의 추가·교환·승계

#### (1) 피보전채권의 추가·교환이 소변경인지 여부

- 피보전채권을 추가하거나 다른 채권으로 교환하는 것은 소송물의 변경을 수반하므로 소의 변경에 해당한다.

#### (2) 제소기간의 준수 여부

- 피보전채권을 추가하는 경우, 추가된 시점을 기준으로 제소기간(취소원인을 안 날로부터 1년, 사해행위가 있는 날로부터 5년)의 준수 여부를 판단한다.

#### (3) 다른 채권자의 피보전채권을 승계하여 소송하는 경우

- 소송 계속 중 피보전채권이 양도되어 승계인이 소송을 승계하는 경우에는 당초 소 제기 시를 기준으로 제소기간을 판단한다.

## V. 판결의 무효

### 1. 판결의 부존재

- 판결의 부존재란 재판의 형식적 외관조차 갖추지 못한 경우를 의미한다. 법관이 아닌 자가 선고하거나, 판결서 작성이 전혀 없는 경우 등이 이에 해당하며 소송법상 아무런 효력이 없다.

## 2. 무효의 판결

### (1) 의의

- 외관상 판결은 존재하나 중대한 하자로 인해 판결로서의 효력이 발생하지 않는 상태를 말한다.

### (2) 무효사유

- 재판권이 없는 법원이 행한 재판, 당사자 대립의 구조를 결여한 경우(사망자를 피고로 한 판결) 등이 무효사유에 해당한다.

### (3) 효력

- 무효인 판결은 기판력이 발생하지 않으며, 집행력도 인정되지 않는다. 별도의 상소나 재심 없이도 그 효력을 부정할 수 있다.

## 3. 판결의 편취

### (1) 편취판결의 의의

- 당사자가 부정한 수단을 사용하여 법원을 기망함으로써 자기에게 유리한 판결을 받아내는 것을 말한다.

### (2) 편취판결의 유형

- 성명모용소송, 허위의 주소로 송달하게 하여 판결을 받는 경우, 증거 위조 등이 대표적인 유형이다.

### (3) 편취판결의 효력

- 편취된 판결이라 하더라도 형식적으로 확정되면 기판력이 발생한다. 다만, 하자의 정도에 따라 무효로 보거나 구제수단을 통해 효력을 배제하여야 한다.

### (4) 구제수단

- 확정 전에는 상소를 통해 다툴 수 있고, 확정 후에는 재심의 소를 제기하거나 판결의 집행이 현저히 부당한 경우 청구이의의 소를 통해 구제받을 수 있다.

## Ⅵ. 결론

- 판결은 민사소송 절차의 종국적 산물로서 기판력을 통해 분쟁을 영구적으로 종식시키는 강력한 효력을 지닌다. 중간판결과 종국판결의 구분을 통해 심리의 효율성을 도모하고, 기판력의 주관적·객관적·시적 범위를 명확히 함으로써 사법 판단의 일관성을 유지한다. 특히 채권자취소소송과 같은 복잡한 실체법적 권리 행사 과정에서 발생하는 기판력의 충돌 문제는 상대적 효력설의 관점에서 당사자의 이익을 균형 있게 조절하여야 한다. 또한 판결의 무효나 편취와 같은 예외적인 상황에 대한 구제수단을 완비함으로써 형식적인 법치주의가 실질적인 정의를 훼손하지 않도록 보완하는 체계가 필수적이다. 이러한 판결 이론의 정립은 국민의 재판받을 권리를 실질적으로 보장하고 사법 신뢰를 구축하는 근간이 된다.

## <제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제1절 청구의 원시적 병합>

### I. 청구의 객관적 병합

#### 1. 서설

##### (1) 의의[민소법 제253조]

- 청구의 객관적 병합이란 하나의 소송절차에서 원고가 피고에 대하여 여러 개의 청구를 동시에 제기하는 것을 말한다. 이는 소송절차의 경제를 도모하고, 동일한 당사자 사이의 관련 분쟁을 한꺼번에 해결하여 판결의 모순·저촉을 방지하는 데 목적이 있다. 민사소송법 제253조는 여러 개의 청구는 같은 종류의 소송절차를 따르는 경우에만 한꺼번에 제기할 수 있다고 규정하고 있다.

##### (2) 공격방법의 복수와의 구별

- 객관적 병합은 소송물 자체가 복수인 경우를 의미한다. 반면, 하나의 소송물(손해배상청구)을 뒷받침하기 위하여 여러 개의 사실관계나 법적 근거(불법행위와 채무불이행)를 주장하는 것은 공격방법의 복수에 해당하며, 이는 병합소송이 아닌 단일소송 내의 자료 제출 문제로 취급된다.

#### 2. 객관적 병합의 요건

##### (1) 동종절차

- 병합되는 여러 개의 청구가 모두 같은 종류의 소송절차에 따라 심판될 수 있어야 한다. 예를 들어 민사소송절차로 진행되는 청구와 행정소송절차 또는 가사소송절차로 진행되어야 할 청구는 원칙적으로 병합할 수 없다. 다만, 관련 사건의 경우 특별법에 따라 예외적으로 병합이 허용되기도 한다.

##### (2) 공통관할

- 여러 개의 청구 중 적어도 어느 하나에 대하여 법원이 관할권을 가지고 있어야 한다. 민사소송법 제25조에 따른 관련재판적 규정이 적용되어, 하나의 청구에 관할권이 있다면 다른 청구에 대해서도 관할권이 인정될 수 있다. 그러나 전속관할에 속하는 청구가 포함된 경우에는 관련재판적이 인정되지 않으므로 병합에 주의를 요한다.

##### (3) 청구 관련성

- 민사소송법 제253조는 청구 간의 관련성을 명시적인 요건으로 규정하고 있지 않다. 따라서 당사자가 동일하다면 원칙적으로 아무런 관련이 없는 청구라도 병합하여 제기할 수 있다. 이를 단순병합의 자유라고 한다. 다만, 뒤에서 서술할 선택적·예비적 병합의 경우에는 그 성질상 청구 간의 양립 불가능성이나 밀접한 관련성이 전제되어야 한다.

### II. 객관적 병합의 태양

#### 1. 단순병합

##### (1) 의의

- 단순병합이란 원고가 여러 개의 청구를 제기하면서 그 모두에 대하여 심판과 인용을 구하는 형태이다. 각 청구는 독립되어 있으며 법원은 모든 청구에 대하여 각각 판단을 내려야 한다.

##### (2) 요건

- 특별한 제한은 없으며 앞서 언급한 객관적 병합의 일반 요건(동종절차, 관할)만 갖추면 된다. 청구 간에 양립이 가능한 경우뿐만 아니라 관련이 없는 청구들도 가능하다.

##### (3) 심판

- 법원은 각 청구에 대하여 별개로 심리하고 판결주문에서 각각에 대하여 인용 또는 기각의 판단을 내려야 한다. 일부 청구에 대해서만 심리를 마친 경우 일부판결을 할 수도 있다.

##### (4) 상소

- 일부 청구에 대해서만 상소가 제기된 경우, 상소되지 않은 부분은 확정되는 것이 원칙이다. 그러나 심리의 편의상 전체가 상소심으로 이심되는 효과가 발생하는 경우도 있다.

##### (5) 관련 문제

- 주된 청구와 그에 부수하는 이자, 지연손해금 청구 등의 병합도 단순병합의 전형적인 예이다. 이때 부수적 청구는 소송가액 산정 시 합산되지 않는 특례가 적용된다.

#### 2. 선택적 병합

##### (1) 의의

- 선택적 병합이란 원고가 여러 개의 청구를 하면서 그중 어느 하나만 인용되면 목적을 달성하는 형태이다. 여러 개의 청구가 동일한 경제적 이익을 목적으로 하거나 법률적 평가만을 달리하는 경우에 주로 활용된다.

##### (2) 요건

- 병합된 여러 청구 사이에 성질상 양립이 가능해야 한다. 또한, 어느 한 청구가 인용되면 다른 청구에 대한 심판이 필요 없어야 한다. 예를 들어 해제에 따른 원상회복청구와 손해배상청구를 선택적으로 제기하는 경우이다.

##### (3) 심판

- 법원은 여러 청구 중 어느 하나를 인용할 수 있으면 그 청구만을 인용하면 되고 나머지는 판단할 필요가 없다. 그러나 모든 청구가 이유 없다고 판단할 때는 모든 청구를 기각한다는 판단을 주문에 표시해야 한다. 일부분만을 인용하고 나머지를 기각하는 일부판결은 허용되지 않는다.

##### (4) 상소

- 선택적 병합에서 원고 승소 판결이 내려져 피고가 상소한 경우, 선택적 청구 전부가 상소심으로 이심된다. 상소심은 원심이 판단하지 않은 다른 청구에 대해서도 심판할 수 있다.

#### 3. 예비적 병합

##### (1) 의의

- 예비적 병합이란 원고가 주위적 청구가 인용될 것을 조건으로 하여 예비적 청구에 대한 심판을 구하는 형태이다. 주로 주위적 청구와 예비적 청구가 서로 양립할 수 없는 관계에 있을 때 사용된다.

##### (2) 요건

- 청구 상호 간에 양립되지 않는 배타적 관계가 있어야 한다. 주위적 청구가 기각되거나 불능이 될 경우를 대비하여 차선책을 마련하는 것이므로, 청구 간에 논리적 선후 관계가 존재해야 한다.

##### (3) 심판

- 법원은 반드시 주위적 청구부터 심판해야 한다. 주위적 청구가 인용되면 예비적 청구는 심판할 필요가 없으며, 주위적 청구가 기각될 때에만 비로소 예비적 청구를 심판한다. 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구에 대해 판단하지 않는 재판의 누락이 발생하지 않도록 주의해야 한다.

#### (4) 상소

- 주위적 청구 기각, 예비적 청구 인용 판결에 대해 피고만 상소한 경우, 주위적 청구 부분도 상소심으로 이심된다. 이를 이심의 범위와 심판의 범위 문제라고 한다. 상소심에서 주위적 청구가 이유 있다고 판단되면 예비적 청구 인용 판결을 취소하고 주위적 청구를 인용해야 한다.

### 4. 부진정예비적 병합

#### (1) 의의

- 부진정예비적 병합이란 청구 상호 간에 양립이 가능함에도 불구하고 원고가 임의로 순위를 붙여 심판을 구하는 형태를 말한다. 예를 들어, 제1차적으로 매매대금 지급을 구하고, 그것이 안 될 경우 제2차적으로 대여금 반환을 구하는 경우이다.

#### (2) 허용 여부

- 과거에는 양립 가능한 청구에 순위를 붙이는 것이 소송절차를 불안정하게 한다고 하여 부정하는 견해가 있었으나, 최근 판례는 원고의 처분권주의를 존중하여 이를 허용하고 있다.

#### (3) 병합요건

- 양립 가능한 청구들 사이에서도 원고가 주관적으로 정한 순서에 따라 심판을 받을 필요성이 인정된다면 가능하다. 특별히 엄격한 객관적 요건을 요구하지 않는다.

#### (4) 인정범위

- 청구의 기초가 동일하거나 경제적 목적이 동일한 경우뿐만 아니라, 전혀 별개의 청구라도 원고가 순위를 붙여 제기한다면 부진정예비적 병합으로 취급될 수 있다.

#### (5) 심판방법

- 기본적으로 예비적 병합의 심판 원칙을 따른다. 즉, 선순위 청구가 인용되면 후순위 청구는 판단하지 않는다. 다만, 선순위 청구가 일부만 인용된 경우 후순위 청구를 심판해야 하는지에 대해서는 원고의 의사 해석에 따라 달라질 수 있다. 판례는 원고가 전부 인용을 조건으로 한 것이라면 일부 인용 시에도 후순위 청구를 심판해야 한다는 입장이다.

### Ⅲ. 결론

- 청구의 원시적 병합은 복잡다단한 현대 사회의 법률 분쟁을 효율적으로 해결하기 위한 핵심적인 제도이다. 단순병합을 통한 절차 경제의 실현, 선택적 병합을 통한 청구권 행사의 유연성 확보, 예비적 병합을 통한 권리 구제의 확실성 제고는 민사소송법이 추구하는 적정·공정·신속·경제라는 이념에 부합한다. 특히, 부진정예비적 병합의 허용은 당사자의 처분권주의를 최대한 존중하려는 사법부의 의지를 보여준다. 다만, 병합의 태양에 따라 이심의 범위나 상소심의 심판 대상이 달라지는 등 기술적인 복잡성이 수반되므로, 법원은 원고의 병합 취지를 정확히 해석하여 재판의 누락이나 모순된 판단이 발생하지 않도록 정밀한 사법적 통제를 수행해야 한다. 이러한 병합소송 이론의 정립은 소송 당사자에게는 예측 가능성을 제공하고 법원에는 일관된 심판 기준을 제시함으로써 사법 정의 실현에 기여한다.

## <제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제2절 청구의 후발적 병합>

### I. 청구의 변경

#### 1. 의의[민소법 제262조]

- 청구의 변경이란 원고가 소송계속 중에 소송물인 청구를 변경하는 것을 말한다. 이는 소의 제기 후에 새로운 청구를 추가하거나 종전의 청구를 다른 청구로 갈음하는 형태로 나타나며, 분쟁의 일거 해결과 소송경제 도모를 목적으로 한다. 민사소송법 제262조는 청구의 기초에 변경이 없는 한 사실심의 변론종결 시까지 청구를 변경할 수 있음을 명시하고 있다.

#### 2. 청구변경의 방법

##### (1) 청구취지의 변경

- 심판의 대상인 결론 부분을 변경하는 것이다. 금전지급청구에서 금액을 증액하거나 감액하는 경우, 또는 특정물의 인도를 구하다가 그 가액의 배상을 구하는 형태가 이에 해당한다.

##### (2) 청구원인의 변경

- 청구를 뒷받침하는 구체적인 사실관계나 법률적 근거를 변경하는 것이다. 동일한 대여금 청구 내에서 대여일자를 정정하거나, 불법행위로 인한 손해배상을 청구하다가 채무불이행으로 인한 손해배상으로 근거 법조를 바꾸는 경우를 포함한다.

##### (3) 공격방어방법의 변경

- 청구의 변경은 소송물 자체의 변경을 의미하므로, 단순히 소송물을 유지한 채 새로운 증거를 제출하거나 사실적 주장을 보충하는 공격방어방법의 변경과는 구별된다. 청구의 기초가 동일하더라도 소송물이 달라지지 않는다면 이는 청구의 변경이 아닌 자료의 보강에 불과하다.

#### 3. 청구변경의 형태

##### (1)교환적 변경

- 종전의 청구를 철회하고 새로운 청구로 갈음하는 것이다. 이는 구청구의 취하와 신청구의 제기가 결합된 형태이다. 실무상 구청구에 대한 소취하의 효력이 발생하므로 피고의 동의 여부가 문제될 수 있으나, 청구기초의 동일성이 인정되는 한 피고의 동의 없이도 가능하다는 것이 통설이다.

##### (2)추가적 변경

- 종전의 청구를 유지하면서 새로운 청구를 덧붙이는 것이다. 이는 청구의 객관적 병합이 사후적으로 발생하는 형태이며, 단순·선택적·예비적 병합의 모습으로 나타날 수 있다.

##### (3)변경형태가 불분명한 경우

- 원고의 의사가 교환적인지 추가적인지 명확하지 않을 때 법원은 석명권을 행사하여 이를 명확히 해야 한다. 일반적으로 원고에게 유리하도록 추가적 변경으로 해석하는 경향이 있으나, 전후 사정에 비추어 종전 청구를 유지할 의사가 없음이 명백하다면 교환적 변경으로 취급한다.

#### 4. 청구변경의 요건

##### (1)동종의 소송절차

- 기존의 소송절차와 변경된 새로운 청구의 소송절차가 같아야 한다. 민사소송 중에 가사소송이나 행정소송으로 변경하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

##### (2)공통의 관할권

- 변경된 신청구가 그 법원의 관할에 속해야 한다. 다만, 민사소송법 제25조의 관련재판적 규정에 의하여 본래의 청구에 관할권이 있다면 신청구에 대해서도 관할권이 인정될 수 있다.

##### (3)청구기초의 동일성

- 가장 핵심적인 요건으로, 신청구가 구청구와 동일한 사회적 사실관계나 경제적 이익을 바탕으로 해야 한다. 양 청구의 이익관계가 밀접하여 구청구의 심리자료를 신청구의 심리에 그대로 활용할 수 있는 경우에 인정된다.

##### (4)소송절차를 현저히 지연시키지 않을 것

- 청구의 변경으로 인하여 새로운 증거조사가 광범위하게 필요하게 되어 소송의 완결이 늦어지는 경우에는 허용되지 않는다. 이는 피고의 방어권 보호와 신속한 재판을 위한 요건이다.

##### (5)사실심에 계속되고 변론종결 전일 것

- 청구의 변경은 1심 또는 항소심에서만 가능하다. 상고심은 법률심이므로 청구의 변경이 허용되지 않는다. 반드시 변론종결 전에 신청되어야 한다.

#### 5. 청구변경의 절차

- 청구의 변경은 서면으로 신청하는 것이 원칙이다. 변경신청서에는 변경된 청구취지와 청구원인을 명확히 기재해야 하며, 이 서면은 피고에게 송달되어야 한다. 다만, 변론기일에서 말로 변경하고 피고가 이에 대해 이의 없이 응한 경우에는 구술에 의한 변경도 유효할 수 있다.

#### 6. 청구변경의 심판[민소법 제263조]

##### (1)청구변경의 적법성 심사와 신청구심판

- 법원은 우선 청구변경의 요건을 심사하여 부적법한 경우 결정으로 각하한다. 요건을 갖춘 경우 신청구를 대상으로 심리를 진행한다. 교환적 변경의 경우 구청구는 심판 대상에서 제외되며, 추가적 변경의 경우 병합소송의 원리에 따라 심판한다.

##### (2)청구변경의 간과판결

- 원고가 청구변경을 신청하였음에도 법원이 이를 간과하고 종전 청구에 대해 판결한 경우 이는 재판의 누락에 해당한다. 이 경우 누락된 부분은 여전히 법원에 계속된 상태로 남게 된다.

##### (3)항소심의 판결주문

- 항소심에서 청구가 교환적으로 변경된 경우, 1심 판결은 실효된다. 따라서 항소심 법원은 1심 판결을 취소하고 신청구에 대하여만 판결을 내려야 한다. 신청구가 이유 있다면 신청구 인용 판결을, 이유 없다면 신청구 기각 판결을 내린다.

### II. 중간확인의 소

#### 1. 의의[민소법 제264조]

- 중간확인의 소는 소송계속 중 본래의 청구의 당부와 관련하여 선결적 법률관계에 대하여 다툼이 있는 경우, 당사자가 그 법률관계의 확정을 위하여 추가로 제기하는 확인의 소를 말한다. 기판력의 범위를 확장하여 분쟁을 근본적으로 해결하는 데 목적이 있다.

#### 2. 요건

##### (1)동종의 소송절차

- 본소와 중간확인의 소는 같은 소송절차에 따라 심판될 수 있어야 한다.

## (2) 공통의 관할권

- 본소가 계속된 법원에 중간확인의 소에 대한 관할권이 있어야 한다. 관련재판적에 의해 관할이 발생할 수 있다.

## (3) 다름이 있는 선결적 법률관계의 확인

- 본소 청구의 재판 결과가 그 법률관계의 존부에 달려 있어야 한다. 예를 들어 소유권이전등기청구 소송 중에 그 전제가 되는 매매계약의 유효 여부를 확인하는 경우이다. 단순히 사실관계의 확인은 대상이 되지 않는다.

## (4) 다른 법원의 전소관할에 속하지 않을 것

- 확인하고자 하는 법률관계가 다른 법원의 전속관할에 속하는 경우에는 제기할 수 없다.

## (5) 본래의 소가 사실심에 계속되고 변론종결 전일 것

- 청구의 변경과 마찬가지로 항소심 변론종결 전까지만 제기가 가능하다.

## 3. 절차

- 중간확인의 소는 독립된 소의 제기이므로 소장의 형식에 준하는 서면을 제출해야 한다. 다만, 기존 소송절차를 이용하므로 인지대 등에 있어서 일정한 혜택이 있을 수 있다.

## 4. 심판

- 법원은 본소와 중간확인의 소를 병합하여 심리하고 하나의 판결로 선고해야 한다. 중간확인의 소가 부적법하면 각하하고, 적법하면 본소의 선결문제로서 판단함과 동시에 주문에서 그 존부를 확정한다.

## III. 반소

### 1. 반소의 의의

#### (1) 개념[민소법 제269조]

- 반소란 소송계속 중에 피고가 원고를 상대로 동일한 소송절차 내에서 제기하는 독립된 소를 말한다. 피고가 수세적 방어에 그치지 않고 공세적 공격을 가하는 형태이다.

#### (2) 인정취지

- 동일한 당사자 사이의 밀접한 관련이 있는 청구들을 하나의 절차에서 심리함으로써 심리의 중복을 피하고 판결의 모순을 방지하며 소송경제를 달성하기 위함이다.

### 2. 반소의 법적 성질

#### (1) 독립한 소

- 반소는 본소에 부수된 방어방법이 아니라 독립된 소이다. 따라서 본소가 취하되더라도 피고의 동의가 없는 한 반소는 소멸하지 않고 독자적으로 존속한다.

#### (2) 반소의 당사자

- 원칙적으로 본소의 피고가 원고가 되고, 본소의 원고가 피고가 된다. 예외적으로 예비적 피고 추가 등 특수한 경우에 제3자를 포함하는 반소가 논의되기도 하나 원칙은 본소 당사자 간의 소송이다.

### 3. 반소의 모습

#### (1) 단순반소와 예비적 반소

- 피고가 조건 없이 제기하는 것이 단순반소이고, 본소가 인용될 것을 대비하거나 기각될 것을 대비하여 제기하는 것이 예비적 반소이다.

#### (2) 재반소

- 원고가 피고의 반소에 대하여 다시 반소를 제기하는 것이다. 이론적으로는 가능하나 소송절차의 복잡화를 방지하기 위해 실무상 엄격히 제한되거나 본소의 청구변경으로 처리되는 경우가 많다.

### 4. 반소의 요건

#### (1) 동종의 소송절차

- 본소와 반소가 같은 종류의 소송절차를 따라야 한다.

#### (2) 공통의 관할

- 본소 법원에 반소에 대한 관할권이 있어야 한다. 민사소송법 제269조 제2항은 반소가 다른 법원의 전속관할에 속하지 않는 한 관할권이 인정됨을 명시하고 있다.

#### (3) 상호관련성

- 반소청구가 본소청구 또는 본소의 방어방법과 법률상·사실상 밀접한 관련이 있어야 한다. 관련성이 없는 반소는 무분별한 소송 지연을 초래할 수 있기 때문이다.

#### (4) 본소절차를 현저히 지연시키지 않을 것

- 반소 제기로 인해 기존 소송의 완결이 늦어지지 않아야 한다. 특히 항소심에서의 반소 제기는 상대방의 심급의 이익을 해칠 우려가 있어 원고의 동의나 반소 청구의 기초가 1심에서 충분히 심리된 경우 등으로 제한된다.

#### (5) 본소가 사실심에 계속되고 변론종결 전일 것

- 상고심에서는 반소를 제기할 수 없다.

### 5. 반소의 절차

#### (1) 반소의 제기

- 반소장 서면을 제출해야 하며, 인지를 첨부해야 한다. 반소장은 원고에게 송달되어야 소송계속의 효과가 발생한다.

#### (2) 반소요건과 일반소송요건의 조사

- 법원은 반소의 특수 요건뿐만 아니라 당사자능력, 소의 이익 등 일반적 소송요건을 모두 갖추었는지 직권으로 조사한다.

### 6. 반소의 심판

#### (1) 본안심판

- 법원은 본소와 반소를 병합하여 심리한다. 판결 주문에서 본소와 반소에 대하여 각각 판단을 내려야 한다. 다만, 본소와 반소가 동일한 목적물을 대상으로 하거나 상계와 관련되는 등 관계가 밀접할 경우 논리적 일관성을 유지해야 한다.

## (2) 반소의 취하

- 피고는 본안에 대한 응소가 있기 전까지 자유롭게 반소를 취하할 수 있다. 본소가 취하된 후에도 반소를 유지할 수 있으나, 본소가 취하되었으므로 반소도 취하하겠다는 의사표시가 있는 경우 절차는 종료된다.

## (3) 채권자취소권과 반소와의 관계

- 피고가 본소에 대한 방어방법으로 채권자취소권을 행사하며 반소를 제기하는 경우, 판례는 채권자취소의 효과를 소송상 주장하기 위해서는 반드시 반소 또는 독립된 소의 형태를 갖추어야 한다고 본다.

## IV. 결론

- 청구의 후발적 병합 제도는 소송계속 중에 발생하는 새로운 분쟁 요소나 방어의 필요성을 기존 절차 내로 수용함으로써 법률관계의 종합적 해결을 가능케 한다. 청구의 변경은 원고에게, 반소는 피고에게 소송의 전략적 구성을 허용하며, 중간확인의 소는 판결의 전제가 되는 법률관계를 명확히 확정 짓는 도구가 된다. 이러한 제도들은 각기 엄격한 요건을 두고 있는데, 이는 소송절차의 안정성과 상대방의 방어권 보장, 재판의 신속성이라는 가치를 조화시키기 위함이다. 특히, 항소심에서의 변경이나 반소 제기는 심급의 이익 침해 가능성이 크므로 더욱 신중한 사법적 판단이 요구된다. 결과적으로 후발적 병합의 적절한 운용은 당사자 간의 실질적 평등을 구현하고 사법 자원의 효율적 배분을 가능하게 하는 민사소송법의 중추적 기능을 담당한다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제1절 공동소송>

**I. 공동소송의 개관**

**1. 의의**

**(1) 개념**

- 공동소송이란 하나의 소송절차에 여러 사람의 원고 또는 여러 사람의 피고가 관여하는 소송 형태를 의미한다. 이는 주관적 병합(객관적 병합은 청구의 병합을 말한다)이라고도 불리며, 단일한 소송계속 내에서 다수의 당사자가 대립하는 구조를 가진다.

**(2) 인정취지**

- 동일한 사실관계나 법률관계에서 비롯된 여러 개의 청구를 하나의 절차에서 심리함으로써 재판의 중복을 피하고 소송비용을 절감하는 소송경제의 도모를 목적으로 한다. 또한, 동일한 사안에 대해 서로 모순되는 판결이 나오는 것을 방지하여 재판의 신뢰를 높이는 효과가 있다.

**(3) 구별**

- 공동소송은 소송대리인이나 소송수행권자와 구별된다. 공동소송인은 각자가 당사자로서의 지위를 가지며, 판결의 효력 또한 원칙적으로 개별 당사자에게 미친다.

**2. 공동소송의 일반요건[민소법 제65조, 제253조]**

- 공동소송이 성립하기 위해서는 주관적 요건과 객관적 요건을 모두 갖추어야 한다. 민사소송법 제65조 전단은 소송목적에 되는 권리나 의무가 여러 사람에게 공통되거나 동일한 사실상·법률상 원인에 바탕을 둔 경우를 규정하고, 후단은 소송목적에 되는 권리나 의무가 같은 종류이며 사실상·법률상 같은 종류의 원인에 바탕을 둔 경우를 규정한다. 또한, 제253조에 따라 여러 개의 청구가 같은 종류의 소송절차를 따라야 하며 공통의 관할권이 존재해야 한다.

**II. 통상의 공동소송**

**1. 통상공동소송의 의의**

- 통상공동소송이란 공동소송인 사이에 소송목적에 법률상 합일적으로 확정될 필요가 없는 공동소송을 말한다. 민사소송법 제65조의 요건을 갖추었으나 필수적 공동소송에 해당하지 않는 모든 경우가 이에 속한다.

**2. 공동소송인 독립의 원칙**

**(1) 의의**

- 공동소송인 1인의 소송행위나 1인에 대한 상대방의 소송행위, 1인에게 발생한 소송사항이 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 않는다는 원칙이다.

**(2) 내용**

- 첫째, 소송진행의 독립이다. 1인에 대한 소송절차의 중단이나 중지는 다른 공동소송인에게 영향을 주지 않는다. 둘째, 소송자료의 독립이다. 1인의 자백이나 증거제출은 다른 인원의 소송자료로 활용되지 않는다. 셋째, 본안결정의 독립이다. 법원은 공동소송인별로 서로 다른 내용의 판결을 내릴 수 있다.

**3. 공동소송인 독립의 원칙의 수정**

**(1) 수정의 원리**

- 통상공동소송이라 하더라도 재판의 모순을 방지하고 심리의 효율을 높이기 위해 독립의 원칙을 완화할 필요가 있다.

**(2) 주장공통의 원칙**

- 공동소송인 1인이 제출한 유리한 주장이 다른 공동소송인에게도 효력을 미치는지에 대해, 우리 판례는 통상공동소송에서는 이를 부정한다. 다만, 변론주의 원칙상 법원이 전체 기록을 토대로 사실을 확정하는 과정에서 간접적으로 반영될 여지는 있다.

**(3) 증거공통의 원칙**

- 공동소송인 1인이 제출한 증거는 다른 공동소송인과의 관계에서도 사실인정의 자료로 삼을 수 있다는 원칙이다. 판례는 증거자료의 불가분성을 근거로 통상공동소송에서도 증거공통의 원칙을 인정한다.

**III. 필수적 공동소송**

**1. 의의**

- 공동소송인 사이에 소송목적에 법률상 합일적으로 확정될 필요가 있는 공동소송을 말한다. 이는 다시 법률상 당사자 전원이 함께 소를 제기하거나 제기당해야만 하는 고유필수적 공동소송과, 각자가 소를 제기할 수 있으나 일단 공동소송이 되면 합일확정이 필요한 유사필수적 공동소송으로 나뉜다.

**2. 고유필수적 공동소송**

**(1) 의의**

- 소송물의 관리처분권이 공동차주나 공동상속인처럼 공동당사자 전원에게 귀속되어, 전원이 합쳐서 소송을 수행하지 않으면 부적법하게 되는 경우이다.

**(2) 인정 여부**

- 합유재산에 관한 소송이나 공동상속재산에 대한 공유물분할청구 등이 이에 해당한다. 다만, 판례는 공유관계에서의 보존행위 등은 고유필수적 공동소송이 아니라고 본다.

**(3) 심판방법**

- 전원이 함께하지 않으면 소를 각하해야 한다. 소송절차에서는 1인의 소송행위가 모두에게 이익이 되는 때에만 효력을 발생하며, 판결은 반드시 전원에 대하여 동일하게 선고되어야 한다.

**3. 유사필수적 공동소송**

**(1) 의의**

- 공동소송인 각자가 단독으로 소를 제기할 권능이 있으나, 판결의 효력이 제3자에게 확장되는 결과 재판의 모순을 피하기 위해 합일확정이 강제되는 경우이다.

**(2) 인정 여부**

- 주주총회결의취소의 소에서 여러 주주가 공동으로 제소하는 경우 등이 대표적이다.

**(3) 심판방법**



- 소송요건은 개별적으로 갖추어도 무방하나, 일단 공동소송이 성립하면 소송자료와 소송진행이 통일되어야 한다. 1인의 상소는 전원에 대하여 효력이 발생한다.

#### **IV. 예비적 · 선택적 공동소송**

##### **1. 의의**

###### **(1) 개념[민소법 제70조]**

- 공동소송인들 중 누구의 청구가 인용될지 불분명하거나, 누구에 대한 청구가 인정될지 불확실한 경우에 대비하여 서열을 붙여 청구하거나(예비적), 선택적으로 청구하는 형태를 말한다.

###### **(2) 인정취지**

- 피고를 누구로 할지, 혹은 원고 중 누가 청구권을 가졌는지 법률적으로 모호할 때 한꺼번에 소를 제기하여 판결의 모순을 막고 당사자의 구제를 도모하기 위함이다.

##### **2. 소송의 유형**

###### **(1) 수동형과 능동형**

- 여러 명의 피고를 상대로 하는 경우를 수동형, 여러 명의 원고가 참여하는 경우를 능동형이라 한다.

###### **(2) 예비형과 선택형**

- 주위적 피고와 예비적 피고를 구분하는 것이 예비형이며, 순위 없이 어느 한 명에 대해서만 청구가 인용되기를 구하는 것이 선택형이다.

###### **(3) 원시형과 후발형**

- 소 제기 당시부터 병합하는 것이 원시형이며, 소송 도중에 피고를 추가하는 방식 등이 후발형이다.

##### **3. 요건**

###### **(1) 법률상 양립 불가능**

- 예비적 · 선택적 공동소송이 허용되기 위해서는 당사자들 사이의 권리 · 의무가 법률상 서로 양립할 수 없는 관계에 있어야 한다. 즉, A에 대한 청구가 인용되면 B에 대한 청구는 반드시 기각되어야 하는 관계여야 한다.

###### **(2) 공동소송인의 일반요건**

- 민사소송법 제65조의 요건을 갖추어야 하며, 주위적 청구와 예비적 청구 사이의 관련성이 인정되어야 한다.

##### **4. 심판방법**

###### **(1) 소송요건의 심사**

- 공동소송인 전원에 대해 개별적으로 소송요건을 심사한다.

###### **(2) 소송자료의 통일**

- 필수적 공동소송에 관한 규정이 준용되므로 소송자료가 통일되어야 한다. 1인의 자백은 다른 이에게 불이익하다면 효력이 없다.

###### **(3) 소송진행의 통일**

- 변론과 판결은 반드시 동시에 행해져야 하며, 일부판결은 허용되지 않는다.

###### **(4) 본안재판의 통일**

- 법원은 양립 불가능한 청구들에 대해 모순 없는 판단을 내려야 한다. 주위적 청구를 인용하면 예비적 청구에 대해서는 판단할 필요가 없으나, 주위적 청구를 기각할 때는 반드시 예비적 청구에 대해 판단해야 한다.

###### **(5) 상소심에서의 소송진행의 통일**

- 일부 당사자에 대한 판결에 대해서만 상소가 제기되더라도 사건 전체가 상소심으로 이심되며, 상소심 법원은 전 당사자에 대해 다시 심판해야 한다.

#### **V. 추가적 공동소송**

##### **1. 의의**

- 소송계속 중에 제3자가 공동소송인으로 가입하거나 기존 당사자가 제3자를 끌어들이는 것을 의미한다. 민사소송법상 명문의 규정은 없으나 실무와 학설에서 논의된다.

##### **2. 해석상 추가적 · 주관적 공동소송 인정 여부**

###### **(1) 학설**

- 긍정설은 소송경제와 분쟁의 일회적 해결을 근거로 허용하자는 입장이고, 부정설은 절차의 복잡화와 상대방의 방어권 침해를 이유로 반대한다.

###### **(2) 판례**

- 대법원은 원칙적으로 민사소송법이 허용하는 예외적인 경우(제68조 필수적 공동소송인 추가 등)를 제외하고는 일반적인 추가적 공동소송을 부정하는 태도를 취하고 있다.

###### **(3) 검토**

- 피고의 동의가 있거나 소송의 기초를 변경하지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용하는 것이 타당하나, 현행법 체계상 명확한 근거가 부족하므로 입법적 해결이 필요하다.

#### **VI. 선정당사자**

##### **1. 의의[민소법 제53조]**

###### **(1) 개념**

- 공동의 이해관계를 가진 여러 사람이 그들 중에서 모두를 위하여 소송을 수행할 1인 또는 여러 명을 선임하는 제도이다. 선정된 자를 선정당사자, 선정한 자를 선정자라고 한다.

###### **(2) 인정취지**

- 다수당사자가 관여하는 소송에서 절차의 복잡성을 피하고 소송을 원활하게 진행하기 위함이다.

##### **2. 요건[민소법 제65조]**

###### **(1) 공동소송을 할 여러 사람이 있을 것**

- 민사소송법 제65조 전단의 요건을 갖춘 다수인이 존재해야 한다.

**(2) 공동의 이해관계가 있을 것**

- 소송목적인 권리·의무가 공통되거나 사실상·법률상 주요한 원인을 같이하여 재판의 결과에 대해 이해를 같이해야 한다.

**(3) 공동의 이해관계가 있는 자 중에서 선정할 것**

- 선정당사자는 반드시 선정자 그룹의 일원이어야 한다. 제3자를 선정하는 것은 허용되지 않는다.

**3. 선정의 방법**

**(1) 의의**

- 선정은 소송계속 전후를 불문하고 할 수 있으며, 서면으로 증명해야 한다.

**(2) 선정의 성질**

- 선정은 일종의 소송상 신임관계로, 대리권의 수여와는 성격이 다르다. 선정당사자는 자신의 이름으로 소송을 수행하는 당사자 본인이 된다.

**4. 선정의 효과**

**(1) 선정당사자의 지위**

- 소송수행권을 독점하며, 모든 소송행위를 할 수 있다. 판결의 결과는 선정자 모두에게 미친다.

**(2) 선정자의 지위**

- 선정자는 소송에서 탈퇴하게 되며, 별도로 소송에 관여할 수 없다. 다만, 선정당사자의 자격이 상실되면 다시 소송에 복귀할 수 있다.

**5. 선정당사자의 자격흡결의 효과**

**(1) 소송요건**

- 선정당사자의 자격은 소송요건이므로 법원은 이를 직권으로 조사해야 한다. 자격이 없는 경우 소를 각하한다.

**(2) 간과판결**

- 자격 흡결을 간과하고 판결이 확정된 경우, 이는 대리권 없는 자에 의한 소송수행과 유사하게 취급되어 재심사유가 될 수 있다.

**6. 선정당사자의 기타 논점**

**(1) 공동의 이해관계가 없는 선정당사자가 인낙한 인낙조서에 대한 재심 가부**

- 공동의 이해관계가 없음에도 선정당사자로 선임되어 행한 인낙은 무효이며, 이에 기초한 인낙조서에 대해서는 준재심의 소를 제기할 수 있다는 것이 판례의 입장이다.

**(2) 선정당사자의 부재소합의**

- 선정당사자가 선정자들을 대표하여 행한 부재소합의는 그 효력이 선정자 전원에게 미친다.

**(3) 선정당사자의 자격상실**

- 선정당사자가 사망하거나 사임하면 자격이 상실된다. 이때 다른 선정당사자가 있다면 그가 소송을 수행하고, 없으면 소송절차는 중단된다.

**VI. 결론**

- 공동소송 제도는 다수의 당사자가 얽힌 복잡한 법률관계를 하나의 사법 절차 안에서 효율적으로 해결하기 위한 필수적 장치이다. 특히, 통상공동소송과 필수적 공동소송의 구별은 당사자의 소송 수행 자유와 재판의 합일확정이라는 가치 사이의 균형점을 찾는 과정이다. 현대 소송에서는 집단적 분쟁이 증가함에 따라 예비적·선택적 공동소송과 선정당사자 제도의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이러한 제도들은 소송절차의 명확성을 확보하고 판결의 모순을 방지함으로써 사법 신뢰를 공고히 하는 데 기여한다. 향후 추가적 공동소송의 광범위한 허용 여부 등 입법적 보완을 통해 다수당사자 소송의 효율성을 더욱 극대화할 필요가 있다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제2절 제3자의 소송참가>

**I. 통상의 보조참가**

**1. 의의[민소법 제71조]**

**(1) 개념**

- 보조참가란 타인 사이의 소송계속 중 소송결과에 대하여 이해관계가 있는 제3자가 한쪽 당사자의 승소를 돕기 위하여 소송에 가입하는 형태를 말한다.

**(2) 인정취지**

- 제3자의 법률상 지위가 당사자 일방의 패소로 인하여 불이익을 입을 우려가 있는 경우, 그 제3자에게 자기의 이익을 옹호할 기회를 부여하고 재판의 모순을 방지하는 데 목적이 있다.

**2. 요건**

**(1) 타인 사이의 소송이 계속 중일 것**

- 보조참가는 타인 사이의 소송이 살아있는 동안에만 가능하다. 판결 확정 후나 소 취하 후에는 참가할 수 없으며, 상고심에서도 가능하다.

**(2) 소송결과에 대하여 이해관계가 있을 것(참가이유)**

- 이때의 이해관계는 법률상 이해관계를 의미한다. 단순히 경제적, 감정적, 사실적 이해관계가 있는 것만으로는 부족하며, 당사자 일방이 패소함으로써 인하여 제3자의 법률상 지위가 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 경우여야 한다.

**(3) 소송절차의 현저한 지연이 없을 것**

- 참가로 인하여 소송절차가 현저하게 지연되어서는 안 된다. 다만, 실무상 이를 이유로 참가를 불허하는 경우는 드물다.

**(4) 소송행위로서의 유효요건을 갖출 것**

- 당사자능력과 소송능력이 있어야 하며, 대리인에 의한 경우 대리권이 증명되어야 한다.

**(5) 참가의 보충성 여부**

- 참가인이 독자적으로 소를 제기할 수 있는 상황이어도 보조참가를 하는 데 지장이 없으므로 보충성은 요구되지 않는다.

**3. 보조참가절차**

**(1) 참가신청**

- 참가의 취지와 이유를 명시하여 서면 또는 구술로 신청한다.

**(2) 참가의 허부**

- 당사자가 이의를 신청하면 법원은 참여 여부를 결정해야 한다. 이의가 없으면 그대로 참가하며, 법원이 직권으로 참가요건을 조사하여 불허할 수도 있다.

**(3) 참가의 종료**

- 본소의 종료, 참가의 취하, 참가불허결정의 확정 등에 의해 종료된다.

**4. 참가인의 소송상 지위**

**(1) 종속적 지위**

- 참가인은 독자적인 당사자가 아니므로 피참가인의 소송행위와 저촉되는 행위를 할 수 없다. 피참가인이 이미 자백한 사실을 부인하거나, 피참가인이 포기한 상소권을 행사할 수 없다.

**(2) 독립적 지위**

- 참가인은 공격방어방법의 제출, 증거신청, 상소 제기 등 모든 소송행위를 스스로 할 수 있다. 피참가인의 행위와 저촉되지 않는 범위 내에서는 독립적 권능을 가진다.

**5. 참가적 효력[민소법 제77조]**

**(1) 의의**

- 보조참가인이 소송에 참여하였음에도 피참가인이 패소한 경우, 그 패소의 책임을 참가인에게도 부담시키는 효력을 의미한다.

**(2) 발생요건**

- 보조참가가 유효하게 이루어지고 피참가인이 패소판결을 받아 확정되어야 한다.

**(3) 범위**

- 판결 주문뿐만 아니라 판결 이유 중에서 패소의 원인이 된 사실인정이나 법률판단에도 미친다. 다만, 전소의 승소 당사자와 참가인 사이에는 발생하지 않으며 피참가인과 참가인 사이에서만 발생한다.

**(4) 참가적 효력의 배제**

- 참가인이 참가 당시 소송의 진행 정도에 따라 소송행위를 할 수 없었거나, 피참가인이 참가인의 소송행위를 방해한 경우, 또는 피참가인이 고의나 과실로 참가인이 알지 못하는 소송행위를 하지 않은 경우에는 효력이 배제된다.

**II. 소송고지**

**1. 의의[민소법 제84조]**

**(1) 개념**

- 소송계속 중 당사자가 그 소송에 참가할 수 있는 제3자에게 소송계속 사실을 법정의 절차에 따라 통지하는 것을 말한다.

**(2) 인정취지**

- 고지자에게는 참가적 효력을 발생시켜 장래의 구상소송 등에서 유리한 지위를 점하게 하고, 피고지자에게는 소송참가 기회를 부여하여 권리를 보호하기 위함이다.

**2. 소송고지의 요건[민소법 제85조]**

- 고지자는 당사자 또는 보조참가인이거나 하거나, 피고지자는 소송참가를 할 수 있는 제3자여야 한다. 고지의 이유와 소송의 진행 정도를 적은 서면을 법원에 제출해야 한다.

**3. 소송고지의 효과**

**(1) 소송법상의 효과[민소법 제86조]**

- 피고지자가 실제로 참가했는지 여부와 상관없이, 참가할 수 있었을 때에 참가한 것으로 보아 참가적 효력이 발생한다.

## (2) 실체법상 효과

- 소송고지서가 제3자에게 송달되면 시효중단 또는 기간준수의 효과가 발생할 수 있다. 이는 최고의 효력을 가지므로 6개월 내에 소 제기 등을 해야 시효중단이 확정된다.

## Ⅲ. 공동소송적 보조참가

### 1. 의의[민소법 제78조]

#### (1) 개념

- 보조참가인에게 판결의 효력이 직접 미치는 경우의 참가를 말한다. 일반 보조참가보다 강력한 지위를 가진다.

#### (2) 인정취지

- 판결의 기판력이 제3자에게 확장되는 경우, 그 제3자의 절차적 보장과 합일확정을 실현하기 위함이다.

### 2. 요건

#### (1) 타인 사이의 소송이 계속 중일 것

- 통상의 보조참가와 동일하다.

#### (2) 당사자적격이 없을 것

- 참가인이 직접 당사자가 되어 공동소송참가를 할 수 있는 상황이라면 공동소송적 보조참가가 아닌 공동소송참가를 해야 한다.

#### (3) 판결의 효력이 미칠 것

- 판결의 기판력이나 집행력이 제3자에게 법률상 당연히 미치는 경우여야 한다. 예컨대 채권자대위소송에서의 채무자나 주주총회결의취소소송에서의 다른 주주 등이 해당한다.

### 3. 참가절차

- 보조참가 절차에 따르나, 재판의 합일확정이 필요하므로 피참가인의 소송 취하나 포기 시 참가인의 동의가 필요할 수 있다.

### 4. 참가인의 소송상 지위

#### (1) 필수적 공동소송 규정준용

- 참가인은 피참가인과 이해관계를 같이하며 판결의 효력을 받으므로 민사소송법 제67조가 준용된다.

#### (2) 독립적 지위

- 피참가인이 소송행위를 게을리하더라도 독자적으로 소송을 유지할 수 있는 강한 독립성이 인정된다.

#### (3) 종속적 지위

- 피참가인의 승소를 돕는 보조적 성격은 남아있으므로 본소를 소멸시키는 행위 등은 할 수 없다.

### 5. 피참가인의 소송상 지위[민소법 제78조, 제67조, 제69조]

#### (1) 유사필수적 공동소송에 준하는 지위

- 피참가인과 참가인은 운명을 같이하므로 소송진행이 통일되어야 한다.

#### (2) 피참가인이 할 수 있는 소송행위

- 통상적인 공격방어방법의 제출 등이 가능하다.

#### (3) 피참가인이 할 수 없는 소송행위

- 참가인에게 불이익한 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 소송상 합의 등은 참가인의 동의 없이 할 수 없다.

### 6. 참가인에 미치는 판결의 효력

- 판결의 기판력이 직접 미치며, 이는 참가적 효력이 아닌 기판력 그 자체로서의 효력을 갖는다.

## Ⅳ. 공동소송참가

### 1. 의의[민소법 제83조]

#### (1) 개념

- 소송목적의 한쪽 당사자와 제3자에게 합일적으로 확정되어야 할 경우, 그 제3자가 공동소송인으로서 소송에 가입하는 것을 말한다.

#### (2) 인정취지

- 필수적 공동소송인이 빠진 채 진행되는 소송의 결함을 치유하고 판결의 모순을 방지하기 위함이다.

### 2. 요건

#### (1) 타인 사이의 소송이 계속 중일 것

- 소송계속 중이어야 하며 상고심에서도 가능하다.

#### (2) 당사자적격이 있을 것

- 참가인이 해당 소송의 당사자로서 본안판결을 받을 자격이 있어야 한다.

#### (3) 합일확정의 효력이 있을 것

- 판결의 효력이 제3자에게 확장되거나 법률상 합일확정이 강제되는 경우여야 한다.

### 3. 참가절차

- 서면으로 신청하며, 필수적 공동소송에 관한 규정이 적용된다.

### 4. 참가인의 소송상 지위

- 참가인은 단순한 보조자가 아니라 완전한 당사자의 지위를 가진다. 따라서 필수적 공동소송인의 1인으로서 민사소송법 제67조에 따른 권리와 의무를 가진다.

## Ⅴ. 독립당사자참가

### 1. 의의[민소법 제79조]

#### (1) 개념

- 타인 사이의 소송계속 중 제3자가 그 소송의 당사자 양쪽 또는 한쪽을 상대방으로 하여 자신의 청구를 병합하여 제기함으로써 3자 간의 분쟁을 한꺼번에 해결하는 제도이다.

#### (2) 인정취지

- 재판의 모순을 방지하고 분쟁을 일회적으로 해결하며, 제3자의 권리 침해를 막기 위함이다.

## 2. 소송의 구조

- 원고, 피고, 참가인의 세 당사자가 대립하는 3면 소송의 구조를 가진다.

## 3. 참가요건

### (1) 타인 사이의 소송이 계속 중일 것

- 사실심 소송계속 중이어야 한다.

### (2) 참가이유

- 민사소송법 제79조에 따라 권리취락참가(소송목적의 전부나 일부가 자기의 권리라고 주장) 또는 사해방지참가(원고와 피고가 공모하여 참가인의 권리를 침해하려 한다고 주장) 중 하나에 해당해야 한다.

### (3) 참가취지

- 원고와 피고 모두를 상대로 하거나(양면참가), 일방만을 상대로(단면참가) 할 수 있다.

### (4) 청구병합의 요건 및 소송요건을 갖출 것

- 참가인의 청구는 기존 소송과 관련성이 있어야 하며 공통의 관할권이 존재해야 한다.

## 4. 참가절차[민소법 제79조, 제72조]

### (1) 참가신청

- 참가신청서를 제출하며 원고와 피고 모두에게 송달되어야 한다.

### (2) 독립당사자참가를 하면서 예비적으로 보조참가를 할 수 있는지 여부

- 판례는 독립당사자참가가 요건 미비로 각하될 것에 대비하여 예비적으로 보조참가 신청을 하는 것을 허용한다.

### (3) 참가신청의 효과

- 새로운 소 제기의 효과가 발생하며 시효중단 등의 효력이 생긴다.

## 5. 참가심판

### (1) 참가요건과 소송요건 조사

- 법원은 직권으로 참가요건을 조사하며 요건 불비 시 각하한다.

### (2) 본안심판

- 세 당사자의 청구를 병합하여 심리한다.

### (3) 본안판결

- 3면 소송의 성질상 세 당사자 간의 권리관계를 모순 없이 확정하는 합일확정판결을 내려야 한다.

### (4) 판결에 대한 상소

- 당사자 1인의 상소는 전원에 대하여 효력이 미치며, 사건 전체가 상소심으로 이심된다.

## 6. 3면 소송의 붕괴

### (1) 본소 취하·각하

- 본소가 부적법하여 각하되거나 취하되더라도 참가인의 청구가 독립적인 요건을 갖추었다면 독립당사자참가 소송은 그대로 유지될 수 있다.

### (2) 참가의 취하·각하

- 참가인이 탈퇴하거나 참가가 각하되면 다시 원고와 피고 사이의 2면 소송으로 돌아간다.

### (3) 소송탈퇴[민소법 제80조]

- 독립당사자참가가 있는 경우, 원고 또는 피고는 상대방의 승낙을 얻어 소송에서 탈퇴할 수 있다. 탈퇴 시 판결의 효력은 탈퇴한 당사자에게도 미친다.

## V. 결론

- 제3자의 소송참가는 당사자 간의 소송이 제3자의 권리나 법률상 지위에 영향을 미칠 때, 그 제3자에게 절차적 참여권을 보장하여 분쟁의 일회적 해결과 재판의 모순을 방지하는 중요한 수단이다. 보조참가부터 독립당사자참가까지 각 제도는 이해관계의 강도에 따라 참가인의 지위와 판결의 효력을 차등화하고 있다. 현대의 복잡다단한 법률관계에서 소송의 파급효과가 당사자를 넘어 제3자에게 미치는 경우가 빈번해짐에 따라, 이러한 참가 제도들을 적절히 활용하여 실질적 정의를 실현하고 사법 자원의 낭비를 막는 지혜가 요구된다. 특히 독립당사자참가와 같은 고도의 병합 형태는 재판부의 세심한 합일확정 노력이 뒷받침되어야 그 취지를 온전히 살릴 수 있을 것이다.

## <제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제3절 당사자의 변경>

### I. 임의적 당사자변경

#### 1. 서설

##### (1) 의의

- 임의적 당사자변경이란 소송계속 중 원고의 신청에 의하여 종전의 당사자를 소송에서 물러나게 하고 새로운 당사자를 가입시키는 것을 말한다. 이는 동일한 소송절차 내에서 당사자의 진용을 바꾸는 것으로서, 실제법상 권리관계의 주체가 착오로 잘못 지정되었거나 소송 도중 주체의 변동이 생겼을 때 소송경제를 도모하기 위해 인정된다.

##### (2) 구별개념

- 소송승계는 당사자의 사망이나 권리관계의 양도 등 실제법적 원인에 의해 당사자가 교체되는 것이나, 임의적 당사자변경은 당사자의 의사에 의하여 교체가 이루어진다는 점에서 차이가 있다. 또한, 소송물인 권리관계의 동일성이 유지된다는 점에서 별개의 소를 제기하는 것과도 구별된다.

#### 2. 허용 여부

##### (1) 학설

- 원칙적 불허설은 당사자의 변경이 새로운 소의 제기와 구소의 취하를 결합한 것이므로 상대방의 동의 없이는 허용될 수 없다고 본다. 반면, 원칙적 허용설은 소송경제와 피고의 방어권 보장을 조화시킬 수 있다면 폭넓게 허용해야 한다는 입장이다.

##### (2) 판례

- 과거 판례는 법률에 명문의 규정이 없는 한 임의적 당사자변경은 허용되지 않는다는 엄격한 입장을 고수하였다. 다만, 최근 판례는 피고의 경정이나 고유필수적 공동소송인의 추가 등 법이 정한 예외적인 경우를 제외하고는 원칙적으로 허용하지 않으면서도, 당사자 표시정정의 범위를 확대하여 실질적인 구제를 꾀하고 있다.

##### (3) 검토

- 피고의 방어권 침해 우려와 소송의 혼란을 방지하기 위하여 법이 규정한 범위를 넘어서는 임의적 당사자변경은 제한되는 것이 타당하다. 다만, 명백한 착오가 있거나 소송경제적 요청이 강한 경우에는 표시정정이나 법정 경정제도를 적극 활용할 필요가 있다.

#### 3. 법적 성질

- 임의적 당사자변경은 기존 당사자에 대한 소의 취하와 새로운 당사자에 대한 소의 제기가 결합한 복합적 성질을 가진다. 따라서 신 당사자에 대한 소제기 시효중단 효과는 경정신청서 제출 시를 기준으로 발생하며, 구 당사자에 대한 소송관계는 원칙적으로 소멸한다.

#### 4. 민사소송법상 임의적 당사자변경

##### (1) 피고의 경정[민소법 제260조]

- 원고가 피고를 잘못 지정한 것이 명백한 경우, 제1심 법원의 변론종결 시까지 원고의 신청에 의하여 법원의 허가를 얻어 피고를 바꿀 수 있다. 이때 피고가 본안에 관하여 응소한 뒤라면 피고의 동의가 필요하다.

##### (2) 고유필수적 공동소송인의 추가[민소법 제68조]

- 공동소송인 전원이 소송당사자가 되어야 하는 고유필수적 공동소송에서 일부가 누락된 경우, 법원은 제1심의 변론종결 시까지 원고의 신청에 의하여 누락된 자를 원고 또는 피고로 추가하는 것을 허가할 수 있다. 이는 부적법한 소각하를 방지하기 위한 제도적 장치이다.

### II. 소송승계

#### 1. 서설

##### (1) 의의

- 소송승계란 소송계속 중 당사자의 지위가 제3자에게 포괄적 또는 특정적으로 이전되는 것을 말한다. 소송절차의 안정과 기판력의 주관적 범위를 일치시키기 위해 인정된다.

##### (2) 구별개념

- 임의적 당사자변경이 주관적 의사에 의한 것이라면, 소송승계는 권리관계의 변동이라는 객관적 사실에 기인한다.

##### (3) 유형

- 상속 등 포괄적 사유에 의한 당연승계와 소송물의 양도 등 특정 사유에 의한 특정승계로 나뉜다. 특정승계는 다시 제3자가 스스로 참가하는 참가승계와 당사자가 제3자를 끌어들이는 인수승계로 구분된다.

#### 2. 당연승계

##### (1) 의의

- 당사자의 사망, 법인의 합병 등 포괄승계 사유가 발생하여 소송절차가 중단되었다가 새로운 승계인이 소송을 수계하는 것을 말한다.

##### (2) 인정 여부

- 사망한 당사자의 권리의무가 상속인에게 승계되는 법률관계라면 당연히 인정된다. 다만, 일신전속적 권리(이혼청구권)의 경우에는 승계되지 않고 소송이 종료된다.

##### (3) 당연승계의 사유

- 당사자의 사망, 법인의 합병, 당사자인 법인격의 소멸, 수탁자의 임무 종료 등이 대표적인 사유이다.

##### (4) 당연승계의 효과

- 소송절차는 중단되며, 수계신청에 의하여 새로운 당사자가 소송을 이어받는다. 중단 중의 소송행위는 원칙적으로 무효이나, 소송대리인이 있는 경우에는 중단되지 않고 대리인이 소송을 계속 수행하게 된다.

#### 3. 특정승계

##### (1) 의의

- 소송물인 권리 또는 의무의 일부나 전부가 특정하여 제3자에게 이전된 경우를 말한다.

##### (2) 유형

- 권리가자 소송물을 양도하여 제3자가 소송에 들어오는 경우와, 의무자가 채무를 인수하여 제3자가 소송을 이어받는 경우로 나뉜다.

##### (3) 변론종결 뒤의 승계인과의 관계

- 민사소송법 제218조 제1항에 따라 변론을 종결한 뒤의 승계인에게는 판결의 효력(기판력)이 미친다. 따라서 소송 도중의 승계인은 승계인으로서 소송에 가입하여 자신의 권리를 방어할 실익이 있다.

#### (4) 소송승계인의 범위

- 대법원은 승계인이라 함은 당사자가 소송물인 권리의무 자체를 승계한 자뿐만 아니라, 그 소송물인 법률관계의 바탕이 된 물적 권리관계를 승계함으로써 판결의 기판력을 받는 자를 포함한다고 해석한다.

#### 4. 참가승계

##### (1) 참가승계의 의의[민소법 제81조]

- 소송계속 중 제3자가 소송 목적인 권리의 전부 또는 일부를 승계하였다고 주장하며 스스로 소송에 가입하는 것을 말한다.

##### (2) 참가승계의 요건

- 타인 사이의 소송이 계속 중이어야 하며, 제3자가 소송물인 권리 또는 의무를 특정하여 승계했어야 한다. 실질적으로 소송적격이 이전되어야 한다.

##### (3) 참가승계의 절차

- 독립당사자참가의 예에 따라 참가신청을 한다. 법원은 승계 여부를 심리하여 승계가 인정되면 참가인을 당사자로 취급한다.

##### (4) 참가승계의 효과

- 참가가 허용되면 기존 당사자는 상대방의 동의를 얻어 소송에서 탈퇴할 수 있다. 판결의 효력은 승계인과 탈퇴인 모두에게 미치며, 승계인은 전 당사자가 행한 소송상태를 그대로 이어받는다.

#### 5. 인수승계

##### (1) 인수승계의 의의

- 소송계속 중 당사자가 소송 목적인 의무를 승계한 제3자를 소송에 강제로 가입시키기 위해 법원에 신청하는 제도이다.

##### (2) 인수승계의 요건

- 소송계속 중일 것과 제3자가 소송물인 의무를 승계하였을 것을 요한다. 원고가 피고 측의 승계인을 상대로 신청하는 것이 일반적이나, 피고가 원고 측의 승계인을 상대로 신청하는 것도 가능하다.

##### (3) 인수승계의 절차

- 당사자의 신청에 의하여 법원이 결정으로 인수 여부를 판단한다. 법원은 제3자에게 심문할 기회를 주어야 한다.

##### (4) 인수승계의 효과[민소법 제82조, 제81조, 제80조]

- 인수결정이 내려지면 제3자는 소송당사자가 된다. 참가승계와 마찬가지로 기존 당사자는 탈퇴할 수 있으며, 탈퇴하지 않더라도 제3자와의 관계에서 판결의 효력이 발생한다. 승계인은 종전 당사자의 소송 수행 결과에 구속된다.

#### Ⅲ 결론

- 당사자의 변경 및 소송승계 제도는 소송절차의 효율성과 권리관계의 실체적 진실을 조화시키기 위한 장치이다. 임의적 당사자변경은 당사자의 의사를 존중하되 상대방의 방어권 보호를 위해 법정 사유로 제한하고 있으며, 소송승계는 실체법적 변동은 소송법적으로 수용하여 기판력의 실효성을 확보한다. 특히, 참가승계와 인수승계는 현대 소송에서 빈번하게 발생하는 채권양도나 채무인수 등에 대응하여 분쟁의 일회적 해결을 가능케 한다. 재판부는 승계 여부를 엄격히 심사하여 부당한 소송 지연을 막는 동시에, 승계인이 전 당사자의 소송상태를 승계함으로써 발생하는 불이익이 절차적 보장의 원칙을 침해하지 않도록 균형 있는 심리를 진행해야 한다.

## <제6편 상소심절차.제13장 총설.제1절 상소의 의의>

### I. 개념

#### 1. 상소의 정의

- 상소란 미확정의 재판에 대하여 하급법원의 판단에 불복하여 상급법원에 그 당부의 조사를 신청함으로써 재판의 취소 또는 변경을 구하는 불복신청 방법을 말한다. 이는 재판의 정확성을 기하고 당사자의 권익을 보호하기 위한 제도적 장치로서, 국가 형벌권이나 사법권의 적정한 행사를 도모하며 오판으로 인한 당사자의 불이익을 구제하는 데 그 일차적인 목적이 있다.

#### 2. 상소의 특징

- 상소는 다음과 같은 세 가지 핵심적 요소를 갖추어야 한다. 첫째, 미확정의 재판을 대상으로 한다. 이미 확정되어 기판력이 발생한 재판에 대해서는 일반적인 상소방법으로 다룰 수 없으며, 재심이나 특별항고와 같은 비상구제수단만이 허용된다. 둘째, 상급법원에 대한 신청이어야 한다. 하급법원의 판단을 상급법원이 다시 검토하게 함으로써 수직적인 심사 구조를 형성한다. 셋째, 재판의 취소 또는 변경을 목적으로 한다. 하급심 재판의 오류를 바로잡아 자신에게 유리한 재판을 얻어내고자 하는 공격적·방어적 성격을 띤다.

#### 3. 상소권의 발생과 소멸

- 상소권은 재판의 선고 또는 고지와 동시에 발생한다. 당사자가 재판의 내용에 만족하지 못할 경우 법이 정한 상소기간 내에 상소장을 제출함으로써 권리를 행사할 수 있다. 상소권은 상소기간의 도과, 상소권의 포기, 상소의 취하 등에 의하여 소멸한다. 특히, 기간 내에 상소를 제기하지 않으면 해당 재판은 확정되어 더 이상 일반적인 상소로는 다룰 수 없게 된다.

#### 4. 상소의 이익

- 상소가 유효하기 위해서는 상소를 제기하는 당사자에게 상소의 이익이 있어야 한다. 우리 판례는 원칙적으로 형식적 불복설에 입각하여 판단한다. 즉, 하급심 판결의 주문과 당사자의 신청(청구취지)을 비교하여 당사자가 신청한 것보다 불리한 판결이 내려졌을 때 상소의 이익이 인정된다. 다만, 예외적으로 판결 주문상으로는 승소하였더라도 판결 이유 중에서 당사자에게 실질적인 불이익이 발생하는 특수한 경우에는 실질적 불복설의 관점에서 이익을 인정하기도 한다.

#### 5. 상소의 종류

- 상소는 불복의 대상이 되는 재판의 종류에 따라 구분된다. 제1심 종국판결에 대한 상소는 항소라 하며, 제2심 종국판결에 대한 상소는 상고라 한다. 한편, 결정이나 명령과 같은 부수적 재판에 대한 상소는 항고라고 부른다. 항고는 다시 그 성격에 따라 일반항고, 즉시항고, 재항고 등으로 세분화되어 각각의 불복 요건과 절차적 기한을 달리한다.

### II. 구별

#### 1. 재심과의 구별

- 상소와 재심은 재판의 오류를 시정한다는 점에서 유사하나, 그 대상과 시점에서 근본적인 차이가 있다. 상소는 미확정 재판을 대상으로 하여 판결의 확정을 차단하는 정지적 효과가 있는 반면, 재심은 이미 확정된 재판의 효력을 사후적으로 배제하기 위한 비상구제수단이다. 또한, 상소는 반드시 상급법원에 제기하여 심판을 구하는 수직적 절차이지만, 재심은 원칙적으로 재판을 내린 당해 법원이 다시 심리하는 수평적 재확인 절차의 성격이 강하다.

#### 2. 이의신청과의 구별

- 이의신청은 넓은 의미의 불복방법에 포함되나, 상소와는 달리 반드시 상급법원에 신청하는 것이 아니다. 예컨대 지급명령에 대한 이의신청이나 소송비용액 확정결정에 대한 이의신청은 해당 처분을 내린 법원에 직접 제출한다. 상소는 심급 구조를 이용한 계층적 불복인 반면, 이의신청은 동일 심급 내에서의 재검토나 절차적 위법의 시정을 요구하는 방법이라는 점에서 구별된다.

#### 3. 특별항고와의 구별

- 특별항고는 불복할 수 없는 결정이나 명령에 대하여 재판에 영향을 미친 헌법 위반이나 법률 위반이 있는 경우에 한하여 대법원에 제기하는 특수한 불복방법이다. 일반 상소가 사실관계의 오류나 일반 법령 적용의 부적절함을 포괄적으로 다루는 것과 달리, 특별항고는 오로지 법령 해석의 통일과 헌법 수호를 위해 지극히 제한적인 사유로만 인정된다는 점이 특징이다.

#### 4. 중간판결에 대한 불복과의 구별

- 중간판결은 소송 진행 중 개별적인 쟁점에 대해 미리 판단을 내리는 것이지만, 이에 대해서는 독립하여 상소할 수 없다. 민사소송법은 소송의 지연을 방지하고 심판의 집중을 도모하기 위하여 중간판결에 대한 불복은 그 후에 나오는 종국판결에 대한 상소와 함께 하도록 규정하고 있다. 즉, 상소는 원칙적으로 절차를 완전히 마무리 짓는 종국판결을 대상으로 한다는 점에서 중간적 판단에 대한 단순한 이의와 차별화된다.

#### 5. 항고와 상고의 구별

- 항고와 상고는 모두 상급법원에 대한 불복이지만 대상 재판이 다르다. 항고는 결정이나 명령에 대한 불복방법이며, 상고는 제2심 판결에 대한 불복 방법이다. 항고는 상대적으로 경미하거나 절차적인 사항을 다루는 경우가 많아 서면 심리 위주로 신속하게 진행되나, 상고는 법률심으로서 원심판결의 법령 위반 여부를 엄격히 심사하며 대법원이 그 심판을 담당한다는 점에서 사법 체계상 중대성이 다르다.

### III. 결론

- 상소 제도는 사법 재판의 정확성을 보장하고 법관의 오류나 편견으로부터 국민의 권리를 보호하는 필수적인 소송법적 장치이다. 미확정 재판을 상급법원에 이심시켜 다시 판단을 받게 함으로써 사법에 대한 국민의 신뢰를 제고하고 법치주의의 실질적인 구현을 가능케 한다. 상소의 개념을 명확히 이해하고 다른 불복수단과의 한계를 구분하는 것은 적절한 재판을 받을 권리를 실현하는 기초가 된다. 따라서 당사자는 상소의 이익과 대상, 기간을 면밀히 검토하여 정당한 권리 구제를 도모하여야 하며, 법원은 상소의 적법성을 엄격히 판단하여 남상으로 인한 소송 지연을 막는 동시에 억울한 오판이 방지되지 않도록 그 운영에 만전을 기하여야 한다. 결국 상소심 절차는 하급심의 독립성을 존중하면서도 상급심의 감독 기능을 조화시켜 공정한 판결을 도출해 내는 사법 시스템의 핵심 보루라 할 것이다.



<제6편 상소심절차.제13장 총설.제2절 상소의 적법요건>

**I. 대상적격**

**1. 유효한 판결일 것**

- 상소는 법원의 판결이 실재하고 유효하게 존재함을 전제로 한다. 따라서 판결 자체가 성립하지 않았거나, 존재하지 않는 판결에 대해서는 상소를 제기할 수 없다. 또한, 판결의 내용이 부존재하거나 무효인 경우에는 상소의 대상이 되지 않는 것이 원칙이다. 다만, 판결이 형식적으로 존재함에도 불구하고 중대한 절차적 하자로 인해 무효인 경우, 그 외관을 제거하기 위한 방편으로 상소를 허용하는 것이 판례의 태도이다.

**2. 선고 후 확정 전의 종국판결일 것**

- 상소는 반드시 선고된 판결을 대상으로 하며, 아직 선고되지 않은 판결 초안이나 내부적 결정 상태에서는 제기할 수 없다. 또한, 상소는 재판의 확정을 차단하는 효력을 가지므로, 이미 확정된 판결에 대해서는 상소가 불가능하다. 대상이 되는 판결은 해당 심급의 절차를 완전히 종결시키는 종국판결이어야 한다. 소송의 일부만을 완결짓는 일부판결이나 추가판결의 대상이 된 부분은 독립하여 상소의 대상이 될 수 있으나, 심리 도중의 판단인 중간판결은 종국판결과 함께 불복해야 하므로 독립적인 상소 대상격이 부정된다.

**II. 적식의 상소제기[민소법 제396조, 제397조, 제425조]**

**1. 법정방식에 따른 상소제기**

- 상소는 서면인 상소장(항소장, 상고장)을 원심법원에 제출함으로써 제기해야 한다. 상소장에는 당사자와 법정대리인, 제1심 판결의 표시와 그 판결에 대한 항소 또는 상고의 취지를 명확히 기재해야 한다. 민사소송법 제397조에 따라 필요 사항이 누락되거나 인지가 불지 않은 경우 원심재판장은 보정 명령을 내리며, 이에 응하지 않을 시 상소장 각하 명령을 내리게 된다. 구두에 의한 상소 제기는 허용되지 않으며, 반드시 법이 정한 서식과 절차를 준수해야 한다.

**2. 상소기간의 준수**

- 상소는 민사소송법 제396조 제1항에 따라 판결서가 송달된 날로부터 2주 이내에 제기해야 한다. 이 기간은 불변기간으로, 당사자가 책임질 수 없는 사유로 기간을 지키지 못한 경우에만 추완이 허용된다. 판결 선고 후 송달 전에도 상소를 제기할 수 있으나, 송달된 후 2주가 경과하면 판결은 확정되어 상소권이 소멸한다. 상소권자가 다수인 경우 각 당사자에게 판결서가 송달된 때로부터 개별적으로 기간을 기산하며, 상소장 제출의 효력은 원심법원에 접수된 시점을 기준으로 판단한다.

**III. 당사자적격**

- 상소를 제기할 수 있는 자는 원심 절차에 관여했던 당사자 또는 그 승계인에 한정된다. 소송에 참여하지 않은 제3자는 판결의 효력을 직접 받지 않는 한 원칙적으로 상소를 제기할 수 없다. 다만, 소송참가인이나 승계인으로서 소송 절차에 편입된 자는 자신의 이익 범위 내에서 상소권자가 될 수 있다. 피상소인 역시 원심의 상대방 당사자여야 한다. 당사자 능력이 없거나 소송 능력이 없는 자가 제기한 상소는 부적법하며, 법정대리권의 흠결 등이 있는 경우에도 적법한 당사자적격으로 인정받기 어렵다.

**IV. 상소의 이익**

**1. 의의**

- 상소의 이익이란 상소인에게 원심판결보다 유리한 판결을 받을 실질적 필요성이 있음을 의미한다. 무익한 상소의 제기를 억제하여 사법 자원의 낭비를 막고 소송 경제를 도모하기 위한 요건이다. 상소의 이익이 없는 상소는 부적법한 것으로 보아 본안 심리 없이 각하한다.

**2. 판단기준**

- 우리 법원은 원칙적으로 형식적 불복설을 취한다. 이는 원심판결의 주문과 상소인의 신청(청구취지)을 비교하여, 신청한 것보다 불리한 주문이 선고된 경우에 상소의 이익을 인정하는 방식이다. 따라서 원고가 청구한 금액 전부를 승소한 경우 원고는 상소의 이익이 없으며, 피고 역시 원고의 청구가 전부 기각된 경우 판결 이유에 불만이 있더라도 원칙적으로 상소할 수 없다. 다만, 판결 주문상으로는 승소했으나 이유 중에서 당사자에게 법률상 중대한 불이익이 발생하는 특수한 경우에는 예외적으로 이익을 인정할 수 있다.

**3. 상소의 이익 유무의 구체적 검토**

- 전부 승소한 당사자는 이익이 없으나, 일부 패소한 경우 패소 부분에 대해 상소할 수 있다. 상계의 항변이 받아들여져 승소한 피고의 경우, 자동채권이 소멸되는 불이익이 있으므로 예외적으로 상소의 이익이 인정되기도 한다. 반면, 단순히 판결의 이유(사실인정이나 법리판단)가 마음에 들지 않는다는 사유만으로는 상소할 수 없다. 또한, 상소 제기 당시에는 이익이 있었더라도 상소심 심리 도중 목적이 달성되거나 권리가 소멸하여 이익이 없어지면 상소는 각하된다.

**V. 상소권 포기·불상소합의 등 상소장애사유가 없을 것[민소법 제394조, 제395조, 제425조, 제390조]**

**1. 상소권 포기가 없을 것**

- 상소권의 포기란 상소권을 행사하지 않겠다는 의사표시를 말한다. 상소 제기 전에는 원심법원에, 상소 제기 후에는 상소기록이 있는 법원에 서면으로 제출해야 한다. 상소권 포기는 철회할 수 없으며, 포기 이후에 제기된 상소는 장애사유가 존재하는 것으로 보아 각하된다. 포기의 의사표시는 명확해야 하며 조건부 포기는 허용되지 않는다.

**2. 불상소합의가 없을 것[민소법 제390조 제1항 단서]**

- 불상소합의란 당사자 쌍방이 특정한 소송에 대하여 상소하지 않기로 하는 합의를 의미한다. 이러한 합의는 서면으로 해야 하며, 유효한 합의가 있는 경우 상소권은 소멸한다. 다만, 불상소합의는 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리에 한하며, 강행법규 위반이나 사회질서에 반하는 경우에는 효력이 부정될 수 있다. 유효한 불상소합의를 위반하여 제기된 상소는 부적법한 상소로서 각하의 대상이 된다.

**VI. 소송행위의 유효요건을 구비할 것**

**1. 신의칙에 위반되지 않을 것**

- 상소권의 행사 역시 소송상 신의성실의 원칙에 지배를 받는다. 당사자가 원심에서 명시적으로 권리를 행사하지 않겠다고 신뢰를 부여한 후 이를 번복하여 상소를 제기하거나, 소송 절차를 오로지 지연시킬 목적으로 명백히 근거 없는 상소를 남용하는 행위는 신의칙 위반으로 간주될 수 있다. 법원은 이러한 경우 상소권 행사의 한계를 일탈한 것으로 보아 부적법 처리를 할 수 있다.

**2. 소송절차 중단 중의 소송행위가 아닐 것**

- 소송 절차가 중단된 상태(당사자의 사망, 파산 등)에서 적법한 수계 절차 없이 이루어진 상소 제기는 원칙적으로 무효이다. 중단 사유가 발생하면 소송은 정지되며, 수계인이 결정되어 절차를 이어받기 전까지는 상소장 제출 등의 소송행위를 할 수 없다. 다만, 소송대리인이 있는 경우에는 절차가 중단

되지 않으므로 소송대리인을 통해 적법하게 상소를 제기할 수 있으나, 그렇지 않은 경우 중단 중의 행위는 유효한 요건을 갖추지 못한 것으로 취급된다.

## **VI. 결론**

- 상소의 적법요건은 상소심의 본안 심리로 나아가기 위해 반드시 통과해야 하는 관문이다. 대상적격, 당사자적격, 상소의 이익, 상소권 포기나 신의칙 위반과 같은 장애사유의 부존재에 이르기까지 모든 요건이 충족되어야만 비로소 상소법원은 원심판결의 당부를 실질적으로 심리할 수 있다. 특히, 상소 기간의 준수와 상소의 이익 유무는 실무상 가장 빈번하게 문제되는 요건으로, 이를 소홀히 할 경우 당사자는 실질적인 불복의 기회를 얻지 못한 채 판결의 확정을 지켜볼 수밖에 없다. 따라서 법원은 직권으로 이러한 요건들을 엄격히 조사하여 사법 절차의 안정성을 꾀해야 하며, 당사자는 각 요건의 법률적 의미를 명확히 이해하여 자신의 권리를 적시에 방어해야 한다. 결과적으로 적법요건의 구비는 상소심 절차의 공정성과 효율성을 담보하는 최우선의 기초가 된다고 할 것이다.

<제6편 상소심절차.제13장 총설.제3절 상소의 효력>

**I. 확정차단과 이심의 효력[민소법 제498조]**

**1. 확정차단의 효력**

- 상소가 제기되면 원심판결의 확정이 저지된다. 민사소송법 제498조에 따라 판결은 상소기간 내에 상소의 제기가 있으면 확정되지 아니하며, 상소심 절차가 진행되는 동안 판결의 집행력이나 기판력은 발생하지 않는다. 이는 불복 당사자에게 상급심에서 다시 심리받을 기회를 보장하기 위함이다. 만약 상소가 부적법하여 각하되거나 상소가 취하되면 차단되었던 확정 효력이 소급하여 발생하게 된다.

**2. 이심의 효력**

- 이심의 효력이란 상소의 제기에 의하여 당해 사건이 원심법원의 수권으로부터 벗어나 상소법원의 심판권 아래로 옮겨지는 효력을 의미한다. 이심의 시기는 상소장을 원심법원에 제출한 때 발생한다. 이심의 효력이 발생하면 원심법원은 해당 사건에 대하여 더 이상 어떠한 재판도 할 수 없으며, 사건에 관한 기록을 상소법원으로 송부해야 한다. 다만, 상소장의 각하 명령이나 판결의 경정 등 부수적인 절차는 예외적으로 원심법원의 권한으로 남는다.

**II 상소불가분의 원칙(이심의 범위)**

**1. 의의**

- 상소불가분의 원칙이란 상소의 제기가 있는 경우, 당사자가 상소장에 기재한 불복의 범위와 상관없이 당해 소송에 결합된 전체 청구가 일단 상소심으로 이심되는 원칙을 말한다. 이는 소송의 단일성을 유지하고 심판의 모순을 방지하기 위한 원칙이다.

**2. 이심의 범위**

- 이심의 범위는 상소인이 불복한 부분에 국한되지 않고 원심판결 전체에 미친다. 예를 들어 원고가 일부 승소한 판결에 대하여 원고만이 일부 패소 부분에 대하여 항소한 경우에도, 승소한 부분까지 포함하여 사건 전체가 상소심으로 이심된다. 다만, 상소심의 심판 범위는 불복 범위에 한정되므로, 이심된 부분 중 불복하지 않은 부분은 상소심에서 판단하지 않고 형식적으로만 옮겨가 있는 상태가 된다.

**3. 단순병합 또는 한 청구에서 불복하지 않은 패소 부분의 확정시기**

- 청구가 단순병합된 경우나 하나의 청구 중 일부에 대해서만 불복한 경우, 상소하지 않은 부분은 상소불가분의 원칙에 따라 상소심으로 이심은 되나 심판 대상에서는 제외된다. 이 경우 불복하지 않은 부분의 확정시기에 대하여 견해의 대립이 있으나, 판례는 상소심 판결이 선고된 때에 비로소 확정된다고 본다. 즉, 이심의 효력으로 인해 판결 전체의 확정이 차단되어 있다가 상소심 재판이 끝나는 시점에 함께 확정되는 것이다.

**III 상소심의 심판범위(불이익변경금지의 원칙)[민소법 제415조]**

**1. 의의**

- 불이익변경금지의 원칙이란 항소심 또는 상고심법원은 상소인의 불복범위를 넘어서 상소인에게 불리하게, 피상소인에게 유리하게 원심판결을 변경할 수 없다는 원칙이다. 이는 처분권주의가 상소심 절차에서도 관철된 결과로 볼 수 있다.

**2. 법적 근거**

- 민사소송법 제415조 본문은 제1심 판결은 그 불복의 한도안에서 바꿀 수 있다고 규정하고 있다. 이는 당사자가 요구하지 않은 이익을 법원이 임의로 부여하지 말아야 한다는 소송법상 원칙을 명문화한 것이다.

**3. 판단기준**

- 불이익한 변경인지 여부를 판단할 때에는 판결의 주문을 기준으로 한다. 판결의 이유는 고려하지 않으며, 원심 판결의 주문과 상소심 판결의 주문을 비교하여 상소인에게 실질적으로 더 불리한 결과가 초래되었는지를 확인한다. 이때 판단은 경제적 관점이 아닌 법률적 관점에서 이루어진다.

**4. 원칙의 내용**

- 상소인이 항소한 경우, 항소법원은 항소인의 불복 신청 한도 내에서만 원심판결을 취소하거나 변경할 수 있다. 상대방인 피항소인이 부대항소를 제기하지 않는 한, 항소법원은 항소인에게 원심보다 더 불리한 판결을 내릴 수 없다. 예를 들어 500만 원 승소한 원고가 1,000만 원을 받기 위해 항소했는데 피고가 항소하지 않았다면, 항소법원은 원고의 청구를 500만 원 미만으로 깎을 수 없다.

**5. 원칙의 예외**

- 이 원칙이 적용되지 않는 예외적인 경우도 존재한다. 첫째, 피항소인이 부대항소를 제기한 경우에는 항소인의 불복 범위를 넘어 원심판결을 항소인에게 불리하게 변경할 수 있다. 둘째, 필수적 공동소송의 경우 공동소송인들 사이의 결과가 일치해야 하므로 이 원칙이 제한될 수 있다. 셋째, 직권조사가 항에 해당하는 경우 법원은 당사자의 불복 범위와 상관없이 판단할 수 있으므로 결과적으로 불이익한 변경이 발생할 수 있다.

**6. 위반의 효과**

- 법원이 불이익변경금지의 원칙을 위반하여 판결을 내린 경우, 이는 법령 위반의 잘못이 있는 판결이 된다. 따라서 당사자는 이를 사유로 상고를 제기할 수 있으며, 상고심에서 해당 판결은 파기 대상이 된다.

**IV 결론**

- 상소의 효력은 소송 절차의 연속성과 당사자의 처분권 보호라는 두 가지 측면에서 중요한 의미를 갖는다. 확정차단과 이심의 효력은 판결이 확정되기 전 상급심의 판단을 받을 수 있는 형식적 토대를 마련해주며, 상소불가분의 원칙은 소송의 분열을 막아 절차의 일관성을 유지한다. 특히, 불이익변경금지의 원칙은 당사자가 상소를 제기함에 있어 예상치 못한 불이익을 당하지 않도록 보장함으로써 상소권 행사의 심리적 위축을 방지한다. 결국 이러한 효력들은 상소심이 제1심의 연장선상에서 사법 정의를 실현하면서도, 당사자가 제기한 불복의 범위 내에서만 국가의 재판권이 행사되도록 하는 민사소송의 대원칙을 준수하는 기제라고 할 수 있다.

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제1절 항소의 개관>

**I. 항소의 의의**

**1. 개념**

- 항소란 제1심 법원의 중국판결에 대하여 불복하는 당사자가 판결의 확정을 차단하고 사건을 상급법원인 항소법원에 이심시켜 다시 심판을 구하는 상소의 일종이다. 민사소송법상 상소 제도는 하급심 법원의 사실인정이나 법리 적용의 오류를 시정함으로써 당사자의 권리를 구제하고, 법령의 해석과 적용의 통일을 기하는 데 그 본질적 목적이 있다. 그중에서도 항소는 사실심의 연장선상에서 사법 자원의 효율적 배분과 실체적 진실 발견 사이의 조화를 도모하는 장치로 기능한다.

**2. 대상 및 요건**

- 항소의 대상은 제1심 법원이 내린 유효한 중국판결에 한정된다. 중간판결이나 결정·명령에 대해서는 독립하여 항소할 수 없으며, 중국판결에 대한 항소와 함께 심판을 받게 된다. 항소가 적법하기 위해서는 항소인에게 항소권이 있어야 하며, 항소의 이익 즉 원심판결보다 유리한 판결을 받을 가능성이 존재해야 한다. 또한 법정 항소기간인 판결서 송달일로부터 2주 이내에 항소장을 제출해야 하는 기간 엄수 요건이 부과된다.

**3. 기능적 특성**

- 항소는 사건을 하급심에서 상급심으로 이심시키는 이심의 효력과 원심판결의 확정을 막는 확정차단의 효력을 가진다. 이를 통해 당사자는 제1심에서 다하지 못한 주장이나 증거를 새롭게 제출할 기회를 얻게 되며, 법원은 제1심 판결의 적정성을 사후적으로 검토할 수 있게 된다. 이는 재판의 신중을 기하고 오판에 의한 당사자의 피해를 최소화하는 현대 민사소송법의 핵심적 권리 구제 수단이다.

**II. 항소심의 구조**

**1. 항소심 구조의 유형과 입법례**

- 항소심의 성격을 어떻게 규정하느냐에 따라 크게 복심주의, 속심주의, 사후심주의의 세 가지 유형으로 구분된다.

**(1) 복심주의**

- 복심주의는 항소심을 제1심과 완전히 독립된 새로운 재판으로 보는 견해이다. 제1심에서의 심리 결과나 소송 자료를 도의시키고 항소심에서 처음부터 다시 심리를 진행한다. 재판의 정확성을 기할 수 있다는 장점이 있으나, 소송 경제 측면에서 비효율적이며 제1심 재판을 무의미하게 만들 우려가 크다.

**(2) 속심주의**

- 속심주의는 항소심을 제1심의 속행으로 보는 구조이다. 제1심에서 수집된 소송 자료를 기초로 하되, 항소심에서 당사자가 새롭게 제출하는 자료(신공격방어방법)를 추가하여 심리한다. 제1심의 성과를 활용하면서도 새로운 사정 변경을 반영할 수 있어 많은 국가에서 채택하고 있는 방식이다.

**(3) 사후심주의**

- 사후심주의는 항소심을 제1심 판결의 당부만을 심사하는 절차로 한정하는 구조이다. 원칙적으로 새로운 사실의 주장이나 증거 제출이 허용되지 않으며, 제1심 판결 당시의 자료만을 근거로 판결의 오류 여부를 판단한다. 상고심과 유사한 성격을 띠며 소송의 신속을 기할 수 있으나 사실관계 규명에 한계가 있다.

**2. 현행법상 항소심의 구조**

**(1) 속심주의의 원칙적 채택**

- 우리 민사소송법은 항소심의 구조에 관하여 원칙적으로 속심주의를 채택하고 있다. 이는 제1심에서 제출된 소송 자료와 항소심에서 새로 제출된 자료를 합쳐서 판결의 기초로 삼는 방식이다. 당사자는 항소심 변론종결 시까지 새로운 주장이나 증거를 제출할 수 있으며, 법원은 이를 바탕으로 제1심 판결의 당부를 판단하는 것이 아니라 판결 시를 기준으로 실체적 권리관계를 확정한다.

**(2) 사후심적 요소의 도입**

- 현대 민사소송법은 적시제출주의를 강화하고 제1심 중심주의를 실현하기 위해 순수한 속심주의에서 탈피하여 사후심적 요소를 가미하고 있다. 당사자가 제1심에서 충분히 제출할 수 있었음에도 고의나 중과실로 뒤늦게 제출한 공격방어방법에 대해서는 실권효를 적용하여 배척할 수 있도록 규정하고 있다. 또한, 항소심에서 새로운 청구의 추가나 변경을 일정한 범위 내로 제한하거나, 변론 준비 절차를 강화하는 등 제1심의 심리 결과가 항소심에서도 존중받을 수 있도록 제도를 운영하고 있다.

**3. 실무상 운영의 특징**

- 현행법상 항소심은 제1심의 연장선이지만, 사실상 제1심에서 성실히 공방을 벌이지 않은 당사자가 항소심에서 이를 만회하려는 시도를 엄격히 규제하는 방향으로 나아가고 있다. 법원은 제1심의 증거조사 결과를 최대한 존중하되, 제1심 판결 이후 발생한 사정이나 제1심에서 미처 발견되지 못한 결정적 증거가 있을 경우에 한하여 적극적으로 판결을 수정한다. 이러한 혼합적 구조는 재판의 신속성과 실체적 정의 실현이라는 두 가치를 동시에 추구하기 위한 법치주의적 결단이다.

**III. 결론**

- 항소는 제1심 재판의 오류 가능성을 인정하고 이를 시정하기 위한 필수적 장치로서, 우리 법제는 이를 속심주의라는 큰 틀 안에서 운영하고 있다. 항소심의 구조가 속심주의를 취함으로써 당사자는 제1심의 미비점을 보충할 기회를 얻게 되지만, 동시에 사후심적 요소의 강화로 인해 제1심에서의 충실한 심리가 소송 전체의 성패를 좌우하는 구조적 특징을 갖게 되었다. 결국 항소 제도는 단순히 재판을 한 번 더 받는 기회가 아니라, 제1심의 성과를 토대로 법률관계의 최종적 적정성을 확보하는 고도화된 심리 단계로 이해되어야 한다. 이러한 구조적 이해를 바탕으로 상소권자는 자신의 불복 사유를 명확히 하고, 법원은 제1심과의 유기적 연결 속에서 공정한 재판권을 행사함으로써 사법 신뢰를 구축해야 한다.

## <제6편 상소심절차.제14장 항소.제2절 항소의 제기>

### I. 항소제기의 방식

#### 1. 항소장의 제출

- 항소는 제1심 판결을 내린 법원에 항소장을 제출함으로써 제기한다. 이를 항소장제출주의라고 하며, 항소심 법원이 아닌 원심법원에 제출해야 한다는 점이 특징이다. 항소장에는 당사자와 법정대리인, 제1심 판결의 표시와 그 판결에 대한 항소의 취지를 반드시 적어야 한다.

#### 2. 항소기간의 준수

- 항소는 판결서가 송달된 날부터 2주 이내에 제기해야 한다. 이 기간은 불변기간이므로 당사자가 책임질 수 없는 사유로 지킨 경우를 제외하고는 연장이 불가능하다. 판결서 송달 전에도 항소를 제기할 수 있으나, 판결이 선고되기 전의 항소제기는 부적법하다.

#### 3. 인지의 첨부 및 송달료 납부

- 항소장에는 민사소송 등 인지법이 정하는 바에 따라 제1심 인지액의 1.5배에 해당하는 인지를 붙여야 한다. 또한 항소장 부분의 송달 및 재판 절차 진행을 위한 송달료를 예납해야 한다.

### II. 재판장의 항소장심사권

#### 1. 원심재판장의 항소장심사권

- 항소장이 접수되면 원심법원의 재판장은 항소장의 필수 기재사항 누락 여부와 인지 첨부 여부를 심사한다. 만약 흠결이 있다면 상당한 기간을 정하여 보정을 명하며, 보정하지 않을 경우 명령으로 항소장을 각하한다. 또한 항소기간을 도과하였음이 명백한 경우에도 원심재판장이 항소장각하명령을 내린다.

#### 2. 항소심재판장의 항소장심사권

- 원심재판장의 심사를 거쳐 기록이 항소심 법원에 송달되면, 항소심 재판장 역시 동일한 권한을 가진다. 원심에서 발견하지 못한 흠결이 있거나 보정 명령을 이행하지 않은 경우 항소심 재판장은 명령으로 항소장을 각하한다.

#### 3. 불복방법

- 재판장의 항소장각하명령에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다. 이는 판결이 아닌 명령에 의한 재판이므로 독립하여 다룰 수 있는 기회를 보장하는 것이다.

### III. 항소의 취하

#### 1. 의의[민소법 제393조]

- 항소의 취하란 항소제기에 의해 개시된 항소심 절차를 항소인이 스스로 종료시키기 위해 행하는 소송행위이다. 항소를 취하하면 소송은 항소제기가 없었던 상태로 돌아가며 원심판결이 확정된다.

#### 2. 요건

- 항소취하는 항소심의 종국판결이 있기 전까지 가능하다. 소의 취하와 달리 상대방의 동의를 필요로 하지 않는데, 이는 피항소인에게 원심판결을 유지하는 것이 통상 불리하지 않기 때문이다. 다만, 항소취하는 서면으로 하는 것이 원칙이나 변론기일 등에서는 말로 할 수도 있다.

#### 3. 효과

- 항소취하가 있으면 항소심 절차는 소급적으로 종료된다. 이로써 제1심 판결은 항소기간 만료 시에 소급하여 확정된 것으로 간주된다. 취하한 자는 다시 동일한 항소를 제기할 수 없다.

#### 4. 항소취하간주

- 당사자 쌍방이 변론기일에 2회 불출석하거나 기일에 출석하더라도 변론하지 아니한 경우, 1월 이내에 기일지정신청을 하지 않거나 지정된 기일에 다시 쌍방 불출석하면 항소를 취하한 것으로 본다. 이를 상소심의 필요적 기일지정 및 취하간주 제도라 한다.

#### 5. 항소취하의 합의

- 당사자 사이에 항소를 취하하기로 하는 소송외의 합의가 가능하다. 이러한 합의가 있음에도 항소를 유지할 경우 법원은 소권의 부존재를 이유로 항소를 각하해야 한다.

#### 6. 항소의 일부취하의 가부

- 수개의 청구 중 일부에 대해서만 항소를 취하하거나, 청구의 수량적 일부에 대하여 취하하는 것은 허용된다. 다만, 주문이 불가분인 경우에는 일부취하가 논리적으로 불가능할 수 있다.

### IV. 부대항소

#### 1. 의의[민소법 제403조]

- 부대항소란 항소심 절차에 편승하여 피항소인이 항소인에 대하여 자기에게 유리하게 항소심판의 범위를 확장하기 위해 제기하는 공격적 소송행위이다. 스스로 항소권을 포기하였거나 항소기간이 지난 경우에도 상대방의 항소에 기해 제기할 수 있다.

#### 2. 인정취지

- 당사자 일방만이 항소한 경우 상소불이익변경금지의 원칙에 의해 피항소인은 원심판결보다 유리한 판결을 얻을 수 없는 것이 원칙이다. 그러나 상대방이 항소를 제기하여 판결의 확정을 막은 이상, 피항소인에게도 불복의 기회를 주어 형평을 기하려는 데 목적이 있다.

#### 3. 법적 성질

- 부대항소는 독립된 상소가 아니며 항소심 절차에 종속된 특수한 소송행위이다. 따라서 주된 항소가 취하되거나 각하되면 부대항소도 원칙적으로 효력을 잃는다.

#### 4. 요건

- 부대항소는 항소심 변론종결 전까지 제기해야 한다. 주된 항소가 적법하게 살아 있어야 하며, 피항소인이 항소인을 상대로 제기해야 한다. 항소권의 포기나 항소기간 도과 후에도 가능하며, 주된 항소의 범위를 넘어서는 것도 허용된다.

#### 5. 방식

- 항소에 관한 규정을 준용하므로 부대항소장을 제출하는 것이 원칙이다. 부대항소장에는 부대항소의 취지와 범위를 명시해야 하며, 주된 항소장과 마찬가지로 인지를 붙여야 한다.

#### 6. 효과

- 부대항소가 제기되면 항소심의 심판 범위는 부대항소인이 불복한 범위까지 확장된다. 법원은 주된 항소와 부대항소를 함께 심리하여 하나의 판결을 내린다. 만약 주된 항소가 취하되면 부대항소는 효력을 잃는 것이 원칙이나, 항소기간 내에 제기된 부대항소는 독립된 항소로 보아 주된 항소의 취하와 상관없이 존속한다.

## **V. 결론**

- 항소의 제기는 제1심 판결의 확정을 차단하고 사법 정의를 실현하기 위한 엄격한 절차적 요건을 필요로 한다. 항소장 제출부터 재판장의 심사, 당사자의 의사에 의한 취하에 이르기까지 모든 과정은 소송의 신속과 당사자의 방어권 보장이라는 균형 위에서 작동한다. 특히 부대항소 제도는 상소불이익변경금지 원칙의 예외로서 당사자 간의 실질적 형평을 도모하는 중요한 수단이 된다. 이러한 제반 절차를 통해 항소심은 제1심의 불완전성을 보완하고 실체적 진실에 부합하는 중국적인 권리 확정을 지향한다. 따라서 소송 당사자는 각 단계의 법적 요건과 효과를 명확히 숙지하여 자신의 소송상 지위를 전략적이고 적법하게 관리해야 할 것이다.

## <제6편 상소심절차.제14장 항소.제3절 항소심의 심리>

### I. 항소의 적법성 심리

#### 1. 의의

- 항소심 법원은 본안에 대한 심리에 들어가기에 앞서 항소가 적법한 요건을 갖추었는지 여부를 먼저 심사한다. 이는 소송요건의 심사와 유사한 성격의 절차로서, 항소가 부적법함에도 불구하고 본안판결을 내리는 것을 방지하기 위함이다.

#### 2. 심사 대상

- 항소의 적법성 심사는 크게 네 가지 측면에서 이루어진다.

##### (1) 항소 제기 방식의 적법성

- 항소장이 원심법원에 제출되었는지, 필수 기재사항이 누락되지 않았는지, 인지액이 정당하게 납부되었는지를 확인한다.

##### (2) 항소기간의 준수 여부

- 판결서 송달 후 2주라는 불변기간 내에 제기되었는지를 엄격히 심사한다.

##### (3) 항소권의 존재 여부

- 당사자가 항소권을 포기하였거나 상소권을 상실한 사유가 있는지를 검토한다.

##### (4) 항소의 이익 유무

- 제1심 판결에 대하여 항소인에게 실질적인 불복의 이익이 있는지를 심사하며, 전부 승소한 자의 항소는 원칙적으로 이익이 없어 부적법하다.

#### 3. 심리의 선순위성

- 항소의 적법성은 소송요건에 해당하므로 법원은 직권으로 이를 조사하여야 한다. 본안심리 결과 항소인의 주장이 이유 있다고 판단되더라도, 항소 자체가 부적법하다면 본안에 대한 판단을 내릴 수 없다. 따라서 적법성 심리는 논리적으로 본안심리에 우선한다.

#### 4. 흠결의 보정과 결과

- 항소장에 흠결이 있는 경우 재판장은 보정명령을 통해 이를 시정할 기회를 부여한다. 만약 보정명령을 이행하지 않거나 보정이 불가능한 부적법 사유(예 : 항소기간 도과)가 명백한 경우에는 변론 없이 판결 또는 명령으로 항소를 각하한다.

### II. 본안심리

#### 1. 속심제의 채택

- 우리 민사소송법은 항소심의 성격에 관하여 속심제를 채택하고 있다. 속심제란 제1심의 심리상태를 그대로 계승하여 다시 심리하는 제도로서, 사후심제나 복심제와 구별된다. 이에 따라 항소심은 제1심에서 제출된 증거자료와 주장뿐만 아니라 항소심에서 새로이 제출된 자료를 종합하여 판결의 기초로 삼는다.

#### 2. 변론의 범위와 갱신권

- 항소심의 변론은 당사자가 제1심 판결의 변경을 구하는 한도 내에서 행해진다. 당사자는 제1심 기일에서의 변론 결과를 항소심 변론에서 진술하여야 하며, 이를 통해 제1심의 심리 결과가 항소심으로 이전된다. 또한 당사자는 항소심 변론종결 전까지 새로운 주장과 증거를 제출할 수 있는 갱신권을 가진다. 다만, 이는 소송의 지연을 목적으로 하거나 실기한 공격방어방법에 해당하지 않아야 한다는 제한을 받는다.

#### 3. 심판의 범위(처분권주의)

- 항소심의 본안심리는 당사자가 불복한 범위 내에서만 허용된다. 이를 상소불가분의 원칙이라 하며, 항소인이 불복하지 않은 부분은 항소심의 심판대상에서 제외된다. 다만, 확정적 차단은 판결 전체에 미치므로 이송이나 파기 시에는 판결 전체가 대상이 될 수 있으나, 당장의 본안판단은 불복 범위로 한정된다.

#### 4. 증거조사의 계승과 신규 조사

- 항소심 법원은 제1심에서 수행된 증거조사 결과를 그대로 사용할 수 있다. 그러나 제1심의 증거조사 결과가 미흡하거나 당사자가 새로운 증거를 신청한 경우, 항소심 법원은 독자적으로 증거조사를 실시할 수 있다. 특히 현대 민사소송에서는 항소심에서의 무분별한 증거 신청을 억제하기 위해 제1심 중심주의를 강화하는 경향이 있으나, 속심제의 본질상 신규 증거조사는 원칙적으로 허용된다.

#### 5. 소의 변경·반소·참가

- 속심제의 특성상 항소심에서도 소의 변경이나 반소의 제기, 당사자 참가가 가능하다. 소의 변경은 항소심에서도 자유롭게 할 수 있으나, 반소의 경우에는 상대방의 심급의 이익을 해칠 우려가 있으므로 상대방의 동의가 있거나 제1심과 심판의 기초가 공통되는 경우에 한하여 허용된다. 독립당사자참가 역시 항소심에서 가능하며, 이 경우 소송은 3면적 소송관계로 발전하게 된다.

#### 6. 불이익변경금지의 원칙

- 본안심리 결과 항소인의 주장이 이유 있다고 인정되더라도, 항소심 법원은 제1심 판결을 항소인에게 불리하게 변경할 수 없다. 이는 항소인만이 항소한 경우에 적용되며, 상대방이 부대항소를 제기하지 않는 한 항소인은 최소한 제1심 판결보다는 나쁜 결과를 얻지 않는다는 신뢰를 보호하기 위함이다.

### III. 결론

- 항소심 심리 절차는 항소의 적법성을 확인하는 단계와 사안의 실체를 파악하는 본안심리 단계로 구분된다. 적법성 심리는 소송 경제와 절차의 정당성을 확보하기 위한 전제 조건이며, 본안심리는 속심제 하에서 제1심의 성과를 계승하고 새로운 자료를 보완하여 실제적 진실을 탐구하는 과정이다. 우리 법제가 채택한 속심제는 당사자에게 충분한 방어 및 공격의 기회를 제공하는 장점이 있으나, 한편으로는 소송의 지연을 방지하기 위한 적절한 통제가 요구된다. 법원은 불이익변경금지의 원칙과 처분권주의를 준수하면서도, 갱신권의 남용을 막아 효율적이고 공정한 재판을 실현해야 한다. 결국 항소심 심리는 제1심 판결의 오류를 시정하고 당사자의 권리 구제를 도모하는 사법 환류 시스템의 핵심적 역할을 수행한다.

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제4절 항소심의 중국재판>

**I. 항소장 각하명령**

**1. 의의 및 성격**

- 항소심의 재판장은 항소장의 필수적 기재사항에 결함이 있거나 법률이 정한 인지가 붙어 있지 않은 경우, 상당한 기간을 정하여 보정을 명하고 그 기간 내에 보정하지 아니한 때에는 명령으로 항소장을 각하한다. 이는 재판장의 소장심사권에 기한 단독 결정으로서 사법행정적 성격과 재판적 성격을 동시에 지닌다.

**2. 발령 시기 및 대상**

- 항소장 각하명령은 항소기록이 항소법원에 송부된 후, 항소심 재판장이 기록을 심사하는 과정에서 행해진다. 원심재판장이 행하는 항소장 각하명령과는 구별되며, 항소법원의 재판장이 보정불이행을 이유로 내리는 최종적인 형식적 재판이다.

**3. 불복방법**

- 항소인은 항소장 각하명령에 대하여 즉시항고를 할 수 있다. 만약 즉시항고를 통해 결함이 보정되거나 인지가 납부되었음이 증명되면 각하명령은 취소되고 항소절차가 계속된다.

**II. 항소각하결정**

**1. 항소이유서 제출[민사소송법 제402조의2]**

- 항소제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하기 위해 항소법원이 원심법원으로부터 항소기록을 송부받으면 바로 그 사유를 당사자에게 통지하도록 하고, 항소장에 항소이유를 적지 아니한 항소인은 항소기록 접수의 통지를 받은 날부터 40일 이내에 항소이유서를 제출하도록 하되, 항소인의 신청이 있는 경우 항소법원은 결정으로 1회에 한하여 위 기간을 1개월 연장할 수 있도록 한다.

**2. 항소이유서 미제출에 따른 각하[민사소송법 제402조의3]**

- 항소인이 법정기간 내에 항소이유서를 제출하지 아니하면 직권조사사항이 있거나 항소장에 항소이유가 기재된 경우를 제외하고는 항소법원으로 하여금 결정으로 항소를 각하하도록 규정하고 있다.

**3. 절차적 특징**

- 이러한 결정들은 변론을 거치지 않고 할 수 있다는 점이 특징이다. 결정의 형식을 취하므로 판결보다 신속하게 절차를 마칠 수 있으며, 이에 대해서는 즉시항고로 불복할 수 있다.

**III. 항소각하판결**

**1. 의의**

- 항소의 요건 중 흠결이 있으나 재판장의 명령이나 결정으로 처리할 수 없는 경우, 또는 변론을 거친 후에 항소가 부적법함이 드러난 경우에 법원이 판결로써 항소를 물리치는 재판이다. 항소기간의 도과, 항소권의 포기, 항소의 이익 결여 등이 주요 사유이다.

**2. 성격**

- 항소각하판결은 항소가 소송요건을 갖추지 못했음을 확정하는 절차판결이다. 본안에 대한 판단은 포함되지 않으며, 원심판결의 당부 자체를 심리하지 않는다.

**3. 효력 및 불복**

- 항소각하판결이 확정되면 제1심 판결은 항소 제기 시로 소급하여 확정된 것과 같은 효과가 발생한다. 당사자는 이 판결에 대하여 상고로써 불복할 수 있다.

**IV. 항소기각판결**

**1. 의의**

- 항소 자체는 적법하게 제기되었으나, 본안심리 결과 제1심 판결이 정당하다고 인정되는 경우에 항소인의 주장을 배척하고 원심판결을 유지하는 재판이다.

**2. 판단 기준**

- 항소심 법원은 제1심 판결의 결론이 정당한지를 기준으로 삼는다. 따라서 제1심 판결의 이유가 다소 부당하더라도 다른 이유에 의하여 결론이 정당하다고 인정되는 경우에는 항소를 기각하여야 한다. 이를 이유교체에 의한 항소기기각이라 한다.

**3. 가집행의 선고**

- 항소기각판결을 할 때에는 원칙적으로 가집행의 선고를 붙이지 않는다. 제1심 판결에 이미 가집행 선고가 붙어 있는 경우가 많기 때문이다. 다만, 필요에 따라 항소심에서 새로이 가집행을 선고하거나 보복적 가집행을 명할 수도 있다.

**V. 항소인용판결**

**1. 자판**

**(1) 의의 및 원칙**

- 항소심 법원이 제1심 판결을 부당하다고 인정하여 이를 취소하고, 스스로 사건의 실체에 대하여 판단을 내리는 것을 의미한다. 속심제를 채택하고 있는 우리 법제하에서 항소인용의 원칙적인 모습이다.

**(2) 사유[민소법 제416조]**

- 제1심 판결이 부당하다고 인정되는 경우 법원은 이를 취소하고 자판한다. 사실관계의 오인, 법리 적용의 오류, 절차적 위법 등이 모두 포함된다.

**2. 환송**

**(1) 필수적 환송[민소법 제418조]**

- 소각하 판결이 부당하여 취소하는 경우, 원칙적으로 사건을 제1심 법원에 돌려보내야 한다. 이는 당사자의 심급의 이익을 보장하기 위함이다. 다만, 제1심에서 충분히 심리되었거나 당사자가 자판에 동의하는 경우에는 예외적으로 자판할 수 있다.

**(2) 절차적 위법에 의한 환송[민소법 제417조]**

- 제1심 판결의 절차가 법률에 어긋날 때 법원은 판결을 취소하고 환송할 수 있다. 관할 위반이나 전속관할 위반 등이 이에 해당한다.

**3. 이송**

**(1) 관할 위반에 의한 이송[민소법 제419조]**



- 제1심 판결이 관할권을 위반하여 판결을 내린 경우, 항소심 법원은 제1심 판결을 취소하고 관할권이 있는 법원으로 사건을 이송하여야 한다.

## **(2) 전속관할과 이송**

- 특히 전속관할을 위반한 제1심 판결은 반드시 취소되어야 하며, 적법한 전속관할 법원으로 이송함으로써 재판의 적정성을 기한다.

## **Ⅵ. 결론**

- 항소심의 종국재판은 항소의 적법성 여부와 본안의 당부를 기준으로 결정, 명령, 판결의 다양한 형태로 나타난다. 형식적 요건을 강조하는 각하 재판은 소송의 불필요한 지연을 방지하며, 기각과 인용 판결은 실체적 정의를 실현하는 도구가 된다. 특히 인용 판결에서 자판과 환송, 이송의 구별은 당사자의 심급 보호와 재판의 효율성이라는 두 가치를 조화시키기 위한 법적 장치이다. 항소심 법원은 이러한 재판 형식들을 엄격히 구분하여 적용함으로써 하급심 판결의 오류를 교정하고 사법 제도의 신뢰를 제고해야 한다.

## <제6편 상소심절차.제15장 상고.제1절 상고의 의의>

### I. 개념

#### 1. 상고의 정의

- 상고란 제2심 판결인 항소심 판결에 대하여 불복하여 대법원에 하는 상소를 의미한다. 이는 판결의 확정을 차단하고 사건을 상급법원으로 이심시키는 효력을 가지는 상소의 일종이다. 항소가 제1심 판결에 대한 전면적인 재심사를 목적으로 하는 속심의 성격을 갖는 것과 달리, 상고는 항소심 판결의 당부만을 법률적인 관점에서 심사하는 사후심이자 법률심의 성격을 지닌다.

#### 2. 상고의 대상

- 상고의 대상은 원칙적으로 고등법원 또는 지방법원 본원 합의부가 제2심으로서 내린 종국판결이다. 또한 제1심 판결에 대하여 당사자 쌍방이 항소권을 유보하고 직접 상고하기로 합의한 경우(비약적 상고)에는 제1심 판결도 상고의 대상이 될 수 있다. 중간판결이나 종국전의 재판에 대해서는 독립하여 상고할 수 없으며, 종국판결에 대한 상고가 있을 때 그 판단의 전제가 된 경우에 한하여 상고심의 판단을 받게 된다.

#### 3. 상고의 목적

- 상고제도의 일차적 목적은 개별 사건에 있어서 부당한 항소심 판결을 시정하여 당사자의 권리를 구제하는 데 있다. 그러나 보다 본질적인 국가적·공익적 목적은 법령의 해석과 적용의 통일을 기하는 것이다. 최고법원인 대법원이 법령 해석의 최종적인 기준을 제시함으로써 법적 안정성을 도모하고, 하급심 판결의 불균형을 해소하여 국민의 평등권을 보장하는 기능을 수행한다.

#### 4. 상고의 요건

- 상고는 적법한 항소심 판결이 존재해야 하며, 상고를 제기할 수 있는 기간(판결서 송달 후 2주) 내에 제기되어야 한다. 또한 상고인에게 상고의 이익이 있어야 한다. 즉, 항소심 판결에 의하여 불이익을 받은 당사자만이 상고를 제기할 수 있으며, 승소한 당사자는 원칙적으로 상고할 수 없다. 다만, 판결이유에 불만이 있거나 상계권 행사의 제한 등 특수한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 인정되기도 한다.

### II. 법률심으로서의 상고심

#### 1. 법률심의 원칙

- 상고심은 원칙적으로 법률심이다. 이는 상고심 법원이 항소심이 확정된 사실관계에 구속되며, 오직 항소심 판결이 법령을 위반하였는지 여부만을 심판의 대상으로 삼는다는 것을 의미한다. 따라서 당사자는 상고심에서 새로운 사실을 주장하거나 증거를 제출할 수 없으며, 상고이유 또한 원칙적으로 법령 위반에 한정된다.

#### 2. 사실관계의 구속력

- 민사소송법은 상고법원이 판결에 의하여 확정된 사실에 기속된다고 명시하고 있다. 즉, 항소심이 적법하게 거친 증거조사를 통해 확정된 사실은 상고심에서 다룰 수 없는 것이 원칙이다. 상고심은 항소심 판결의 기초가 된 사실이 기록에 나타난 자료와 부합하는지, 그 과정에서 채증법칙 위반이나 심리미진의 과오가 없는지를 검토할 뿐, 독자적으로 새로운 사실을 인정하지 않는다.

#### 3. 사실심의 예외적 검토

- 법률심 원칙에도 불구하고 사실관계에 관한 판단이 상고심의 심리 대상이 되는 경우가 있다. 첫째, 항소심의 사실인정 과정에 있어 채증법칙 위반이 있는 경우이다. 논리와 경험의 법칙에 반하여 증거를 취사선택하거나 사실을 인정한 경우, 이는 단순한 사실인정의 문제가 아니라 법령 위반의 문제로 취급되어 상고이유가 된다. 둘째, 심리미진의 경우이다. 판결 결과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사실에 관하여 심리를 제대로 하지 않은 경우 상고심은 이를 파기할 수 있다. 셋째, 직권조사사항에 관한 사실이다. 법원의 관할, 당사자 능력, 소송대리권 등 법원이 직권으로 조사해야 할 사항에 대해서는 상고심도 독자적으로 사실을 조사할 수 있다.

#### 4. 상고심의 심리 범위

- 상고심은 상고이유서에 기재된 상고이유에 의하여 심리하며, 그 범위를 벗어나 심판할 수 없는 것이 원칙이다. 이를 본론주의적 성격의 투영이라 볼 수 있다. 다만, 판결에 영향을 미친 법령 위반이나 직권조사사항에 대해서는 상고이유에 포함되지 않았더라도 상고법원이 직권으로 심판할 수 있다. 특히 소송요건의 흠결이나 전속관할 위반, 재판권의 부존재 등은 상고이유의 기재 여부와 관계없이 상고심의 판단 대상이 된다.

#### 5. 심리불속행 제도

- 대법원은 법률심으로서의 기능을 효율적으로 수행하기 위해 상고심절차에 관한 특례법에 따른 심리불속행 제도를 운용한다. 상고이유가 법률이 정한 특정한 사유(헌법 위반, 법령 해석의 중대한 오해, 판례 상반 등)를 포함하지 않는 경우, 더 이상 심리를 하지 않고 상고를 기각하는 제도이다. 이는 상고심이 모든 사건의 사실관계를 재검토하는 것이 아니라, 법적 가치가 큰 사건에 집중하여 법령 통일의 기능을 완수하기 위한 장치이다.

### III. 결론

- 상고는 항소심 판결에 대한 최종적인 불복 수단으로서, 권리 구제의 마지막 단계이자 법령 해석의 통일을 기하는 고도의 공익적 절차이다. 법률심 원칙에 따라 상고심은 사실관계 확정보다는 법리적용의 적정성을 심사하는 데 주력하며, 이는 하급심의 법 집행을 감독하고 국가 전체의 법적 질서를 유지하는 기반이 된다. 따라서 상고심 절차는 단순한 사건의 연장이 아니라 법률적 쟁점을 정제하여 최고법원의 판단을 구하는 정교한 법적 과정으로 이해되어야 한다. 당사자와 대리인은 사실심에서 미진했던 법리적 논거를 상고이유로 구성하여 법률심의 본질에 부합하는 소송행위를 수행하여야 하며, 대법원은 이를 통해 법의 지배를 실현하고 국민의 기본권을 최종적으로 수호하는 역할을 다하여야 한다.

## <제6편 상소심절차.제15장 상고.제2절 상고이유>

### I. 일반적 상고이유

#### 1. 판결에 영향을 미친 법령 위반

- 상고는 원심판결이 법령에 위반되었음을 이유로 하는 경우에만 제기할 수 있다. 민사소송법 제423조는 상고는 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 하는 때에만 할 수 있다고 규정하고 있다. 여기서 법령 위반이란 성문법뿐만 아니라 관습법, 조리, 판례 등 법원(法源)이 되는 모든 규범의 해석과 적용에 있어서의 과오를 포함한다.

#### 2. 판결에 영향을 미친다는 의미

- 일반적 상고이유가 인정되기 위해서는 단순히 법령 위반이 존재한다는 것만으로는 부족하며, 그 위반이 판결의 결론에 영향을 미쳤어야 한다. 즉, 그 법령 위반이 없었더라면 판결의 결과가 달라졌을 가능성이 있는 경우를 의미한다. 만약 원심판결의 이유에 법령 위반의 잘못이 있다 하더라도, 다른 이유에 의하여 결론이 정당하다고 인정되는 경우에는 판결에 영향을 미친 것이 아니므로 상고이유가 될 수 없다.

#### 3. 실체법 위반

- 실체법 위반은 주로 법률관계의 발생, 변경, 소멸에 관한 법규의 해석이나 적용의 오류를 의미한다. 대표적으로 법률행위의 해석을 잘못하거나, 권리의 존부에 관한 법률적 판단을 그르친 경우이다. 또한 확정된 사실에 대하여 적용할 법령을 잘못 선택하거나, 법령의 의미를 곡해하여 적용한 경우도 실체법 위반에 해당한다. 상고심은 원심이 확정된 사실을 바탕으로 이러한 실체법적용의 당부를 심사한다.

#### 4. 절차법 위반

- 절차법 위반은 소송의 진행 과정이나 판결의 성립 과정에서 소송법적 규정을 위반한 경우를 의미한다. 증거조사 절차의 위반, 변론주의 원칙의 위반, 석명권 행사의 해태 등이 이에 해당한다. 다만, 모든 절차상 위반이 상고이유가 되는 것은 아니며, 앞서 언급한 바와 같이 그러한 위반이 판결의 결과에 영향을 미쳤음이 인정되어야 한다.

### II. 절대적 상고이유

#### 1. 의의 및 특성

- 민사소송법 제424조 제1항은 판결의 결과에 영향을 미쳤는지 여부를 묻지 않고 무조건 판결을 파기해야 하는 중대한 절차적 하자를 규정하고 있다. 이를 절대적 상고이유라고 한다. 일반적 상고이유와 달리 이 사유들은 그 자체로 소송의 근간을 흔드는 중대한 위반이므로, 법원은 별도의 인과관계 증명 없이 원심판결을 파기하게 된다.

#### 2. 법률에 따라 판결법원을 구성하지 아니한 때

- 재판관의 수가 부족하거나, 법정된 자격이 없는 자가 재판에 관여한 경우, 또는 법관의 사무분담 원칙에 어긋나게 재판부가 구성된 경우 등을 의미한다. 이는 재판의 공정성과 적법성을 담보하는 법원 구성의 원칙을 위반한 것이므로 절대적 상고이유가 된다.

#### 3. 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 법관이 판결에 관여한 때

- 제척 사유가 있거나 기피 신청이 인용된 법관이 재판에 관여한 경우이다. 또한 전심 재판에 관여했던 법관이 상급심 재판에 관여하는 등 직무 집행에서 배제되어야 할 법관이 판결을 내린 경우를 포함한다. 다만, 기피 신청이 거부된 경우에 대해서는 별도의 항고 절차를 거쳐야 하므로 여기서의 관여와는 구별된다.

#### 4. 대리권의 흠결

- 법정대리권, 소송대리권 또는 법인 대표자의 대표권에 흠이 있는 경우이다. 소송능력이 없는 자가 대리인 없이 소송을 수행하거나, 위임장 없이 변호사가 소송을 대리한 경우가 대표적이다. 이는 당사자의 절차적 권리를 심각하게 침해하는 것이므로 절대적 상고이유가 된다. 다만, 소송 진행 중 당사자가 이를 추인한 경우에는 하자가 치유된다.

#### 5. 전속관할에 관한 규정 위반

- 전속관할은 공익적 목적에 의하여 특정 법원에만 재판권을 부여한 것이므로, 이를 위반하여 재판한 경우 하자가 중대하다고 보아 절대적 상고이유로 규정하고 있다. 임의관할 위반은 상고이유가 되지 않는 것과 대조적이다.

#### 6. 변론의 공개 규정 위반

- 헌법과 소송법이 정한 재판 공개의 원칙을 위반하여 정당한 사유 없이 비공개로 변론을 진행한 경우이다. 이는 재판의 투명성을 보장하는 민주적 소송 절차를 무시한 것이므로 판결 결과와 관계없이 파기 사유가 된다.

#### 7. 판결의 이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때

- 판결서에는 당사자의 주장과 증거에 대한 법원의 판단 근거가 명확히 기재되어야 한다. 이유를 전혀 기재하지 않았거나(이유불비), 기재된 내용만으로는 결론을 도출할 수 없는 경우, 또는 이유의 전후 맥락이 서로 상충하여 결론이 무엇인지 알 수 없는 경우(이유모순)가 이에 해당한다.

### III. 그 밖에 상고이유로서의 재심사유

#### 1. 상고이유와 재심사유의 관계

- 민사소송법 제424조 제2항은 판결 확정 전이라도 재심사유(제451조 제1항)가 있는 경우에는 이를 상고이유로 삼을 수 있다고 규정하고 있다. 재심은 이미 확정된 판결에 대한 비상구제수단이지만, 아직 판결이 확정되지 않은 상고심 단계에서 해당 사유가 발견되었다면 굳이 판결 확정을 기다려 재심을 청구하게 할 필요 없이 상고심에서 이를 해결하도록 하는 취지이다.

#### 2. 주요 사유의 검토

- 재심사유 중 상고이유로 자주 인용되는 것으로는 판결의 기초가 된 문서나 증거가 위조·변조된 경우, 증인·감정인 등의 허위진술이 판결의 증거가 된 경우, 당사자가 상대방의 주소나 성명을 허위로 기재하여 판결을 받은 경우 등이 있다. 또한 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 경우도 재심사유이자 곧 상고이유가 된다.

#### 3. 사실관계 확정과의 경계

- 재심사유 중 증거의 위조 등은 사실인정의 기초가 되는 부분이다. 법률심인 상고심은 원칙적으로 새로운 증거를 조사할 수 없으나, 재심사유의 존부를 확인하기 위한 범위 내에서는 예외적으로 사실조사가 허용될 수 있다. 다만, 실무적으로는 원심판결 확정 후 관련 형사판결 등을 통해 위조 사실이 객관적으로 드러난 경우에 이를 근거로 상고이유를 판단하는 것이 일반적이다.

#### 4. 판단누락의 특수성

- 원심이 당사자의 공격방어방법에 대하여 판단을 하지 않은 판단누락은 재심사유임과 동시에 독립된 상고이유로 기능한다. 이는 절대적 상고이유 중 이유불비와 유사한 성격을 띠지만, 판결문의 형식적 기재 여부보다는 당사자의 실질적 주장에 대한 법원의 응답 여부에 초점을 맞춘다는 점에서 구별된다.

#### **N. 결론**

- 상고이유는 법률심인 상고심의 심판 범위를 확정(劃定)하는 핵심적인 요소이다. 일반적 상고이유가 판결의 결과에 영향을 미친 법령 위반을 폭넓게 포괄한다면, 절대적 상고이유는 소송 절차의 공정성을 지키기 위한 최소한의 금도(襟度)를 규정한 것이다. 또한 재심사유를 상고이유로 포섭하는 것은 소송경제와 당사자의 권리 구제를 조화시키기 위한 입법적 배려이다. 상고인은 단순히 원심판결에 불복하는 것에 그치지 않고, 제한된 상고이유 중 어느 것에 해당하는지를 명확히 소명해야 하며, 대법원은 이를 근거로 사법정의를 최종적으로 실현하게 된다. 이러한 상고이유 체계는 법치주의의 실질적 구현을 위한 제도적 장치로서 그 의미가 매우 크다.

## <제6편 상소심절차.제15장 상고.제3절 상고심절차의 개시와 심리>

### I. 하급심 규정의 준용

- 상고와 상고심의 소송절차에는 특별한 규정이 없으면 항소심절차에 대한 규정을 준용하고(민소법 제425조), 항소심의 소송절차에는 특별한 규정이 없으면 제1심의 소송절차에 관한 규정이 준용되므로(민소법 제408조), 결국 상고 및 상고심의 소송절차에는 특별한 규정이 없는 한 항소심 및 제1심의 소송절차에 관한 규정이 준용되게 된다.

### II. 상고심절차의 개시

#### 1. 상고의 제기

- 상고는 항소심판결에 대하여 불복하는 당사자가 상고장을 원심법원(항소심법원)에 제출함으로써 시작된다. 상고제기기간은 항소심판결서가 송달된 날부터 2주 이내이며, 이 기간은 불변기간이다. 상고장에는 당사자와 법정대리인, 제1심 및 항소심판결의 표시, 그 판결에 대한 상고의 취지를 기재하여야 한다.

#### 2. 상고기록의 송부와 수리

- 상고장이 제출되면 원심법원은 상고장의 적식 여부를 심사한 후 상고기록을 작성하여 상고법원(대법원)으로 송부한다. 대법원 서신과는 상고기록을 전달받으면 이를 접수하고 상고기록접수통지서를 당사자에게 송달한다. 이 통지는 상고이유서 제출기간을 계산하는 기준점이 되므로 절차상 매우 중요하다.

#### 3. 상고이유서의 제출

- 상고인은 상고기록접수통지를 받은 날부터 40일 이내에 상고이유서를 제출하여야 한다. 상고장에 상고이유를 구체적으로 적지 않은 경우에는 반드시 이 기간 내에 별도의 상고이유서를 제출해야 하며, 이를 해태할 경우 상고법원은 별도의 심리 없이 결정으로 상고를 기각한다. 상고이유서에는 원심판결의 어떠한 점이 법령에 위반되었는지를 구체적으로 명시하여야 한다.

#### 4. 답변서의 제출과 교환

- 상고이유서가 제출되면 대법원은 그 부분을 상대방(피상고인)에게 송달한다. 피상고인은 송달받은 날부터 10일 이내에 답변서를 제출할 수 있다. 답변서는 상고인의 주장을 반박하고 원심판결의 정당성을 옹호하는 내용을 담는다. 이후 필요에 따라 다시 상고인이 반박서를 제출하는 등 서면 교환 절차가 이루어질 수 있다.

### III. 상고심의 심리원칙

#### 1. 법률심원칙

- 상고심은 원심판결의 법령 위반 여부만을 심판하는 법률심이다. 따라서 원심이 적법하게 확정된 사실관계는 상고법원을 기속하며, 상고법원은 새로운 증거조사를 하거나 사실관계를 재확정할 수 없다. 다만, 사실확정 과정에 있어 채증법칙 위반이나 논리칙·경험칙 위배와 같은 법령 위반이 있는 경우에는 이를 법률적 관점에서 심사할 수 있다.

#### 2. 사후심원칙

- 상고심은 항소심판결 당시의 상태를 기준으로 그 판결의 당부를 사후적으로 심사하는 사후심의 성격을 갖는다. 항소심까지는 변론종결 시까지 새로운 사실이나 증거를 제출할 수 있는 속심적 성격이 있으나, 상고심에서는 원칙적으로 새로운 사실의 주장이나 증거의 제출이 허용되지 않는다.

#### 3. 서면심리주의

- 상고심은 원칙적으로 당사자의 변론 없이 상고장, 상고이유서, 답변서 등 기록에 나타난 서면만을 근거로 심리한다. 민사소송법은 상고심에서 변론 없이 판결할 수 있도록 규정하고 있으며, 실제 대법원 재판의 대다수는 변론 절차 없이 서면심리만으로 종결된다. 다만, 법원이 법률적 쟁점의 해명을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 변론을 열어 당사자의 진술을 들을 수 있다.

#### 4. 상고이유에 의한 제한

- 상고심의 심리 범위는 원칙적으로 당사자가 주장한 상고이유에 한정된다. 이를 상고이유의 구속력이라 한다. 다만, 직권조사사항(소송요건, 전속관할 위반, 절대적 상고이유 등)에 대해서는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 스스로 조사하여 판단할 수 있다.

### IV. 상고심절차의 특례

#### 1. 상고심절차에 관한 특례법의 적용

- 대법원 업무의 과중을 방지하고 신속한 권리 구제를 위해 상고심절차에 관한 특례법이 시행되고 있다. 이 법은 민사소송, 가사소송, 행정소송의 상고심 절차에서 일반적인 민사소송법 규정보다 우선하여 적용되는 특례를 담고 있다.

#### 2. 심리불속행 제도

- 상고심 특례법의 가장 핵심적인 제도는 심리불속행 기각이다. 상고이유가 법령이 정한 특정한 사유(헌법 위반, 법률 해석의 중대한 오류, 대법원 판례와의 상반 등)를 포함하지 않는 경우, 대법원은 본안 심리를 하지 않고 결정으로 상고를 기각할 수 있다. 이는 상고기록접수통지를 받은 날부터 4개월 이내에만 할 수 있으며, 이 경우 판결이유를 별도로 적지 않아도 된다.

#### 3. 심리불속행의 제외 사유

- 모든 사건에 심리불속행이 적용되는 것은 아니다. 절대적 상고이유가 있는 경우나 공익적 견지에서 대법원의 판단이 반드시 필요한 중대한 법률적 쟁점이 포함된 사건은 심리불속행 대상에서 제외되어 본안 심리에 착수하게 된다. 가압류·가처분 등 신청사건이나 형사사건 등에는 이 제도가 적용되지 않는다.

### V. 결론

- 상고심절차는 원심의 사실확정을 전제로 법령 적용의 정당성만을 엄격히 심사하는 고도의 법률적 과정이다. 절차의 개시 단계에서부터 상고이유서 제출 기한의 준수 등 형식적 요건이 매우 강조되며, 심리 과정 역시 서면 중심의 사후심 원칙을 고수한다. 특히 심리불속행 제도는 대법원이 최고의 법률 해석 기관으로서 본연의 기능을 수행하도록 돕는 장치인 동시에, 당사자에게는 상고이유 작성의 구체성과 법률적 논거의 치밀함을 요구하는 문턱이 된다. 결론적으로 상고심은 단순한 사실관계의 억울함을 호소하는 자리가 아니라, 원심판결에 내포된 법적 과오를 논리적으로 규명하여 법적 안정성을 도모하는 절차라 할 수 있다.

## <제6편 상소심절차.제15장 상고.제4절 상고심의 중국재판>

### I. 상고장 각하명령

#### 1. 원심재판장의 상고장 각하명령

- 상고가 제기되었으나 상고장에 법률이 정한 필수적 기재사항이 누락되었거나, 규정된 금액의 인지가 붙어 있지 않은 경우 원심재판장은 상고인에게 상당한 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 상고인이 이 보정명령을 받고도 정해진 기간 내에 흠결을 보정하지 아니한 때에는 원심재판장은 결정으로 상고장을 각하한다. 이는 상고심의 업무 부담을 줄이고 명백히 부적법한 상고를 사전에 차단하기 위한 장치이다.

#### 2. 상고법원 재판장의 상고장 각하명령

- 상고기록이 상고법원에 송달된 후에도 원심단계에서 발견하지 못한 상고장의 흠결이 발견될 수 있다. 이때 상고법원의 재판장은 다시 보정을 명할 수 있으며, 상고인이 이에 응하지 않을 경우 명령으로써 상고장을 각하한다. 또한, 상고인이 상고이유서를 법정 기간인 40일 이내에 제출하지 아니하거나, 제출된 상고이유서가 법령이 정한 방식에 어긋나는 경우에도 별도의 변론 없이 명령으로 상고를 각하하게 된다.

### II. 상고각하판결

#### 1. 의의 및 사유

- 상고각하판결은 상고제기 자체가 부적법하여 본안에 관한 심리를 거절하는 재판이다. 상고장 각하명령이 주로 형식적인 서면의 흠결을 대상으로 한다면, 상고각하판결은 상고권의 유무, 상고기간의 도과, 상고이익의 부존재 등 소송요건의 불비가 있는 경우에 행해진다. 예를 들어 상소권 포기 후의 상고나 부상소의 합의가 있음에도 제기된 상고 등이 이에 해당한다.

#### 2. 절차적 특징

- 상고법원은 상고의 부적법함이 명백한 경우 변론을 열지 않고 판결로써 상고를 각하할 수 있다. 소송요건은 직권조사사항이므로 당사자의 주장이 없더라도 법원은 스스로 이를 조사하여야 하며, 판결 시까지 흠결이 보정되지 않으면 각하 판결을 선고한다. 다만, 상고이유서 미제출로 인한 각하는 판결이 아닌 결정의 형식을 취하는 경우가 많다는 점에서 일반적인 소송요건 불비와 구별된다.

### III. 상고기각판결

#### 1. 본안심리 결과 상고이유의 부존재

- 상고법원이 본안 심리를 수행한 결과, 상고인이 주장하는 상고이유가 인정되지 않거나 원심판결이 법령을 위반하지 않았다고 판단될 때 내리는 재판이다. 상고심은 법률심이므로 원심이 확정된 사실관계가 상고법원을 기속하며, 그 사실관계에 기초한 법률 적용이 정당하다면 상고는 기각된다.

#### 2. 이유의 교체에 의한 기각

- 원심판결이 판단 근거로 삼은 법리나 이유가 적절하지 않더라도, 다른 법리나 근거에 비추어 볼 때 결론적으로 원심의 주문이 정당하다고 인정되는 경우에는 상고를 기각한다. 이를 이유의 교체라고 하며, 상고법원은 원심의 잘못된 논거를 바로잡으면서도 최종적인 결과가 타당하다면 원심판결을 유지한다.

#### 3. 상고심절차에 관한 특례법상 심리불속행 기각

- 상고이유가 헌법 위반, 법률 해석의 중대한 오류 등 특례법이 정한 특정 사유에 해당하지 않는 경우, 상고법원은 본안 심리를 더 이상 진행하지 않고 상고를 기각할 수 있다. 이는 판결의 형식을 취하지만 판결이유를 기재하지 않아도 된다는 특징이 있으며, 대법원의 재판 자원을 효율적으로 배분하기 위해 널리 활용되고 있다.

### IV. 상고인용판결[민소법 제436조, 제438조]

#### 1. 원판결의 파기

- 상고법원이 상고이유가 정당하다고 인정하여 원심판결을 취소하는 것을 파기라고 한다. 민사소송법 제436조에 따라 상고법원은 상고이유가 있다고 인정할 때에는 원판결을 파기하여야 한다. 파기되는 범위는 원칙적으로 상고인이 불복한 범위 내에 한정되지만, 상고이유가 된 잘못이 판결 전체에 영향을 미치거나 불가분적으로 연결된 경우에는 판결 전부를 파기할 수 있다.

#### 2. 환송 또는 이송

- 원판결을 파기한 경우, 상고법원은 원칙적으로 사건을 다시 심리하도록 원심법원에 돌려보내는 것을 환송이라 한다. 민사소송법 제436조 제1항에 의거하여 사건을 환송받은 법원은 상고법원이 파기의 이유로 삼은 법률상 판단에 기속된다. 만약 사건이 원심법원의 관할이 아니거나 다른 법원에서 심리하는 것이 적절하다고 판단되는 경우에는 이송 결정을 내릴 수도 있다. 이로써 사건은 다시 항소심 단계로 돌아가 사실관계와 법률관계를 재차 심리받게 된다.

#### 3. 자판

- 민사소송법 제438조는 예외적으로 상고법원이 사건을 하급심으로 돌려보내지 않고 스스로 직접 판결하는 자판을 규정하고 있다. 자판이 허용되는 경우는 확정된 사실에 대하여 법령 적용이 잘못되었음을 이유로 판결을 파기하는 경우로서, 사건이 충분히 성숙하여 다시 사실심을 거칠 필요가 없을 때이다. 상고법원이 스스로 판결을 내림으로써 소송 경제를 도모하고 분쟁을 조기에 종결시키는 효과가 있으나, 법률심인 상고법원의 특성상 매우 제한적인 범위 내에서 이루어진다.

### V. 결론

- 상고심의 중국재판은 형식적 요건의 심사로부터 시작하여 본안의 법률적 정당성 판단에 이르기까지 단계별로 체계화되어 있다. 상고장 각하나 상고각하판결이 절차적 적법성을 담보한다면, 상고기각과 인용판결은 법령 해석의 통일을 기하고 개별 사건의 정의를 실현하는 역할을 수행한다. 특히 파기 환송 제도는 하급심에 대한 상고심의 법률적 지도 기능을 구체화하며, 자판 제도는 예외적인 상황에서 신속한 재판을 보장한다. 상고심의 재판은 단순히 해당 사건의 결론을 내는 것을 넘어 국가 전체의 법 집행 기준을 확립한다는 점에서 중대한 사법적 의미를 지닌다.

## <제6편 상소심절차.제16장 항고.제1절 항고의 의의>

### I. 항고의 개념

#### 1. 항고의 정의와 본질

- 항고란 판결 이외의 재판인 결정이나 명령에 대하여 불복을 신청하는 상소의 일종이다. 민사소송법상 재판은 그 형식에 따라 판결, 결정, 명령으로 구분되는데 판결에 대한 상소 수단이 항소와 상고라면 결정과 명령에 대한 상소 수단은 항고이다. 이는 재판의 성격에 따라 불복 절차를 이원화하여 소송의 효율성과 신속성을 도모하기 위한 장치이다. 항고는 상소의 일종이므로 상소 일반의 원칙이 적용된다. 하급법원의 재판에 대하여 상급법원에 구제를 구하는 단계적 구조를 가지며, 항고의 제기로 인하여 재판의 확정기 차단되는 확정차단력과 사건이 상급심으로 옮겨지는 이심력을 발생시킨다. 다만, 판결에 대한 항소와 달리 항고는 절차의 간이성과 신속성을 중시하므로 반드시 변론을 거쳐야 하는 것은 아니며, 서면 심리만으로 재판할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

#### 2. 항고권의 발생과 소송구조

- 항고를 제기하기 위해서는 항고인에게 불복의 이익인 항고이익이 존재해야 한다. 결정이나 명령에 의하여 자기의 법률상 지위가 침해되었거나 불이익을 입은 당사자 또는 이해관계인이 항고권을 행사할 수 있다. 또한 항고는 법률이 명문으로 허용하는 경우이거나 재판의 성질상 불복이 당연히 예정된 경우에 한하여 허용된다. 소송구조 측면에서 항고는 독립된 상소절차로서 원재판의 당부만을 심사하는 사후심적 성격과 새로운 자료를 제출할 수 있는 속심적 성격을 동시에 보유한다.

### II. 항고의 유형

#### 1. 시기에 따른 구분

- 일반항고는 제기 시기에 따라 보통항고와 즉시항고로 구분된다.

##### (1) 보통항고

- 보통항고는 결정이나 명령의 성질상 즉시 확정할 필요가 없는 경우에 허용되며 당해 절차가 존속하는 한 언제든지 제기할 수 있는 항고를 말한다. 다만, 보통항고는 제기하더라도 원재판의 집행을 정지시키는 효력이 당연히 발생하는 것은 아니며 법원의 별도 결정이 있어야만 집행이 정지된다.

##### (2) 즉시항고

- 즉시항고는 법률에 명문의 규정이 있는 경우에 한하여 허용되며 재판이 고지된 날부터 일정한 짧은 기간 내에 제기하여야 하는 항고이다. 민사소송법상 즉시항고 기간은 1주이다. 즉시항고는 신속한 확정이 필요한 재판을 대상으로 하며 제기 시 원재판의 집행을 정지시키는 효력을 가진다는 점이 보통항고와 구별되는 가장 큰 특징이다.

#### 2. 심급에 따른 구분

- 항고는 그 심급적 위치에 따라 일반항고와 재항고로 나뉜다.

##### (1) 일반항고

- 제1심 법원의 결정이나 명령에 대하여 항고법원에 불복하는 첫 번째 단계의 항고를 의미한다. 이는 판결의 항소에 대응하는 개념이다.

##### (2) 재항고

- 항고법원·고등법원 또는 항고심으로서의 지방법원 합의부의 결정 및 명령에 대하여 다시 불복하는 절차를 의미한다. 재항고는 상고와 유사한 성격을 지니며 대법원이 관할하게 된다. 재항고는 원재판에 법령 위반 등의 중대한 사유가 있는 경우에 한하여 제기할 수 있다.

#### 3. 특별한 형태 : 특별항고

- 특별항고는 불복할 수 없는 결정이나 명령에 대하여 재판에 영향을 미친 헌법 위반이나 법률 위반이 있음을 이유로 대법원에 제기하는 비상 불복 수단이다. 일반적인 항고 절차를 거칠 수 없는 확정된 재판에 대하여 헌법 수호와 법령 해석의 통일을 위해 예외적으로 인정되는 제도이다.

### III. 항고의 적용범위

#### 1. 대상이 되는 재판의 범위

- 항고의 대상은 원칙적으로 결정과 명령에 한정된다. 소송 절차상의 부수적 사항이나 집행 절차에서의 판단 등 판결 형식을 취하지 않는 재판들이 주된 대상이다. 예를 들어 소장각하결정, 소송비용액확정결정, 부동산경매절차에서의 매각허가결정 등이 이에 해당한다. 판결의 경우 그 내용이 절차적 사항이라 하더라도 항고의 대상이 될 수 없으며 항소로 다루어야 한다.

#### 2. 인적 적용범위

- 항고는 소송 당사자뿐만 아니라 재판으로 인하여 직접 권리를 침해받은 제3자에게도 개방되어 있다. 판결에 대한 항소가 원칙적으로 당사자에게만 허용되는 것과 비교하여 항고는 재판의 효력이 미치는 이해관계인의 범위를 폭넓게 인정하는 경향이 있다. 이는 결정이나 명령이 당사자 이외의 자에게 실질적인 영향을 미치는 경우가 많기 때문이다. 판례에 따르면 재판의 결과에 대하여 법률상 이해관계를 가지는 자는 항고권을 행사할 수 있는 적격을 가진다.

#### 3. 법률적 적용범위

- 항고는 민사소송법뿐만 아니라 민사집행법, 비송사건절차법, 가사소송법 등 다양한 법 영역에서 활용된다. 각 법률은 해당 절차의 특성에 맞게 항고의 제기 기간, 방식, 효력 등을 별도로 규정하고 있다. 특히, 민사집행 절차에서는 집행의 신속성과 채권자의 이익 보호를 위해 즉시항고 제도를 광범위하게 운용하고 있으며 항고 이유의 서면 제출 강제 등 엄격한 절차적 요건을 부과하기도 한다.

#### 4. 적용의 제한과 예외

- 법률에 의하여 불복이 금지된 결정이나 명령에 대해서는 일반항고를 제기할 수 없다. 또한 대법원의 결정이나 명령에 대해서는 항고의 성질상 상급법원이 존재하지 않으므로 항고가 불가능하며 오직 특별항고의 요건을 갖춘 경우에만 대법원 자체에 대한 비상 불복만이 가능하다. 소송절차의 원활한 진행을 위해 중간적 결정이나 부수적 명령에 대해서는 항고를 제한하고 최종 판결에 대한 상소 시 함께 다투도록 하는 경우도 존재한다.

### IV. 결론

- 항고는 판결에 의한 종국적 해결 이외의 소송 과정에서 발생하는 다양한 법률적 쟁점들을 효율적으로 시정하기 위한 필수적 제도이다. 항고의 유형을 보통항고, 즉시항고, 특별항고 등으로 세분화하여 운영하는 것은 재판의 신속성과 당사자의 권리 구제라는 상충하는 가치를 조화시키기 위한 입법적 노력의 결과이다. 항고 제도를 통해 법원은 오판을 스스로 교정할 기회를 얻으며 당사자는 불의의 결정이나 명령으로 인한 피해를 방지할 수 있다. 이와 같은 항고 절차의 의의와 유형 및 범위를 정확히 이해하는 것은 복잡한 민사소송 절차 전반을 관통하는 불복 체계를 파악하는 데 중추적인 역할을 한다. 또한 실무적으로 즉시항고의 기간 준수와 항고이유서 제출 등 절차적 요건을 엄격히 준수하는 것이 권리 구제의 실효성을 확보하는 관건이 된다.



## <제6편 상소심절차.제16장 항고.제2절 항고의 절차>

### I. 항고의 제기

#### 1. 항고장의 제출

- 항고를 제기하고자 하는 자는 항고장을 원재판을 한 법원인 원심법원에 제출하여야 한다. 이는 항고심법원에 직접 제출하는 것이 아니라 원심법원을 경유하도록 함으로써 원심법원이 스스로 자신의 재판을 검토하고 오판을 교정할 기회를 부여하기 위함이다. 항고장에는 당사자와 법정대리인, 항고의 대상이 되는 원재판의 표시, 그 재판에 대한 항고의 취지를 기재하여야 한다. 민사소송법은 항소의 경우와 달리 항고 이유의 기재를 강제하지 않는 것이 원칙이나, 실무상 신속한 심리를 위해 항고 이유를 함께 적거나 별도의 항고이유서를 제출하는 것이 일반적이다. 다만, 민사집행법상 즉시항고의 경우에는 항고장에 항고 이유를 적지 아니한 때에는 항고장을 제출한 날부터 10일 이내에 항고이유서를 제출하여야 하며, 이를 위반할 경우 항고가 각하될 수 있음에 유의해야 한다. 항고장의 제출은 재판의 고지를 받은 날로부터 가능하며, 재판의 고지 전이라도 재판이 성립한 이상 항고를 제기할 수 있다는 것이 통설의 입장이다.

#### 2. 항고기간

- 항고의 제기 기간은 항고의 종류에 따라 차이가 있다. 보통항고의 경우에는 법률상 특별한 기간의 제한이 없으므로 원재판이 취소됨으로써 얻을 수 있는 이익이 존속하는 한 언제든지 제기할 수 있다. 반면, 즉시항고는 재판이 고지된 날부터 1주 이내에 제기하여야 하는 불변기간의 제한을 받는다. 이 기간은 당사자가 재판의 고지를 받은 날부터 기산하며, 기간의 말일이 공휴일에 해당할 경우 그 다음 날까지로 연장된다. 즉시항고 기간은 불변기간이므로 당사자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 기간을 준수하지 못한 경우에는 소송행위의 추후 보완이 허용될 수 있다. 그러나 기간을 도과하여 제기된 즉시항고는 부적법한 것으로서 각하의 대상이 된다. 재항고 역시 즉시항고에 관한 규정이 준용되므로 원심판결의 고지를 받은 날로부터 1주 이내에 제기하여야 한다.

### II. 항고의 효력

#### 1. 확정차단력과 이심력

- 항고가 적법하게 제기되면 원재판의 확정력이 차단되는 확정차단력이 발생한다. 이는 상소 공통의 효력으로서 재판이 상급심의 심판 대상이 됨을 의미한다. 또한 항고장의 제출과 동시에 당해 사건은 원심법원의 수권에서 벗어나 항고심법원으로 옮겨지는 이심력이 발생한다. 다만, 항고의 경우 원심법원이 항고가 이유 있다고 인정하여 스스로 재판을 경정할 수 있는 심사수권이 인정되므로, 실제적인 사건의 기록 송부는 원심법원의 경정 절차가 종료된 이후에 이루어진다.

#### 2. 집행정지의 효력

- 보통항고는 제기하더라도 원재판의 집행을 정지시키는 효력이 당연히 발생하지 않는다. 따라서 재판의 집행을 정지시키기 위해서는 항고법원이나 원심법원으로부터 별도의 집행정지 결정을 받아야 한다. 이와 대조적으로 즉시항고는 법률에 특별한 규정이 없는 한 집행을 정지시키는 효력을 가진다. 즉시항고가 제기되면 원재판에 기한 후속 절차의 진행이 법률상 당연히 멈추게 된다. 이는 즉시항고의 대상이 되는 재판이 확정되어야만 효력이 발생하는 경우가 많기 때문이다. 다만, 집행절차의 지연을 방지하기 위해 민사집행법 등 특별법에서는 즉시항고의 경우에도 집행정지 효력을 부정하고 별도의 집행정지 명령을 받도록 규정하는 경우가 다수 존재하므로 개별 법령의 검토가 필요하다.

### III. 항고의 심판

#### 1. 원심법원의 처리와 경정결정

- 항고장이 제출되면 원심법원은 먼저 항고의 적법 여부를 심사한다. 항고가 부적법하고 그 흠결을 보정할 수 없는 경우에는 결정으로 항고를 각하한다. 항고가 적법하다고 판단될 경우 원심법원은 항고가 이유 있는지 여부를 실질적으로 검토한다. 이때 원심법원이 항고가 이유 있다고 인정하는 때에는 그 재판을 스스로 경정하여야 한다. 이를 항고의 전심절차 또는 자조적 교정이라 한다. 이는 결정이나 명령이 판결에 비해 절차적 엄격성이 낮으므로 신속하게 오류를 바로잡기 위한 장치이다. 만약 원심법원이 재판을 경정하지 아니할 때에는 항고장 접수일부터 2주 이내에 항고기록을 항고법원에 송부하여야 한다.

#### 2. 항고심의 심리와 결정

- 항고심의 심리는 원칙적으로 서면심리에 의한다. 판결 절차와 달리 반드시 변론을 열어야 하는 것은 아니며, 필요한 경우에 한하여 변론을 열거나 당사자 및 이해관계인을 심문할 수 있다. 항고심은 항고인의 불복 신청 범위 내에서 원재판의 당부를 심사하며, 새로운 증거의 제출이나 사실상의 주장이 허용되는 속심적 성격을 가진다. 심리 결과 항고가 부적법하거나 이유 없다고 인정될 때에는 결정으로 항고를 각하하거나 기각한다. 반대로 항고가 이유 있다고 인정될 때에는 원재판을 취소하고 항고심법원이 직접 재판하거나, 사건을 원심법원에 환송 또는 이송한다. 항고심의 결정은 당사자에게 고지함으로써 효력이 발생하며, 이에 대해 불복이 있는 경우 요건에 따라 재항고를 제기할 수 있다.

### IV. 결론

- 항고의 절차는 원심법원을 경유하는 제기 방식과 원심법원 스스로의 경정 권한을 핵심으로 한다. 이는 판결 절차에 비하여 신속성과 간이성을 강조하는 결정·명령의 특성을 반영한 것이다. 즉시항고와 보통항고의 기간 차이, 집행정지 효력의 유무 등은 실무상 권리 구제의 성패를 가르는 중요한 요소가 된다. 특히 원심법원의 경정 제도는 불필요한 상급심의 업무 부담을 줄이고 당사자에게 빠른 시정을 제공한다는 점에서 효율적인 사법 운영을 가능케 한다. 항고인은 각 재판의 성질에 따른 정확한 불복 기간과 방식을 준수하여야 하며, 법원은 형식적 요건뿐만 아니라 실질적 사유를 면밀히 검토하여 재판의 정당성을 확보하여야 한다. 이러한 체계적 절차 운영을 통해 민사소송법은 소송 경제와 당사자의 절차적 기본권 보호라는 양대 목표를 조화롭게 달성하게 된다.



<제7편 재심절차.제17장 재심.제1절 재심의 개념>

**I. 의의**

**1. 재심의 정의**

- 재심이란 이미 확정된 중국판결에 대하여 실체적 또는 절차적 하자가 있는 경우, 그 판결의 부당함을 시정하기 위하여 당사자의 소제기로 그 판결을 취소하고 이미 종료된 사건을 다시 심판하는 비상한 구제방법을 의미한다. 통상의 상소인 항소나 상고가 미확정 판결을 대상으로 하여 그 확정을 차단하는 효력을 가지는 것과 달리, 재심은 이미 판결의 확정력이 발생한 이후에 그 효력을 소급적으로 배제시키려는 목적을 가진다. 따라서 재심은 확정판결이 가지는 기판력을 깨뜨리는 예외적인 절차로서, 법적 안정성을 해칠 우려가 있으므로 법률이 정한 엄격한 사유가 있는 경우에만 허용된다.

**2. 재심의 대상과 성격**

- 재심의 대상은 확정된 중국판결이다. 여기에는 본안판결뿐만 아니라 소각하 판결과 같은 절차적 판결도 포함된다. 또한 항고나 재항고에 의하여 불복할 수 있는 결정이나 명령이 확정된 경우에도 재심에 준하는 준재심이 인정되어 동일한 취지의 구제가 가능하다. 재심은 성격상 사후적 구제수단이자 형성적 소송의 성질을 갖는다. 재심소송은 확정판결의 효력을 취소시키는 재심소와 본안사건을 다시 심리하는 본안심판이 결합된 독특한 형태를 취한다. 이는 소송법상 이미 종결된 법률관계를 부활시키는 것이므로 민사소송법 제451조 이하의 규정에 따라 엄격하게 운용된다.

**3. 다른 불복방법과의 관계**

- 재심은 상소와 보충적 관계에 있다. 당사자가 상소에 의하여 재심사유를 주장하였거나, 알고도 주장하지 아니한 때에는 재심을 제기할 수 없다. 이는 상급심의 판단을 거친 사항에 대하여 다시 재심으로 다투는 것을 방지하여 재판의 중복을 피하기 위함이다. 또한 재심은 확정판결의 효력을 직접 다투는 것이므로, 확정판결의 집행을 저지하기 위한 강제집행정지 신청이나 청구이의의 소와는 별개의 절차로 진행된다. 다만, 재심의 소가 제기되었다 하더라도 당연히 집행정지의 효력이 발생하는 것은 아니며, 별도의 집행정지 결정을 받아야 재판의 집행을 멈출 수 있다.

**II. 인정취지**

**1. 구체적 타당성의 실현**

- 민사소송의 궁극적인 목적은 진실한 사실관계에 바탕을 둔 정당한 판결을 통해 사법적 정의의 실현하는 데 있다. 판결이 확정되면 기판력이 발생하여 더 이상 다툴 수 없는 것이 원칙이지만, 만약 그 판결이 위조된 증거에 기초하였거나 법관의 범죄행위가 개입되는 등 중대한 하자가 있음에도 불구하고 그대로 방치한다면 국가 재판에 대한 국민의 신뢰는 근본적으로 흔들리게 된다. 재심 제도는 이처럼 판결의 형성 과정이나 내용에 도저히 묵과할 수 없는 결함이 있는 경우, 법적 안정성을 희생하더라도 구체적 타당성과 실체적 진실을 우선시하여 당사자의 억울함을 해소해주기 위해 존재한다.

**2. 법적 안정성과의 조화**

- 재심은 무제한적으로 허용되지 않으며 법적 안정성과의 조화를 꾀한다. 만약 재심이 아무런 제한 없이 허용된다면 확정판결을 믿고 형성된 새로운 법률관계가 언제든 뒤집힐 수 있다는 불안을 초래하게 된다. 이를 방지하기 위해 우리 민사소송법은 재심사유를 한정적으로 열거하고 있으며, 재심의 제척기간을 설정하여 일정 기간이 지나면 더 이상 다툴 수 없도록 규정하고 있다. 즉, 재심은 재판의 위신을 지키기 위한 정의의 요청과 사회의 평온을 유지하기 위한 법적 안정성의 요청 사이에서 타협점을 찾는 장치라고 할 수 있다.

**3. 절차적 기본권의 보장**

- 헌법상 보장된 재판을 받을 권리는 단순히 재판 형식만을 갖추는 것이 아니라, 공정한 절차에 따라 정당한 재판을 받을 권리를 포함한다. 재심 사유 중 당사자의 대리권 흠결이나 판결에 영향을 미칠 중대한 사항에 대한 누락 등은 당사자의 절차적 조력권이나 진술권이 심각하게 침해된 경우를 상정한 것이다. 이러한 절차적 하자를 시정하지 않는 것은 국가의 보호의무 위반에 해당할 수 있으므로, 재심은 당사자에게 최후의 방어 기회를 부여함으로써 헌법적 가치를 소송법적으로 구체화하는 기능을 수행한다.

**4. 법치주의의 수호**

- 국가 기관인 법원에 의해 내려진 판결이 객관적 진실에 반하거나 부정한 방법에 의해 도출된 경우, 이를 시정하는 것은 국가 스스로의 오류를 인정하고 바로잡는 법치주의적 태도이다. 재심 제도는 사법부의 오판 가능성을 겸허히 수용하고 이를 제도적으로 교정할 수 있는 길을 열어둠으로써, 법치국가로서의 정당성을 확보하는 역할을 한다. 특히, 형사 판결과 연계된 재심 사유 등은 사법 정의가 권력이나 범죄에 의해 오염되었을 때 이를 자정할 수 있는 최후의 보루가 된다.

**III. 결론**

- 재심 제도는 확정판결의 기판력이라는 원칙을 깨고 예외적으로 허용되는 비상한 구제절차이다. 이는 실체적 정의와 구체적 타당성을 확보하여 오판으로 인한 당사자의 피해를 최소화하려는 취지에서 비롯되었다. 하지만 법적 안정성을 저해할 위험이 크기 때문에 민사소송법은 재심사유를 엄격히 제한하고 제척기간을 두어 이를 통제하고 있다. 결국 재심의 운영은 판결의 권위와 안정성을 유지하면서도, 명백히 정의에 반하는 재판 결과를 시정해야 한다는 사법의 도덕적 책무를 이행하는 균형 잡힌 시각이 요구된다. 당사자는 재심의 요건과 사유를 면밀히 검토하여야 하며, 법원은 확정판결의 신뢰를 유지하는 범위 내에서 신중하게 재심 절차를 운용하여 법치주의를 실현하여야 한다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제2절 재심의 소송물>

**I. 재심소송의 구조**

**1. 형성소송과 본안심판의 결합**

- 재심소송은 이미 확정된 판결의 효력을 소급적으로 배제시키고자 하는 형성소송의 성격과, 그 판결의 기초가 된 원래의 사건을 다시 심리하는 본안심판의 성격이 복합적으로 결합된 독특한 구조를 가진다. 통상의 소송이 하나의 소송물에 대하여 심리를 진행하는 것과 달리, 재심은 확정판결을 취소할 것인가에 대한 판단이 선행되어야 하며 그 사유가 인정될 때에만 비로소 과거의 사건에 대한 심리로 이행하게 된다. 따라서 재심절차는 논리적으로 판결의 효력을 다투는 단계와 본안의 당부를 다투는 단계로 이원화되어 운영된다.

**2. 절차적 단계성**

- 재심의 구조는 크게 세 단계로 구분할 수 있다. 첫째, 재심의 소가 적법한지 여부를 심사하는 재심의 적법성 심사 단계이다. 여기서는 재심기간의 준수나 재심 피고의 적격 등 소송요건을 검토한다. 둘째, 재심사유가 존재하는지를 확정하는 재심사유의 존부 심사 단계이다. 민사소송법 제451조 각 호에 규정된 사유가 실제 존재하는지 판단하며, 사유가 인정되지 않으면 재심기각판결을 내리게 된다. 셋째, 재심사유가 인정될 경우 과거의 확정판결 이전 상태로 돌아가 사건을 다시 심리하는 본안의 재심판 단계이다. 이 단계에서는 종전의 소송자료와 새로운 자료를 함께 검토하여 승패를 다시 결정하게 된다.

**3. 심판의 비상성**

- 재심은 확정판결의 기판력을 깨뜨리는 비상한 구제수단이다. 따라서 일반적인 상소와 달리 확정판결에 중대한 흠이 있음을 입증해야 하는 특수성이 존재한다. 이러한 구조적 특성으로 인해 재심법원은 먼저 재심사유에 대한 증거조사를 마친 뒤, 사유가 있다고 판단될 때에만 본안에 대한 심리를 개시한다. 만약 재심사유가 존재하더라도 본안판결의 결과가 종전과 동일할 것으로 판단된다면, 법원은 재심청구를 기각할 수 있는데 이는 재심이 결과적으로 부당한 판결을 바로잡기 위한 수단임을 방증하는 구조적 특징이라 할 수 있다.

**II. 재심사유와 소송물**

**1. 재심소송물의 정의**

- 재심절차에서의 소송물은 확정판결의 취소청구권과 원래의 본안청구라는 두 가지 요소가 결합된 것으로 이해된다. 다수설과 판례의 입장에 따르면, 재심소송의 직접적인 목적은 확정판결의 기판력을 배제하고 사건을 원상태로 돌리는 데 있으므로, 재심사유 자체가 소송물 구성의 핵심적인 단위가 된다. 즉, 당사자가 주장하는 구체적인 재심사유는 소송의 범위를 결정하며, 법원은 당사자가 제출한 사유의 범위를 벗어나 임의로 다른 사유를 근거로 판결을 취소할 수 없다.

**2. 재심사유의 개별성과 소송물**

- 민사소송법 제451조 제1항 각 호에 규정된 개별적 재심사유는 각각 독립된 소송물을 형성한다. 만약, 당사자가 여러 개의 재심사유를 주장한다면, 이는 소송물의 병합과 유사한 형태를 띠게 된다. 예를 들어 판결에 영향을 미칠 중요한 사항의 누락과 증거의 위조를 동시에 주장한다면, 법원은 각각의 사유에 대하여 개별적으로 존부를 판단하여야 한다. 이때 각 사유는 서로 독립되어 있으므로 하나의 사유가 부정되더라도 다른 사유가 인정되면 확정판결은 취소될 수 있다.

**3. 본안청구와의 관계**

- 재심사유가 인정되어 판결이 취소되면, 원래의 소송물인 본안청구가 다시 심판의 대상이 된다. 이때의 소송물은 재심 전의 소송물과 동일성을 유지한다. 재심은 새로운 소를 제기하는 것이 아니라 과거에 종결된 소송을 부활시키는 것이기 때문이다. 따라서 본안의 재심판 단계에서는 종전 소송에서 주장했던 공격방어방법과 재심절차에서 새롭게 제출된 자료들이 혼합되어 심리된다. 결론적으로 재심의 소송물은 재심사유에 의한 취소권이라는 형성적 요소와 본안청구의 당부라는 실체적 요소가 단계적으로 연결된 구조를 취한다.

**4. 판례의 경향**

- 대법원은 재심사유의 구체적 내용이 소송물로서의 성격을 가짐을 명확히 하고 있다. 판례에 따르면 재심의 소는 확정판결에 대한 불복방법이므로, 당사자가 선택한 특정 재심사유에 대해서만 심리권이 발생한다. 또한, 재심사유가 인정되지 않을 경우 본안에 대한 심리를 진행하지 않고 소송을 종결해야 한다는 입장을 고수한다. 이는 재심이 기판력을 무너뜨리는 예외적 절차인 만큼, 소송물의 범위를 엄격히 확정하여 법적 안정성을 보호하려는 취지로 해석된다. 특히, 재심사유 중 일부만이 인정되는 경우에도 전체 판결을 취소할 것인지, 아니면 해당 부분에 한정할 것인지에 대해 소송물의 불가분적 성격을 고려하여 판단하고 있다.

**III. 결론**

- 재심소송의 소송물은 단순한 본안의 재심판에 그치는 것이 아니라, 확정판결의 효력을 부정하기 위한 재심사유를 기초로 형성된다. 재심은 형성적 단계와 실체적 단계가 결합된 특수한 구조를 지니며, 각 단계에서 다루어지는 대상은 논리적으로 연결되어 있으면서도 독립적인 심판 대상이 된다. 특히, 민사소송법이 규정하는 개별적 재심사유는 재심소송의 범위를 확정하는 결정적인 척도가 되며, 이는 당사자주의와 처분권주의의 원칙에 따라 법원의 심리 범위를 제한하는 기능을 수행한다. 결과적으로 재심의 소송물을 명확히 이해하는 것은 무분별한 재심 제기를 방지하고, 확정판결의 신뢰성을 유지하면서도 명백한 하자가 있는 경우에 한하여 정의를 실현하고자 하는 제도적 균형을 유지하는 데 필수적이다. 향후 재심 절차에서는 기술적 발전이나 사회적 변화에 따라 새로운 형태의 재심사유가 논의될 수 있으나, 소송물의 기본 골격인 취소권의 행사와 본안의 재확정이라는 본질적 틀은 유지되어야 할 것이다. 당사자는 소송을 제기함에 있어 구체적이고 명확한 재심사유를 특정하여 소송물의 범위를 확정하여야 하며, 법원은 이를 바탕으로 엄격한 법리 적용을 통해 기판력의 예외적 배제 여부를 신중히 결정하여야 한다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제3절 적법요건>

**I. 재심의 대상적격**

**1. 확정된 중국판결**

- 재심은 확정된 중국판결을 대상으로 한다. 아직 확정되지 아니한 판결에 대해서는 항소나 상고라는 통상의 상소절차를 통해 구제받아야 하므로, 재심을 제기할 수 없다. 확정의 시점은 상소기간의 경과, 상소권의 포기 또는 취하, 상고기각 판결의 선고 등으로 더 이상 통상의 방법으로 다룰 수 없게 된 때를 의미한다. 중간판결이나 소송지휘에 관한 결정 등은 재심의 대상이 되지 않으며, 중국판결이라 하더라도 그 판결이 유효하게 존재하는 상태여야 한다.

**2. 대상적격 인정 여부에 대한 구체적 검토**

- 본안판결뿐만 아니라 소각하 판결이나 상소기각 판결과 같은 소송판결도 중국판결인 이상 재심의 대상이 될 수 있다. 다만, 화해권고결정이나 이행 권고결정, 지급명령 등이 확정된 경우에는 민사소송법 제461조에 의하여 준재심의 대상이 될 뿐, 직접적인 재심의 대상은 아니다. 또한, 판결의 당사자가 아닌 제3자가 제기하는 제3자 재심의 소의 경우에도 대상이 되는 것은 타인 간에 선고되어 확정된 중국판결이다. 대법원 판례는 항소심에서 본안판결을 한 경우 하급심 판결은 항소심 판결에 흡수되므로 원칙적으로 항소심 판결만이 재심의 대상이 된다는 흡수설의 입장을 취하고 있으나, 재심사유가 하급심 판결에만 존재하는 경우에는 예외를 인정한다.

**II. 재심기간[민소법 제456조]**

**1. 재심사유를 안 날로부터 30일**

- 당사자가 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 소를 제기하여야 한다. 이는 불변기간으로서 당사자의 책임 없는 사유로 준수하지 못한 경우가 아닌 한 연장될 수 없다. 재심사유를 안 날이란 단순히 판결에 하자가 있음을 인식하는 수준을 넘어, 민사소송법 제451조 각 호에서 정한 구체적인 사유가 발생하였음을 객관적으로 알게 된 날을 의미한다. 만약, 재심사유가 형사상 처벌받을 행위에 의한 것인 경우(제451조 제1항 제4호 내지 제7호), 그 처벌 판결이 확정되었음을 안 날이 기준이 된다.

**2. 판결확정 후 5년**

- 재심의 소는 원칙적으로 판결이 확정된 날로부터 5년이 경과하면 제기할 수 없다. 이는 법적 안정성을 기하기 위한 제척기간의 성격을 가진다. 앞서 언급한 30일의 단기 기간과 5년의 장기 기간 중 어느 하나라도 경과하면 재심의 소는 부적법하여 각하된다. 다만, 대리권의 흠결(제451조 제1항 제3호)이나 기판력의 저촉(제11호)을 이유로 하는 경우에는 이 5년의 제한을 받지 않는다. 이는 절차적 정의의 중대한 침해나 판결 간의 모순을 해결해야 할 필요성이 법적 안정성보다 우선하기 때문이다.

**III. 재심의 이익**

- 재심을 통해 확정판결을 취소하고 본안에 대해 다시 심판을 받는 것이 청구인에게 현실적인 이익이 있어야 한다. 만약, 재심사유가 인정되더라도 본안심판의 결과가 종전과 동일할 것이 명백하거나, 이미 판결의 목적이 달성되어 취소의 실익이 없는 경우에는 재심의 이익이 부정된다. 또한, 상소를 통해 다룰 수 있었음에도 불구하고 당사자가 이를 게을리하여 확정된 경우에는 재심의 이익을 제한적으로 해석하는 경향이 있다. 재심의 이익은 소송요건의 하나로서 법원이 직권으로 조사하며, 이익이 없는 경우에는 소를 각하한다.

**IV. 재심당사자적격**

- 재심의 소를 제기할 수 있는 자는 원칙적으로 확정판결의 당사자 및 그 승계인이다. 재심 피고 역시 원판결의 당사자 및 승계인이 된다. 판결의 효력이 미치지 않는 제3자는 원칙적으로 재심을 제기할 수 없으나, 예외적으로 제3자의 권리를 해하는 판결이 선고된 경우 민사소송법 제449조에 따른 제3자 재심의 소를 제기할 수 있는 적격이 부여된다. 당사자 적격의 유무는 원판결의 표시를 기준으로 판단하며, 당사자의 성명이나 지위가 오기된 경우에는 정정 절차를 거쳐 적격을 확인한다.

**V. 재심사유의 주장**

- 당사자는 재심소장 또는 변론에서 구체적인 재심사유를 특정하여 주장하여야 한다. 법원은 당사자가 주장하지 아니한 사유를 근거로 판결을 취소할 수 없다는 처분권주의의 원칙이 적용된다. 재심사유는 소 제기 시에 모두 제출하는 것이 원칙이나, 재심기간 내라면 추가하거나 변경하는 것이 가능하다. 다만, 재심기간이 경과한 후에 새로운 재심사유를 추가하는 것은 소의 변경으로 간주되어 허용되지 않는 것이 원칙이다. 각각의 재심사유는 독립된 소송물과 유사한 지위를 가지므로 심리 역시 개별적으로 이루어진다.

**VI. 보충성**

- 재심은 다른 구제수단이 없는 경우에만 허용되는 보충적 성격을 지닌다. 민사소송법 제451조 제1항 단서에 의하면, 당사자가 상소에 의하여 재심사유를 주장하였거나 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 재심의 소를 제기할 수 없다. 이는 재심이 상소절차를 대신하거나 당사자의 부주의를 구제하기 위한 수단으로 남용되는 것을 방지하기 위함이다. 따라서 재심을 제기하고자 하는 자는 해당 사유를 상소 단계에서 다룰 수 없었음을 소명하여야 하며, 항소심에서 이미 판단이 내려진 사유에 대해서는 다시 재심으로 다투는 것이 금지된다.

**VI. 개별적 재심사유[민소법 제451조]**

**1. 의의**

- 민사소송법 제451조 제1항은 재심을 허용하는 사유를 11가지로 한정하여 규정하고 있다. 이는 기판력의 원칙에 대한 예외로서, 재판의 공정성과 진실 발견을 위해 불가피한 경우를 법정화한 것이다. 법원은 이 규정을 유추해석하거나 확장해석하는 데 신중을 기하며, 명문의 규정에 부합하는 사유가 존재할 때에만 비로소 기판력을 배제한다.

**2. 재심사유**

- 주요 재심사유로는 첫째, 판결 법원의 구성이 법률에 어긋난 경우(제1호)와 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 법관이 관여한 경우(제2호)가 있다. 둘째, 법정대리권 · 소송대리권 등에 흠이 있는 경우(제3호)이다. 셋째, 판결의 기초가 된 증거가 위조 · 변조되었거나(제6호), 증인 등의 허위진술이 판결의 증거가 된 경우(제7호)이다. 단, 이 경우에는 처벌받을 행위에 대하여 유죄판결이 확정되거나 증거부족 외의 이유로 확정판결을 얻을 수 없는 때에만 허용된다. 넷째, 판결의 기초가 된 민사 · 형사판결이나 행정처분이 변경된 경우(제8호)와 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 경우(제9호) 등이 포함된다. 마지막으로 재심을 제기할 판결이 전에 확정된 판결과 어긋나는 경우(제11호), 즉 기판력의 저촉도 중요한 재심사유 중 하나이다.

## Ⅷ. 결론

- 재심의 적법요건은 확정판결의 기판력을 존중하면서도 중대한 하자가 있는 경우에 한하여 예외적으로 문호를 개방하려는 법원의 엄격한 의지를 반영한다. 재심의 대상적격, 보충성, 법정된 개별적 재심사유에 이르기까지 모든 요건은 소송의 경제성과 법적 안정성을 확보하기 위한 장치들이다. 특히, 재심기간의 엄격한 준수와 보충성 원칙은 당사자가 상소절차를 성실히 이행하도록 유도하며, 확정판결의 권위를 함부로 훼손하지 못하게 하는 심리적·법적 저지선 역할을 수행한다. 따라서 당사자는 재심을 준비함에 있어 자신이 주장하는 사유가 민사소송법 제451조의 어느 항목에 정확히 부합하는지, 그리고 상소 절차에서 이를 주장하지 못한 정당한 사유가 있는지를 면밀히 검토하여야 한다. 법원은 이러한 적법요건을 구비하지 못한 소에 대해서는 본안 심리에 나아가지 않고 즉시 각하함으로써 소송 질서를 유지한다. 결론적으로 재심 적법요건에 대한 명확한 이해는 실체적 진실 발견과 법적 평화 유지라는 민사소송의 두 가지 핵심 가치를 조화시키는 출발점이라 할 수 있다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제4절 재심절차>

**I. 관할법원**

**1. 전속관할**

- 재심의 소는 민사소송법 제453조 제1항에 따라 재심을 제기할 판결을 내린 법원의 전속관할에 속한다. 이는 재심절차가 본래의 확정판결을 내린 법원에서 그 오류를 스스로 시정하게 함이 합리적이라는 취지에서 비롯된 것이다. 전속관할이므로 당사자 간의 합의에 의한 관할 창설이나 변론관할의 발생이 허용되지 않으며, 법원은 직권으로 관할권을 조사하여 관할권이 없는 경우 해당 법원으로 이송하여야 한다.

**2. 상소각하판결의 확정**

- 상소각하판결이 확정된 경우, 그 각하판결 자체에 재심사유가 있다면 해당 상소심 법원이 재심의 관할법원이 된다. 그러나 상소각하판결로 인해 확정된 원심판결(하급심 판결)에 대하여 재심을 제기하고자 하는 경우에는 그 원심판결을 내린 법원이 관할권을 가진다. 이는 상소각하판결이 본안에 대한 판단을 포함하지 않으므로, 실질적인 쟁점은 원심 법원에서 다루어져야 하기 때문이다.

**3. 상소기각판결의 확정**

- 심급을 달리하는 법원이 같은 사건에 대하여 내린 판결들에 각각 재심사유가 있는 경우, 원칙적으로 각 판결을 내린 법원이 관할권을 가진다. 다만, 항소심에서 사건을 본안심판하여 상소기각판결이 확정된 때에는 하급심의 판결이 상급심 판결에 흡수되는 관계에 있으므로 상급심 법원이 통합하여 관할하는 것이 원칙이다. 만약, 단일한 재심사유가 상하 심급 판결 모두에 공통으로 존재하는 경우에는 상급법원이 이를 병합하여 심리하는 것이 재판의 모순을 방지하는 데 적절하다.

**4. 재심의 소를 제기할 법원을 그르친 경우**

- 당사자가 전속관할을 오인하여 관할권 없는 법원에 재심의 소를 제기한 경우, 법원은 이를 부적법하다 하여 곧바로 각하해서는 안 된다. 민사소송법 제34조의 이송 규정에 따라 관할권이 있는 법원으로 사건을 이송하여야 한다. 이때 재심제척기간의 준수 여부는 소를 처음 제기한 때를 기준으로 판단하므로, 이송으로 인해 당사자가 불이익을 입지 않도록 보호한다.

**II. 중간판결**

- 재심절차는 크게 재심의 적법성을 심사하는 단계와 본안의 당부를 심사하는 단계로 구분된다. 법원은 먼저 재심의 소가 적법한지, 즉 재심기간을 준수하였는지와 재심사유가 실제로 존재하는지를 심리한다. 만약 재심사유가 인정된다면 법원은 재심청구가 이유 있다고 판단하여 원판결을 취소하는 중간판결을 할 수 있다. 이 중간판결은 원판결을 파기하고 소송을 원판결 이전의 상태로 되돌리는 효력을 가진다. 다만, 법원은 중간판결을 하지 않고 곧바로 본안에 대한 종국판결을 내릴 수도 있으며, 실무상으로는 절차의 간이화를 위해 종국판결에서 재심사유의 존부와 본안의 승패를 한꺼번에 판단하는 경우가 많다.

**III. 소송절차**

- 재심의 소송절차는 민사소송법 제455조에 따라 원칙적으로 각 심급의 일반적인 소송규정을 준용한다. 재심의 소가 제기되면 법원은 먼저 소의 적법 여부를 조사하며, 소장이 형식적 요건을 갖추지 못한 경우 보정명령을 내리거나 재판상 소장각하명령을 할 수 있다. 소가 적법한 것으로 인정되면 본안 심리에 들어가며, 이 단계에서의 심판 범위는 당사자가 재심사유로 주장한 범위 내로 한정된다. 즉, 재심절차에서도 처분권주의와 변론주의가 적용되므로 법원은 당사자가 주장하지 않은 사실을 근거로 원판결을 취소할 수 없다. 또한, 재심의 소를 제기하더라도 원판결의 집행이 당연히 정지되는 것은 아니며, 집행을 정지시키기 위해서는 별도의 집행정지 신청을 하여 법원의 결정을 받아야 한다. 본안 심리 결과 재심사유가 인정되지 않으면 재심기각판결을, 사유는 인정되나 원판결이 결과적으로 정당하다고 판단되면 상소기각과 유사한 형태의 판결을 내리게 된다.

**IV. 재심의 소에서 피참가인의 소의 취하**

- 소송계속 중 제3자가 한쪽 당사자를 돕기 위하여 보조참가를 한 상태에서 재심이 제기된 경우, 피참가인(원래의 당사자)이 소를 취하할 수 있는지가 문제 된다. 보조참가인은 피참가인의 소송 행위에 종속되므로, 피참가인이 재심의 소를 취하하면 재심절차는 종료되는 것이 원칙이다. 그러나 공동소송적 보조참가나 독립당사자참가의 경우처럼 참가인의 독자적인 권리 보호가 필요한 경우에는 피참가인의 취하 행위가 참가인에게 불리하게 작용하지 않도록 제한된다. 특히, 재심절차는 확정된 판결을 뒤집는 중대한 절차이므로, 피참가인이 상대방과 합의하여 임의로 소를 취하함으로써 참가인의 이익을 해하는 행위는 소송법상 신의칙이나 참가인의 지위에 따라 그 효력이 부정될 수 있다.

**V. 결론**

- 재심절차는 확정된 판결의 기판력을 깨뜨리는 비상구제수단인 만큼, 그 관할과 심리 절차에 있어 엄격한 규율이 적용된다. 전속관할 원칙을 통해 재판의 전문성과 일관성을 유지하며, 중간판결 제도를 두어 재심사유의 존부를 별도로 확정할 수 있는 길을 열어두고 있다. 또한, 일반 소송절차의 규정을 준용함으로써 당사자의 절차적 권리를 보장하되, 재심의 특수성을 고려하여 심판 범위를 제한하고 집행정지에 관한 별도의 요건을 부과하고 있다. 특히, 관할법원을 그르친 경우의 이송 처리나 참가인이 개입된 상황에서의 소 취하 문제는 재심절차가 단순한 재심판을 넘어 복잡한 이해관계가 얽혀 있음을 보여준다. 따라서 재심을 수행하는 당사자와 법원은 해당 사건이 어느 법원의 전속관할에 해당하는지, 재심사유의 주장이 적절히 이루어졌는지, 소송행위가 다른 참가인의 권리를 침해하지 않는지를 종합적으로 고찰하여야 한다. 이러한 치밀한 절차적 통제는 결국 사법 판결의 안정성과 구체적 타당성이라는 두 가치를 조화롭게 실현하는 토대가 된다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제5절 준재심>

**I. 의의[민소법 제461조]**

**1. 준재심의 개념**

- 준재심이란 확정된 판결이 아닌 조서나 결정·명령에 대하여 재심사유와 유사한 중대한 하자가 있는 경우, 그 효력을 다투기 위하여 제기하는 비상구제수단을 의미한다. 민사소송법 제461조는 조서에 대한 준재심을 규정하고 있으며, 제449조 등은 결정·명령에 대한 재심(준재심)을 준용하고 있다. 이는 재판의 형식은 판결이 아니더라도 실질적으로 확정판결과 동일한 효력을 가지거나 소송절차를 종결시키는 효력이 있는 경우, 판결의 재심에 준하여 그 오류를 시정할 기회를 부여하기 위함이다.

**2. 제도의 취지**

- 민사소송법상 기판력이나 집행력이 부여되는 법률관계의 확정에는 사법 정의의 실현을 목적으로 한다. 그러나 절차적 과정에서 재심사유에 준하는 치명적인 결함이 발생하였음에도 불구하고 재판의 형식이 판결이 아니라는 이유로 불복을 차단하는 것은 부당하다. 따라서 확정판결에 대한 재심 제도를 원용하여 법적 안정성과 구체적 타당성을 조화시키려는 것이 준재심 제도의 핵심적인 존재 이유다.

**II. 요건**

**1. 대상의 적격성**

- 준재심의 대상은 크게 두 가지로 구분된다. 첫째, 확정된 결정 또는 명령이다. 항고로 불복할 수 있는 결정이나 명령이 확정된 경우, 재심사유가 존재한다면 재심의 규정을 준용하여 준재심을 제기할 수 있다. 둘째, 재심사유가 있는 조서다. 화해조서, 청구의 포기·인낙조서와 같이 확정판결과 동일한 효력을 가지는 조서가 그 대상이 된다. 다만, 단순한 변론조서와 같이 기판력이 없는 조서는 준재심의 대상이 되지 않으며, 기판력이 발생하는 조서에 한하여 독립된 소로써 그 효력을 다투 수 있다.

**2. 재심사유의 존재**

- 준재심은 판결에 대한 재심사유(민사소송법 제451조 제1항 각 호)를 그대로 원용한다. 대표적인 사유로는 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 법관이 관여한 경우, 대리권의 흠결이 있는 경우, 증거가 된 서류나 증언 등이 위조 또는 허위인 경우, 재판의 기초가 된 판결이나 행정처분이 변경된 경우 등이 포함된다. 조서에 대한 준재심의 경우, 화해나 인낙의 의사표시 과정에 기망이나 착오 등 민법상의 취소사유가 있는 것만으로는 부족하며, 반드시 민사소송법이 정한 엄격한 재심사유가 존재하여야 한다.

**3. 기간 및 관할의 준수**

- 준재심의 소 역시 판결의 재심과 마찬가지로 재심사유를 안 날부터 30일 이내, 그리고 해당 조서나 결정이 확정된 날부터 5년 이내에 제기하여야 한다. 관할법원은 해당 조서가 작성된 법원 또는 해당 결정·명령을 내린 법원의 전속관할에 속한다. 만약, 상급심에서 화해가 성립하여 조서가 작성되었다면 해당 상급심 법원이 준재심의 관할법원이 된다.

**4. 법률상 이익의 존재**

- 준재심을 통하여 얻고자 하는 권리구제의 이익이 현존하여야 한다. 이미 해당 법률관계가 다른 경로로 해소되었거나 준재심을 통해 조서의 효력을 부인하더라도 당사자에게 실질적인 이익이 돌아가지 않는 경우에는 부적당한 소가 될 수 있다. 또한 조서의 무효를 주장하는 방법으로서 별소(별개의 소송)를 제기하는 것은 원칙적으로 허용되지 않으며, 반드시 준재심의 절차를 밟아야 한다는 것이 통설과 판례의 태도다. 이는 확정판결과 동일한 효력을 가지는 조서의 권위를 존중하고 소송절차의 혼란을 방지하기 위함이다.

**III. 결론**

- 준재심 제도는 확정판결 이외의 재판 형식이나 소송행위 기록에 대하여 재심에 준하는 불복의 길을 열어줌으로써 사법 절차의 완결성을 높이는 장치다. 조서나 결정·명령이 가지는 강력한 법적 효력을 고려할 때, 그 성립 과정의 중대한 하자를 방지하는 것은 법치주의 원칙에 반하기 때문이다. 그러나 동시에 재심사유를 엄격히 한정하고 제척기간을 두는 것은 이미 확정된 법률관계를 무기한 불안정한 상태에 두지 않겠다는 입법적 결단이다. 특히, 조서에 대한 준재심은 당사자의 합의에 의해 성립된 화해 등이 사후적으로 공격받는 경우이므로, 판결의 재심보다 더욱 신중한 접근이 요구된다. 당사자는 단순히 자신의 의사표시에 하자가 있었다는 주장만으로는 조서의 효력을 뒤집을 수 없으며, 법이 정한 재심사유를 구체적으로 증명하여야 한다. 이러한 엄격한 요건은 준재심이 남용되는 것을 막고, 재판의 권위와 법적 안정성을 수호하는 필수적인 방어선 역할을 수행한다. 결국 준재심은 절차적 정의를 회복하기 위한 마지막 보루로서, 판결 중심의 구제 체계가 미처 닿지 못하는 사각지대를 보완하는 소송법상의 핵심적 기제로 기능한다.

## <수소법원>

### I. 수소법원의 의의

- 민사소송법이나 형사소송법 등 절차법에서 빈번하게 등장하는 수소법원(受訴法院)이란 현재 특정한 사건이 제기되어 그 사건을 실제로 담당하고 있는 법원을 의미한다. 한자 풀이 그대로 소송(訴)을 받은(受) 법원을 뜻하며, 해당 사건에 대한 심리(Trial)를 진행하고 최종적으로 판결을 내릴 권한과 의무를 가진 주체다. 수명법관이나 수탁법관이 수소법원의 업무를 보조하거나 대행하는 하위 개념이라면, 수소법원은 재판의 본체이자 중심축이라고 할 수 있다.

### II. 수소법원의 발생과 구성

#### 1. 수소법원의 발생 시점

- 수소법원의 개념은 원고가 소장을 제출하거나 검사가 공소를 제기하여 법원에 사건이 접수되는 순간 발생한다. 소가 제기되기 전에는 단순히 재판권이나 관할권을 가진 추상적 의미의 법원만이 존재하지만, 특정한 사건번호가 부여되고 재판부가 배당되는 순간 그 재판부는 해당 사건의 수소법원이 된다.

#### 2. 수소법원의 인적 구성

- 수소법원은 판사 1인으로 구성된 단독판사 체제이거나, 판사 3인(재판장, 우배석, 좌배석)으로 구성된 합의체 체제일 수 있다. 사건의 경중이나 법률적 난이도에 따라 결정되며, 합의체인 경우 그 합의체 전체가 하나의 수소법원으로서 기능을 수행한다. 수명법관은 이 수소법원의 구성원 중 일부가 특정 임무를 수행하는 형태다.

### III. 수소법원의 주요 권한과 직무

#### 1. 심리 및 증거조사의 주도

- 수소법원은 재판 절차의 주인공으로서 당사자의 주장을 듣고 증거를 조사한다. 직접주의 원칙에 따라 수소법원이 직접 증인을 신문하고 현장을 검증하는 것이 원칙이다. 수명법관이나 수탁법관에게 업무를 맡기는 것은 지리적, 시간적 제약이 있는 경우에 한정된 예외적 조치이며, 핵심적인 심리는 반드시 수소법원이 주관해야 한다.

#### 2. 소송지휘권의 행사

- 재판이 원활하게 진행되도록 절차를 이끄는 소송지휘권은 수소법원의 고유 권한이다. 변론기일을 정하거나 변경하고, 당사자에게 설명을 요구하는 석명권을 행사하며, 불필요하게 재판을 지연시키는 행위를 제재하는 등의 모든 절차적 판단을 내린다.

#### 3. 종국판결의 선고

- 소송 절차의 최종 목적인 판결은 오로지 수소법원만이 할 수 있다. 수명법관이나 수탁법관이 조사한 내용은 수소법원에 보고되어 판결의 기초 자료로 쓰일 뿐, 그들이 독자적으로 판결을 내릴 수는 없다. 수소법원은 심리 결과를 종합하여 법률을 적용하고 최종적인 결론을 도출한다.

### IV. 수소법원과 다른 법원 개념의 비교

#### 1. 관할법원과 차이

- 관할법원은 특정 사건을 재판할 수 있는 추상적인 자격이 있는 법원을 말한다. 예를 들어 서울에 사는 사람이 부산에 사는 사람을 상대로 소송을 낼 때, 서울중앙지방법원과 부산지방법원은 모두 관할법원이 될 수 있다. 그러나 실제로 소송이 부산지방법원에 접수되었다면, 부산지방법원이 그 사건의 수소법원이 된다. 즉, 관할법원은 재판을 할 수 있는 후보군이고 수소법원은 현재 재판을 하고 있는 곳이다.

#### 2. 상소심 법원과 관계

- 1심에서 재판을 진행 중일 때는 1심 법원이 수소법원이다. 그러나 1심 판결에 불복하여 항소하게 되면 사건 기록이 2심으로 넘어가게 되고, 이때부터는 2심(항소심) 법원이 새로운 수소법원이 된다. 수소법원이라는 명칭은 사건의 진행 단계에 따라 이동하는 상대적인 개념이다.

### V. 관련 판례 및 실무상 쟁점

#### 1. 수소법원의 전속적 판단 권한

- 판례에 따르면 소송 비용의 담보 제공 명령이나 소송 구조의 결정 등 사건의 실체와 밀접하게 연관된 절차적 결정은 반드시 수소법원이 행해야 한다. 다른 법원의 법관이 이를 대신 결정할 경우 이는 절차상 중대한 하자가 되어 무효가 될 수 있다. 이는 사건의 내용을 가장 잘 아는 수소법원이 판단하는 것이 실체적 진실 발견에 가장 부합하기 때문이다.

#### 2. 이송과 수소법원의 지위 승계

- 사건을 다른 법원으로 보내는 이송 결정이 확정되면, 기존의 수소법원은 더 이상 해당 사건의 수소법원이 아니게 된다. 판례는 이송 결정 이후의 모든 소송 서류와 증거 조사는 이송받은 새로운 수소법원에서 관리해야 하며, 기존 법원이 행한 처분 중 일부는 이송받은 법원을 구속하는 효력을 가진다고 보고 있다.

#### 3. 가처분 및 가압류와의 관계

- 본안 소송이 진행 중인 경우, 해당 본안 사건을 담당하는 수소법원은 보전처분(가압류, 가처분)에 대한 관할권도 함께 가지는 경우가 많다. 실무적으로 본안의 수소법원이 보전처분의 내용까지 종합적으로 고려하여 판단하는 것이 재판의 일관성을 유지하는 데 유리하기 때문이다.

### VI. 결론

- 수소법원은 법적 분쟁의 실질적인 해결이 이루어지는 장소이자 주체다. 소송의 시작부터 끝까지 재판의 공정성과 신속성을 책임지며, 증거를 직접 확인하고 법리를 적용하여 사회적 정의를 실현하는 역할을 수행한다. 수명법관이나 수탁법관 등의 보조적 장치들이 존재하는 이유도 결국 수소법원이 더 정확하고 효율적인 판결을 내릴 수 있도록 지원하기 위함이다. 따라서 수소법원의 개념을 명확히 이해하는 것은 소송 절차 전반의 흐름을 파악하는 데 가장 기초적이면서도 중요한 과정이라 할 수 있다.

## <수명법관과 수탁법관>

### I. 수명법관과 수탁법관의 의의

- 민사소송법상 법원은 원칙적으로 합의체 또는 단독판사가 스스로 심리하고 판결하는 것이 원칙이다. 그러나 사건의 특성상 또는 효율적인 재판 진행을 위하여 재판판결의 주체인 수소법원이 아닌 특정 법관에게 일정한 소송행위를 수행하게 할 필요가 있다. 이때 등장하는 개념이 수명법관과 수탁법관이다. 수명법관은 합의체의 구성원으로서 특정한 임무를 부여받은 법관을 의미하며, 수탁법관은 수소법원이 아닌 다른 법원의 법관으로서 특정 사무의 집행을 부탁받은 법관을 의미한다.



## II. 수명법관의 개념과 직무 범위

### 1. 수명법관의 정의

- 수명법관은 합의제 법원에서 재판장으로부터 특정한 소송행위를 하도록 명을 받은 그 합의체의 구성원인 법관을 말한다. 이는 수소법원 자체의 내부적 분업 체계에 해당하며, 재판의 신속과 효율을 위해 활용된다. 수명법관은 자신이 소속된 재판부의 사건을 다루는 것이므로 수소법원의 심리 과정과 밀접하게 연관되어 있다.

### 2. 주요 직무 내용

- 수명법관은 주로 증거조사나 화해 권고, 쟁점 정리 등의 업무를 수행한다. 법원이 현장검증이나 감정을 실시해야 할 때 합의체 전원이 이동하기 어려운 경우 수명법관을 지정하여 해당 절차를 진행하게 할 수 있다. 또한, 변론준비절차를 주재하여 당사자의 주장과 증거를 미리 정리함으로써 본 변론이 집중적으로 이루어질 수 있도록 돕는다.

### 3. 법적 지위

- 수명법관은 독자적으로 판결을 내릴 수는 없으나, 자신이 명을 받은 범위 내에서는 재판장과 유사한 권한을 행사한다. 수명법관이 행한 처분에 대하여 당사자가 이의를 제기하는 경우, 이는 해당 수명법관이 소속된 수소법원이 결정으로 판단하게 된다.

## III. 수탁법관의 개념과 직무 범위

### 1. 수탁법관의 정의

- 수탁법관은 수소법원의 소재지 외의 지역에서 소송행위를 할 필요가 있을 때, 그 지역을 관할하는 다른 법원의 법관에게 해당 사무를 촉탁하여 수행하게 된 법관을 의미한다. 즉, 수소법원 외부의 법관에게 협조를 구하는 형태다.

### 2. 주요 직무 내용

- 수탁법관은 주로 거리가 멀어 수소법원에 출석하기 어려운 증인의 신문, 다른 지역에 위치한 물건에 대한 검증이나 감정 등을 담당한다. 예를 들어 서울중앙지방법원에서 진행 중인 재판의 증인이 제주도에 거주하고 이동이 불가능한 사정이 있다면, 제주지방법원의 법관에게 증인신문을 촉탁할 수 있고 이때 제주지방법원의 법관이 수탁법관이 된다.

### 3. 법적 지위

- 수탁법관은 촉탁받은 특정 사항에 대해서만 권한을 가진다. 수탁법관은 촉탁받은 사항을 조사하는 과정에서 부수적으로 필요한 사항이 있다면 그 범위 내에서 조사를 확장할 수도 있다. 수탁법관의 처분에 대한 이의신청 역시 해당 법관이 소속된 법원이 아니라 사무를 맡긴 수소법원에서 처리하는 것이 원칙이다.

## IV. 수명법관과 수탁법관의 비교 및 차이점

### 1. 소속의 차이

- 수명법관은 사건을 담당하고 있는 수소법원 합의체의 일원이다. 따라서 사건의 실체와 쟁점에 대해 이미 깊이 이해하고 있는 상태에서 업무를 수행한다. 반면, 수탁법관은 수소법원과 별개의 법원에 소속된 법관으로서 오로지 부탁받은 특정 행위만을 수행하기 위해 일시적으로 관여한다.

### 2. 활용 목적의 차이

- 수명법관은 주로 재판의 효율성과 전문성을 위해 활용된다. 복잡한 사건에서 쟁점을 미리 정리하거나 증거를 선별하는 등 내부적 업무 부담의 성격이 강하다. 이에 반해 수탁법관은 지리적 한계 극복이 주된 목적이다. 먼 거리의 증인이나 증거물에 접근하기 위한 사법 공조의 성격을 띤다.

### 3. 권한 부여 방식

- 수명법관은 재판장의 명에 의해 지정되나, 수탁법관은 수소법원의 촉탁에 의해 해당 법원의 법관 중에서 정해진다. 즉, 수명법관은 인적 지정의 성격이 강하고 수탁법관은 기관 간 협조 요청에 따른 직무 수행의 성격이 강하다.

## V. 관련 판례와 실무상 유의사항

### 1. 증거조사 절차의 하자

- 대법원은 수명법관이나 수탁법관에 의한 증거조사가 법령이 정한 요건을 갖추지 못한 채 이루어졌을 경우 그 증거능력을 엄격하게 판단한다. 수소법원이 직접 심리할 수 있는 상황임에도 합리적 이유 없이 수명법관에게 증거조사를 맡기는 것은 직접주의 원칙에 위배될 소지가 있다는 취지다.

### 2. 수명법관의 조서 작성

- 실무적으로 수명법관이 증인신문 등을 진행한 경우 작성된 조서는 수소법원에서 직접 신문한 것과 동일한 효력을 가진다. 판례는 이러한 조서의 기재 내용이 변론 전체의 취지와 합쳐져 판결의 기초가 될 수 있음을 인정하고 있다.

### 3. 재위탁의 금지

- 수탁법관은 자신이 촉탁받은 사무를 다시 다른 법관에게 재촉탁할 수 없다. 이는 사법 행정의 명확성과 책임 소재를 분명히 하기 위함이다. 다만, 동일 법원 내의 다른 법관이 사무를 인계받는 것은 가능하다.

## VI. 결론

- 수명법관과 수탁법관은 민사소송의 효율적 진행과 지리적 한계 극복을 위한 필수적인 제도다. 수명법관은 합의체 내부의 효율적 분업을 통해 재판의 집중도를 높이며, 수탁법관은 원거리 증거나 증인에 대한 접근성을 보장하여 당사자의 편의를 도모한다. 이 두 제도는 수소법원이 모든 절차를 직접 수행해야 한다는 직접주의 원칙의 예외로서 작용하되, 실체적 진실 발견이라는 소송의 목적을 달성하기 위해 유기적으로 운용되고 있다.